

Derecho Comercial IV

Contratos Mercantiles y Concursos

Matías Zegers y Roberto Guerrero

5% TBL I, 26 y 27 de agosto

5% TBL II, 16 y 17 de septiembre

25% Solemne oral, 9 de octubre

15% Trabajo de Investigación

50% Examen oral, 9 de diciembre

CAPÍTULO I: Comercio exterior

1. Introducción al curso y especialmente al comercio internacional.

El derecho mercantil es un derecho de contratos, porque el comercio es una actividad que parte y muere a propósito de relaciones jurídicas generalmente bilaterales a través de las cuales se intermedian bienes y servicios.

De hecho, uno de los contratos más importantes (por su objeto) es el contrato de seguros, que estudiaremos este semestre. Y por otro lado, en Derecho Concursal la insolvencia afecta directamente la libertad contractual misma. Es por todo lo anterior que este semestre se reduce a entender el efecto de los contratos en las relaciones interpersonales porque el comercio es una especie de “red de contratos”.

El comercio exterior se enfoca en dos grandes hitos:

(1) La CV internacional de mercaderías.

El tránsito internacional a través del transporte es lo que mueve la economía del mundo, y eso genera varios problemas no porque haya comercio entre distintas nacionalidades sino por los riesgos que esto supone, lo que se suma a que el contrato de CV se entiende de manera distinta a nivel internacional (ej: cómo se perfecciona).

El mundo, a través de fórmulas establecidas entre las naciones sobre todo a partir del fin de la 2GM con la creación de la ONU y otros organismos, ha ido creando reglas y consensos para solucionar estos temas. Y en relación a la CV internacional, también ha habido que consensuar ciertas normas que las encontramos en la Convención de Viena sobre CV internacional de mercaderías.

La Lex Mercatoria supone cómo el derecho internacional establece reglas generales que norman el comercio en base a la costumbre internacional.

(2) Operaciones de comercio exterior.

2. La compraventa internacional de mercaderías.

2.1 Generalidades

Se encuentran reguladas fundamentalmente en la Convención de Viena (11/04/80) sobre compraventa internacional de mercaderías. Chile la ratificó el 1° de enero de 1985. Esta Convención surge como un impulso de la ONU.

La Convención es una norma supletoria absoluta porque casi siempre hay acuerdo expreso entre las partes.

La gran duda que se intenta resolver es el **momento de perfeccionamiento** del contrato de compraventa. En Chile la CV se perfecciona con la aceptación pero en esta Convención el perfeccionamiento se basa en la recepción de la aceptación.

Su **ámbito de aplicación** es la compraventa internacional de mercaderías entre partes con establecimientos en diferentes estados, independiente de si son civiles o comerciales, e independiente de su nacionalidad, art. 1. Sin embargo, no define venta, contrato o bienes, pero cuando se habla de establecimiento, se quiere circunscribir el problema a un tema netamente mercantil.

En general involucra:

- a) Todo contrato de compraventa (entrega de una cosa a otra por un precio) de mercaderías (cosas con destino comercial).
- b) Contratos de arrendamiento y compra: Leasing.

Excluyen:

- a) Permuta
- b) Subastas: Existen diferentes ordenamientos jurídicos que no son compatibles.
- c) Compraventa de valores mobiliarios, títulos o efectos de comercio: Generalmente existen disposiciones especiales en los ordenamientos jurídicos nacionales, muchas veces imperativos, p.ej. control de cambios.
- d) Compraventa de buques y aeronaves: Existencia de registros.
- e) Compraventa de electricidad.
- f) Bienes de uso familiar o doméstico.

El problema de la compraventa internacional no es el objeto del contrato, sino su carácter de internacional, ya que las partes que contratan se encuentran en diversos Estados, sometidas a jurisdicciones distintas. Por otro lado, desde el punto de vista del cumplimiento de las obligaciones que genera el contrato mismo, la distancia entre las partes magnifica los problemas, principalmente respecto a dos elementos: la entrega y el riesgo.

Lo más relevante acá son los términos comerciales que sirven para determinar qué buscan las partes del contrato de compraventa, específicamente en relación a los riesgos. La distancia presenta un gran problema porque ¿dónde se hizo la entrega y cuándo se traspasa el riesgo desde el vendedor al comprador o importador?

El tema no es hacerse dueño de la cosa porque en el comercio internacional el dominio no se transfiere con la mera entrega, sino a través de un título de crédito (*carta de porte* si es transporte terrestre y *conocimiento de embarque* si es transporte marítimo). La forma de pago incluye la entrega de estos títulos de crédito, pero es la entrega de las cosas la que supone el riesgo porque lo que quiere el comprador es asumir el riesgo teniendo físicamente las cosas, mientras que el vendedor quiere dejar de correr el riesgo al comenzar a transportar las cosas.

¿Cómo se soluciona esto? Determinando quién asume los riesgos o costos. Si el comprador quiere que le entreguen las cosas sin riesgo alguno, generalmente lo que va a tener que hacer es pagar

(ej: contratar un seguro). Todo va a depender de la capacidad de negociación y de lo que las partes acuerden.

Según la Convención, el lugar de entrega es en manos del transportista y si no hay transporte cuando se ponen a disposición del comprador pero ¿en el lugar de destino o en la fábrica? Eso depende de las partes.

2.2 Formación del contrato

Generalmente en los contratos de compraventa internacional se unen una pluralidad de elementos:

- i. Facultativos: Negociaciones y tratos preliminares.
- ii. Necesarios: Oferta y aceptación.

¿Cuándo hay contrato y cuándo se forma el consentimiento? Esta discusión ha evolucionado en el tiempo, perfeccionándose en la práctica con los usos y costumbres de la *lex mercatoria*, que nace con la navegación y alcanza una madurez en la Edad Media, para luego volver con el nacimiento de los Estados. Desde la Segunda Guerra Mundial, la *lex mercatoria* se transforma en los Estados reunidos en organismos formales, en un esfuerzo para definir términos para facilitar un entendimiento formal en aspectos mercantiles, impulsado por la Organización de Naciones Unidas. En este contexto surge la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, que establece normas muy generales para marcar un rumbo y dar un espacio de solución para evitar los conflictos comerciales.

Existió en la Convención toda una discusión, fundamentalmente basada en los diferentes sistemas legales, de cuál era el momento en que se perfeccionaba el contrato:

- Declaración.
- Expedición.
- Recepción.
- Conocimiento: Derecho Comparado
- En Chile, (Art. 97 del Código de Comercio), al momento de la aceptación.

Se trató de crear un sistema uniforme que recogiera en definitiva el tema de la recepción. Se llegó a que se perfeccionara al momento de surtir efecto la aceptación de la oferta conforme a lo señalado en la Convención (el art. 24 define que se entiende por “llegar al destinatario”): “*cuando se comunica verbalmente o se entrega por cualquier otro medio personalmente o en su establecimiento, dirección postal o residencia habitual*”. Esto funcionó bien en un principio, hasta que las comunicaciones empezaron a recibirse vía correo electrónico.

De acuerdo a lo anterior, la importancia radica entonces en la oferta y en la aceptación:

a) Oferta: Propuesta de celebración del contrato realizada por el vendedor.

Para que sea tal, la oferta debe ser:

- 1) Proposición para realizar un contrato: Es más bien de carácter general.
- 2) Con intención de obligarse: Debe tener intención de concluir el contrato. Se trata de un elemento subjetivo que presenta muchos problemas de interpretación, que debe tratar de delimitarse.
- 3) Debe estar suficientemente definida: Se refiere a:
 - Descripción de los bienes: elementos ciertos formas de determinarlo.
 - Cantidad
 - Precio

Con estos criterios se determina si la oferta es concreta, si no lo es no valdrá como tal: Es información.

Por eso la Convención es lo suficientemente flexible como para permitir y autorizar fórmulas de precios que efectivamente sean flexibles.

b) Aceptación: Ulterior declaración de voluntad por parte del destinatario de la oferta que perfecciona el contrato.

La Convención la define como toda declaración u otro acto del destinatario que indique asentimiento a una oferta.

La aceptación debe:

- 1) Hacerse en la forma requerida por el oferente.

Sea tácita o expresa: Requiere un comportamiento concluyente.

¿Lo es el silencio? No necesariamente, debe estarse a las negociaciones y a la conducta anterior de las partes.

- 2) Debe ser conforme o congruente con la oferta.

Debe reproducir el mismo contenido sustancial.

Hay que tener cuidado con las contraofertas (adiciones, limitaciones o modificaciones): A veces se acepta, si el cambio no altera sustancialmente la oferta, a menos que el oferente original reclame de inmediato la discrepancia. Existe una definición de cambio sustancial pero es de carácter amplio.

- 3) Debe ser tempestiva:

Debe ser comunicada dentro del plazo de vigencia, de lo contrario caduca.

Si no hay plazo, será el prudente de acuerdo al lugar, características de la transacción y los medios usados.

Si es verbal: Se debe dar de inmediato.

2.3 Términos comerciales

2.3.1 Generalidades

En un contrato de compraventa internacional, al tener que transportar las cosas o bienes objeto del contrato de un lugar a otro, las partes establecen unos términos comerciales para determinar la obligación del vendedor, que es fundamentalmente la entrega. La entrega es la que define el traspaso del riesgo de una parte a otra.

De acuerdo a la Convención, el lugar de entrega de las mercaderías será:

- a) Si involucra transporte: En manos del primer porteador.
- b) Si no lo involucra: Las pone a disposición del comprador.

Estas son las reglas generales, de carácter subsidiario, en caso de que las partes no hayan pactado nada distinto.

Generalmente en una compraventa internacional existe “la venta con entrega indirecta”: El vendedor gestiona por terceros independientes el transporte y la entrega al comprador, con lo que asume determinadas obligaciones. Por ello, es indiferente la entrega sino que importa el modo de realizarla y fundamentalmente el lugar, ya que con ello se determinan obligaciones adicionales.

Estas cláusulas de entrega son las denominadas **Incoterms o International Commercial Terms**.

En su origen, los Incoterms fueron creados basados exclusivamente en el transporte marítimo, pero esto se ha visto desbordado y superado por prácticas muy frecuentes, tales como el transporte aéreo, los containers y el transporte multimodal.

Como la Convención dejó a las partes la tarea de llegar a acuerdos, se fueron creando distintas modalidades de entrega y asunción de riesgos y la Cámara de Comercio Internacional (asociación voluntaria pero privada) fue identificando formas habituales de pactar la entrega y la asunción de riesgos. Se codificaron estas formas a través de **INCOTERMS**.

Los INCOTERMS facilitan las negociaciones entre las partes porque basta con que en el contrato de CV se determine que se entrega de X manera usando incluso solo una sigla, para que se entiendan las obligaciones de las partes.

Los INCOTERMS están constantemente actualizándose y lo importante acá es la transferencia de riesgo más que de dominio. Es una forma importante en que se reducen costos de transacción, porque se determinan las obligaciones de las partes en base a modelos generales.

2.3.2 Concepto

Los Incoterms son un conjunto de términos de tres letras que regulan las responsabilidades de las empresas en los contratos de compraventa de mercancías. Son publicados por la ICC (International Chamber of Commerce), y actualizados regularmente de acuerdo a la práctica vigente, siendo la última revisión del 2020. En la última revisión de los Incoterms se hicieron cambios mínimos respecto a los Incoterms del 2010.

¿Cuál es su función? Fijan las reglas para determinar las obligaciones del comprador y del vendedor según sean usados diferentes términos comerciales. En general establecen:

- a) Qué obligaciones tiene el vendedor para entregar.
- b) Qué actos debe realizar el comprador para asegurar la entrega.
- c) Qué costos asume cada parte.
- d) En qué punto de la entrega se transfiere el riesgo del vendedor al comprador.

Por el contrario, no establecen propiedad sobre las mercancías (se refieren a la transferencia del riesgo, no del dominio).

No solo establecen normas, sino que reconocen 11 formas distintas de pactar la entrega y los riesgos, de manera de que una vez que las partes acuerdan una de esas formas, ellas saben a qué atenerse porque están definidas en los Incoterms. De esta manera, las partes no tienen que acordar todo. Facilitan el comercio exterior proporcionándole siglas a las distintas maneras de realizar la entrega y asumir los riesgos.

2.3.3 Naturaleza jurídica

Los Incoterms, al provenir de la ICC no son parte de una legislación nacional, ni son un tratado o convención internacional, sino que es simplemente una sistematización de normas y costumbres que hizo un organismo independiente, la Cámara de Comercio Internacional.

¿Cuál es entonces su naturaleza jurídica?

- a) Se trata de usos escritos que pueden ser incorporados expresamente a un contrato de compraventa internacional de mercaderías.
- b) Si no son incorporados y simplemente se usan, se les tiene de todos modos como parte integrante del contrato de compraventa.

Es decir, tienen valor como *soft law* si se pactan en el contrato, pero también tienen valor como costumbre, lo que es relevante en los sistemas anglosajones. En caso de que se use un Incoterm sin haberlo pactado, tiene valor jurídico en cuanto haya generado costumbre entre los comerciantes.

2.3.4 Clasificación

Los Incoterms son 11 y se dividen en 4 grupos:

- a) Clase "E":

El vendedor pone las mercaderías a disposición del comprador en los propios locales del vendedor. El riesgo se traspa en ese instante. Es la forma más fácil de efectuar la entrega, desde el punto de vista del vendedor, ya que se entrega en el lugar donde las cosas se fabrican o donde las cosas se encuentran.

El vendedor no asume ni el transporte, ni el seguro, y por lo tanto todos los costos son del comprador.

a.1 EXW - EX WORKS (En fábrica): El vendedor no responde de carga, transporte o seguro. Por tanto, todos los costos son para el comprador.

El comprador compra más barato pero asume todos los riesgos para recibir las mercaderías donde las necesita.

b) Clase "F":

Al vendedor se le encarga que entregue la mercancía en el país de origen a un medio de transporte escogido y pagado por el comprador. El riesgo se traspasa con la entrega al transportista, al costado del buque o una vez que sobrepasa la borda del buque, respectivamente. Aumentan las obligaciones del vendedor porque le tiene que entregar las cosas al transportista.

El que paga el transporte es el comprador pero el vendedor lo que tiene que hacer es llevar las mercaderías a donde está el medio de transporte. Es más caro para el comprador porque el vendedor le va a vender más alto por el costo de la entrega de mercaderías en el medio de transporte.

El riesgo se traspasa entregadas las mercaderías al transportista.

b.1 FCA - FREE CARRIER (Franco transportista): La entrega sea realizada por el vendedor al transportista o a la persona designada por el comprador en las instalaciones de la empresa compradora o en otro lugar específicamente designado. El riesgo se transmite del vendedor al comprador en el punto de entrega.

Normalmente se usa para el transporte terrestre, mientras que las siguientes formas suponen la existencia de un barco.

b.2 FAS - FREE ALONGSIDE SHIP (Franco al costado del buque): Entrega en puerto convenido al lado del buque designado por el comprador, previo despacho de exportación. Esta es la modalidad para el comercio marítimo. El despacho de aduanas de exportación será por cuenta del vendedor.

El costo del vendedor llega hasta que las mercaderías se dejan al disposición para el embarque ("al costado del barco").

b.3 FOB - FREE ON BOARD (Franco a bordo): Ha sobrepasado la borda del buque. También se relaciona con el comercio marítimo, ya que el vendedor entrega las mercaderías a bordo del buque designado por la compradora. Se le agrega el costo de la grúa que pone el container dentro del barco. El despacho de aduanas de exportación será por cuenta del vendedor.

Es la forma más habitual y el vendedor se hace cargo del costo hasta embarcar y estibar la mercadería. Se llama "free on board" justamente porque no hay gasto o costo hasta el embarque.

c) Clase "C":

El vendedor contrata y asume los costos del transporte, pero sin asumir riesgo de pérdida o daño de la mercancía o costos adicionales derivados u ocurridos después de la carga y despacho. Este riesgo será del comprador desde el momento en que se realiza la entrega al primer transportista en el país de origen.

El vendedor asume el costo del transporte y eventualmente su riesgo. Entonces comprar una mercadería con valor clase C es mucho más cara que con valor clase F.

c.1 CFR - COST AND FREIGHT (Costo y flete): Se aplica al comercio marítimo. El vendedor entrega la mercadería a bordo del buque, y paga gastos y flete hasta el puerto de destino. Riesgo se transfiere al comprador al traspasar la borda del primer transportista. El despacho de aduanas de exportación será por cuenta del vendedor.

El riesgo es del comprador cuando se desembarcan las mercaderías en el puerto.

c.2 CIF - COST, INSURANCE AND FREIGHT (Costo, seguro y flete): Igual que CFR pero además del flete se paga el seguro, despachado para exportación al puerto de destino. Aplicable solo al comercio marítimo.

Si el transporte es multimodal:

c.3 CPT - CARRIAGE PAID TO (Transporte pagado hasta): El vendedor debe contratar y pagar los costos de transporte o flete hasta el lugar de destino convenido. El riesgo se extingue con la entrega de la mercancía al primer transportista. El despacho de aduanas de exportación será por cuenta del vendedor. Es lo mismo que el CFR, pero por medio de transporte multimodal (no solo marítimo).

c.4 CIP - CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (Transporte y seguro pagado hasta): Igual que CPT, el vendedor paga todo el transporte más el seguro (que cubre el transporte, sólo en su cobertura mínima). El despacho de aduanas de exportación será por cuenta del vendedor. Es lo mismo que el CIF, pero medio de transporte multimodal (no solo marítimo).

d) Clase "D":

El vendedor soporta todos los gastos y riesgos para que la mercadería llegue a su destino. Esto hace que el precio que deba pagar el comprador sea mayor.

d.1 DAP - DELIVERED AT PLACE (Entregado en lugar): La entrega de las mercancías se realiza cuando éstas son puestas a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada, listas para ser descargadas, pero sin descargar, en el lugar de destino. El riesgo se traspasa cuando las mercancías llegan al lugar de destino. El despacho de aduanas de exportación será por cuenta del vendedor.

El vendedor no solo desaduana si no, por ejemplo, contrata un camión que lleve las mercaderías al destino final y cuando ese camión llega a destino, entonces ahí se traspasa el riesgo.

d.2 DPU - DELIVERED AT PLACE UNLOADED (Entregado en lugar descargado)¹: El vendedor realiza la entrega de la mercancía y transmite el riesgo cuando la pone a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada, descargada por sus medios, y en el punto de destino convenido. Es el único Incoterm que obliga al vendedor a hacer la descarga en destino. El despacho de aduanas de exportación será por cuenta del vendedor.

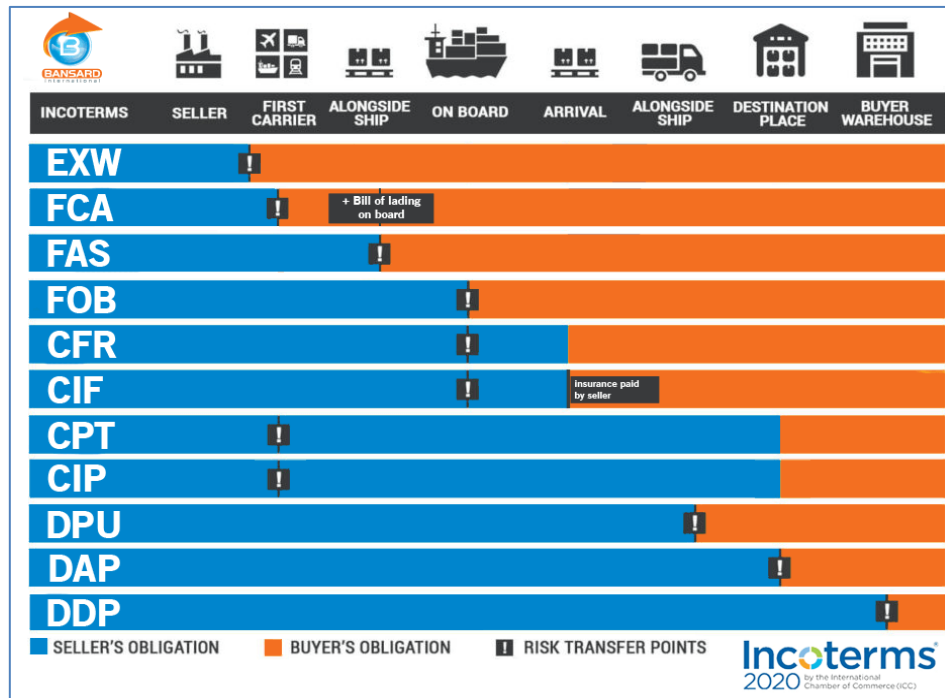
¹ Nuevo Incoterm del 2020, reemplazando al DAT "Delivered At Terminal" del 2010.

Se traspassa el riesgo cuando se descargan las mercaderías en destino, es decir, cuando se ponen a disposición fuera del medio de transporte.

d.3 DDP - DELIVERED DUTY PAID (Entregado con derechos pagados): Igual que DAP pero el vendedor asume todos los costos y gastos de importación (no sólo de exportación). Representa la máxima responsabilidad para el vendedor. El realiza la entrega cuando de la mercancía cuando la pone a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada, preparada para la descarga (pero sin descargar) y en el punto de destino designado, despachada para la importación.

El vendedor se hace cargo de absolutamente todo hasta el pago de todos los gastos de importación y exportación.

Para mayor comprensión de las obligaciones y riesgos de las partes bajo los distintos Incoterms, se acompaña el siguiente cuadro referencial:



Los INCOTERMS se negocian y lógicamente tienen precios (por ejemplo, es más caro comprar si los riesgos los asume el vendedor), entonces acá es sumamente relevante la capacidad de negociación de las partes.

3. Operaciones de comercio exterior

3.1 Documentos de embarque y su importancia respecto de la obligación de entrega.

Es la natural evolución de los Incoterms, que sólo regulan la entrega y el riesgo. En este caso, se busca regular también el pago, ya que el pago se realiza generalmente contra la transferencia de los documentos que acreditan el dominio de las mercaderías, más que contra la entrega e inspección de las mismas.

A pesar de que son anteriores a los INCOTERMS, hoy en día lo normal es que estos últimos se reflejen en los conocimientos de embarque y sean parte sustantiva de los mismos. El documento de embarque supone:

- 1) Entrega de los bienes.
- 2) Regulación del riesgo.
- 3) Pago.

Se ha llegado a la costumbre de que la entrega no es de cosas o mercaderías sino que es de documentos. El comprador no se hace dueño de las cosas hasta que el vendedor le entregue la carta de porte o conocimiento de embarque, que son títulos de crédito. Entonces, todo el comercio funciona sobre una hipótesis documentaria, a pesar de que en la realidad sea de mercaderías y de dinero.

De alguna manera, cuando hablamos del contrato de transporte la forma de transferir el dominio de las cosas es entregar documento mismo representativo de la mercadería. Como la distancia es un elemento fundamental, si existe ya ese factor reconocido de distancia entonces para eliminar incertezas sobre quién es el dueño de la cosa (sobre todo durante el transporte), aparecen estos documentos.

En resumen, como hay distancia entre las partes, ya no es tan claro el momento de transferencia del dominio y el riesgo por eso estos documentos determinan cuándo sucede ello (principalmente a través de INCOTERMS). ***La tradición no se produce con entrega física de bienes sino con la entrega de documentos***, lo que da certeza en cuanto al riesgo porque el comprador no se hace dueño sino hasta que recibe los títulos de créditos.

El origen de estas instituciones se encuentra en los Fenicios.

3.1.1 Operatoria

¿Cómo opera el “pago contra documentos”? Sigue un mecanismo determinado, según quién sea la persona que participa en el mismo:

a) Vendedor:

a.1 Vende, embala y factura. La cosa debe estar adecuadamente embalado y luego se emite una factura.

a.2 Entrega al transportador, que emite el Conocimiento de embarque o Bill of Lading (BL) al vendedor o a su orden.

El que sigue siendo dueño es el vendedor, y nace un documento nominativo o a la orden.

b) Transportador: debe emitir el BL, conducir las mercaderías y las entregará;

b.1 Al consignatario de las mismas (el mismo vendedor o quien él indique).

b.2 Al endosatario del conocimiento de embarque (cuando se emitió a la orden).

c) Comprador:

BL es usado para pagar contra la factura o el documento de venta. El comprador podrá tomar posesión de las mercaderías sólo si tiene el BL debidamente endosado a su nombre o si es el consignatario.

En ese sentido, el documento de embarque solo recoge la conducción de las mercaderías, y en general en las facturas se establece cuándo efectivamente se hace la transferencia de dominio (en base a los INCOTERMS).

d) Bancos. El Banco del Vendedor debe cobrarle al Comprador. Para ello:

d.1 Recibe del vendedor un título: BL, emitido por el transportador, lo que le da control sobre los bienes.

d.2 El comprador no puede tomar posesión de los bienes sin el BL: Paga y entonces obtendrá el BL.

Evolución actual

Si esto es muy consistente en el tiempo, es normal que las empresas constituyan agencias u oficinas comerciales que pagan e inspeccionan localmente para evitar todos estos riesgos de la CV internacional.

Generalmente los pasos son los siguientes:

1. Vendedor: Obtiene BL negociable (a la orden).
2. Vendedor: Entrega al banco:
 - (i) Una factura o nota de débito.
 - (ii) Un draft de BL: Bill of exchange (letra de cambio).
3. Vendedor: Endosa el BL y, en su caso entrega la letra de cambio librada al Banco. Muchas veces además de esto se emiten también otros títulos de crédito como garantía; por ejemplo le digo al comprador que acepte una letra de cambio.
4. Banco del Vendedor:
 - (i) Si no hay Carta de Crédito: Es una cobranza.
 - (ii) También puede descontarla.
5. Banco del Vendedor:
 - (i) Envía el draft (o letra de cambio) y documentos de cobro al comprador.
 - (ii) Generalmente lo realiza a través de otro banco: Banco del Comprador.
6. Banco del Comprador:
 - (i) Notifica al Comprador.
 - (ii) Comprador: Paga (plazo de 3 días) o acepta para pagarla después.
7. Comprador paga contra los documentos, y no contra la existencia o entrega misma de los bienes.
8. Banco Comprador entrega el pago al Banco del Vendedor.

3.1.2 Riesgos

Las operaciones de comercio exterior implica riesgos para ambas partes, debido a que las obligaciones del comprador y vendedor no se cumplen en el mismo minuto ni en el mismo lugar, lo que se suma a que hay varias jurisdicciones distintas incorporadas.

La única manera de desarrollar el comercio es teniendo niveles de seguridad altos en relación a la entrega de la cosa (contrato de transporte terrestre, marítimo o multimodal) y el pago de la misma. Ahora, hay un riesgo que se corre incluso aunque tengamos establecida la forma de pago y de entrega, y ahí aparecen los seguros.

Es importante determinar en este tipo de transacciones los riesgos de cada parte:

El riesgo del vendedor está en enviar las cosas sin que le paguen. Por tanto, si el vendedor envía los bienes, será pagado antes que el BL o los bienes sean entregados al comprador: No pierde el dominio antes del pago.

El riesgo del comprador está en pagar sin que le envíen las cosas. Por tanto, si el comprador da la orden de pago a su banco, dichos fondos le llegan al vendedor.

Hoy en día incluso esto se ha complejizado por la extensión del concepto de caso fortuito o fuerza mayor en relación al COVID. Si las mercaderías se quedan varadas en un puerto porque no hay vuelos, ¿quién corre el riesgo?

Por lo tanto:

a) Vendedor.

El vendedor a estas alturas (i) ha enviado los bienes sin que le hayan pagado y (ii) no tiene garantía de pago, salvo esta "Promesa".

Si el comprador no paga, (i) llegan las mercaderías y el comprador, pese a tener el borrador de BL y la factura, no paga (incumplimiento del contrato), y (ii) vendedor tiene derecho a demandar, por incumplimiento de contrato: resolución o cumplimiento forzado más indemnización de perjuicios. Esto último en general no sirve mucho, porque ¿qué hago con las mercaderías por mientras? Además los fallos se demoran mucho tiempo.

El problema es que dicha demanda debería presentarse en un país extranjero, lo que generalmente se evita por gastos extras, demoras y por la poca certeza.

El gran beneficio es que el vendedor tiene siempre el dominio de la cosa, pero operacionalmente es un problema para el comerciante por eso es importante determinar los medios de pago del comprador.

Como todavía tiene el control de los bienes, podría tratar de retornarlos y comercializarlos en su país, pero (i) para embarcarlos, necesita un agente o representante, (ii) el retorno supone un 2º embarque, lo que puede subir demasiado los costos.

Si durante el trayecto el comprador no paga, puedo efectivamente traer las cosas devuelta pero eso es caro y quizás incluso puedo preferir venderlas en el puerto de llegada. Pero eso puede generar más problemas porque tengo que conseguir alguien que las venda, tengo que conseguir el comprador, etc.

La alternativa es la liquidación en el lugar donde se encuentran los bienes, aunque también existen riesgos si no se cuenta con representantes.

b) Comprador.

El comprador tiene (i) un documento que le permite adquirir el dominio de las cosas y (ii) un certificado de seguro (no siempre) que cubre la pérdida de las cosas.

Los riesgos que puede sufrir son:

- (i) Pérdida o robo de las cosas.
- (ii) El transportador puede ser negligente en la estiba u operación y dañar las mercancías.
- (iii) Los bienes enviados pueden no estar conformes con el contrato de venta. Esta disconformidad puede venir de que envía cosas de otra calidad (scrap paper) o que esté mal etiquetado, con el consiguiente problema aduanero.
- (iv) Un tercero puede robar el BL (si está emitido al portador) y presentarse con ella para adquirir el dominio.
- (v) Pueden existir diferencias entre los bienes y el BL de tal modo que el BL establezca que los bienes tienen un determinado estado y en realidad tienen otro.
- (vi) BL es falsificado y no se envían los bienes.

Algunos de ellos se solucionan con la cobertura que dan los Incoterms o con otros mecanismos tales como el Certificado de Inspección de las mercaderías, que es un documento que se suele exigir como parte de los documentos que deben acompañar una operación de comercio exterior.

Por eso, los problemas que realmente permanecen son:

1) Pérdida de BL, seguido por una falsificación de un endoso y el consiguiente error en la entrega.

En general lo más problemático se relaciona con los robos o falsificaciones de los BL porque probar que son fraudulentos o que el sujeto no tiene derecho a exigir las mercancías no es fácil. Por eso lo más seguro sería que el BL se emita nominativamente.

Generalmente, los BL que se emiten son de dos tipos:

- No negociables: Blanco. No sirven para el “pago contra documentos”, se entrega sólo al consignatario.

- **Negociables. Amarillo.** Es generalmente a la orden, va a permitir que el mismo documento sea endosado, siendo dueño el tercero que esté en posesión de ella.

El transportador entregará las mercancías al que se encuentre en posesión del BL y lo tenga endosado a su nombre. La posesión es crucial y el transportador determina a quien se la entrega.

El transportador será responsable si entrega las mercancías a cualquiera que no sea el tenedor del BL. Por eso el BL es un título, ya que su posesión, debidamente endosada, da derecho sobre los bienes. En este sentido, también da control a los bancos.

El tenedor del BL tiene casi derecho absoluto sobre los bienes, excepto en caso de no existir endoso en cuyo caso lógicamente no le podrá entregar los bienes al poseedor del BL, y si los entrega es responsable de ello.

También será responsable al que se los entregaron, quien a su vez puede perseguir al que se la entregó hasta descubrir el último responsable.

A la vez, el poseedor real reclamará al transportador y éste a la compañía de seguros.

2) Error en la descripción. Generalmente el transportador tiene la obligación de entregar los bienes descritos en el BL, señalando cantidad y calidad. El problema es que generalmente el transportador no sabe que es lo que está transportando, ya que están en containers, no revisan las mercaderías, no las cuentan y no revisan su calidad.

Por eso es que existen a su vez disclaimers o exenciones de responsabilidad que se utilizan con cierta habitualidad, tales como las cláusulas “Desconocido contenido o condición” o “Said to contain”.

Lógicamente si el transportista debió saberlo o lo sabía, no puede excepcionar su responsabilidad. Generalmente se establece un sistema de responsabilidades de:

- **Número de bultos:** Para determinar que esté todo.
- **Peso:** Para determinar el peso total.

Puede que las partes designen un intermediario que asegure la calidad, género y especie de las cosas que se envían para evitar este riesgo.

3) Falsificación. Si el transportador emite un BL sin que existan bienes que sean transferidos, el transportador será responsable por esos bienes. El problema comienza cuando el transportador nunca emitió el BL por que se falsificó. El comprador la adquirió de buena fé, probablemente a través de bancos, y se encuentra que el transportista no tiene bien alguno que entregar. No se dan entonces los casos anteriores, ya que no hay falta de entrega o error en la descripción.

Lógicamente no existe responsabilidad para el transportista ya que no lo emitió, será responsable el emisor (falsificador) si es ubicable.

Si lo falsificado es el endoso, cada uno persigue el endosante hasta determinar quien es el falsificador según la cadena de endosos.

4) BL electrónicos (USA). No está definido, no requiere que sea escrita o en papel o firmado, por lo que puede ser electrónico. Sin embargo, todas las referencias se hacen a que el BL sean en papel, tanto el endoso como la entrega.

Se ha autorizado en determinadas legislaciones desde el año 1982 y 1988 el uso de BL electrónico para informar sobre bienes, transportista y el consignatario, pero en general no se señala como hacer la transferencia o el endoso.

Existe también el Chase Sea Documents: Fondo de documentos, un depósito que luego se transfiere electrónicamente con respaldo de estos sea documents.

Esto se relaciona con el uso de la tecnología blockchain que da más seguridades en relación a la transferencia de dominio y de riesgos.

3.2 Medios de pago

3.2.1 Orden de pago

La orden de pago es una transferencia bancaria que puede ser condicionada o no condicionada, según si es documentada o simple. Le ordeno al banco que entregue el dinero al vendedor.

Si existe una relación cercana entre el comprador y el vendedor, el proveedor le remite los documentos de embarque en forma directa al importador para que éste pueda disponer de la mercadería y le remita el pago en la forma que hayan acordado en el respectivo contrato de compraventa.

Para hacer este pago, que comprende la adquisición y la remesa de la correspondiente moneda extranjera, el importador puede recurrir a un banco para que realice dichas operaciones, vendiéndole las divisas y remesándolas, por medio de estas órdenes de pago.

La orden de pago puede ser:

- a) Simple: El comprador no condiciona el pago al beneficiario a la obligación de entregar documento alguno. En ese caso, normalmente el pago se realiza mediante una transferencia bancaria.
- b) Documentada: El comprador ordena a su banco el pago, sujeto a la condición que el vendedor entregue los documentos especificados en la orden, como facturas, documentos de transporte, certificado de inspección, lista de contenidos, etc.

Esta forma de pago no es usual por la existencia del crédito documentario que está muy regulado y cumple el mismo objetivo. Como exige due diligence respecto del banco, es un medio de pago que es bastante caro.

3.2.2 Cobranzas

En este caso el proveedor entrega el juego de documentos de embarque a un banco, para que éste, por intermedio de su corresponsal en el país del comprador, efectúe la gestión de cobro.

Esta gestión puede consistir en entregar los documentos al importador contra:

- a) Pago de su precio,
- b) Recibo simple: El comprador queda en una relativa libertad para determinar la fecha en que realizará el pago.
- c) Aceptación de una letra de cambio (también llamada “draft”): La fecha quedará determinada por el vencimiento que señale el documento aceptado.

Para el manejo de las cobranzas de importaciones y exportaciones existen convenciones de uso internacional que facilitan y uniforman su proceso, denominadas “Reglas Uniformes para las Cobranzas” de la Cámara de Comercio Internacional (ICC).

Según estas reglas, los documentos que se usan para la cobranza se clasifican en:

- a) Documentos comerciales: Son los documentos de embarque.
- b) Documentos financieros: Son los pagarés, letras de cambio, cheques y otros documentos que se utilicen para obtener el pago de dinero.

3.2.3 Cartas de crédito

En operaciones de comercio exterior existe el gran riesgo de que las cosas no lleguen, entonces hay un gran problema de confianza sobre todo porque hay que pagar antes de que las cosas lleguen.

La carta de crédito es un documento, entonces hablamos de “crédito documentario” o “acreditivo”. Las cartas de crédito son el ***instrumento mediante el cual se paga una operación de importación (comercio exterior), sin que haya flujo de dinero desde el comprador al vendedor.*** Son un componente fundamental para resguardar los intereses de ambas partes de la CV, de manera que el comprador paga cuando le llegan las cosas pero que el vendedor sepa que se le va a pagar.

Se facilita el pago y se asegura que el pago se va a realizar de la forma convenida desde el importador al exportador. Como el importador no tiene seguridad de las cosas que compró (puede que incluso no se haya fabricado el producto), ese es el problema práctico que se soluciona con la carta porque el importador entrega un documento que representa y demuestra que si el exportador cumple, va a haber un pago bajo las condiciones que pacten las partes.

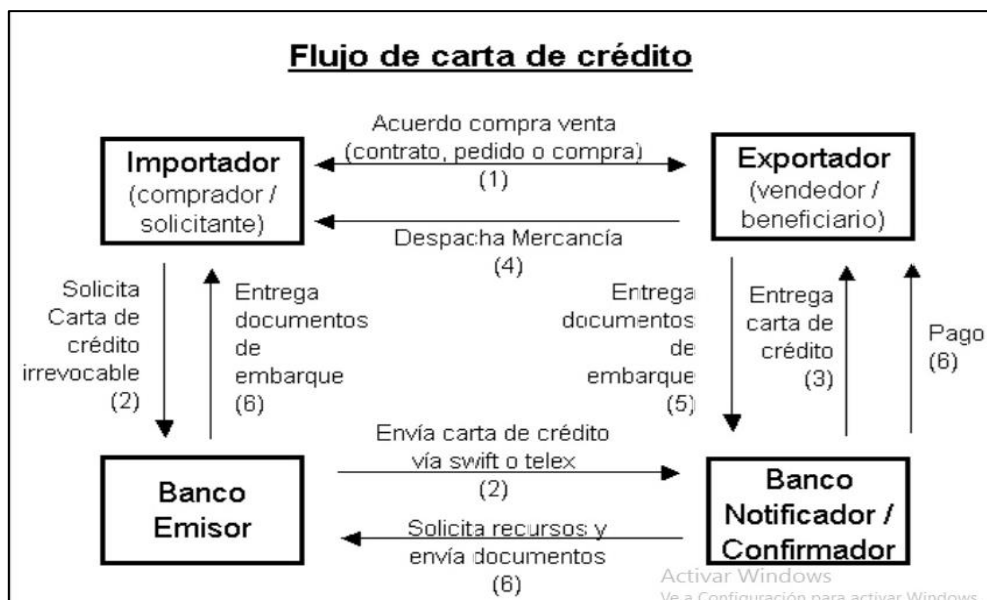
Esto se hace a través de los bancos, entonces tenemos un documento emitido por un tercero (banco comercial).

El documento tiene que tener un nivel de seguridad alto, por eso es un banco el que lo emite. Por eso la Carta tiene una función, aunque menos visible, de garantía porque es un instrumento que da seguridad, en este caso, de pago. No es un respaldo del pago sino que se le da seguridad al exportador de que se le va a pagar si este cumple sus obligaciones. Por lo tanto, no es solo una forma de pago, sino que además cumple una ***función de garantía.***

Se le ha sacado a este instrumento la mayor cantidad de elementos de discrecionalidad; por eso la carta se basta a sí misma porque en ella están todas las condiciones de las que depende el pago. Esto es seguridad para ambas partes porque si el vendedor cumple sus obligaciones, sabe que se le va a pagar pero el comprador tiene seguridad de que el banco sólo va a pagar si se cumplen las condiciones. Por lo tanto, cumple una **función de documento abstracto** porque se basta a sí misma independiente de que hay un negocio causal.

Por último, para evitar elementos de discusión, toda la mecánica del **proceso de importación y pago se hace por medio de documentos**. No solo la carta es documento sino que todo se documenta, especialmente el cumplimiento de las condiciones pactadas. Por ejemplo, si pacto que la fruta debe tener X nivel de acidez, eso se debe documentar. Y las partes son las que determinan cuáles son estos documentos, por ejemplo, la opinión de un experto en acidez de frutas.

A) Flujo de la Carta de Crédito



1) Contrato de CV internacional entre comprador y exportador. Puede ser una orden de compra, e incluso puede existir antes de que las mercaderías existan.

En este contrato se pactan todas las condiciones sobre la cosa, la entrega y especialmente el pago (por medio de incoterms normalmente). Es clave porque hay que juntar las condiciones del contrato con las de la carta (se traspasan esas condiciones a la carta), y en ese momento voy al banco para que se abra una carta de crédito.

2) Apertura de la carta de crédito en el banco. El banco debe aceptarme poner las condiciones pactadas por las partes, condiciones que tienen que ser fácilmente verificables a través de documentos para que el banco acepte.

3) Emisión de la carta de crédito irrevocable por parte del banco.

4) Envío de la carta por telex bancario o Swift al banco del vendedor.

5) El banco del vendedor confirma que recibió la carta y le notifica ello al vendedor. El comprador ya sabe que cuenta con el medio de pago, y para que le paguen solo tiene que cumplir con las condiciones de la carta (la condición más importante normalmente es la entrega de las mercaderías).

6) Despacho de la mercadería a través de un transporte. El documento de embarque certifica la entrega de las mercaderías al transportista, pero como no le entrego el documento de embarque al importador que aún no me paga, entonces lo que hace el vendedor es enviar los documentos de embarque a través de un barco.

7) El vendedor le da los documentos (de transporte y demás certificaciones pactadas) **a su banco local**, que los envía al banco emisor o banco del comprador. Es común que se pida también acá una factura para ingresar las mercaderías a Chile.

8) Negociación: el banco emisor hace una revisión formal de la documentación, asegurándose de se cumplan las condiciones de los documentos enviados.

9) Pago al vendedor a través de su banco.

B) Valor de emisión de cartas de crédito.

Se emitirá por el valor que se haya convenido en el contrato celebrado entre el comprador y el vendedor, pudiendo incluir elementos adicionales como Incoterms, garantías (para el comprador o el vendedor), etc.

C) Validez de la Carta de Crédito.

Tiene diferentes plazos:

(i) Plazo para utilizarla.

Según la Ley General de Bancos (Art. 69, Nº 10), es función de los bancos emitir Cartas de Crédito, con plazos que no excedan de un año. El plazo a que se emite la carta no puede ser superior a un año, lo que no significa que se pague en ese plazo sino que cuando pido la carta, tengo que hacerlo en el momento en que el transporte se vaya a producir.

Es decir, el beneficiario va a poder utilizarla para negociar con su contraparte durante ese período de tiempo. Este plazo es distinto al que tiene el beneficiario para su pago después de ser utilizada, que puede ser superior a un año, según lo acordado.

El Banco solamente entrega una validez por un año porque lo que hace el Banco al final es darle un crédito al cliente, con el objetivo de que el cliente financie la importación. Esto es una actividad mercantil del comerciante que quiere traer mercadería para venderla, entonces para eso requiere de un crédito del banco. El banco hace un préstamo de corto plazo por el impacto en la balance del propio banco; son obligaciones crediticias de corto plazo. El legislador no quiere que haya una obligación “eterna” por parte del banco.

Puede que no exista crédito cuando se abre la Carta pero el cliente da el dinero inmediatamente. El contra de esto es que se inmoviliza el capital, pero no tengo que pagar intereses y reajustes del capital.

(ii) Plazo de pago del crédito.

Puede que haya otro plazo pactado entre el comprador y su banco, en virtud del cual el cliente tiene que pagar el crédito que le otorgó el banco (si hubo financiamiento por parte del banco).

(iii) Plazo dentro del cual debe ser embarcada la mercadería.

Si cuenta con un Informe de Importaciones, el plazo de embarque no puede exceder el de la vigencia del documento: Actualmente 120 días.

(iv) Plazo dentro del cual han de presentarse los documentos para su negociación:

Es un plazo posterior a la fecha de embarque e inferior a un año desde la fecha de misión de la Carta de Crédito.

(v) Regla General (dictada por la ICC).

A falta de acuerdo (no es lo normal), se usan estas normas.

La ICC generó además los denominados “Usos y Reglas Uniformes relativos a las Cartas de Crédito”, que es una normativa generalmente aceptada en todo el mundo para la operatoria de las cartas de crédito y dan seguridad respecto de su funcionamiento y efectividad.

Los créditos deben indicar la fecha de su vencimiento y el lugar de presentación de los documentos para su pago. Si no indica fecha, rechaza los documentos presentados después de 21 días contados desde la fecha de embarque.

El vendedor no quiere que la Carta quede sujeta a interpretaciones, entonces la Carta generalmente sigue ciertos formatos.

D) Modalidades de Apertura de Cartas de Crédito entre el ordenante y el banco emisor.

¿Cómo hago para no tener problemas de confianza, sabiendo que comprador/vendedor están en lugares distintos?

(i) Con financiamiento del banco:

Al momento de la apertura, el cliente paga:

- Gastos
- Comisión
- Reembolsa valor del acreditivo una vez que se reciban los documentos de embarque

Esta modalidad beneficia al importador, ya que no inmoviliza fondos hasta el momento en que realiza la cobertura. El banco otorga el crédito, que se hace efectivo al momento en que la Carta de Crédito es pagada en el exterior.

Generalmente la garantía existente son los documentos de embarque que por el otorgamiento del crédito se extienden a la orden del banco. Si no hay pago del crédito, el banco puede hacerse de las mercaderías.

(ii) Depósitos en moneda chilena.

La carta acá solo se usa para dar seguridad al exportador que se va a pagar el precio de la CV. Como el importador no puede adquirir anticipadamente la moneda extranjera (Ley del Banco Central que eventualmente puede limitar el acceso a divisas por medio del mercado cambiario formal), entrega el equivalente en moneda nacional al tipo de cambio de la fecha de la apertura de la Carta de Crédito (produciéndose una venta condicional de moneda extranjera).

Los problemas que genera esto es que inmoviliza fondos y además que puede sufrir el riesgo de la variación del tipo de cambio.

(iii) Depósitos en moneda extranjera.

Puede que, a pesar de lo señalado en el caso anterior, un importador tenga disponibilidad propia de moneda extranjera. En este caso, el banco emite la Carta de Crédito contra el monto del depósito.

E) Forma de pago

También puede emitirse en esta modalidad una Carta de Crédito a plazo, no sólo a la vista. El pago al beneficiario se realice después de cumplirse un plazo determinado contado (i) desde la fecha del embarque de las mercancías o (ii) desde la fecha de la negociación de la Carta de Crédito.

Esto en definitiva es un crédito del proveedor, pero garantizado por la Carta de Crédito, siendo el beneficio que dicho crédito se mantiene hasta la fecha de vencimiento.

Como operación de pago de una importación, el dinero representativo de la Carta puede pagarse al fabricante **a la vista** (emito la carta y basta que el fabricante la presente para el pago) **o a plazo** (habría un crédito proveedor entre exportador e importador, además del crédito del cliente con su banco, y puede coordinarse que sean créditos absolutamente equivalentes).

Los departamentos de operaciones de comercio exterior de los bancos son sumamente activas y una de sus funciones principales es generar la mecánica para negociación de las cartas de crédito (revisión de la carta). Esto porque como es una orden irrevocable, si el banco paga y se equivoca no puede repetir contra el cliente.

F) Transacción mediante Carta de Crédito.

Generalmente las partes son:

1. Comprador: Importador o cliente.
2. Banco del comprador.
3. Vendedor.
4. Banco en país del vendedor: Opcional
5. Transportista (emite los documentos que permiten transferir el dominio).

Además, involucra a lo menos varios contratos:

- a) Compraventa
- b) Bill of Lading: Representativo del contrato de transporte.
- c) Carta de Crédito: Promesa del banco comprador (y si es confirmada, también del banco del vendedor) de pagar bajo ciertas condiciones una vez probado que el vendedor ha enviado los bienes.

G) Etapas:

1) Contrato de Compraventa:

Las partes fijan las condiciones, siendo estas partes exclusivamente el comprador y vendedor. Con ello el vendedor emite la factura, con lo que en Chile se gestiona el Informe de Importación, que contempla el “acreditivo” como forma de pago. Con ello, el importador puede abrir la Carta de Crédito.

2) Contrato de transporte:

Generalmente las partes están distantes, no hay comunicación ni presencia directa entre ellos, por lo que las mercaderías deben ser trasladadas.

Para eso, el Vendedor generalmente contrata el transporte: BL (bill of lading o conocimiento de embarque) emitido por el transportista. Por él, a cambio del pago del flete, el transportista entregará las mercaderías:

- a. Al consignatario: Si el BL es nominativo.
- b. Al portador o a la orden de quien se emitió (endosatario) si es negociable.

De esta manera se asegura la entrega de los bienes, mientras que la Carta de crédito asegura el pago.

3) Carta de Crédito:

Antes de enviar las mercaderías y al no estar en contacto con el comprador, el vendedor quiere asegurarse que le pagarán.

Para ello, muchas veces no es suficiente,

- a. La promesa de pago del comprador,
- b. La promesa del banco del comprador, a lo mejor no lo conoce,
- c. Prefiere por tanto una promesa de un banco conocido, ojalá de su país.

La carta de crédito es un contrato, una promesa realizable por un banco que pagará al vendedor el precio del contrato de compraventa. Es una promesa de pago que asume el banco y no el importador mismo, de que cumplidas ciertas condiciones va a pagar.

El pago se realizará en definitiva contra demostración del envío de las mercaderías, es decir, del BL, que significa (i) que las mercancías están enviadas, (ii) que están destinadas al comprador y (iii)

que el banco que otorga la Carta de Crédito puede controlar el envío mediante la posesión del BL (se asegura el pago del crédito por el comprador).

A veces me interesa estar seguro de que lo que se entrega es lo que compré y ahí entran ciertos certificados de inspección o permisos de exportación.

La Carta de Crédito puede tener diferentes modalidades, pero será muy importante los plazos de validez para embarcar y negociar.

Según si el pago está confirmado entre el banco del vendedor y el del comprador (llamado para estos efectos “banco negociador”) o no lo está, se hará el pago una vez que el vendedor acompañe todos los documentos que se hayan previsto en el contrato de compraventa por las partes. Habitualmente son los siguientes:

- a. BL negociable.
- b. Factura: Términos de compra, número de bienes, etc.
- c. Seguros: Póliza.
- d. Certificado de Inspección: Emitido por una firma de inspección, señalando que los bienes están conformes.
- e. Permiso de exportación o certificado de salud.
- f. Certificado de origen (Chile tiene TLC con ciertos países entonces solo con este certificado no se pagan aranceles en Chile).
- g. Inspección sanitaria

También puede que el pago sea a la vista o a plazo, una vez se haya acreditado todo lo anterior. El momento más importante es la revisión, que hace que el banco negociador para determinar si tiene todos los antecedentes:

- Si están conformes: Lo envía al banco emisor de la Carta de Crédito, quien a su vez lo revisa, da el visto bueno y el banco negociador paga.
- Si no lo están y los bancos pagan, es responsabilidad de los bancos.

Con ello se produce el intercambio de documentos. El Banco cobra como intereses por financiamiento si lo hay, pero otro es cuánto cobra por el servicio de gestión de la Carta de crédito con el banco del exportador.

4) Contrato de seguro

En un contrato de transporte, las cosas perecen para el acreedor (comprador), porque ya es dueño de las cosas. Si las cosas vienen de China, aumentan los riesgos por parte del transporte por lo tanto muchas veces, y como parte de los INCOTERMS, se involucran seguros para la etapa de transporte.

4. La situación en Chile

En Chile, por el sistema que hemos adoptado hace más de 40 años (apertura hacia el comercio exterior), si leemos las normas del BC en relación a la regulación de cambios internacionales, nos

vamos a encontrar con que normalmente las normas excluyen de limitaciones los pagos en el comercio exterior.

En general hay pocas restricciones al comercio internacional, más allá de obligaciones de información.

CAPÍTULO II: Contratos de seguro

Son herramientas jurídicas que permiten dar seguridades adicionales al **comercio internacional**. A parte de su función económica, es una herramienta que facilita el comercio internacional que requiere de un transporte riesgoso como es el marítimo.

Los seguros nacieron a propósito del comercio marítimo por la inseguridad de este tipo de transportes; son una forma de atenuar (no eliminar) los riesgos de pérdida de las mercaderías en tránsito. Hay menciones a este contrato ya en el Código de Hammurabi. El seguro es antiguo porque es una actividad humana que nace casi con el comercio mismo.

Ahora, también lo estudiamos porque el seguro se desarrolla en forma organizada a través de empresas. De hecho, desde 1929 tenemos normas que crean las compañías de seguro. Entonces, la **industria aseguradora** es una actividad mercantil, porque hay una actividad intermediadora de riesgos.

El riesgo siempre está presente en la actividad mercantil, de hecho es común que las cosas se encarezcan porque el precio incorpora dicho riesgo. Entonces, para sacar de ese precio el riesgo, aparece un tercero que intermedia el riesgo y se hace cargo del mismo.

¿Por qué la empresa de seguro está dispuesta a cobrar poco para hacerse cargo de un riesgo mucho más caro? Por que la compañía de seguro es capaz de prever estadísticamente y con alto grado de certeza qué riesgos se van a materializar, lo que se suma a que la compañía asegura muchos riesgos entonces recibe más que las indemnizaciones que tiene que pagar; hay una suerte de “mutualidad” porque todos aportan con su prima y se hacen cargo entre todos de que a uno le pase algo.

El seguro no solo es un gasto sino que lo más importante es que se traspassa un determinado riesgo a otra persona.

El año 2013 se modificó el ccom en estas materias, y se modernizó la normativa sobre el contrato (**arts 512 y ss**).

Factores extrajurídicos que explican la actividad del aseguramiento

1. El fundamento económico del seguro

El estudio de los fenómenos que dicen relación con el riesgo no necesariamente se relacionan con la ciencia jurídica porque hay elementos económicos (valoración del riesgo), matemáticos (probabilidades), actuariales, etc.

El seguro es una garantía frente a un riesgo determinado entonces como el asegurador provee esa garantía (seguridad) contra una consecuencia patrimonial adversa que provoca un perjuicio, esos

efectos se reparten entre un conjunto de personas (PN o PJ) cuando están expuestas a un mismo tipo de riesgos (por eso hablamos de una especie de mutualidad).

El seguro es un producto del riesgo. Todo riesgo engendra una preocupación y un deseo de seguridad. La finalidad del seguro consiste en dar seguridad contra el riesgo. Pero esta seguridad no puede alcanzarse por la supresión directa del hecho temido (fuego, granizo, robo, enfermedad, muerte, etc.), sino tan sólo por la certeza de que, al sobrevenir la situación que se teme tendremos a nuestra disposición un valor económico que la compense.

Este valor seguro que se espera sustituye al valor cuya pérdida se teme. El seguro pone lo seguro en lugar de lo inseguro: esta es la esencia de la institución. De aquí los dos elementos fundamentales del concepto del seguro: *el riesgo y la aportación de un sustitutivo económico*.

El seguro como operación económica, consiste en una garantía contra las consecuencias patrimoniales dañosas provocadas por la verificación de un riesgo determinado, cuyos efectos se reparten entre una pluralidad de sujetos expuestos a un mismo tipo de riesgo. Es el factor mutual presente desde los inicios históricos de este negocio jurídico el que da viabilidad económica al seguro. Se provoca mediante la dispersión o reparto de los efectos del daño o necesidad económica, una morigeración de las consecuencias que ocurren por la verificación del riesgo asegurado o siniestro.

Hay una atomización de los efectos del daño por eso se pueden atenuar las consecuencias de los siniestros.

En resumen, los individuos, en las actividades que realizan, están expuestos a distintos riesgos.

Pero las personas por lo general no lo sienten como un problema, porque normalmente se visualiza el problema cuando este se sufre y no antes. La existencia de riesgos permanentes de distinta naturaleza, entonces, se suma a la sensación de que esto no es verdaderamente un problema hasta que no se experimenta una situación que me hace buscar un resguardo.

a) Objeto:

Su objeto es indemnizar que las personas sufran alteraciones en su patrimonio o pierdan o dañen su vida a consecuencia de imprevistos o accidentes.

Es una forma a la vez técnica y colectiva de previsión con dos pasos, la prevención y luego la indemnización.

El asegurador tiene sobre todo un rol económico que es restituir la pérdida de patrimonio.

b) Evolución Histórica:

1. Mutualidad: Unión de muchas personas que están expuestas a los mismos riesgos, bajo el compromiso de que entre todas satisfacerán la indemnización de las pérdidas ocurridas a algún miembro de la asociación.
2. Préstamo gruesa ventura: Al prestamista se le paga un precio (la prima) sin límite de usura, en expediciones comerciales. Si la expedición se pierde, el prestamista no recupera el negocio.

3. Transferencia de riesgo: La persona amenazada, mediante el pago de una suma de dinero, se garantiza de ser indemnizada por un tercero en caso de ocurrir un siniestro previsto.
4. Seguro moderno: Combinación de sistemas. Si en la apariencia el asegurado transfiere el riesgo materia del contrato al asegurador, este es administrado por una vasta multitud de unidades económicas sujetas a riesgo, medio a través del cual los asegurados se apoyan mutuamente.

1.1 El riesgo en la función económica del seguro

Riesgo significa la posibilidad de que, por azar, ocurra un hecho que produzca una necesidad patrimonial/económica. El riesgo es un estado (estado de necesidad económica) que se produce por consecuencia de un hecho.

Es la probabilidad de ocurrencia de un hecho que va a provocar una necesidad económica, de lo contrario, el riesgo puede no ser asegurable.

- a) Baeza: Amenaza de pérdida o deterioro que afecta o a bienes determinados o a derechos específicos o al patrimonio mismo de una persona en su totalidad. También puede recaer sobre la vida, salud física o psicológica de una persona.
- b) Art. 513 letra t): Eventualidad de un suceso que ocasione al asegurado o beneficiario una pérdida o una necesidad susceptible de estimarse en dinero

La amenaza de esta probabilidad de ocurrencia motiva a que las personas busquen evitar ese daño o morigerarlo.

En general el riesgo se relaciona directamente con la posibilidad que efectivamente ocurra. Soportar el riesgo querrá decir sufrir las consecuencias económicas de la realización del hecho previsto como posible, dar seguridad contra el riesgo, pero ello no puede alcanzarse suprimiendo directamente el hecho temido. Es así como el riesgo deberá necesariamente transferirse a un tercero, distinto a aquél que está expuesto a dicha necesidad. La transferencia a otro del riesgo que nos amenaza puede concretarse mediante el mecanismo de las mutuas o mutualidades, que consisten en un grupo de personas que amenazadas a un mismo riesgo o riesgo análogo buscan resguardo, o mediante el moderno sistema asegurador, desarrollado por compañías de seguro legalmente constituidas. Son estas entidades, las que asumen el riesgo que un individuo particular les traspasa.

Clasificación del riesgo

1) Riesgos puros o especulativos

- a) Riesgos puros: Por la connotación negativa, un riesgo puro es equivalente al 100%, ya que si ocurren son devastadores. P.ej. Fuego, inundación, etc.
- b) Riesgos especulativos: También llamados empresariales, son en general los del comercio, y no son asegurables, ya que para eso existen otras transacciones comerciales.

2) Riesgos fundamentales o particulares

a) **Riesgos fundamentales:** Hay riesgos que afectan a toda la sociedad, ya que tienen elementos de catástrofe. P.ej. guerra, huracán. Son eventos tan grandes que atañen a toda la sociedad.

b) **Riesgos particulares o individuales:** Es una pérdida para un individuo determinado o para un número relativamente chico de individuos. Es el más habitual.

Reacción al riesgo

La reacción al riesgo va a depender de si lo valoramos y de si hemos tomado conciencia del él:

a) **Imprevisión** (no se previene nada). Hay riesgos que aceptamos,

- 1) Sabemos que no son eliminables o evitables en un 100%.
- 2) No lo conocemos.
- 3) Sus consecuencias no son serias.
- 4) Las consecuencias de evitarlo son inaceptables.
- 5) Deseamos el riesgo.

Hay empresas que tienen riesgos que son tan caros de asegurar que prefieren el “autoseguro” (asumen las consecuencias eventuales del riesgo).

b) **Prevención.** Hay riesgos que tratamos de evitar, aquellos que afectan nuestra vida o nuestro bienestar, tanto a nivel individual como a nivel social.

En ese sentido, podemos intentar prevenir los riesgos o tratar de morigerar sus efectos. ¿Cómo los evitamos?

- Mejorando los métodos. P.ej. Nuevos equipos, mayor seguridad y bajan los costos.
- Fusiones: Tener más capacidad de soportar siniestros.
- Seguro: Se transfiere el riesgo al fondo, a la compañía.

c) **Previsión.** Lo que se hace es traspasarle a otro el riesgo; no es una venta del riesgo jurídicamente hablando sino que otro se hace cargo del riesgo. Cuando quiero transferirle el riesgo a otro, esto puede hacerse mediante dos sistemas:

c.1 Mutualidades. En la mutualidad, el conjunto de los que están expuestos a un mismo riesgo se resguarda a sí mismo, lo que se encuentra en el Código de Hamurabbi (todos los que están expuestos al mismo riesgo en una vía comercial, responden si a alguno le pasa algo).

c.2 Sistema de seguro moderno.

Hay que tener claro que el traspaso del riesgo no es ilimitado porque no todos los riesgos que afectan la esfera económica se asumen por el asegurador (no todos los riesgos son asegurables, hay algunos riesgos que siendo asegurables son excluidos por la ley, p.ej si hay dolo en la contratación del seguro, y hay algunos riesgos excluidos convencionalmente).

El seguro nunca puede ser ocasión de ganancia para el asegurado, y la descripción del riesgo que está obligado a hacer el asegurado es esencial porque permite que la compañía determine si el riesgo es asegurable y cuáles son sus límites, probabilidades, costos, etc.

Elementos

a) Posibilidad: Debe existir la posibilidad de que ocurra un hecho dañoso o surja una necesidad patrimonial

b) Incertidumbre: Si la esencia del seguro consiste en poner lo seguro en lugar de lo inseguro, para que exista la institución tiene que haber una inseguridad o incertidumbre.

Nadie busca un seguro contra acontecimientos imposibles y nadie lo concede contra acontecimientos ciertos.

c) Azar: La realización del hecho previsto ha de ser fortuita, entendiendo por fortuito todo lo que es independiente de la voluntad de la persona amenazada por el hecho previsto como posible.

El concepto del azar en el contrato de seguro tiene una doble cara. Este azar domina siempre toda la operación de seguro aisladamente considerada, pero la explotación en masa que caracteriza la actividad de las empresas aseguradoras permite un cálculo preciso sobre la realización del riesgo.

d) Necesidad Pecuniaria: En la doctrina del seguro, todo riesgo implica la amenaza de que ocurra un hecho que provoque una necesidad pecuniaria.

1.2 Aportación de un sustitutivo económico

La esencia del seguro, como institución económica, está en que produce la cobertura inmediata de un valor sustraído por cualquier causa de un patrimonio privado, mediante otro valor (valor de sustitución o de reemplazo).

Lo ideal es que ambos valores se equiparen totalmente, es decir, que haya cobertura completa. Cuando el de sustitución queda por debajo, el seguro no cumple íntegramente su finalidad. Cuando queda por encima, el seguro se convierte en pura especulación.

Entre el hecho temido y la aportación del sustitutivo económico debe existir una relación de causa efecto. Esta relación de causalidad debe estar determinada antes de la realización del hecho, de tal modo que la persona amenazada tenga la certidumbre de que cuando ocurra ese hecho ingresará en su patrimonio un valor que reemplace al valor perdido.

Esa certidumbre no puede ser matemática, sino tan sólo jurídica, bajo la forma de una acción contractual que le permita reclamar al asegurado la entrega del sustitutivo. Ese negocio jurídico constituye el contenido del Derecho de Seguro.

En síntesis, sea cual sea su forma de explotación, el seguro es mutualidad o no es seguro. Este es elemento económico constante en el seguro, aunque varíe su forma jurídica.

No toda institución que sirva para asegurar, mediante un negocio jurídico, un sustitutivo o reparación al amenazado por un riesgo es un seguro. Lo será únicamente cuando aquella finalidad

se alcance mediante la distribución del daño entre un gran número de personas amenazadas por idénticos riesgos.

Seguro, económicamente hablando, es la cobertura recíproca de una necesidad pecuniaria y estimable relativa a múltiples economías amenazadas de igual modo.

El seguro moderno, para esta transferencia de riesgo, sigue una serie de normas técnicas:

a) Ampliación de la masa de seguros:

Mientras más riesgos cubro, más grande es el número de asegurados que tengo. Si tengo más asegurados percibiré más primas y eso hará que al tener siniestros tengo porcentualmente menos egresos, porque la probabilidad de tener siniestros es una progresión aritmética, y el número de asegurados en una progresión geométrica.

b) Homogeneidad de riesgos cubiertos:

Son riesgos susceptibles de ser medidos de tal modo que la compañía tiene certeza de poder pagar las indemnizaciones.

c) Fraccionamiento de los montos asegurados:

La cantidad asegurada debe permitir que el valor de la prima esté al alcance de la mayoría de la gente. Si asegura un monto alto, la prima es también más alta.

d) Reaseguros:

El sistema funciona de tal modo que una compañía puede asegurar sus riesgos con otra compañía para que la indemnización y primas no sean tan altas.

e) Cálculo científico de la prima:

Corresponde matemáticamente a la obligación del asegurador, más gastos más utilidad. Ello permite abarcar primas y dar mayor acceso.

1.3 Conceptos relevantes

Contrato en que una parte le transfiere un riesgo a otra que se hace cargo de indemnizar a la parte que transfirió el riesgo si ocurre un evento dañoso. El que “vende el riesgo” es quien está expuesto a sufrirlo, aunque se puede asegurar el riesgo que va a sufrir un tercero.

Si el riesgo se materializa, entonces la aseguradora indemniza y repara el daño volviendo al estado en que se encontraban las cosas.

Como el otro corre el riesgo, entonces quien corre el riesgo paga una prima para que el riesgo lo asuma el asegurador. Si el riesgo se materializa dentro del período, entonces el asegurador paga la indemnización que corresponda (depende de lo que se haya pactado, pero nunca puede ser mayor al valor del daño).

Entonces, el comprador del riesgo es la aseguradora, el vendedor el asegurado y el precio es la prima.

La **póliza** es la prueba de que existe un contrato de seguro, y ahí constan las condiciones del contrato de seguro.

2. Legislación aplicable

2.1 Fuentes legales

Normas de derecho privado

a) Código de Comercio, art. 512 y siguientes (regulación recientemente modificada por la Ley 20.667, que entró en vigencia el 1 de diciembre de 2013)². Constituye la fuente principal, en razón del criterio de imperatividad contenido en el Art 542.

b) Código Civil.

c) Ley 19.496: Ley de Protección al Consumidor (en cuanto a la regulación de los contratos de adhesión). c) DFL 251: Normas sobre las empresas de seguros, contiene normativa sobre cómo se debe ejercer el comercio del seguro en Chile.

Normas de derecho público

a) CPR.

b) DFL 251 (Normas sobre las empresas de seguros, contiene normativa sobre cómo se debe ejercer el comercio del seguro en Chile.).

c) DL 3.538 (ley orgánica de la CMF, que fiscaliza estas materias).

d) Normas relacionadas con los seguros sociales.

d.1) Ley 16.744: Seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

d.2) DL 3.500: Fondos de Pensiones.

d.3) Ley 18.490: Seguro obligatorio para cubrir accidentes personales causados por vehículos motorizados.

2.2 Fuentes convencionales

La fuente principal es la **el contrato y su póliza**, y en especial sus condiciones generales.

Contrato y póliza no son lo mismo pero esta última da cuenta de la existencia del contrato. El contrato ya existe desde el acuerdo de voluntades, siendo la póliza únicamente la prueba.

En Chile, desde la entrada en vigencia de la Ley 20.667, al igual que en el derecho comparado, el contrato de seguro es consensual y la póliza sólo sirve de antecedente o prueba del contrato de seguro. Art. 513 letra p).

² En el año 2010 los efectos del Terremoto que afectó a nuestro país, impulsaron una iniciativa modificatoria del Título VIII, Libro II del Código de Comercio. Se trata de una iniciativa que tiene su génesis en un trabajo preparatorio que data de 1990. Este proceso, de más de 20 años culminó con la promulgación y posterior publicación de la Ley 20.667 en el Diario Oficial de la República el 09 de mayo del 2013.

Las pólizas son verdaderos formularios, donde se distinguen:

- a) Condiciones Generales: Iguales para todos los seguros del mismo tipo.
- b) Condiciones Particulares: Lo que corresponde a todo lo que de particular tiene el seguro.

Es por lo tanto un contrato dirigido regulado y vigilado por el poder público: CMF. Es por ello que se deben registrar las condiciones generales de las pólizas en la CMF. Excepción: Compañías de Seguros Generales, si:

- Asegurador y asegurado son personas jurídicas.
- Monto de prima anual no sea inferior a 200 UF.

También hay **normas de aplicación internacional** que se adoptan contractualmente en determinados contratos de seguros, como las reglas de York y las de Amberes.

3. Principio de imperatividad de las normas que rigen el Contrato de Seguros

El artículo 542 Comercio introduce un criterio de imperatividad³ en las normas que regulan el contrato de seguro, al disponer:

Art. 542 ccom. *Carácter imperativo de las normas. Las disposiciones que rigen al contrato de seguro son de carácter imperativo, a no ser que en éstas se disponga otra cosa. No obstante, se entenderán válidas las estipulaciones contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado o el beneficiario.*

Exceptúanse de lo anterior, los seguros de daños contratados individualmente, en que tanto el asegurado como el beneficiario, sean personas jurídicas y el monto de la prima anual que se convenga sea superior a 200 unidades de fomento, y los seguros de casco y transporte marítimo y aéreo.

Antiguamente (antes del 2013) el principio era el de disponibilidad, es decir, que las partes podían disponer de las cláusulas del contrato. Pero actualmente las normas que establece la ley son de OP y por lo tanto indisponibles por las partes.

Esto afecta tanto la interpretación como la fiscalización del contrato de seguro.

3.1 Significado de la Imperatividad del Art. 542 y fuentes normativas

La imperatividad debemos entenderla en el contexto del carácter de orden público de protección de la norma legal, categorización que impide a los contratantes establecer una regla diversa a la contenida en la ley. Esta inmovilidad del contenido normativo legal, busca tutelar al contratante en desventaja, que nuestro legislador ha entendido es el asegurado o contratante del seguro, en calidad de consumidor, debido al carácter masivo o estandarizado del contrato de seguro (contrato de adhesión). Dicha masividad deja al asegurado en una posición de “desventaja”, por lo que el legislador abandona su posición de partida neutral y pasa a considerar que existe una

³ Consideremos que la normativa decimonónica que rigió hasta el 01 de diciembre del 2013, contenida en el Código de Comercio era por lo general dispositiva. Este criterio normativo de imperatividad constituye uno de los ejes centrales de la reforma introducida por la Ley 20.667.

situación de desequilibrio estructural entre las partes, que justifica que la reglamentación proveída y la imperatividad de las normas que regulan el contrato de seguro.

Lo que manda es la ley y los contratantes no pueden pactar algo distinto del contenido legal, lo que busca cuidar o tutelar al contratante más débil (el asegurado, que es una especie de consumidor). La aseguradora no es contratante “fuerte” por tener más espalda económica, sino porque predetermina el contenido del contrato; estamos ante un contrato de adhesión al menos respecto de las condiciones generales del contrato porque no se justifica tener que estar pactando día a día distintos contratos con distintos contenidos por un tema de rapidez del tráfico jurídico.

Hay un límite a la libertad contractual bastante grande pero el tema es que puede que la imperatividad sea costosa para el asegurador entonces eso al final lo asume el asegurado.

3.2 Efectos de la Imperatividad en la actividad de los aseguradores y en la función fiscalizadora de la CMF

a) Desde el punto de vista del asegurador: Se restringe su libertad en la elaboración de condiciones generales de la contratación. Los aseguradores sufren, en consecuencia, el rigor y las consecuencias normativas e interpretativas de ser los “predisponentes” del contrato.

b) Desde el punto de vista de la CMF: La facultad discrecional de la CMF para controlar el contenido de las condiciones generales que integran el contrato de seguro (art 3 letra e) DFL 251), queda desplazada por ley y se subordina normativamente al artículo 542 (que establece el carácter de imperatividad a las normas que rigen el contrato de seguro). En virtud de lo anterior, el inciso 4to del artículo 3 letra e) del DFL 251 se encuentra derogado tácitamente.

La CMF puede decir que una norma contractual no es aplicable, entonces hay una labor interpretativa y conductora de las relaciones contractuales. Es más, la CMF puede fijar mediante NCG las disposiciones mínimas de las pólizas.

3.3 Excepciones a la Imperatividad

El artículo 542, establece como parámetros de exclusión de la imperatividad los siguientes:

- a) Los casos en los que la ley dispone otra cosa;
- b) Los casos en los que se pacten condiciones más beneficiosas para el asegurado o el beneficiario (puede ser distinto de asegurado);
- c) “Seguros sobre grandes riesgos”: los *seguros de daños* contratados individualmente, en que tanto el asegurado como el beneficiario, sean personas jurídicas y el monto de la prima anual que se convenga sea superior a 200 unidades de fomento, y *los seguros de casco y transporte marítimo y aéreo*.
 - c.1 El primer caso dice relación con empresas porque exige que hayan PJ.
 - c.2 Los otros casos prevén el daño que pueden sufrir barcos o aviones en la actividad de transporte. Esto porque también se asume que son grandes riesgos.

En estos casos, excepcionalmente, el legislador deja subsistente el principio dispositivo o de autonomía de la voluntad.

3.4 Efectos de la inobservancia de la Imperatividad

La inobservancia al artículo 542 produce la ineficacia contractual, en concreto la nulidad absoluta del seguro, total o parcial, según los casos; por contravención a norma expresa de orden público.

4. El contrato de seguro

4.1 Concepto

Art. 512 ccom. *Contrato de seguro. Por el contrato de seguro se transfieren al asegurador uno o más riesgos a cambio del pago de una prima, quedando éste obligado a indemnizar el daño que sufre el asegurado, o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones pactadas.*

No se anula la definición antigua, pero se moderniza. Este artículo reconoce de mejor manera la actividad mercantil del aseguramiento porque reconoce diversas prestaciones que puede suponer el contrato de seguro, lo que le da más flexibilidad a la elaboración de los productos de seguro.

Lo más importante es entender que el asegurador asume un riesgo, una carga, que implica un evento dañoso mientras el asegurado queda libre de esos efectos. Pero no todos los riesgos que afectan la esfera económica de una persona pueden ser objeto de un seguro (ya sea legal o convencionalmente), entonces el asegurador carga un **riesgo determinado y correctamente delimitado o circunscrito**, por eso es importante la etapa precontractual para determinar el riesgo, su delimitación, plazo, etc.

Es un contrato mercantil por la actividad de intermediación.

4.2 Cambio sustancial en la definición y características del Contrato de Seguro.

Previo a la reforma, el contenido decimonónico del contrato de seguro se caracterizaba de la siguiente forma: “Art. 512: *Contrato bilateral, condicional y aleatorio por el cual una persona natural o jurídica toma sobre sí por un determinado tiempo todos o algunos de los riesgos de pérdida o deterioro que corren ciertos objetos pertenecientes a otra persona, obligándose mediante una retribución convenida, a indemnizarle la pérdida o cualquier otro daño estimable que sufran los objetos asegurados*”.

Se dejaban fuera a los seguros de vida y los demás relacionados (como seguros de salud). Además, no se consideraban otras prestaciones que no tienen carácter indemnizatorio por ejemplo si choco el auto y el seguro incluye una grúa; o el caso de un seguro de salud cuando hay prestaciones que no son indemnización sino por ejemplo el auxilio telefónico de un doctor.

a) Críticas a la antigua definición legal:

En la discusión de la reforma legal al sistema de seguros, la definición del antiguo artículo 512 fue sometida a las siguientes consideraciones:

a.1 La definición está obsoleta:

1. No es un contrato aleatorio, ya que:

- No hay contingencia de ganancia, sólo pérdida.
- Se paga por traspaso del riesgo, es conmutativo.

2. Calidad de asegurador no puede pertenecer a personas naturales, art. 4º DFL 251.

a.2 Definición incompleta: No se refiere a seguros de vida, salud, integridad física, psíquica.

a.3 Definición errónea:

- Califica el contrato de condicional, cuando es puro y simple; las obligaciones de las partes nacen desde el primer momento: Traspasa el riesgo. Existe un derecho eventual, que es que el asegurador pague la indemnización si ocurre el siniestro.
- No es aleatorio, es conmutativo (riesgo vs. precio) incluyendo la obligación de pagar la prima y la del asegurador de pagar la indemnización.

b) Características actuales del Contrato de Seguro:

El concepto de contrato de seguro que introduce nuestro legislador mediante la Ley 20.667, no refiere características de este contrato. No obstante ello, se trata en el contexto de nuestro derecho común de un contrato que tiene las siguientes características:

b.1 Bilateral: Ambas partes, asegurador y asegurado, quedan recíprocamente obligados. El *primero* al cumplimiento de la prestación convenida en el caso de ocurrencia del riesgo asegurado y el *segundo* al pago de la prima. Además, entre ambos elementos –prima y riesgo– debe haber *proporcionalidad*, presupuesto fundamental para la viabilidad económica de la actividad del aseguramiento. Por ejemplo, si se cubre un activo que vale 100mil pesos y la prima es de 200mil pesos, evidentemente no hay proporcionalidad.

La obligación esencial del asegurador es la de tomar el riesgo de la forma establecida en el contrato, lo que puede tener como consecuencia eventual la indemnización en caso de que se produzca el siniestro. Pero hay que tener claro que el asegurador no hace desaparecer el riesgo.

b.2 Oneroso; Busca un beneficio para ambos contratantes. Advertimos, eso sí, que para el asegurado – en los casos de seguros de daños – no puede haber ganancia, utilidad o enriquecimiento, ya que ello atenta en contra del principio indemnizatorio de los seguros de daños, que nuestro legislador recoge expresamente en el artículo 550.

La indemnización solo tiene naturaleza compensatoria (que el asegurado quede en las mismas condiciones en que se encontraba antes del siniestro) y no puede generar utilidad para una de las partes.

b.3 Conmutativo: Asegurado debe pagar la prima y asegurador debe pagar la indemnización, por lo tanto hay prestaciones equivalentes.

- Para el asegurador es una actividad basada en el cálculo de prima por cada seguro. Es por ello que quizá se equivoca y pierde en un contrato determinado, pero no en la generalidad.

El negocio asegurador está reservado para SA especiales porque se requiere un patrimonio mínimo, además de que se exigen ciertas “posiciones” relevantes como la figura del actuario porque esto es un negocio estadístico matemático para que la aseguradora efectivamente pueda beneficiarse del contrato.

A lo que se apunta es que las probabilidades de que se produzcan TODOS los siniestros asegurados es muy baja (o si se producen, ello va a suceder en un espacio de tiempo amplio).

- Para el asegurado, no es aleatorio porque excluye la posibilidad de ganancia y porque nunca pierde, ya que si no hay siniestro paga por la transferencia de riesgo, y si lo hay, por la indemnización compensatoria.

A partir de la reforma, varios autores consideran que sí hay un factor de aleatoriedad, sobre todo en los seguros de persona porque depende de lo que contrato, el monto de la indemnización. Esto procede en relación a la proporcionalidad del seguro que contrato con la indemnización que recibo, porque en algunos escenarios puede que no haya tal proporcionalidad y que eventualmente la indemnización genere algo de utilidad. Esto sucede en los seguros de vida porque es difícil avaluar la pérdida patrimonial que produce la pérdida de una persona.

Las aseguradoras en casos de seguros de vida cobran una determinada póliza que es un promedio del riesgo en toda la vida de una persona. En ese sentido, si una persona joven toma el seguro entonces está pagando “más” de lo que le correspondería porque el riesgo es menor, y si una persona adulta toma el seguro entonces está pagando “menos” porque el riesgo es mayor, pero el tema es que la aseguradora hace un promedio.

¿No depende la aleatoriedad de la contingencia incierta de ganancia o pérdida, es decir, que se produzca o no el siniestro? En el contrato de seguro lo que se traspasa es el riesgo, entonces ahí no hay tanta aleatoriedad independiente de si puede o no producirse el siniestro en el futuro (“contingencia incierta de ganancia o pérdida”). El tema es que yo ya traspasé el riesgo, la cosa es si después ese riesgo se transforma o no en siniestro.

b.4 Contrato de adhesión (en los casos de contratación estandarizada): La actividad del aseguramiento en esta dimensión, se desarrolla sobre la base de condiciones generales de la contratación que se integran al contrato de seguro celebrado entre el asegurador y el asegurado. El primero es el predisponente, el que determina el contenido del contrato, con limitaciones legales y en el contexto de la imperatividad que ha introducido nuestro legislador en el artículo 542. El asegurado, se limita, por lo general, a tomarlo o dejarlo.

Todos los contratos de seguro tienen que estar registrados con el regulador (CMF).

b.5 Negocio jurídico de máxima buena fe (*uberrimar bonae fidei*): Asegurador y asegurado descansan en la veracidad de la información que recíprocamente se traspasan. Si bien, la *bona fide* que se observa en el contrato de seguro, no se trata de una regla especial en sí (ya que todos los contratos deben tener este elemento), pero se resalta este punto para asentar de manera clara que en este tipo de contratos no cabe la posibilidad de negociar sobre la base del *dolus bonus*, esto es, aquella artimaña permitida en el comercio con el fin de obtener algo de ventaja.

Por ejemplo, cuando contrato un seguro de vida tengo que dar toda la información de salud pertinente y no puedo omitir datos relevantes sobre enfermedades preexistentes. O cuando cobro la indemnización del seguro del auto, no puedo pedir que me arreglen 2 topones si solo uno es producto del siniestro.

Si no hay buena fe, entonces esto afecta en la exigibilidad de las obligaciones contractuales y en el traspaso del riesgo.

b.6 Es un contrato de tráfico: Lo característico del contrato de seguro es el desplazamiento de un riesgo mediante el pago de un precio: por el hecho de recibir ese precio, el asegurador desplaza sobre su patrimonio el riesgo que gravitaba sobre el patrimonio del asegurado. Es decir, en todo seguro, la realización del siniestro provoca daños indemnizables para el asegurado, cuyas consecuencias económicas van a ser soportadas por el asegurador en razón de la mecánica del seguro.

Eventualmente, si se materializa el siniestro, la aseguradora va a tener que indemnizar.

4.3 Clasificación

a) Según la actividad y medio empleado: seguro terrestre, marítimo o aéreo. Esto viene de la época de los fenicios.

b) Clasificación legal (Art. 544): Nuestro legislador en las modificaciones que introduce el año 2014 abandona la división tradicional entre seguros terrestres y seguros marítimos, recogiendo una clasificación entre seguros de daños (que divide entre reales y patrimoniales) y seguros de personas:

b.1 Seguros de daños (art. 545): aquellos que tienen por objeto la indemnización de los daños sufridos por el asegurado y pueden recaer sobre cosas corporales, derechos o sobre un patrimonio.

b.2 Seguros de personas (art. 588): aquellos seguros que cubren los riesgos que puedan afectar la existencia, la integridad física o intelectual, la salud de las personas y los que garantizan a éstas, dentro o al término de un plazo, un capital o una renta temporal o vitalicia.

Lo que se garantiza es un cierto nivel de patrimonio, con el pago de un capital o una renta (voy pagando por medio de flujos mensuales permanentes en el tiempo).

Las compañías de seguros generales atienden riesgos de seguros de daño, mientras que las compañías de seguros de vida atienden riesgos de seguros de personas.

c) En base a los asegurados:

c.1 Mutuos: Se reúne un grupo de personas con el fin de asegurarse recíprocamente contra determinados riesgos, asumiendo cada persona el carácter de asegurado y el conjunto de ellas el de asegurador. A pesar de ser un contrato individual, esto juega con la

ley de los grandes números porque dependo de que otros contraten la póliza para que la aseguradora me pueda pagar la indemnización pactada.

c.2 Privado: Contratación individual.

c) En base a la indemnización: La indemnización puede ser total o parcial.

d) En función del daño indemnizable:

d.1 Seguros de cosas (incendio, robo). Daño efectivo: disminución patrimonial evidente

d.2 Seguros de personas (accidentes, enfermedad). Daño emergente sobre el cuerpo humano, aparte del daño patrimonial ocasionado por los gastos de curación y el lucro cesante proveniente de la inactividad temporal o definitiva (aunque esto es más difícil de determinar lógicamente, por ejemplo no es lo mismo la póliza que asegura la pierna de Alexis Sánchez hoy que la que era hace 10 años).

d.3 Seguros de vida. Además del daño emergente de la pérdida de la vida y el de los consiguientes gastos inherentes a toda defunción. Se produce también el lucro cesante por el término del trabajo.

4.4 Sujetos del contrato de seguro

a) Asegurador o compañía de seguros

El Asegurador es quien se hará cargo de las consecuencias dañosas de una necesidad económica (riesgo asegurado) que provoca la ocurrencia del siniestro, previo pago de la prima.

Art. 513 letra b): *El que toma de su cuenta el riesgo.*

Al tomar por su cuenta el riesgo, el gran tema son las consecuencias de la producción del siniestro. El DFL 251 regula la actividad aseguradora y exige ciertas características para el asegurador.

a.1) Sociedades aseguradoras

Nuestro ordenamiento jurídico restringe la actividad mercantil del aseguramiento a sociedades que deben ajustarse a las normas contenidas en el DFL 251:

1) Como **“personas hábiles”** para ser aseguradora, el Art. 4 del DFL 251 establece que *“Sólo pueden ejercer el comercio de seguros las SA constituidas en Chile con el objeto único de desarrollar este giro”*.

También pueden desempeñar esta actividad:

- Agencias de compañías de seguros que existen antes del DL 3057/78
- Empresas extranjeras de seguros con la que se contrata directamente, excepto en casos de seguros obligatorios y del DL 3500. Son en general pólizas de seguros de vida (cuando las aseguradoras chilenas no puedan hacer frente a una gran indemnización) o de seguros de daños muy específicos. Art. 46 del DFL 251: Ellos no pueden hacer comercio de seguros en Chile.

2) En relación a la **constitución de la aseguradora**, el artículo 9 del DFL 251 establece que *“la constitución legal de las sociedades anónimas aseguradoras y reaseguradoras, se hará de conformidad a los artículos 126 y siguientes de la ley de sociedades anónimas”*.

3) El DFL 251 en su artículo 8 dispone una **división de las compañías de seguros** apuntando al tipo de aseguramiento o riesgo cubierto, y consecuencia de ello delimitando el objeto social. Dispone la norma citada, que *“las compañías se dividirán en dos grupos. Al primero pertenecerán las que aseguren los riesgos de pérdidas o deterioro en las cosas o el patrimonio. Al segundo, las que cubran los riesgos de las personas o que garanticen a éstas, dentro o al término de un plazo, un capital, una póliza saldada o una renta para el asegurado o sus beneficiarios”*. No obstante lo dispuesto en el artículo 8 del DFL 251, el artículo 11 del mismo cuerpo legal dispone en su inciso 2º que *“las entidades aseguradoras de uno y otro grupo podrán cubrir los riesgos de accidentes personales y los de salud”*.

En las compañías de seguros generales los riesgos que se traspasan pueden ser muy diversos, entonces no es tan lineal la proporción entre riesgo y evento como sucede en el caso de los seguros de vida en que sí hay una relación lineal entre riesgo y edad.

La compañía de seguros debe tener un capital mínimo (90 mil o 120 mil UF dependiendo del tipo de compañía de seguro), además de que debe haber una reserva técnica (sólo se puede invertir esa parte de la plata en instrumentos determinados por la CMF y el DFL, para asegurar que se pueda responder de los siniestros). Por eso esto es un negocio financiero, de hecho, las compañías de seguro son inversionistas institucionales, y por eso también la CMF regula tanto el negocio de aseguramiento como las pólizas propiamente tales.

4) Finalmente y en cuanto a los **seguros de crédito**, el inciso 3º del artículo 11 del DFL 251 dispone que *“los riesgos de crédito deberán ser asegurados sólo por compañías del primer grupo que tengan por objeto exclusivo precisamente cubrir este tipo de riesgo, pudiendo, además, cubrir los de garantía y fidelidad. Las aseguradoras de crédito no podrán otorgar esta cobertura ni aceptar su reaseguro, cuando el asegurado o el deudor de éste sea persona relacionada con la compañía aseguradora o reaseguradora, según el caso. Se exceptuarán de esta prohibición los seguros de crédito a las exportaciones”*.

a.2) ¿Por qué está regulada la compañía de seguros?

Es una contratación en masa, afecta a gran cantidad de personas y son intereses cuantiosos.

- 1) Genera acumulación de grandes capitales y reservas técnicas, cuya inversión debe ser reglamentada para dar rentabilidad y seguridad a quienes han contraído obligaciones con ella. Esto porque las compañías de seguro son inversionistas institucionales.
- 2) El seguro es un respaldo de la integridad de los patrimonios que forman la economía personal y nacional, por lo que la garantía debería estar sujeta a la vigilancia del estado.

No basta que los particulares lo decidan; es el mercado quien también debe hacerlo.

- 3) Es necesario que un mercado sea creíble para entrar en el negocio de reasegurar.

A pesar de lo anterior, las autoridades están conscientes que no puede ahogar una actividad económica, y se ha liberalizado mucho desde el año 1980, con mucho capital invertido.

Antes la CMF fijaba primas y pólizas, con una actividad monopólica por la Caja Reaseguradora y el ISE (actividad monopólica del Estado).

a.3) La Actividad Aseguradora

1) Por qué nos aseguramos

- No queremos correr ningún riesgo
- No queremos correr riesgos más allá de los que podemos soportar
- No queremos correr riesgos más allá de los que queremos soportar

La actividad aseguradora persigue la cobertura de los riesgos que puedan correr personas, objetos o derechos ante la posibilidad de que les afecte la ocurrencia de determinados eventos dañosos futuros e inciertos.

2) Tipos de seguros

- Seguro de robo
- Seguro de incendio
- Seguro de vida
- Seguro de crédito
- Seguro de responsabilidad civil
- Seguro de transporte
- Seguro de accidentes
- Seguro de salud

3) El seguro como actividad mercantil (para la compañía de seguros). El desarrollo de esta actividad hace que haya una determinada estructura.

a.4) Por qué hay aseguradores: la mutualidad de riesgos

En las mutuales todos los que participan ponen plata y ayudan a quienes están en necesidad. Esto no funcionaba muy bien porque el fondo común que se iba poniendo entre los participantes eventualmente se podía terminar y no iba a alcanzar para soportar el siniestro.

Hubo otros esquemas que no funcionaron, pero con la evolución más moderna de las compañías de seguros (últimos 40 años), se ha tratado de generar una configuración tal en la compañía para tener un patrimonio (capital aportado por los socios más las primas) que pueda neutralizar los riesgos incluso si se transforman en siniestros.

Los aseguradores suponen que tienen la habilidad para neutralizar los riesgos y por ello son capaces de asumir un grupo importante de ellos (tráfico jurídico) y de cobrar a los asegurados un precio por dicho traslado desde el patrimonio del asegurado al del asegurador.

- Gran número de operaciones. El número de pólizas debe ser muy alto porque eso aumenta la masa de operaciones que contribuye a su capital.
- Neutralización del riesgo.

Lo que hacen las compañías en teoría es asumir riesgos individuales, pero si lo vemos en términos generales si hay muchas operaciones entonces las probabilidades de que ocurran todos los siniestros es bajísima. Además, por ejemplo, imaginemos que las pólizas de seguros de vida tienen un valor de 7mil pesos y yo choco; en ese caso la indemnización va a ascender imaginemos a los 7millones entonces ahí la indemnización se paga con todas las demás pólizas.

Lo que hace la aseguradora con el riesgo es repartirlo o diluirlo entre todos lo que pagan la póliza. Los que efectivamente garantizan que se vaya a poder pagar la indemnización son todos los asegurados por la compañía que pagan una póliza.

- Operaciones uniformes.
- Cobertura mutua. Todos al final hacen frente a las indemnizaciones de los siniestros que le ocurren a los demás asegurados y esto, además, permite darle rentabilidad al capital.
- Bases técnicas.
- Especialización.

¿Cómo se diferencian las aseguradoras? (1) por el precio, porque hay compañías que a pesar de dar la misma cobertura cobran menos (o compañías que cobran más), y (2) marketing (reputaciones, conexiones como amistades/familia, “regalos”, etc) .

Todos los tipos de seguro tienen como base económica inexcusable la reunión de un gran número de operaciones de la misma especie para llegar a neutralizar el riesgo, repartiéndolo sobre una masa de operaciones uniformes.

El seguro es cobertura mutua de múltiples economías individuales afectadas por los mismos riesgos. Acá se conjuga la idea de que la contratación es individual pero que el negocio del seguro se basa en la contratación en masa.

El asegurador se limita a enlazar esas economías, formando con la contribución de todas ellas un fondo común de bienes que le permite hacer frente a los siniestros que se produzcan. Esto exige la explotación en masa del seguro y con arreglo a un plan que permita calcular sobre la base de los siniestros probables el importe de la contribución de cada asegurado

La explotación en masa del negocio del seguro se funda en un doble dato:

- (1) Primero, que los riesgos que amenazan la vida o el patrimonio no afectan a todos, ni los afectan en la misma medida (si así fuere, la prima del seguro debería ser equivalente al valor actual del capital asegurado y el seguro implicaría un gasto inútil). Si nos afectara a todos en la misma medida deberíamos ajustar la prima según cómo afecta el riesgo a cada

asegurado, pero el seguro en realidad es un instrumento de distribución colectiva porque de lo contrario la forma de poner precio al riesgo sería uno a uno (si el riesgo fuera x, se cobraría x, pero eso no es así porque hoy en día el riesgo se distribuye entre muchas personas).

(2) Segundo, que los hechos fortuitos, cuando se observan en gran número, demuestran una realización regular. Esta ley, llamada ley de los grandes números, permite a las empresas aseguradoras determinar, con referencia a cierto plazo de tiempo y a cierto objeto asegurado, la frecuencia con que resulta afectado por un riesgo también determinado (ej., fuego, granizo). Cuando en un gran número de observaciones aisladas un determinado hecho ocurre en un cierto número de casos, se llama probabilidad estadística. Por esto, el negocio de seguros es altamente técnico.

Acá se unen tres factores: determinación de riesgo, previsión de riesgos y formas de diversificación de riesgos (base financiera que cubre los riesgos si se materializan en siniestros).

a.5) Cómo deben ser los aseguradores: especialización

Entonces, sólo montado sobre bases rigurosamente técnicas, el seguro es capaz de ofrecer auténtica seguridad.

- Elementos científicos para identificar los riesgos (ingeniería)
- Elementos científicos para prever los riesgos (estadística)
- Elementos científicos para diversificar los riesgos (finanzas)

Pero la base técnica requiere, a su vez, que el asegurador sea un empresario organizado para crear esa mutualidad de riesgos en que descansa el seguro.

Por estas razones, la industria aseguradora sólo puede ser realizada con garantía de éxito por empresarios especializados con respaldo económico, aptos para organizar la explotación industrial conforme a un plan racional con el auxilio de métodos estadísticos y finísimos cálculos matemáticos.

b) Contrayente o contratante

Es quien celebra el contrato y soporta las obligaciones. Puede o no ser el asegurado.

Art. 513 letra f): el que celebra el seguro con el asegurador y sobre quien recaen, en general, las obligaciones y cargas del contrato.

c) Asegurado

Quien queda libre del riesgo producto de la contratación del seguro.

Art. 513 letra a): aquél a quien afecta el riesgo que se transfiere al asegurador.

El asegurado es el titular del interés asegurable y es quien se verá afectado directamente por la ocurrencia del riesgo, recibiendo en la mayoría de los casos la indemnización respectiva por parte de la aseguradora (salvo que se pacto como *beneficiario* a otra persona distinta del asegurado).

Ej. en un seguro de vida, puedo yo contratarlo y soy asegurada (yo corro el riesgo de muerte), pero el beneficiario son los miembros de mi familia.

Por eso, puede existir:

- a) Seguro contratado a beneficio propio: El asegurado contrata directamente y por sí el seguro, o bien lo contrata uno a nombre de otro como representante legal, mandatario o administrador, radicando los efectos directamente en el asegurado, art. 1448 del Código Civil.
- b) Seguro contratado por cuenta o a beneficio de un tercero sin facultad de representación, en cuyo caso hay una estipulación a favor de otro (art. 1449 del Código Civil), el asegurado no es parte del contrato mientras no manifieste su aceptación.

También puede existir si se toma en cumplimiento de un pacto especial, p.ej. crédito hipotecario.

Las obligaciones del contrato son de cuenta y cargo exclusivo del contratante. Además, puede que la persona del asegurado sea indeterminada al momento de contratar el seguro porque no sabe quién es el dueño o porque es un seguro colectivo.

d) Beneficiario

Art. 513 letra c): *el que, aún sin ser asegurado, tiene derecho a la indemnización en caso de siniestro.*

Estipulación a favor de otro, beneficiario reclama indemnización.

El beneficiario debe tener interés en la persona o cosa asegurada (relacionada con el riesgo): pecuniario (en cosas o patrimonio) o moral (en personas).

4.5 Formación del Contrato de Seguro y los deberes Precontractuales de Información

Con la entrada en vigencia de la Ley 20.667 se introduce un cambio sustancial en esta materia, pues el contrato de seguro pierde su carácter solemne (antes se perfeccionaba con el otorgamiento de la póliza) y pasa a ser un contrato consensual.

A su vez, la señalada ley se ha preocupado de los deberes de información que tienen los contratantes en la fase *in contrahendo*, incorporando expresamente obligaciones a las partes en este sentido, recogiendo las exigencias de la buena fe *in contrahendo*, a fin de proteger al contratante que se encuentra en una situación de desventaja o en una posición vulnerable.

En ese sentido, y al ser un contrato de adhesión, muchas veces no quedaba claro al asegurado cuáles eran las condiciones de la póliza (ej. el seguro del auto sólo corre si el conductor es mayor de 25 años). Pero por el otro lado, hay un deber de información por parte del contratante respecto de los riesgos que efectivamente afectan al asegurado; por lo tanto, la ley ha precisado que la información que se debe entregar es la que pide la compañía (formulario de preguntas).

4.5.1 Deber de Información del Asegurador

En los Art. 514 inciso 2° y 529 N° 1, se impone expresamente el deber de informar del asegurador al tomador, por escrito toda información relativa al contrato de seguro que se celebrará.

El contenido o extensión de este deber de informar, se relaciona con los datos que el asegurador debe proporcionar al tomador, para que este conozca de qué forma quedará protegido por el seguro que está contratando, de modo que no basta sólo con informar el objeto o cobertura, sino que también debe comprender todo aquello a que puede acceder en caso de un siniestro.

En general en los seguros de cosas, además, se suman inspecciones entonces el traspaso de información es bastante cierto. Pero en seguro de personas es más subjetivo porque puede que yo tenga una condición que crea que no es relevante, pero por eso el formulario debe ser bueno (ej. “tiene alguna otra condición pre existente”), lo que se suma a que está mucho más sistematizado el tema de los riesgos dependiendo de las condiciones particulares.

Estos formularios son elaborados por la compañía pero su contenido puede estar sujeto a la fiscalización de la CMF (ej. alguien denuncia una pregunta lo que abre un procedimiento de mediación y luego resolución de controversias).

4.5.2 Deber de Información del Asegurado o Contratante

El asegurado tiene el deber de informar sobre el riesgo que pesa sobre él y que es objeto del seguro.

La Ley 20.667 limita el contenido de este deber, a lo que pregunte el asegurador mediante un formulario de preguntas. Art. 524 N° 1, 525 y 539.

4.6 Regulación del Contrato de Seguro.

Lo realiza la CMF, quien autoriza por resolución el establecimiento de una compañía de seguros.

a) Capacidad de endeudamiento:

- Cías. de Seguros Generales: 5 veces su patrimonio.
- Cías de Seguros de Vida: 15 veces su patrimonio.

b) Compañía debe constituir una reserva técnica respecto de riesgos ocurrido y no pagados o no reportados: provisorios.

Estas reservas deben estar libres de todo gravamen o medida precautoria, para disponer libremente de ellos al momento de pagar el seguro.

c) Aparte de la Reserva Técnica se tiene un patrimonio libre, 80% invertido según instrucciones de CMF y 20% de libre inversión.

d) Capital mínimo 90.000UF (compañías generales), 120mil UF (compañía de seguros de vida).

e) Autorización de la CMF

4.7 Auxiliares del Comercio de Seguros.

No son parte de la compañía de seguros pero sí auxiliares a ella.

1. Corredores de seguros:

Asesoran a personas que se aseguran por su intermedio, ya que orientan acerca de las condiciones del mercado y ofrecen la cobertura necesaria para los riesgos que pretende asegurar. Realizan la intermediación entre quien quiere contratar un seguro y quien lo ofrece.

En general ya no se da esta intermediación, por ejemplo no es común que alguien contrate un corredor para el SOAP. Pero en seguros complejos sí es más común, o en casos en que quiero ayuda del corredor durante toda la vigencia del contrato.

Este corredor tiene que estar habilitado como tal y están sujetos a supervisión de la CMF.

2. Liquidadores de seguros:

Encargados de investigar los siniestros y determinar si están cubiertos por la póliza. Determinan:

- El valor del objeto asegurado al momento del siniestro
- Monto de los perjuicios
- Suma de indemnizaciones

Se supone que es una persona independiente, pero lo paga la compañía de seguros. También está comprometido y relacionado con el corredor, porque es su mercado natural; el corredor puede influir que no se nombre a tal liquidador, por ejemplo.

El asegurado nunca puede presentar un liquidador, solo puede objetar eventualmente el nombramiento del liquidador o la liquidación efectuada por este.

5. Elementos del contrato de seguros

Otra de las innovaciones relevantes introducidas por la ley 20.667 se relaciona con los elementos de la esencia del contrato de seguro del artículo 521.

Esta norma menciona como “requisitos esenciales del contrato de seguro” el **riesgo asegurado** (su traspaso), la **estipulación de prima** y la **obligación condicional del asegurador de indemnizar** (si se materializa el riesgo en un siniestro).

A diferencia del artículo 518 decimonónico (previo a la reforma), el interés asegurable deja de ser un presupuesto de validez de este contrato. Nuestro legislador precisa en el artículo 546, la exigencia de concurrir el interés asegurable, como un presupuesto para dar lugar a la indemnización. Entonces, no es esencial para que se forme el contrato pero sí para que se indemnice.

Art. 521 ccom. *Requisitos esenciales del contrato de seguro. Nulidad. Son esenciales del contrato de seguro, el riesgo asegurado, la estipulación de prima y la obligación condicional del asegurador de indemnizar.*

La falta de uno o más de estos elementos acarrea la nulidad absoluta del contrato.

Son nulos absolutamente también, los contratos que recaigan sobre objetos de ilícito comercio y sobre aquellos no expuestos al riesgo asegurado o que ya lo han corrido.

5.1 El riesgo

El riesgo es elemento base del contrato de seguro, pero además sin riesgo no existiría el comercio mismo porque la actividad mercantil es riesgosa en sí, en el sentido de que nadie puede tener certeza que va a tener éxito y lo mismo sucede con el financiamiento (desde el punto de vista de quien financia) como estudiamos el semestre pasado.

No hay actividad aseguradora sin personas que se quieren cubrir de esos riesgos, por lo tanto el tema del riesgo va más allá del contrato de seguro en sí. Ahora, si lo enfocamos en el contrato de seguro en sí, es un aspecto central para ambas partes del contrato: para el *asegurado* porque es quien está expuesto a los riesgos y mejor los conoce y sabe de qué quiere precaverse para asegurar su actividad, y para el *asegurador* porque se va a hacer cargo de él por un pago (y ese pago se corresponde exactamente o se procura que así sea, con el riesgo).

El riesgo es una **amenaza de pérdida o deterioro** que afecta a:

1. Bienes determinados
2. Derechos específicos
3. Patrimonio de una persona en su totalidad

Esta amenaza puede gravitar además sobre

1. La vida (riesgo de muerte)
2. La salud (riesgo de enfermedad)
3. La integridad física e intelectual (riesgo de accidente)

En general, podría definirse el riesgo como *la posibilidad de un suceso dañoso que amenaza bienes determinados, derechos a exigir prestaciones, al patrimonio mismo en forma indeterminada o a la vida, salud o integridad de una persona.*

Es decir, la noción de RIESGO envuelve la de cosa, derecho, patrimonio o persona asegurada, porque no se concibe el riesgo, al menos respecto del contrato de seguro, como una pura abstracción.

5.1.1 Definición Legal de Riesgo

El art. 513 letra t) define el riesgo como *la eventualidad de un suceso que ocasione al asegurado o beneficiario una pérdida o una necesidad susceptible de estimarse en dinero.*

Este riesgo busca proteger la eventualidad de que se produzca una pérdida o deterioro en bienes, derechos o en un patrimonio (seguros de vida, se asegura el impacto patrimonial de la muerte de una persona en cuanto fuente de ingreso).

La definición de riesgo que introduce nuestro legislador mediante la ley 20.667 permite superar la problemática y discusión doctrinal sobre la definición de riesgo contenida en el inciso 2º del artículo 513, sustituido. La norma decimonónica describía el riesgo como la *ocurrencia de un caso fortuito*, conceptualización que generó problemas especialmente en la asunción del riesgo de

responsabilidad civil, que supone la ocurrencia de una conducta culposa del asegurado. Además, se supera también de la norma antigua la circunscripción del riesgo a objetos, ya que la amenaza que importa el riesgo no sólo recae sobre objetos

- Se criticaba que se hablara de ocurrencia de un caso fortuito (imprevisto que no se puede resistir o prever), porque justamente estamos asegurando algo que sí se puede prever o al menos los daños provocados se pueden evitar. Además, la muerte no es en ningún caso un caso fortuito porque es un hecho cierto.
- Los riesgos no solo proceden respecto de objetos sino respecto de la vida o integridad física/intelectual de una persona.

Mientras más amplios los riesgos, más amplias las posibilidades de cobertura.

5.1.2 Elementos del Riesgo

En general, la medida del peligro que corre una cosa o persona en un tiempo determinado, cuestión indispensable de conocer antes de asegurar un riesgo, no es un hecho aislado del mundo sensible (ej. percibo que puedo chocar mi auto), sino una construcción del mundo lógico, basada en antecedentes empíricos del pasado que son de tipo estadístico.

Es decir, para deducir la posibilidad de ocurrencia de un siniestro se analiza la experiencia pasada acerca de siniestros semejantes. En ese sentido, la experiencia determina si el riesgo existe y si es lógico asegurarlo y cubrirlo.

Componentes del Riesgo:

- a) El concepto de riesgo excluye la idea de “imposibilidad”, porque un suceso que no es susceptible de ocurrir no constituye amenaza ni peligro. Si el hecho es imposible, entonces no constituye amenaza o riesgo.
- b) En cambio, un suceso que necesariamente debe ocurrir es incluíble en la noción de riesgo, si no hay certidumbre acerca de cuándo puede acaecer (como el riesgo de muerte de la persona).
- c) Además, en general, el riesgo debe referirse a un suceso futuro, porque la eventualidad es un concepto normalmente sólo concebible en lo porvenir. Si el hecho es pasado ya no es un riesgo sino que ya hay un daño. Sin embargo, en la medida que el riesgo sea una *incertidumbre*, puede importar riesgo un suceso ya ocurrido, si se ignora el hecho de su ocurrencia (ART. 1166 del C. Comercio). Entonces, pueden asegurarse objetos siniestrados si no se sabe que ocurrió el hecho, no solo en el caso del seguro marítimo.
- d) Por último, sólo puede darse el calificativo de riesgo a aquella eventualidad de causar un daño, lo que excluye del concepto a los sucesos indiferentes. Asimismo, tampoco son riesgos los acontecimientos que, si bien acarrearán gastos, son inseparables de la vida diaria, de ocurrencia ordinaria o indiferentes (ej. no voy a asegurar mi lápiz Bic).

La ocurrencia del evento se denomina “SINIESTRO”, concepto que el Código define en el artículo 513, letra x) como *la ocurrencia del riesgo o evento dañoso contemplado en el contrato*.

5.1.3 Dimensiones del Riesgo

El riesgo en la perspectiva del aseguramiento tiene una triple dimensión:

a) Perspectiva jurídica, la doctrina define el riesgo como la *posibilidad de surgir una necesidad o la posibilidad de un evento dañoso*. Hablamos del riesgo no en cuanto a sus efectos sino en cuanto a lo que realmente es.

El concepto legal de riesgo asegurado de nuestro ordenamiento jurídico comprende tanto el evento incierto en los seguros de daños (pérdida o daño), como en los seguros de personas (necesidad; se cubre la necesidad que genera la ausencia o la falta de integridad de la persona).

La doctrina identifica como uno de los elementos del riesgo la incertidumbre, que se relaciona con la posibilidad de ocurrencia de un evento futuro, respecto del cual no se sabe si se producirá (*incertidumbre absoluta*), o la interrogante sobre su ocurrencia no está en su verificación, sino en el cuándo (*incertidumbre relativa*).

b) Perspectiva técnica, se refiere al grado posibilidad de verificación del evento, esto es, su probabilidad, factor que desde el punto de vista técnico tendrá suma relevancia, ya que es susceptible de medición y constituye, junto a la intensidad del riesgo, la suma asegurada, la duración del contrato y la tasa de interés, los factores que permiten la tarificación del seguro, la fijación de la prima.

Esto determina si el riesgo es susceptible de medición y es cada día es más preciso.

c) Perspectiva económica, la relacionamos con la actividad empresarial de la compañía aseguradora. Se trata de una perspectiva, que si bien se aparta del análisis puramente contractual, tiene una relevancia considerable en el proceso de contratación, a fin de establecer la conveniencia o no de asumir un riesgo en concreto.

Es determinar simplemente si la compañía quiere o no quiere asumir el riesgo, no dentro de una esfera contractual sino mercantil y comercial.

5.1.4 Determinación del Riesgo Asegurable

El asegurador no asume un riesgo ilimitadamente, cargará solamente un evento de peligro determinado, correctamente circunscrito. Este riesgo concreto que asume el asegurador, obedece a un proceso de determinación que comprende dos fases:

(1) Determinación Técnica: La actividad del aseguramiento tiene viabilidad económica en la medida que el asegurador soporte solo una fracción del total de los riesgos asumidos y protege la comunidad de riesgos que permite hacer frente efectivo a las indemnizaciones que debe pagar por la ocurrencia de siniestros. Frente a esto, el asegurador debe:

a) Seleccionar los riesgos que le interesa cubrir (políticas de suscripción de riesgos).

- b) Analizar el evento de peligro, fijando determinadas condiciones técnicas de aseguramiento, como parámetros de prima, deducibles, franquicias, reaseguros, cláusulas de cobertura, etc.
- c) Agrupación de riesgos por homogeneidad, ya que finalmente será la comunidad de riesgos análogos la que soporta las consecuencias del evento de peligro.

(2) Determinación jurídica:

- a) Individualización del riesgo: Individualizar el riesgo implica describirlo, con el fin de establecer si se trata de un evento posible, cuya verificación provoca un daño, un menoscabo patrimonial o una necesidad de carácter económica. Los eventos imposibles o no susceptibles de causar un daño no son asegurables al no ser constitutivos de un riesgo. La descripción en detalle del riesgo se materializa a través de dos vías distintas, pero interdependientes; una legal y otra convencional:

a.1 Descripción legal: consiste en la individualización genérica del riesgo asegurable hecha por el legislador. Apunta a garantizar una cobertura mínima, evitando que los aseguradores en la confección de contratos estandarizados desnaturalicen el riesgo, al incorporar exclusiones que hagan inoperante la cobertura. Se controla y garantiza, al mismo tiempo, el contenido del contrato en favor del asegurado. Con todo, si a esta primera descripción del riesgo asegurable, adicionamos una norma que haga imperativas las disposiciones que regulen el contrato de seguro, la protección mínima contemplada por el legislador se hace inalterable por voluntad de los contratantes.

Es la descripción genérica que permite estandarizar los riesgos.

a.2 Descripción convencional es la contenida en los condicionados generales o pólizas estandarizadas y en los condicionados particulares de la póliza. Los contratantes acuerdan el amparo o cobertura por inclusión, al individualizar el evento en todos sus aspectos, y luego por exclusión, al precisar que variables del riesgo no estarán comprendidas dentro del denominado riesgo asegurado.

OJO que cuando hay reticencia respecto de elementos determinantes e inexcusables no suponen necesariamente presumir mala fe, sino que en realidad hay un incumplimiento de la obligación esencial de entregar información por parte del asegurado.

5.1.5 Cobertura (prestación del asegurador)

El riesgo tiene que ser perfectamente conocido por ambas partes, y principalmente por quien está más lejos del riesgo que es el asegurador. Entonces, este elemento debe estar muy delimitado porque ambas partes deben saber qué va a cubrir el seguro y cuál es el evento que de ocurrir va a ser indemnizado.

La delimitación de riesgo precedentemente expuesta, permite circunscribir el ámbito de cobertura que limita la prestación del asegurador, ya sea causal, espacial, temporal o en cantidad.

Art. 530 ccom. *Riesgos que asume el asegurador. El asegurador responde de los riesgos descritos en la póliza, con excepción de las situaciones expresamente excluidas por ella.*

A falta de estipulación, el asegurador responde de todos los riesgos que por su naturaleza correspondan, salvo los excluidos por la ley.

NO todos los riesgos se cubren de la misma forma, ej. la póliza va a durar solo 10 años, o solo cubro la posibilidad de accidentes de tránsito si el auto no entra a Santiago, o se responde solo del 70% del valor de la cosa, o solo se responde si el incendio no procede de un acto imprudente del asegurado, etc.

Para poder poner condiciones o exclusiones que obligan a tomar resguardo al asegurado o que saquen de la obligación de indemnizar ciertas circunstancias, hay que conocer el riesgo. No es lo mismo asegurar un incendio en una fábrica de muebles donde hay elementos de fácil combustión, que asegurar una fábrica lechera.

Y la delimitación del riesgo se hace mediante las exclusiones, es más, *a falta de estipulación el asegurador responde de todos los riesgos que por naturaleza les corresponda* entonces la carga de la exclusión está en el asegurador. Ej. decir que no se protege contra incendios si es una zona en que siempre hay rayos y la empresa no tiene pararrayos.

La cobertura puede definirse como la *garantía que beneficia al asegurado y que obliga condicionalmente al asegurador, determinando la prestación de este último en caso de verificarse el siniestro.*

Clasificación Legal de los Riesgos

El Código de Comercio clasifica los riesgos entre:

1) Aquellos de los cuales responde naturalmente el asegurador, aun sin mención expresa, salvo estipulación en contrario.

Sin necesidad de estipulación expresa, se entiende que el asegurador asume los riesgos que estén constituidos por casos fortuitos.

Naturalmente, debe entenderse que el asegurador responde de todos los casos fortuitos comprendidos dentro del ramo de seguros (tipo de seguro) en que quede incluido el contrato celebrado. Es decir, si el seguro es de incendio sobre mercaderías depositadas en un establecimiento comercial, el asegurador no responde de las pérdidas ocasionadas durante el transporte terrestre de esas mercaderías.

El asegurador puede, por pacto expreso, exonerarse de la responsabilidad por determinados casos fortuitos constitutivos de riesgos del ramo respectivo (ej. no se indemnizan los daños causados por incendio si es provocado por una persona).

Es lo que ocurre en las pólizas cuando, por ejemplo, se pacta la exclusión de daños provenientes de guerra, invasión, revolución, etc.

2) Aquellos de los cuales el asegurador responde sólo en caso de estipulación expresa.

A menos que exista una estipulación expresa en contrario, el asegurador no responde de los siguientes riesgos

a) El vicio propio de la cosa asegurada.

Es decir, *el germen de destrucción o deterioro que llevan en sí las cosas por su propia naturaleza o destino*, aunque se las suponga de la más perfecta calidad en su especie.

El ART. 549 autoriza a asegurarlo a virtud de estipulación expresa.

b) La culpa leve o levísima del asegurado.

El problema se vuelve difícil al tratarse la posibilidad de cubrir el riesgo constituido por la culpa leve o levísima del propio asegurado.

Desde luego, no cabe duda que el dolo y la culpa grave del asegurado no pueden ser asumidos por el asegurador (sería cubrir la mala fe) y que constituyen, entonces, la tercera categoría legal de los riesgos.

Pero respecto de la culpa leve y levísima, creo que no existe inconveniente que el asegurador asuma ese riesgo, porque en ello no hay comprometido un interés público que la ley quisiera proteger con una prohibición absoluta.

c) Los actos culpables o dolosos de las personas por las cuales el asegurado responde civilmente. (ARTS. 2320, 2321 y 2322 del C. Civil). Por ejemplo, cumpla con cubrir la responsabilidad civil emanada de la negligencia de un empleado que tuvo como consecuencia que un objeto cayera en la cabeza de un cliente.

3) Aquellos de los cuales no puede constituirse responsable en caso alguno (seguro prohibido por ley).

El dolo y la culpa grave del asegurado no pueden ser asumidos por el asegurador.

Consecuencias de un seguro que cubriera el evento de dolo o culpa grave del asegurado:

De acuerdo al artículo 10 del Código Civil, el seguro sería nulo absolutamente. Por otra parte, dicho efecto se produciría además por lo dispuesto en el artículo 1467 por ilicitud de la causa del contrato, en cuyo caso la sanción de nulidad absoluta se encuentra establecida en el artículo 1682.

Sin embargo, de acuerdo con el artículo 1683, esta nulidad no podría ser alegada por las partes contratantes, ya que lo habrían celebrado el contrato sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba. La compañía de seguros es una SA especial y técnica y debió saber que se contrataba con dolo, entonces no puede aprovecharse ni alegar la nulidad.

Esta solución resulta a todas luces inadecuada para el seguro y podría llevar fácilmente a la quiebra a las compañías o a fraudes y colusiones entre compañías y asegurados. Además, en realidad no necesariamente las partes están conscientes del vicio porque no necesariamente se contrató con dolo o culpa grave.

Ahora, igual voy a poder alegar por la vía del objeto ilícito.

Por tal motivo, es necesario concluir que los eventos de dolo y culpa grave del asegurado no constituyen un riesgo y, consecuentemente, en ausencia de dicho elemento esencial del contrato de seguro, el contrato es ineficaz.

Esto porque el riesgo requiere de una incertidumbre, que es incompatible con la idea de estar algo sujeto a la mera voluntad, malicia o imprudencia temeraria del asegurado.

Independiente de la discusión, la compañía nunca va a responder de estos riesgos.

5.1.6 Individualización y Delimitación del Riesgo

En todo contrato de seguro, el riesgo que asume el asegurador está individualizado y delimitado, porque no se concibe el seguro que cubra todos los riesgos a que puedan estar expuestos una persona y su patrimonio. Art. 530 ccom.

El día que ocurra el siniestro la aseguradora va a contratar un liquidador que lo que va a hacer es interpretar la póliza y determinar si procede la indemnización (van siempre a intentar buscar las razones por las cuales no procede).

La individualización y delimitación del riesgo se producen de diversas maneras:

a) Cada contrato de seguro se refiere a un ramo determinado y, dentro del ramo, a una modalidad específica

Por ejemplo, dentro de los seguros de cosa, un seguro de incendio es distinto de seguro de inundación o de robo. Entonces, puedo ir delimitando el riesgo sacándole cosas a un evento o a un riesgo muy genérico, ej. el riesgo de terremoto es muy amplio porque a consecuencia de un terremoto puede haber un incendio o un maremoto, entonces una manera de delimitarlo es decir que se cubren solo daños estructurales en la construcción pero no la rotura de vidrios.

Esto no quiere decir que en un mismo contrato no pueda estipularse la cobertura de más de un riesgo y, aun, de riesgos de distinto ramo o grupo (ej., seguro de automóviles, donde se cubre el riesgo sobre una cosa y el riesgo sobre el patrimonio, o incluso un riesgo de responsabilidad civil personal por causarle un daño a un tercero).

b) El riesgo queda delimitado por el objeto sobre el cual recae el seguro (cosa determinada, derecho determinado, persona determinada).

No es lo mismo asegurar una fábrica a que asegurar la máquina X que se encuentra dentro de ella. Entonces la manera más precisa de asegurar es por unidad de cada cosa objeto del seguro.

El principio no es tan absoluto, porque existen los llamados *seguros flotantes* ("entran y salen cosas"), en los cuales las cosas aseguradas no están determinadas al inicio del contrato, pero deben ser individualizadas cada cierto tiempo. Esto es porque puede que la cosa asegurada va cambiando todo el tiempo (ej. una compañía tiene inventarios entrando y saliendo permanentemente de una bodega, o un transportista que transporta distintas cargas todos los días).

Entonces, la la ley permite asegurar universalidades. El ART. 548 admite cierta indefinición al establecer que los establecimientos de comercio y los cargamentos terrestres o marítimos pueden ser asegurados con o sin designación específica de las mercaderías, y que el menaje de una casa puede ser asegurado sin especificación, salvo en cosas de gran precio, como alhajas, objetos de arte y otras análogas.

Art. 548 ccom. *Aseguramiento de universalidades. Los establecimientos industriales, mineros, agrícolas, comerciales, los cargamentos terrestres, marítimos y aéreos y, en general, las universalidades o conjuntos de bienes que por su ubicación u otra circunstancia sean materia de un mismo seguro, se podrán asegurar con o sin designación específica de los bienes que los contengan o compongan. Los muebles que constituyen el menaje de una casa pueden ser también asegurados en esa misma forma, salvo los que tengan un gran precio, como las alhajas, cuadros de alto valor, objetos de arte u otros análogos, los cuales serán asegurados con designación específica.*

En uno y otro caso el asegurado deberá individualizar los objetos asegurados y justificar su existencia y valor al tiempo del siniestro.

c) Exclusiones de responsabilidad por ciertas causas del siniestro

El riesgo queda también delimitado por las estipulaciones del contrato que excluyen la responsabilidad del asegurador para el caso que el siniestro ocurra en ciertas circunstancias o por ciertas causas. Por ejemplo, si el siniestro sobreviene al realizar una actividad peligrosa, no se indemniza el daño en la persona, o no indemnizo los daños causados por un incendio que proviene de culpa del asegurado.

d) El riesgo puede ser delimitado temporalmente

Los seguros se contratan por un tiempo determinado, normalmente, por un año (de lo contrario, las primas serían carísimas y valdrían casi lo mismo que el valor de la cosa). Según el ART. 518 N° 5, constituye una mención obligatoria de la póliza el tiempo por el cual el asegurador asume los riesgos materia del contrato.

El Código reglamenta además la situación que se produciría si el comienzo y consumación de un siniestro no caen, ambos, dentro del plazo previsto en la póliza. En tal caso:

- El asegurador es responsable si el accidente comienza antes y concluye después de vencido el plazo fijado en la póliza.
- El asegurador no responde si el siniestro ha comenzado antes del contrato y se ha consumado después de su celebración.

Art. 532 ccom. *Época del siniestro. Si el siniestro se iniciare durante la vigencia del seguro y continuare después de expirada, el asegurador responderá del importe íntegro de los daños. Pero si principiare antes y continuare después que los riesgos hubieren comenzado a correr por cuenta del asegurador, éste no será responsable del siniestro.*

e) El riesgo puede ser delimitado espacialmente, fijándose en el contrato los límites espaciales dentro de los cuales debe ocurrir el siniestro para que ocasione la responsabilidad del asegurador

En efecto, es frecuente, sobre todo en los seguros de cosas, que en la póliza se señale el lugar en que se encuentran o dónde deben mantenerse, porque para el asegurador no son indiferentes los distintos lugares, ya que unos pueden presentar mayores condiciones de seguridad que otros.

Es común en el caso de daños de autos, por ejemplo, la aseguradora solo cubre accidentes si se maneja el auto en la Región Metropolitana.

f) Delimitación por la vía de las obligaciones.

5.1.7 Conocimiento del Riesgo

Es indispensable que el asegurador tome para sí riesgos que conozca y pueda calcular, prever o pronosticar para determinar la prima que se va a cobrar. Y acá es que prima la buena fe del asegurado en cuanto dar la información relevante al asegurador al respecto. Es más, el ccom acá incorpora normas específicas en relación a los vicios del consentimiento.

La formación del consentimiento solo va a ser válida si el asegurador tiene todos los factores para ponderar la real magnitud del peligro que está asumiendo, porque sin esto es imposible que él pueda consentir en la prima que va a recibir. Entonces dado que el asegurado quien tiene la mayor cantidad de información, él es quien debe informar respecto de los aspectos que para el asegurador sea importante.

En cada contrato de seguro, el asegurador asume uno o más riesgos concretos por un precio determinado, que es la prima; pero, como el riesgo no es una cosa del mundo sensible, sino una concepción de orden lógico, es evidente que el consentimiento del asegurador sólo será válido si ha estado en condiciones de conocer todos los factores que permitan una ponderación realista de la verdadera magnitud de peligro que encierra el riesgo asumido.

Las condiciones en que el seguro es contratado, la prima que pueda fijarse y, desde luego, la posibilidad misma de que sea aceptado por la compañía, dependen de las informaciones que el asegurador pueda tener sobre el riesgo ofrecido.

- La póliza debe enunciar todas las circunstancias que puedan suministrar al asegurador un conocimiento completo y exacto de los riesgos (ART. 518 Nº 4)
- Obligación del asegurado la de declarar sinceramente todas las circunstancias necesarias para identificar la cosa asegurada y apreciar la extensión de los riesgos (ART. 525)

En el seguro de incendio, se prescribe que en la póliza debe indicarse la situación de los inmuebles asegurados, su destino y uso, el destino y uso de los inmuebles colindantes, en cuanto estos datos puedan influir en la estimación de los riesgos, los lugares en que se encuentran depositados los muebles objeto del seguro, etc.

Lo importante es que el peso y la carga del señalamiento de las condiciones o circunstancias que delimitan el riesgo recaen no sobre el asegurado sino sobre el asegurador que tiene que ser diligente al pedir la información (cuestionarios). Todo lo que no se pregunta, en principio, va a ser de su responsabilidad salvo que haya clara mala fe por parte del asegurado. Y siempre en la duda, la interpretación será a favor del asegurado por el principio de imperatividad especialmente en relación al artículo 524 numeral 1.

Art. 524 ccom. *Obligaciones del asegurado. El asegurado estará obligado a: 1º. Declarar **sinceramente** todas las circunstancias que solicite el asegurador para identificar la cosa asegurada y apreciar la extensión de los riesgos;*

Art. 567 ccom. *Contenido de la póliza. Además de las enunciaciones que exige el artículo 518, la póliza deberá expresar la ubicación, destino y uso de los inmuebles asegurados, y de los edificios colindantes, en cuanto estas circunstancias puedan influir en la estimación de los riesgos.*

Iguals menciones deberá contener la póliza respecto a los inmuebles en que se encuentren colocados o almacenados los bienes muebles, cuando el seguro verse sobre estos últimos.

En resumen, basta que el asegurado informe al tenor de lo que solicite el asegurador (formularios). Si el asegurador no solicita información, luego no puede alegar errores/reticencias/inexactitudes.

El incumplimiento de esta esencial obligación de información completa y sincera de parte del asegurado el asegurador podrá rescindir el contrato (ART. 525). Ante la duda, siempre es mejor declarar incluso aquellos elementos insignificantes que no van ni siquiera a alterar la prima, porque la reticencia puede llevar a la no indemnización del daño.

- a) Si o se ha producido el siniestro y el error/reticencia es determinante, el asegurador puede rescindir el contrato (ahora, también lógicamente puede ofrecer una modificación del contrato). Pero si no es determinante, puede proponer una modificación del contrato para adecuar la prima o las condiciones de cobertura.
- b) Si se produjo ya el siniestro y lo que se omitió es determinante para el riesgo, entonces el asegurador queda liberado de su obligación de indemnizar. Si no es determinante, el asegurador tiene derecho a rebajar la indemnización proporcionalmente a lo que se habría cobrado de prima al haber conocido esa información.
- c) Nada de esto aplica si el asegurador conoció o debió haber conocido los errores/reticencias/inexactitudes o si los subsana o los acepta expresamente.

Además, en caso de dolo o fraude del asegurado, el asegurador puede demandar el pago de la prima si no hubiere sido cancelada, o retenerla, todo aunque no hubiere corrido riesgo alguno y sin perjuicio de las sanciones penales que pudieran proceder.

Art. 525 ccom. *Declaración sobre el estado del riesgo. Para prestar la declaración a que se refiere el número 1 del artículo anterior, será suficiente que el contratante informe al tenor de lo que solicite el asegurador, sobre los hechos o circunstancias que conozca y sirvan para identificar la cosa asegurada y apreciar la extensión del riesgo.*

Convenido el contrato de seguro sin que el asegurador solicite la declaración sobre el estado del riesgo, éste no podrá alegar los errores, reticencias o inexactitudes del contratante, como tampoco aquellos hechos o circunstancias que no estén comprendidos en tal solicitud.

Si el siniestro no se ha producido, y el contratante hubiere incurrido inexcusablemente en errores, reticencias o inexactitudes determinantes del riesgo asegurado en la información que solicite el asegurador de acuerdo al número 1º del artículo anterior, el asegurador podrá rescindir el contrato. Si los errores, reticencias o inexactitudes sobre el contratante no revisten alguna de dichas características, el asegurador podrá proponer una modificación a los términos del contrato, para adecuar la prima o las condiciones de la cobertura a las circunstancias no informadas. Si el asegurado rechaza la proposición del asegurador o no le da contestación dentro del plazo de diez días contado desde la fecha de envío de la misma, este último podrá rescindir el contrato. En este último caso, la rescisión se producirá a la expiración del plazo de treinta días contado desde la fecha de envío de la respectiva comunicación.

Si el siniestro se ha producido, el asegurador quedará exonerado de su obligación de pagar la indemnización si proviene de un riesgo que hubiese dado lugar a la rescisión del contrato de acuerdo al inciso anterior y, en caso contrario, tendrá derecho a rebajar la indemnización en proporción a la diferencia entre la prima pactada y la que se hubiese convenido en el caso de conocer el verdadero estado del riesgo.

Estas sanciones no se aplicarán si el asegurador, antes de celebrar el contrato, ha conocido los errores, reticencias o inexactitudes de la declaración o hubiere debido conocerlos; o si después de su celebración, se allana a que se subsanen o los acepta expresa o tácitamente.

5.1.8 Agravación de los Riesgos (Art. 526)

Es obvio que si el asegurador ha asumido un riesgo concreto, cabal y exactamente ponderado, su magnitud no puede ser aumentada durante la vigencia del contrato por el propio asegurado, sin que eso tenga necesarias consecuencias jurídicas.

La lógica detrás es que la prima se calcula sobre la probabilidad de ocurrencia del siniestro, y si este se hace más probable es porque se agravó el riesgo y hay reglas que tratan sobre cómo se cubre la aseguradora y qué obligaciones hay para el asegurado en relación al agravamiento de los riesgos.

El incremento de la magnitud de un riesgo se denomina agravación del mismo, y si es obra del asegurado, ello importa una infracción a una de sus más esenciales obligaciones.

Es obligación del asegurado la de emplear todo el cuidado y celo de un diligente padre de familia para prevenir el siniestro.

Las obligaciones del asegurado son: a) no agravación del riesgo y b) dar notificación de la agravación en 5 días del conocimiento de la misma.

Art. 524 ccom. *Obligaciones del asegurado. El asegurado estará obligado a:*

4°. Emplear el cuidado y celo de un diligente padre de familia para prevenir el siniestro;

5°. No agravar el riesgo y dar noticia al asegurador sobre las circunstancias que lleguen a su conocimiento y que reúnan las características señaladas en el artículo 526;

Art. 526 ccom. *Agravación de riesgos asegurados. El asegurado, o contratante en su caso, deberá informar al asegurador los hechos o circunstancias que agraven sustancialmente el riesgo declarado, y sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato, dentro de los cinco días siguientes de haberlos conocido, siempre que por su naturaleza, no hubieren podido ser conocidos de otra forma por el asegurador.*

Se presume que el asegurado conoce las agravaciones de riesgo que provienen de hechos ocurridos con su directa participación. Si el siniestro no se ha producido, el asegurador, dentro del plazo de treinta días a contar del momento en que hubiere tomado conocimiento de la agravación de los riesgos, deberá comunicar al asegurado su decisión de rescindir el contrato o proponer una modificación a los términos del mismo para adecuar la prima o las condiciones de la cobertura de la póliza. Si el asegurado rechaza la proposición del asegurador o no le da contestación dentro del plazo de diez días contado desde la fecha de envío de la misma, este último podrá dar por rescindido el contrato. En este último caso, la rescisión se producirá a la expiración del plazo de treinta días contado desde la fecha de envío de la respectiva comunicación.

Si el siniestro se ha producido sin que el asegurado, o el contratante en su caso, hubieren efectuado la declaración sobre la agravación de los riesgos señalada en el inciso primero, el asegurador quedará exonerado de su obligación de pagar la indemnización respecto de las coberturas del seguro afectadas por el agravamiento. No obstante, en caso que la agravación del riesgo hubiera conducido al asegurador a celebrar el contrato en condiciones más onerosas para el asegurado, la indemnización se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiera aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo.

Estas sanciones no se aplicarán si el asegurador, por la naturaleza de los riesgos, hubiere debido conocerlos y los hubiere aceptado expresa o tácitamente.

Salvo en caso de agravación dolosa de los riesgos, en todas las situaciones en que, de acuerdo a los incisos anteriores, haya lugar a la terminación del contrato, el asegurador deberá devolver al asegurado la proporción de prima correspondiente al período en que, como consecuencia de ella, quede liberado de los riesgos.

Excepto en la modalidad de los seguros de accidentes personales, las normas sobre la agravación de riesgos no tendrán aplicación en los seguros de personas.

1) Si se agravó el riesgo y no se comunicó pero no se ha producido el riesgo, el asegurador puede terminar el contrato o proponer cambios a la prima.

2) Si ya se produjo el siniestro y el asegurado no declaró la agravación, el asegurador queda exonerado de su obligación respecto de las coberturas que fueron afectadas por el agravamiento. Salvo que el asegurador hubiera celebrado igualmente el contrato pero en condiciones más onerosas (pero ahí la indemnización es proporcional a la prima que se hubiese cobrado).

5.1.9 Cesación de los Riesgos

El o los riesgos asumidos por un asegurador pueden cesar o extinguirse en forma absoluta o relativamente a la persona del asegurado.

a) Cesación Absoluta

Los riesgos cesan absolutamente cuando la cosa, derecho, patrimonio o persona dejan de estar expuestos al riesgo asegurado.

- Nave asegurada que fuere desguazada
- Incendio sobre una casa que fuere demolida
- Empresario asegurado contra accidentes del trabajo que pone término a su giro y despide a su personal
- Seguro de garantía sobre un contrato que es anulado o resuelto, etc.

Si los riesgos cesan absolutamente, el seguro termina y esta terminación puede ser sólo parcial, si los riesgos se han extinguido sólo parcialmente.

b) Cesación Relativa

- Transferencia de una cosa asegurada a otra persona, ya que, perdido el interés del vendedor sobre la cosa enajenada, deja de existir riesgo para él y éste es transferido con la cosa al adquirente
- Empleador que tiene un seguro de fidelidad funcionaria relativo a un empleo que se contrata con otro empresario, etc.

En el caso de la cesación relativa de los riesgos por traspaso del interés asegurado a otra persona conforme a las reglas de las pólizas, es necesario que la compañía consienta en la transferencia del contrato de seguro para que éste subsista y pase el adquirente a tener la calidad de asegurado.

5.2 La prima

5.2.1 Reglamentación y Concepto

Es el precio que se paga para que el asegurador se haga cargo del riesgo y es un elemento central del contrato; quizás la obligación más importante del mismo.

Un requisito esencial del contrato de seguro es la prima. El ART. 513 letra s) establece que la prima consiste en la “*retribución o precio del seguro*”. Esta es la misma definición que antiguamente reconocía el código. El pago de la prima constituye la principal obligación del contratante y su incumplimiento acarrea la terminación del contrato, según dispone el artículo 528.

El **artículo 512**, al definir el contrato de seguro, dice que el asegurador asume los riesgos a cambio del pago de una prima, por lo tanto la conmutatividad del contrato se da por el pago de la prima. Además, el artículo 521 declara como elemento esencial la determinación de la prima y el **artículo 524** establece como obligación esencial del asegurado pagar la prima.

La prima y su pago –tiempo, lugar y forma- es considerada por el artículo 518 del como una de las menciones mínimas que debe contener todo contrato de seguro y su documento justificativo, la póliza. Recordemos que en la propuesta que entrega el asegurador está la prima o método para su cálculo, en base a la información que entrega el asegurado.

Tiene una dimensión legal y técnica, y se puede mirar desde el punto de vista *contractual* (lo que se pacta) y una *dimensión financiera* porque no solo representa un valor por la actividad de intermediación del riesgo sino que para la aseguradora pesan obligaciones financieras como mantener algunas reservas en el estado financiero para responder de los siniestros futuros eventuales.

5.2.2 Proporcionalidad Prima-Riesgo

La unión de prima y riesgo es tal que hay una proporción entre ambas, porque sobre eso descansa la actividad del asegurador.

Entre la prima y el riesgo existe una interdependencia directa, ya que en caso de siniestro la indemnización se obtendrá en la medida en que la prima ha sido adaptada o adecuada al riesgo. En ese sentido, la medición del riesgo y la probabilidad/estadística de ocurrencia es lo que permite al asegurador fijar un valor por asumir cada riesgo particular.

En general el cálculo de la prima se hace en base a un conjunto de riesgos homogéneos, lo que se suma a la posibilidad específica de ocurrencia del riesgo para el asegurado específico que quiere un seguro.

Esta interdependencia es tal que si hay problemas con el riesgo (ej. agravación), ello también arrastra a la prima.

5.2.3 En qué puede consistir la prima

Art. 527 ccom. *De la prima. El asegurador gana la prima desde el momento en que los riesgos comienzan a correr por su cuenta, y tendrá derecho a percibir o retener su totalidad en caso que fuera procedente la indemnización por un siniestro de pérdida total o finalizase la vigencia de acuerdo con el artículo 523. Convenida la vigencia de la cobertura por un plazo determinado, la prima se devengará proporcionalmente al tiempo transcurrido.*

La prima puede consistir en una cantidad de dinero, en la entrega de una cosa o en un hecho estimable en dinero.

Salvo pacto en contrario, el pago de la prima se hará al entregarse la póliza, el certificado de cobertura o el endoso, según corresponda, y deberá hacerse en el domicilio del asegurador o en el de sus representantes, agentes o diputados para el cobro.

Transferido el riesgo, el asegurador tiene derecho a recibir la prima.

La prima puede consistir en una *cantidad de dinero*, o en la *prestación de una cosa o de un hecho estimable también en dinero*. Si nada se estipula se entiende que se paga en dinero. (ART 527). En la práctica la prima sólo se paga en dinero.

La norma del ART. 10 del DFL 251 señala que las primas deben expresarse en Unidades de Fomento, a menos que se pacten en moneda extranjera, con arreglo a las disposiciones legales vigentes. Se pueden pactar otros mecanismos de reajustabilidad siempre que estén autorizados por la CMF.

Nuestro legislador ha optado por seguir el principio de divisibilidad de la prima, lo cual no se relaciona con el pago de la prima anual en periodos mensuales o en cuotas, sino que con el derecho del asegurador para cobrar íntegramente el valor de la prima, en tanto los riesgos corran a su cargo.

5.2.4 Época del Pago

Según el ART. 527 la prima se pagará al momento de entregarse la póliza. El asegurador gana irrevocablemente la prima desde ese momento. Hay que recordar que el asegurador comienza a correr con los riesgos desde la celebración del contrato, ya que los riesgos son de parte del asegurador desde que el contrato se perfecciona, salvo pacto en contrario.

Ahora, el derecho para cobrar nace una vez perfeccionado el contrato, por disposición del artículo 523 que dice que ahí es cuando se traspasan los riesgos. Por lo tanto, la entrega de la póliza determina el momento del pago no el momento en que nace la obligación, y de hecho puede pactarse un momento de pago distinto.

5.2.5 Lugar del pago

Según el ART. 527, se hará el pago en el domicilio del asegurador o en el de sus representantes, agentes o diputados para el cobro.

5.2.6 Forma de pago

Debe estarse a lo pactado. Puede pagarse de una sola vez o parcialmente, por meses o por años.

5.2.7 Divisibilidad de la prima

El legislador optó por seguir el principio de divisibilidad de la prima. En la historia de la ley se señala que el asegurador ganaba la totalidad de la prima desde que los riesgos corrían por su cuenta, pero gracias a este principio se gana la prima solo por el período efectivo de cobertura. Esto no se relaciona con el pago en cuotas, que también es posible.

La indivisibilidad dice relación con exigir el pago íntegro de la prima sobre la base de un factor anual (que es el período normal de prima), aunque la cobertura termine antes del período de cálculo, entonces la divisibilidad faculta exigir el pago solo cuando los riesgos corren efectivamente a su cargo (y esto se desprende de la palabra “proporcional” del artículo 527).

La excepción a esto son los casos de pérdida total en seguros de daño y término de cobertura por el inciso final del artículo 523.

Art. 527. *De la prima. El asegurador gana la prima desde el momento en que los riesgos comienzan a correr por su cuenta, y tendrá derecho a percibir o retener su totalidad en caso que fuera procedente la indemnización por un siniestro de pérdida total o finalizase la vigencia de acuerdo con el artículo 523. Convenida la vigencia de la cobertura por un plazo determinado, la prima se devengará proporcionalmente al tiempo transcurrido.*

5.2.8 Partes que comprende la prima

La prima comprende dos partes:

Hay una prima pura, teórica o neta, que es la suma que, según los datos técnicos, corresponde exactamente a los riesgos que toma el asegurador en el respectivo contrato. El monto de la prima pura depende de varios factores, tales como la probabilidad de riesgo, la intensidad del mismo, la suma asegurada, la duración del seguro, etc.

La otra parte de la prima es el recargo, o sea, el conjunto de gastos requeridos para el funcionamiento de la empresa aseguradora, que se integran proporcionalmente a la prima y que comprenden las comisiones, los gastos de cobranza de las primas y los gastos generales de administración y gestión. La suma de la prima pura y el recargo se llama prima comercial.

5.2.9 Derechos del asegurador en caso de no pago de la prima

La prima en general supone una obligación de dar.

Art. 528 ccom. *No pago de la prima. La falta de pago de la prima producirá la terminación del contrato a la expiración del plazo de quince días contado desde la fecha de envío de la comunicación que, con ese objeto, dirija el asegurador al asegurado y dará derecho a aquél para exigir que se le pague la prima devengada hasta la fecha de terminación y los gastos de formalización del contrato.*

Producida la terminación, la responsabilidad del asegurador por los siniestros posteriores cesará de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial alguna.

Según el ART.528 el no pago de la prima al vencimiento del plazo convencional o legal, producirá la terminación del contrato a la expiración del plazo de 15 días contado desde la fecha de envío de la comunicación dirigida al asegurado y autoriza al asegurador para exigir que se le pague la prima devengada hasta la fecha de terminación y los gastos de formalización del contrato (lo que se relaciona con el principio de divisibilidad).

¿Aplica la misma regla del artículo 1489 para el caso de incumplimiento del pago de la prima (precio)? Las normas generales del cc regulan la condición resolutoria tácita, entonces la pregunta es si esta norma confluye con el artículo 528 del ccom. La solución es que acá el tema es que ADEMÁS se le da una facultad especial al asegurador que es terminar el contrato pero cobrando la prima ya devengada.

Es importante entender que el no pago de la prima no solo trastoca la relación singular que existe entre asegurado y asegurador sino que el afecta a la comunidad de riesgos completa. Todos los riesgos homogéneos que sirven para tarificar la prima, también se afectan entonces no solo se vulnera una relación contractual individual. Por lo tanto, cabe preguntarse si para que el asegurador termine el contrato deben darse ciertos presupuestos, como si basta el simple retardo o si deben concurrir otros presupuestos como la culpa o dolo.

Para solucionar este tema la terminación del contrato debiese operar sin necesidad de culpa/dolo del asegurado y por el solo hecho de retrasar el pago de la prima ello debiese ser presupuesto para la terminación del contrato porque no solo hay una protección del asegurador. Por otra parte, si hay dolo o culpa ahí eso lo que entra a jugar es otro aspecto que es el aspecto indemnizatorio eventual si se da a lugar a un juicio que emana del incumplimiento.

Por último, los 15 días son un espacio de protección del asegurado no para remediar el incumplimiento sino que permite que no haya necesidad de declaración judicial para la terminación, además de que se le da tiempo razonable al asegurado para celebrar otro contrato de seguro.

Pacto comisorio con cláusula de ipso facto

Esta especie de pacto comisorio consiste en la estipulación de que, a falta de pago del precio de la compraventa, el contrato se resolverá ipso facto, o sea, sin más. El Código Civil dispone que, aún en este caso, el comprador puede enervar la acción resolutoria pagando el precio dentro de las veinticuatro horas de notificada la demanda.

Se ha discutido si se puede insertar un pacto comisorio con cláusula de ipso facto en contratos distintos del de compraventa y si, siendo ello posible, la cláusula de ipso facto dejaría al deudor la facultad de enervar la acción, pagando dentro de las veinticuatro horas. Buena parte de la doctrina y jurisprudencia se han inclinado en el sentido de que, en virtud del principio de la libertad contractual, el pacto comisorio es admisible en contratos distintos del de compraventa y que, habiendo cláusula de ipso facto, hay que estarse a lo pactado para determinar si existe o no el plazo de veinticuatro horas para enervar la acción pagando. Si las partes nada dicen, se entiende que no existe tal plazo.

La CMF ha aplicado estos principios al seguro. Es válido el pacto comisorio en orden a que el no pago de la prima resuelva ipso facto el seguro (Fallo arbitral de 26 de octubre de 1939, citado por el Repertorio de Jurisprudencia. Código de Comercio. T. I, p. 161. n. (2)).

6. Objetos del seguro

6.1 Objeto

No todo es asegurable. Se pueden asegurar todas las cosas, corporales e incorporeales. Ejemplo de seguros que recaen sobre cosas corporales:

- Como ejemplo de cosa incorporal, se puede asegurar un patrimonio en el caso de un seguro de responsabilidad civil. Lo que se protege ahí es una cosa incorporal que es el patrimonio como universalidad, a pesar de que este está compuesto de cosas corporales.
- Lo mismo sucede en el caso de un seguro para lucro cesante (flujos futuros), que es una cosa incorporal.
- El seguro de crédito (art. 579) también corresponde a una forma de asegurar una cosa incorporal que emana de una relación contractual, porque se asegura la obligación en caso de incumplimiento por parte del deudor.
- El seguro de caución (art. 582) va en la misma línea de seguros sobre cosas incorporales.

Las cosas son asegurables, siempre y cuando cumplan algunos requisitos:

a) Existan al tiempo del contrato o en la época en que principien a correr los riesgos por cuenta del asegurador.

Incuestionablemente que si las cosas no llegan a existir en dicha época, el seguro sería inexistente, por faltarle un requisito esencial: el riesgo. En efecto, mal puede haber riesgo si no hay cosa que lo soporte.

En cuanto al seguro de las ganancias o beneficios esperados, debemos advertir que se trataría de un seguro sobre cosas que no existen, de suerte que estaríamos en presencia de un seguro inexistente. Sin embargo, conviene tener presente que no es lo mismo ganancia o beneficio esperado que lucro cesante y que el seguro cuyo objeto es este último es perfectamente válido y se practica con frecuencia; en el lucro cesante la cosa sí existe y es cierta, no es una expectativa.

b) Tengan un valor estimable en dinero.

El valor de las cosas, estimable en dinero, es un factor fundamental del seguro, porque la indemnización del siniestro no puede, normalmente, satisfacerse de otro modo que en dinero. Claro está que podría estipularse que el asegurador reemplazara la cosa perdida o dañada por otra de la misma especie; pero ésta es una manera excepcional de operar.

c) Puedan ser objeto de una especulación lícita (art. 521: son absolutamente nulos los contratos que recaigan sobre objetos de ilícito comercio).

El seguro debe versar sobre una cosa de lícito comercio. He aquí un caso típico de un límite a las posibilidades de asegurar sustentado en un principio de orden ético. Ej. no puedo asegurar un cargamento de cocaína.

d) Se hallen expuestas a perderse por el riesgo que tome sobre sí el asegurador

Si no es así, el seguro sería inexistente, por faltarle uno de sus requisitos esenciales. En efecto, si el riesgo descrito en el contrato no amenaza a la cosa objeto del seguro, no existe riesgo, porque el riesgo no se da en el vacío.

No pueden asegurarse:

1. Los objetos de ilícito comercio

2. Las cosas íntegramente aseguradas, a no ser que el último seguro se refiera a tiempo o riesgos diversos.

Esto no impide que no hayan pluralidad de seguros pero el artículo 550 reconoce que el seguro de daños es de mera indemnización, lo que se repite en relación a la pluralidad de seguros del artículo 556.

Además, el artículo 558 se pone en el caso del sobreseguro, es decir, si la suma asegurada excede el valor del bien asegurado, cualquiera de las partes puede exigir su reducción, así como la de la prima, salvo que dicho valor se hubiere pactado conforme el art. 554. Ahora bien, si el sobreseguro proviene de la mala fe del asegurado el contrato será nulo.

3. Las cosas que ya han corrido el riesgo (art. 521).

En cuanto a las cosas que ya han corrido el riesgo, salvándose o pereciendo, sin duda que el seguro de ellas sería más que nulo, inexistente, porque le faltaría un elemento esencial del contrato: el riesgo.

Se debe advertir que en materia de seguro marítimo y conforme a lo preceptuado en el artículo 1166, es nulo y de ningún valor el seguro contratado con posterioridad a la cesación de los riesgos, si al tiempo de su celebración el asegurado o quien contrató por él tenían conocimiento de haber ocurrido el siniestro, o el asegurador de haber cesado los riesgos. A contrario sensu, debe entenderse que el seguro marítimo contratado después de haber cesado los riesgos es válido, siempre que ninguna de las partes haya tenido conocimiento de la ocurrencia de dicha cesación.

6.2 Valor de las Cosas Objeto del Seguro.

El valor de las cosas objeto de un seguro tiene relevancia desde muchos puntos de vista en el grupo de los seguros que recaen sobre cosas determinadas. Desde luego, existe un principio rector que señala que, respecto del asegurado, el seguro es un contrato de mera indemnización y jamás puede ser para él la ocasión de una ganancia (Art. 550 ccom).

La traducción práctica de este principio implica que el límite de la obligación de indemnizar a que pueda estar sujeto el asegurador está circunscrito por el valor de la cosa objeto del contrato, en el momento del siniestro. Este valor es su valor comercial o, más propiamente todavía, su valor de reposición.

El número 7º del artículo 518 lo señala como una de las menciones necesarias de la póliza.

El valor de la cosa más que relevante para determinar qué se indemniza (porque generalmente se va a indemnizar el daño efectivo), sirve para determinación de la prima.

El valor en seguros de vida no se considera el “deterioro” de la persona sino el efecto que puede generar en un patrimonio la vida o la muerte de ella. Sin embargo, sí existen objetos asegurables cuyo valor pueda ir disminuyendo o aumentando en el tiempo, p.ej. cuando aseguro un auto que va depreciándose, entonces el valor de reposición (valor asegurado) va a ir mutando.

El monto asegurado puede o no coincidir con el valor del objeto materia del seguro y ser, entonces, igual, inferior o superior a éste. Se habla, entonces, de *seguro suficiente*, *insuficiente* o *infraseguro* y *sobreseguro*.

- a) Si el monto asegurado coincide con el valor del objeto, no se presente problema alguno.
- b) Si excede de este valor, el seguro sólo es eficaz hasta el verdadero valor de la cosa materia del seguro.

En la hipótesis del sobreseguro, se aplica integralmente el principio de la limitación de la indemnización hasta el monto del verdadero valor de la cosa asegurada. En el hecho resulta, entonces, que el asegurado ha pagado por la cobertura un valor superior al real, ya que la prima debe estar en relación con el monto asegurado.

Habría buenas razones para sostener que el sobreseguro es una forma de sobrevalorizar las cosas aseguradas y entonces, conforme al artículo 558, si ha habido simple error, podría el asegurado requerir la rebaja de la prima y, por consiguiente, la devolución del exceso pagado por este concepto. Si existe dolo, procede la nulidad del contrato y en caso de dolo del asegurado, el asegurador puede retener las primas pagadas.

- c) Si el seguro es insuficiente, la ley considera al asegurado como asegurador de aquella parte del valor de la cosa asegurada no cubierto por la póliza y, en caso de siniestro, la indemnización se regula de acuerdo con la regla proporcional.

La razón de esta indemnización proporcional es bien clara: el asegurado sólo ha transferido una parte del riesgo y, por consiguiente, la prima sólo se ha calculado con relación a esta parte. En el seguro a primer riesgo la prima es, naturalmente, más alta que en el caso normal.

Acá hay una especie de co seguro porque el asegurado asume una parte del riesgo y la aseguradora asume la otra parte.

Este principio no tiene aplicación si los interesados han estipulado que el asegurado no soportará parte alguna de la pérdida o deterioro, sino en el caso de que el monto del siniestro exceda de la suma asegurada (seguro a primer riesgo). En estos casos la cobertura es total y por lo tanto no hay un co seguro.

7. El interés

7.1 Principio Legal.

El objeto del seguro está constituido por el interés que tiene el asegurado en el bien expuesto al riesgo. Se asegura ese interés y no el bien en sí. (ART. 520).

¿Por qué es el interés el objeto del seguro y no el bien en sí? Sin interés, el riesgo de que desaparezca el bien es indiferente y no hay sentido en asegurar la cosa. Además, si hay un siniestro a mi no me van a reemplazar el bien de la misma forma (ej. se quemó completamente mi auto), entonces no es el objeto en sí mismo sino el interés respecto del objeto que constituye la base del contrato.

Ahora, esto no significa que se indemniza en relación al valor “afectivo” que tiene el asegurado con la cosa, porque eso es muy poco objetivo.

7.2 Qué se entiende por “interés”.

A efectos del seguro, por interés hay que entender *aquella especial situación del asegurado respecto de un determinado bien que le hace susceptible de sufrir un daño al producirse el evento (siniestro).*

Esta situación especial proviene de encontrarse el asegurado en relación económica con el bien en cuestión. No considera una relación moral o afectiva.

Dicha relación se produce, entonces, entre un sujeto y una cosa apta para satisfacer una necesidad, razón por la cual es susceptible de ser valorada económicamente.

Aunque normalmente la relación económica entre el sujeto y la cosa tendrá su base en una relación jurídica (de propiedad, tenencia, fideicomiso, etc.) no es el aspecto jurídico de esa relación lo que se toma en cuenta a efectos de determinar el interés asegurable.

Para que exista interés, basta una mera relación de hecho del sujeto con la cosa, siempre que esta relación haga susceptible al sujeto de sufrir un daño al producirse un evento determinado. Lo que se privilegia es la relación económica por sobre la relación jurídica.

Se trata, por lo tanto, de un concepto económico. Y esto se desprende del concepto mismo de seguro, que tiene por finalidad una reparación (indemnización) de tipo económico, lo que supone un perjuicio de igual naturaleza.

7.3 Tipos de “intereses”.

- a) Seguros contra daños en las cosas: esa relación de interés es fácilmente visible.
- b) Seguros de personas: no cabe negar la existencia del interés asegurable, porque el hombre, independiente de su condición de persona humana, es susceptible de ser valorado económicamente y en este sentido nada se opone a que pueda ser objeto de una relación de interés asegurable.

Ese interés existe siempre en toda persona respecto de sí misma (relación del hombre como persona y su cuerpo, que puede ser dañado en su integridad física, en su salud o en su vida misma). Pero además esa relación de interés puede darse entre una persona y otra, con lo cual ningún seguro de personas está exento de tener por objeto un interés.

Probablemente una persona de 18 que no contribuye patrimonialmente en su casa, el impacto económico que produce su pérdida es distinto a su muerte el padre de familia.

- c) Seguros de patrimonio: existirá una relación económica indirecta del asegurado con la cosa o bien del tercero que al resultar dañado genera la obligación.

Por lo menos, es evidente que a consecuencia de la responsabilidad contraída por el asegurado, siempre resultará expuesto al riesgo el interés directo de éste sobre la parte de su patrimonio que haya de ser sacrificada para saldar la deuda contraída con el tercero dañado.

7.4 Quiénes tienen interés.

- Propietario
- Co-copropietario
- Fideicomisario
- Usufructuario
- Arrendatario
- Acreedor (por la garantía del derecho general de prenda)
- Administrador de bienes de terceros

7.5 Sanción por la falta de interés.

Si miramos el interés como un presupuesto del riesgo, es razonable que la sanción a la falta de interés sea la ineficacia del contrato de seguro. Es decir, si no hay interés, no hay riesgo y, no habiendo riesgo, el seguro es inexistente

Art. 520 ccom. *Interés asegurable. El asegurado debe tener un interés asegurable, actual o futuro, respecto al objeto del seguro. En todo caso es preciso que tal interés exista al momento de ocurrir el siniestro.*

Si el interés no llegare a existir, o cesare durante la vigencia del seguro, el contrato terminará y el asegurado tendrá derecho a la restitución de la parte de la prima no ganada por el asegurador correspondiente al tiempo no corrido.

7.6 Valor del interés y suma asegurada.

7.6.1 El interés asegurado tiene necesariamente un valor económico

- a) En unos seguros (normalmente relacionados con intereses en las cosas) se determina a posteriori por criterios objetivos.

En estos casos, el valor del interés puede variar de unos momentos a otros del contrato, por lo que se habla de *valor inicial* (al momento en que se toma la póliza), *valor final* (al momento inmediatamente anterior al siniestro) y *valor residual* (posterior a la ocurrencia del siniestro).

El que realmente interesa a efectos del seguro es el **valor final**, aunque las partes pueden fijar y aceptar expresamente en la póliza el valor del interés que ha de tenerse en cuenta para el cálculo de la indemnización (pólizas estimadas), en cuyo caso el asegurador sólo puede impugnar el valor estimado cuando su aceptación haya sido prestada por medio de dolo o grave error.

- b) En otros seguros (especialmente los seguros de personas) se determina a priori con arreglo a cantidades fijas, establecidas legal o convencionalmente.

7.6.2 “Respecto del asegurado, el seguro es un contrato de mera indemnización y jamás puede ser para él ocasión de una ganancia”. (ART. 550)

- Si hay exceso de valoración por error, las partes pueden exigir su reducción, salvo que se hubiere pactado su valor conforme al Art. 554
- Si hay exceso de valoración por dolo, el asegurador tendrá derecho a la prima íntegra a título de pena y el asegurado no tendrá derecho a la indemnización, sin perjuicio de la acción penal correspondiente (ART. 558)

7.6.3 No hay que confundir el *valor del interés* que se asegura con la llamada *suma asegurada*, que representa la medida en que el interés asegurable queda cubierto por el seguro.

La *suma asegurada*, libremente establecida en la póliza por el asegurado, no sólo sirve de base para el cálculo de la prima (a mayor suma, mayor prima), sino que representa además el límite máximo de la prestación del asegurador. La forma de objetivizar el interés que tengo respecto de la cosa, es la suma asegurada como una mención pactable en el contrato.

a) En los seguros de vida, el asegurador está siempre obligado a satisfacer la totalidad de la suma asegurada (no se deprecia la persona).

b) En los seguros de cosas, la situación no es igual. La suma asegurada puede o no coincidir con el valor del objeto materia del seguro y ser, igual, inferior o superior al valor del interés. Estaremos en presencia de un:

b.1 Seguro suficiente o pleno, cuando coincidan plenamente el valor del interés y la suma asegurada (aunque un seguro pleno puede dejar de serlo en el tiempo). En este caso no se presenta problema alguno.

b.2 Seguro insuficiente, parcial o infraseguro, si la suma asegurada es inferior al valor del interés. Esta situación puede ocurrir por voluntad del asegurado al tomar el seguro o puede sobrevenir en el curso del contrato.

¿Qué pasa en los casos en que el bien se deprecia, por qué se permite determinar el valor inicial? ¿no supondría afectar el principio indemnizatorio? Acá lo que se quiere evitar es la fluctuación del valor de la cosa asegurada, y normalmente este valor se va a mantener dentro de ciertos parámetros de mercado por eso es aceptable que se establezca este valor indemnizable. Ahora, si este valor es muy superior al de mercado, ahí correspondería que solo se pague el valor máximo de la cosa y que haya devolución de la sobreprima.

8. El reaseguro

8.1 Concepto.

Por muy perfecto que sea el cálculo de probabilidades, sólo señala tendencias. Entre dicho cálculo y la realidad existen diferencias que, en estadísticas, se denominan desviaciones. Puede ocurrir, por consiguiente, que los siniestros que ocurren en un determinado período sean más numerosos o más importantes de lo previsto por el asegurador, lo que producirá las pérdidas consiguientes.

Todo esto supone un dilema para el asegurador que asume distintos riesgos, porque a su vez tiene que minimizar sus riesgos, lo que ocurre a por medio de la división de riesgos. Se descargan todo o parte de los riesgos asumidos en un tercero.

El principio de la división de los riesgos aconseja al asegurador, cubrir riesgos de distinta naturaleza, en áreas geográficas diversas y entre distintas categorías de personas. Este principio lo induce también a hacer participar a otros aseguradores en la cobertura de los riesgos. En tal evento, podemos estar frente a la hipótesis del reaseguro.

Una forma de dividir los riesgos es el reaseguro. En términos generales podríamos decir que el reaseguro es el seguro del asegurador.

¿Cuál es el negocio? Un poco lo mismo que sucede en las operaciones de descuento; la aseguradora sabe que le pagan 10 de prima, luego paga él 7 de prima, y la utilidad es 3.

Más específicamente, se le ha definido como ***“el contrato por el cual al asegurador descarga en otra persona, llamada reasegurador, el todo o parte de los riesgos que ha asumido personalmente”***. Planiol y Ripert, T. XI, Nº 1257, p. 621. Esta definición no es muy acertada porque, como veremos, el reasegurador no reasegura los mismos riesgos asumidos por el asegurador.

También se ha dicho que el reaseguro es un contrato por el cual el asegurador se cubre contra los efectos del seguro que ha consentido al asegurado.

El asegurador puede ocurrir a otro asegurador y asegurar el riesgo que para él significa la eventualidad de pagar la indemnización al asegurado.

Las partes del contrato de reaseguro son el asegurador, que en este caso toma el nombre de reasegurado, y el reasegurador. Pero entre el asegurado original y la reaseguradora no hay NINGUNA relación: si ocurre el siniestro, sigue respondiendo la aseguradora original. En este nuevo contrato hay un nuevo interés pactado, una nueva prima, etc. y esto tiene muchas consecuencias jurídicas en los efectos del contrato de reaseguro.

En la práctica, el contrato de reaseguro supone que la aseguradora contrata un seguro para cubrir sus propios riesgos, no es que traspasa el mismo riesgo que a su vez el asegurado le había traspasado.

El reaseguro se práctica frecuentemente en el ámbito internacional. El asegurador de un país recurre a un reasegurador de un país diverso, lo que produce una difusión de los riesgos en un ámbito geográfico más amplio.

¿Cómo funciona el reaseguro económicamente?

El asegurador asegura un conjunto de riesgos parecidos, entonces eventualmente puede reasegurar un riesgo específico o ese conjunto de riesgos completos porque la probabilidad de siniestro es muy alta (ej. 10mil casas aseguradas contra terremotos en Santiago). La diversificación de riesgos

A) Definición del Código

El Código de Comercio se refiere al reaseguro en su **artículo 584** el que señala que *“Por el contrato de reaseguro el reasegurador se obliga a indemnizar al reasegurado, dentro de los límites y*

modalidades establecidas en el contrato, por las responsabilidades que afecten su patrimonio como consecuencia de las obligaciones que éste haya contraído en uno o más contratos de seguro o de reaseguro”.

En realidad la definición no habla de lo que es el seguro sino más bien de sus efectos. No se habla de “transferencia de riesgo” sino que de indemnización, además de que en este caso solo se asegura el patrimonio de la aseguradora en el evento de que se produzca el siniestro reasegurado. Ya no importa qué paso con la cosa o la vida asegurada, sino que importa que se produzca la obligación de indemnización del siniestro por parte de la compañía de seguros.

Es un contrato que no aplica tan localmente porque cuando opero en un determinado ámbito geográfico, la posibilidad de tener compañías de reaseguro en relación a compañías de seguro está limitado y no hace mucho sentido desde un punto de vista de negocios. No existen compañías de reaseguro generales en Chile y solo tenemos una compañía de reaseguros de vida (Caja Reaseguradora).

En ese sentido, esto último lleva a que para interpretar este tipo de contratos se hace referencia a los usos y costumbres internacionales (lex artis internacional).

Art 584 inciso final ccom. *En estos contratos, servirán para interpretar la voluntad de las partes los usos y costumbres internacionales sobre reaseguros.*

B) Definición doctrinaria

La doctrina ha definido el contrato de reaseguro como *“un contrato bilateral en el que una de las partes, el asegurador directo, cede la responsabilidad que le afecta en los seguros contratados, total o parcialmente a otra, el reasegurador, obligándose este último a restituirle proporcionalmente, las indemnizaciones que debe pagar en razón de sus contratos de seguros a cambio de una retribución consistente en el total o parte de las primas recibidas”.*

Esta es una definición tradicional que habla de “cesión de responsabilidad”, cuestión que se critica. En realidad, no se cede la responsabilidad sino que hay dos responsabilidades distintas y lo que transfiere la aseguradora a la reasegurador es otro riesgo; no hay relación entre ambas responsabilidades ni accesoriedad.

8.2 Naturaleza Jurídica.

- A) Sociedad: Se ha pretendido señalar que el reaseguro sería una especie de sociedad, entre cedente y reasegurador, sin embargo, dicha comparación no procede bajo punto de vista alguno, por cuanto en el contrato de reaseguro no están presentes ninguno de los elementos propios de la sociedad (no se pacta algo en común, no hay repartición, no hay affectio societatis).
- B) Cesión: Asimismo se ha vinculado al reaseguro con una cesión. Este paralelo tampoco resulta acertado toda vez que nunca en un contrato de reaseguro habrá vínculo entre asegurado y reasegurador. La reaseguradora, por ejemplo, no podría oponer excepción de dolo por parte del asegurado original.

- C) Fianza: Tampoco podrá considerarse al reaseguro una fianza, por cuanto éste no es nunca una garantía, y el único obligado al pago del seguro es el asegurador quien estará obligado para con asegurado aún cuando el reasegurador no pague.

Asimismo y a diferencia de la fianza en este contrato no hay derecho de reembolso, ni tampoco relación jurídica entre el asegurado y el reasegurador, como si la hay entre acreedor y fiador.

- D) Seguro: Descartadas las posibilidades anteriormente descritas y por básico que parezca, se ha llegado a la conclusión que el contrato que más se asemeja al reaseguro participando de misma naturaleza jurídica es el propio contrato de seguro. Es un contrato de seguro más simple porque solo se asegura el patrimonio de la aseguradora.

Siendo en este caso:

- La cosa asegurada, el patrimonio de la compañía aseguradora
- El riesgo, la amenaza o posibilidad de pérdida que sufre la compañía de seguro por los eventuales pagos de indemnizaciones que debe hacer en cumplimiento de las obligaciones contratadas.

El riesgo no es la ocurrencia del siniestro sino el desembolso que tiene que hacer la aseguradora.

El riesgo ofrece la particularidad de ser siempre el mismo: la eventualidad de que el reasegurado deba pagar la indemnización a su asegurado. No existe aquí la diversidad de riesgos que hay en el seguro: incendio, terremoto, naufragio, muerte, etc.

El riesgo en el reaseguro no envuelve culpa del reasegurado, sino mero cumplimiento de la obligación que le viene impuesta por el contrato de seguro, que consiste cabalmente en indemnizar a su asegurado en caso de siniestro. En esto se diferencia el reaseguro del seguro de responsabilidad que requiere culpa del asegurado.

Por lo tanto, una vez que paga la aseguradora se produce el “siniestro” para la reaseguradora. Por eso no se exige buena fe contractual que es más propia del contrato de seguros. En la medida de que se produce el pago, surge el siniestro para la compañía de reaseguro.

- La prima, el pago que la compañía de seguros hace a la compañía reaseguradora.

8.3 Historia.

Hasta 1928 no existían en Chile normas legales sobre reaseguros y por consiguiente estos se podían contratar tanto en Chile como en el extranjero.

Ese año, sin embargo, se dictó la legislación sobre comercio de seguros nacionalizando dicha actividad, alterando también lo que hasta ese momento había sido la costumbre en materia de reaseguro.

En dicho año se dispuso que las compañías debían contratar los reaseguros entre ellas mismas, y de existir excedentes que no fueran cubiertos por ellas, debían ser reasegurados obligatoriamente por la caja reaseguradora de Chile, que era una sociedad de economía mixta con participación del

estado y de las mismas compañías quienes quedaron obligadas a suscribir parte de su capital. De este modo, la caja quedó con el monopolio de los reaseguros.

Con las modificaciones del año 1980, se consagró una amplia libertad en la contratación de reaseguros, terminando con el monopolio que hasta ese momento había tenido la caja reaseguradora, la que se privatizó.

Esto generó que existieran 3 alternativas para contratar reaseguros: a) constitución de reaseguradoras en Chile, b) contratar con compañías extranjeras que se pueden inscribir en la CMF y c) operar a través de corredores por medio de los cuales se contratan (entonces la fiscalía extranjera no se sujeta a la fiscalización de la CMF).

8.4 Requisitos Legales para la Constitución y Operación de Compañías Reaseguradoras.

Para el análisis de este párrafo corresponde subdistinguir, entre las compañías reaseguradoras constituidas como sociedades chilenas, las compañías reaseguradoras extranjeras facultadas para operar en Chile, y los reaseguros contratados por corredores extranjeros autorizados para ofrecer sus reaseguros en Chile.

8.4.1 Constitución de Compañías Reaseguradoras en Chile

La ley faculta el establecimiento de sociedades anónimas cuyo objeto exclusivo consista en operar reaseguros, para cuyo efecto deben tener un capital mínimo de 60.000 UF.

8.4.2 Requisitos de las compañías extranjeras para contratar en Chile

La ley de seguros también permite que las compañías chilenas se reaseguren con Compañías extranjeras siempre que estas se encuentren inscritas en un registro que para estos efectos mantiene la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que entre otras formalidades exige que se acredite que la entidad reaseguradora tiene un capital igual o superior a 300.000 UF.

8.4.3 Contratación de reaseguros a través de corredores extranjeros

Finalmente las empresas de seguros que operan en Chile pueden efectuar su contratación de seguros a través de Corredores de Reaseguradores Extranjeros quienes deben inscribirse en un registro especial que lleva la CMF. A estos corredores se les exige además de otros requisitos formales que contraten una póliza para responder del correcto y cabal cumplimiento de sus obligaciones, con un mínimo de 20.000 UF llamada Póliza de Errores y Omisiones.

A través de estos registros, la CMF busca mantener un control sobre la contratación de reaseguros que llevan a cabo las entidades aseguradoras que funcionan en nuestro país. A la CMF le interesa saber qué riesgos están o no cubiertos.

La contratación de reaseguros en el extranjero se encuentra gravada por un impuesto adicional equivalente al 2% de la prima cedida. (Art. 59 de la ley de la Renta). En cuanto a la ley de la renta hay 4 grandes impuestos: *1era categoría* (PJ), *2da categoría* (trabajadores dependientes), *impuesto global complementario* (en la medida de que se tenga una gran renta) e *impuesto adicional* (personas residentes en el extranjero). Entonces si yo contrato una póliza de seguros y tengo que

pagarle la prima al corredor extranjero, él tiene que pagar un impuesto adicional del 2% por ser extranjero.

8.5 Principales Mercados Reaseguradores.

El reaseguro implica por su naturaleza misma, una gran capacidad financiera, ya que el mercado natural de los reaseguradores son las compañías de seguros. De ahí que los así llamados centro reaseguradores sean países de sólida estabilidad financiera. El mercado de reaseguro debe ser un mercado robusto para asumir todos estos riesgos.

Veamos cuales son los principales mercados reaseguradores para los seguros contratados en Chile:

- A) En un indiscutible primer lugar se ubica el **LLOYDS de Londres**, formado por varios sindicatos, y en el cual cada uno de ellos va aceptando en diversos porcentajes la cesión del riesgo.

Este mercado era importante en materia de transportes mercantes en su origen. Se formaban sindicatos de aseguradores, lo mismo que sucede hoy en día porque se forman sindicatos de reaseguradoras que van asumiendo riesgos.

También es importante destacar que en Inglaterra existen otros sindicatos que si bien no pertenecen a Lloyds son sumamente importantes por cuanto asumen muchos de los riesgos cedidos por nuestro mercado.

- B) En segundo lugar, cabe destacar otros **mercados de Europa Continental**, a saber Alemania, Francia y Suiza, (Muenchener, Scor, y la Suiza de Reaseguros). Han perdido competitividad porque el sistema financiero gira en torno a los bancos que han sido bastante golpeados en estos países últimamente (salvo en Suiza).
- C) Si bien **España** es naturalmente un centro reasegurador más pequeño que los países mencionados anteriormente, corresponde destacar su vocación por el mercado latinoamericano, y en este sentido hay que destacar especialmente la importancia que tiene MAFRE en Chile.
- D) También hay que mencionar a **Estados Unidos** como un mercado reasegurador sumamente importante, sin embargo, la mayor parte de su capacidad financiera la tiene copada con su mercado interno. Sin embargo, es un mercado en sí mismo entonces tiene poca interacción internacional.
- E) **Japón** también es un centro reasegurador preponderante, puesto que la mayoría de las grandes empresas japonesas como Mitsubishi Mitsui, el Sumitomo etc, se dedican al negocio reasegurador. Sin embargo, y por regla general, Japón como centro reasegurador se ha vinculado más que ningún otro centro reasegurador, al mercado asiático.

En Chile en particular las reaseguradoras japonesas dan cobertura a empresas japonesas localizadas en nuestro país, lo que se ha denominado como el “Japan Interest”.

Todo esto hace relevante entender los usos y costumbres porque hay muchas reglas que no están en los contratos pero son parte del soft law que en esta materia es plenamente aplicable.

8.6 Contrato de Reaseguro en el Extranjero.

Dado que lo que se busca al contratar un reaseguro es atomizar los riesgos, y que por regla general se necesita una gran capacidad financiera, en definitiva la mayoría de los reaseguros se contrata o con compañías extranjeras facultadas para operar en Chile o a través de corredores extranjeros con compañías extranjeras. Veamos ahora las modalidades de estos contratos y los problemas que se pueden originar.

8.7 Clasificación.

Esto depende de si estoy reasegurando un riesgo individual o no.

8.7.1 Especial

Ejemplo: aseguro mi casa contra el riesgo de incendio con el asegurador A y éste ocurre al reasegurador B para reasegurar este contrato específico. Para este efecto se otorgará entre el reasegurado y el reasegurador una póliza individual.

Convenido entre cedente y reasegurador, es acordado generalmente en atención a un riesgo individual, el cual es avaluado y tarificado por los suscriptores, quienes además fijan los términos y condiciones del mismo.

Antiguamente, este tipo de reaseguro se empleaba en aquellos casos de alta especialización, como seguros de aviación, joyas, etc., hoy día sin embargo y no obstante su mayor costo, se ha difundido y es usado en varios en casi todos los ramos.

El uso del reaseguro facultativo ha dado paso al denominado “fronting”, que en definitiva es un contrato de seguro convenido directamente entre Asegurado Original y Reasegurador (con la intervención de un corredor de reaseguros), el cual con posterioridad es ofrecido a un Asegurador Cedente, el que por una comisión acepta emitir una póliza de Seguro, sin que necesariamente retenga ninguna proporción del riesgo.

Por ejemplo, la aseguradora no puede asegurar una obra de arte entonces necesita que una reaseguradora lo haga. Pero en la práctica la reaseguradora la que origina el negocio, busca una aseguradora que se relacione el asegurado y al final la reaseguradora paga una comisión a la aseguradora por la intermediación.

8.7.2 General

Para este efecto se celebra un contrato por el cual el reasegurado y el reasegurador convienen en reasegurar el total o una cuota de los seguros que contrate el reasegurado. Estos contratos reciben el nombre de tratados.

En el reaseguro de tratados, se ceden parte o la totalidad de la cartera de riesgos en los mismos términos que los ha contratado el asegurador, por un porcentaje de la prima.

Clasificación de los tratados:

a) Reaseguro de excedente de riesgo

En esta especie de tratado se pacta que el reasegurador reasegurará los contratos de seguro del reasegurado en cuanto excedan lo que se denomina el “pleno de conservación”, o sea, el monto de seguros sobre un cierto riesgo que, durante un cierto tiempo, el reasegurado puede financieramente contratar, tomando en cuenta los factores estadísticos correspondientes. Así, si el pleno de conservación de un reasegurado para el riesgo de incendio es de 100 en un año, el reasegurador estará obligado a aceptar reaseguros por el exceso sobre esa cantidad.

b) Reaseguro de excedente de siniestros (*excess loss*)

En este caso, la obligación de reaseguro se refiere a un porcentaje de siniestros, no de riesgos. Ejemplo: se conviene reasegurar el 75 % de los siniestros que ocurran en cierto período. Si el reasegurado tiene un seguro específico con un asegurado, por 100, y ocurre el siniestro, el reasegurado soportará una pérdida de 25 y los 75 restantes le serán reembolsados por el asegurador.

Por lo tanto, el porcentaje que supera cierto número, es de responsabilidad de la reaseguradora.

c) Reaseguro de excedente de pérdidas. (*stop loss*)

En este caso el reasegurador se obliga a rembolsar reasegurado las indemnizaciones que este último debe pagar en exceso de una suma global determinada de antemano para el correspondiente ejercicio. Ejemplo: el reasegurador se obliga a rembolsar al asegurado las indemnizaciones que pague en 2003, en exceso de 100.

d) Reaseguro con reciprocidad

En este caso, el reasegurador se obliga, a su vez, a reasegurar con el reasegurado sus propios seguros directos. En tal forma, ambas partes son reasegurado y reasegurador, pero con respecto a seguros diversos.

e) Reaseguro a prima de riesgo

Este es un reaseguro practicado especialmente por las compañías de seguro de vida que comienzan sus actividades. En sus primeros años, estas compañías no han alcanzado a generar suficientes reservas matemáticas para cubrir los riesgos y recurren a esta especie de reaseguro respecto de los riesgos aún no cubiertos por esas reservas. Este reaseguro se practica en Suecia y en los países del Norte de Europa. Sobre las reservas matemáticas volveremos al tratar del seguro de vida.

Las compañías de seguros de vida determina una prima cara al principio pero barata al final porque los riesgos van aumentando. Al principio con las primas no puede cubrir indemnizaciones, entonces se reasegura esa posibilidad (si se empiezan a morir los clientes, que la aseguradora no se quede sin espalda financiera).

8.8 La retrocesión

El reasegurador puede, a su vez, tomar un reaseguro de segundo grado con otro reasegurador. Este reaseguro recibe el nombre de retrocesión. Este proceso puede repetirse varias veces, dando por resultado una verdadera cascada de reaseguros, con lo cual se maximiza la división de los riesgos.

El reaseguro no se agota con un solo contrato de reaseguro sino que pueden haber múltiples contratos de reaseguro. La reaseguradora puede reasegurar a su vez el riesgo en otra aseguradora individual o en un sindicato de aseguradoras.

8.9 Inoponibilidad del reaseguro del asegurado.

El asegurado no es parte en el reaseguro.

El reaseguro no es un contrato accesorio al contrato de seguro. El riesgo original que asume la aseguradora es absolutamente independiente del contrato de reaseguro, en que el riesgo es solo de indemnización patrimonial cuando la aseguradora debe pagarle al asegurado original.

De lo contrario derivan dos consecuencias: el asegurado no tiene acción contra el reasegurador y, por otra parte, el reasegurado no queda libre de su responsabilidad frente al asegurado por el hecho de reasegurarse. En esto se diferencia el reaseguro del seguro de la solvencia del asegurador.

8.10 Reglamentación legal del reaseguro.

Nuestra legislación se ocupa poco del reaseguro, limitándose a proporcionar una definición e indicar cuáles son las acciones que tiene el asegurado en contra del reasegurador.

ART. 584 al 587

8.11 DFL 251.

El DFL 251 contiene diversas normas sobre reaseguros:

(a) El artículo 16 dispone que

El reaseguro de los contratos celebrados en Chile lo harán las entidades aseguradoras y reaseguradoras con compañías de seguros y reaseguros autorizadas para operar en el país (inciso 1º).

(b) Los incisos 2º y 3º del artículo 16 se refieren a las “entidades facultadas para reasegurar”, cuya existencia se autoriza. Tales entidades deben constituirse como sociedades anónimas, con el objetivo exclusivo de operar en reaseguros de uno o ambos grupos, quedando sujetas a la fiscalización de la CMF en conformidad a la ley. Estas entidades reaseguradoras deben tener un capital pagado y reservas patrimoniales no inferiores a 120.000 unidades de fomento por cada grupo que operen.

El artículo 16 bis establece que también pueden reasegurar las entidades extranjeras de reaseguros que se encuentren inscritas en el registro de reaseguradores extranjeros que lleva la CMF, las cuales deberán cumplir con los requisitos que el mismo artículo 16 bis establece, a saber:

Un capital superior a 300.000 UF; Acreditar su constitución legal en el país de origen; Acreditar su capacidad de pago en moneda de libre convertibilidad; y finalmente, acompañar copia auténtica de sus estatutos vigentes y otros documentos, Finalmente, deberán establecer un representante legal en Chile con poder para contestar demandas.

9. El seguro de vida

9.1 Definición

No es necesariamente un seguro de mera indemnización porque es difícil regular eso: lo que se asegura es básicamente la vida, la muerte de una persona, su integridad física/intelectual o la salud de las mismas.

El seguro de vida *es un contrato por el cual el asegurador, a cambio de una prima anual o única, promete una suma de dinero al contratante o al beneficiario por él designado, bajo ciertas eventualidades que dependen de la vida o de la muerte del contratante o de un tercero*. Planiol y Ripert, T. XI, Nº 1376, p. 797.

La definición anteriormente citada destaca las variedades fundamentales del seguro de vida: el seguro en caso de muerte y el seguro en caso de vida o de supervivencia. Estas dos clases de seguro de vida son también reconocidas por nuestro C. de C. en su Art. 572. Veremos oportunamente que la combinación de estas dos especies de seguro de vida da origen a lo que se denomina el seguro mixto.

La definición de este artículo recoge diversas posibilidades dentro de este tipo de seguro:

- a) Riesgos de vida (existencia);
- b) Integridad física o intelectual;
- c) Salud de las personas;
- d) Renta vitalicia (por un plazo)

Se habla de seguro de vida o de seguro de muerte. **El seguro de muerte** se genera cuando muere una persona (ese es el siniestro), pero en el **seguro de vida** el siniestro supone que una persona se mantuvo con vida luego de un siniestro (se asegura un cierto capital por si una persona sobrevive un hecho o determinada edad).

En el caso del seguro de vida el riesgo es sobrevivir al hecho, por ejemplo, porque no voy a poder costear mi vida luego de ese momento (no tengo más ingresos).

9.2 Características

La referida definición pone también de relieve dos características importantes del seguro de vida:

a) El seguro de vida puede ser contratado por la propia persona de cuya vida o muerte depende el pago de la suma asegurada (ya sea porque quiero garantizarle el pago a un heredero, o porque quiero garantizarme a mí misma un capital por sobrevivir); y también puede ser contratado por una persona distinta de aquella de cuya vida o muerte depende el pago de dicha suma.

Recordemos que, conforme a las reglas del seguro, el asegurado debe tener un interés real y efectivo en la conservación de la cosa asegurada y que, sin ese interés, el seguro es nulo. Sin embargo, ese interés es un interés pecuniario; en cambio, en el seguro de vida basta el interés moral.

En los seguros generales debía haber un interés real en la cosa asegurada, interés patrimonial/económico por eso el contrato es meramente indemnizatorio. Pero en seguros de vida/muerte, esta regla se rompe porque no hay manera objetiva de avaluar la vida de una persona. Si valorizo el efecto patrimonial de la muerte de una persona (ej. aporte económico que eventualmente podría hacer una persona a la familia), eso no es suficiente porque nunca voy a poder predecir esto, ej. ahora estudiamos derecho pero puede que después seamos multimillonarios o terminemos como monjes budistas.

No hay una reparación patrimonial económica sino que hay libertad para fijar el monto de indemnización. NO estoy limitada por el valor o interés patrimonial, porque puede haber un interés incluso afectivo, y en esa base se determina el monto asegurado. En resumen, basta que exista un interés moral entonces es mucho más subjetivo; por lo tanto es difícil para la aseguradora probar que no cubre un determinado interés.

Otra diferencia entre un seguro de muerte y un seguro de daños es que la muerte es un siniestro inminente, ahora, en general estos seguros no cubren para toda la vida de una persona.

b) El seguro puede contratarse a favor del asegurado o de un beneficiario designado por éste. Esta última posibilidad no está contemplada expresamente por el ccom entre las disposiciones pertinentes al seguro. Sin embargo, el C. Civil, en su Art. 1449, contempla la estipulación a favor de un tercero o estipulación a favor de otro, de la cual esta especie de seguro no es sino una aplicación particular.

Esto se explica justamente porque no se necesita un interés concreto y real, como vimos antes.

¿Qué pasa si yo nunca supe que soy beneficiaria? La aseguradora debería ponerse en contacto con el beneficiario pero eventualmente podría haber un incumplimiento contractual y que no lo haga.

9.3 Carácter no indemnizatorio del seguro de vida

El seguro de vida se diferencia fundamentalmente del resto de los seguros en cuanto la obligación de indemnizar que asume el asegurador no constituye la reparación del daño causado por la muerte de la persona de cuya vida depende el seguro, ni por su sobrevivencia más allá de cierta época. Lo que se asegura es un capital; en el caso del seguro en caso de muerte, el capital que el difunto no alcanzó a formar; y en el seguro en caso de vida, el capital que el asegurado no pudo formar antes de cierta fecha.

Como la determinación exacta de este capital es imposible o, por lo menos, muy difícil, las partes la fijan libremente, sin limitación de ninguna especie. Por consiguiente, el seguro de vida no tiene el carácter esencialmente indemnizatorio que tienen los demás seguros.

La determinación del monto asegurado es “libre” y no se relaciona necesariamente con las circunstancias que se enfrentan. Al momento de contratar, como parte de las condiciones particulares, las partes van a determinar el monto.

9.4 El seguro en caso de muerte

El riesgo que toma el asegurador sobre sí puede ser el de la muerte del asegurado dentro de un determinado tiempo o en ciertas circunstancias. Sin embargo, este concepto se refiere sólo a una de las variedades del seguro en caso de muerte, llamado seguro temporal.

La indemnización, en el seguro en caso de muerte, puede consistir en un **capital** o en una **renta** (ej. pago de una renta vitalicia desde que se murió una determinada persona, esto sobre todo sucede cuando la familia requiere de dinero para sobrevivir mes a mes para no tener que administrar todo el capital. Además, en este caso el dinero sigue rentando), aunque generalmente consiste en un capital. Si el asegurado ha designado beneficiario, la indemnización deberá ser pagada a dicho beneficiario; en caso contrario, la indemnización se colaciona o agrega en la herencia del asegurado, es decir, sucesión testada/intestada.

La designación de beneficiario puede hacerse en la póliza misma o en acto posterior. Se ha discutido si la designación puede revocarse. No cabe duda de que ella puede revocarse antes de su aceptación por el beneficiario. Pero, ¿podría revocarse después? Si se aplica la regla del Art. 1449 del C. Civil, sobre la estipulación a favor de un tercero, pareciera que no es posible. Con todo, se ha sostenido que, en el seguro, la intención de las partes sería que la aceptación del beneficiario pudiera darse sólo después de la muerte de la persona cuya vida se asegura. De esta suerte, el beneficiario no podría dar su aceptación antes del deceso de dicha persona, y, por tanto, la designación sería revocable en vida de dicha persona, cuantas veces ésta quisiera.

Ahora, independiente de todo esto en general no va a existir dicha aceptación por parte del beneficiario (ya sea porque no conoce que existe el seguro o porque será difícil probar esa aceptación sobre todo si es tácita). Por lo tanto SIEMPRE podrá el asegurado revocar la persona del beneficiario del seguro.

OJO se habla en genérico de seguros de vida, dentro de los cuales tenemos los seguros de muerte y de vida.

9.5 Variedades del seguro en caso de muerte

El seguro en caso de muerte es de dos clases:

- a) Seguro de vida entera o seguro vitalicio (da lo mismo cuándo se muere la persona).
- b) Seguro temporal (se paga solo si la muerte ocurre en cierto plazo). Esto procede, por ejemplo, si la persona se somete a ciertos riesgos como sucede en el caso de los seguros de viaje que tienen una parte de seguros de vida. Otra razón podría ser que yo quiero que el seguro solo me cubra cuando tengo mayores gastos, por ejemplo, familiares.

En el primero, el asegurador garantiza el pago de la indemnización a la muerte del asegurado, cualquiera que sea el tiempo en que ella acaezca. En cuanto a la prima, puede ella en este caso ser

una prima única o una prima anual, pagadera durante cierto tiempo o durante toda la vida. Las primas acá son caras porque son un promedio de los riesgos a que estoy expuesta en mi vida, que van aumentando con la edad.

En el seguro temporal el asegurador se obliga a pagar la indemnización si la muerte del asegurado ocurre dentro de cierto plazo o en ciertas condiciones. Esta modalidad se emplea cuando el asegurado va a estar expuesto a ciertos riesgos especiales, durante cierto tiempo. Por ejemplo, durante un viaje, una expedición científica; etc. También podría tomarse por un acreedor sobre la vida de su deudor, para el evento de que este muera antes del plazo para el pago de la deuda, estando ésta insoluta. Obviamente en estos casos la prima es más baja que en el caso del seguro de vida vitalicio.

9.6 El seguro en caso de vida

En este seguro el asegurador se obliga a pagar la indemnización al asegurado si éste sobrevive a cierta fecha. Al igual que en el seguro en caso de muerte, la indemnización puede consistir en un capital o en una renta vitalicia. La prima puede ser una prima única o primas periódicas.

En esta especie de seguro, el asegurador queda libre de la obligación de indemnizar si el asegurado muere antes de la época prefijada. Esto, naturalmente, constituye una enorme desventaja para el asegurado y para su familia. Para contrarrestar esta desventaja existe lo que se llama **el contraseguro**, mediante el cual, en virtud de una pequeña prima adicional, el asegurador se obliga, en caso de muerte prematura del asegurado, a rembolsar a sus herederos el monto de las primas pagadas. Por lo tanto, hay un seguro de muerte + un seguro de vida.

9.7 Los Seguros Mixtos o seguros dotales

Para evitar lo injusto que resulta el seguro en caso de vida en el evento de que el asegurado muera antes de la fecha estipulada en el contrato, se recurre a **los llamados seguros mixtos**. En este caso se pacta que el asegurador pagará la indemnización al asegurado, si sobrevive a una determinada fecha, o a sus herederos o beneficiarios, si muere antes de dicha fecha. En realidad, aquí estamos en presencia de dos seguros; uno en caso de vida y otro en caso de muerte; pero uno solo de ellos está llamado a producir efecto.

De esta manera se cubre tanto el riesgo de morir como el riesgo de sobrevivir. No es lo mismo que el contraseguro porque en el seguro mixto hay dos pólizas distintas, pero en el contraseguro tenemos una póliza de seguro de vida y tenemos contratado además un seguro de muerte.

El llamado **Seguro Dotal** es una variedad de seguro mixto consiste en que el asegurador, a cambio de una prima que cesa de deberse a la muerte del asegurado, promete pagar la indemnización en una determinada fecha, si a esa fecha está vivo el beneficiario designado. Por lo tanto, en esa fecha hay una doble condición: el beneficiario debe estar vivo además de que debe morir la persona sujeto del seguro.

Hay aquí un seguro en caso de vida sobre la cabeza del beneficiario y otro en caso de muerte sobre la cabeza del asegurado (con respecto a las primas devengadas entre el tiempo de su

muerte y la fecha en que debe pagarse la indemnización al beneficiario). Si el beneficiario muere antes que el asegurado, el asegurador no deberá indemnización y el asegurado perderá las primas pagadas. Esto último puede evitarse mediante un contraseguro, según ya se ha visto.

Esto se explica porque si el beneficiario no existe ya no hay interés, además de que la prima va a ser más barata.

9.8 Provocación del Siniestro y Suicidio

El siniestro causado dolosamente por el beneficiario privará a este del derecho a la prestación establecida en el contrato.

El suicidio del asegurado, salvo pacto en contrario, sólo quedará cubierto a partir del segundo año desde la celebración del contrato (ART. 598). Esto de alguna manera busca evitar que el motivo para contratar el seguro sea justamente para suicidarme y que mi beneficiario reciba la indemnización.

9.9 Inexistencia de la persona cuya vida se asegura

Así como en el seguro, en general, no pueden asegurarse las cosas que no existen, así, en el seguro de vida, no puede asegurarse la vida de personas que, al tiempo del contrato, no existían, aún cuando las partes ignoren su fallecimiento. En este caso, el seguro será inexistente si la persona está muerta al momento de contratar.

9.10 La prima en el seguro de vida

El seguro de vida ofrece la particularidad de que el asegurado sólo está obligado al pago de la primera prima. El pago de las primas siguientes es facultativo. El no pago de dichas primas implica terminación del seguro por la sola voluntad del asegurado. Sin embargo, las pólizas establecen que después de haber pagado las primas durante cierto tiempo, el asegurado puede dejar de pagarlas, con derecho a que se le restituya una parte de las primas pagadas, que corresponde a la reserva matemática.

En general las compañías aceptan pagar las primas totales luego de producido el siniestro si el siniestro es posterior al no pago de la prima.

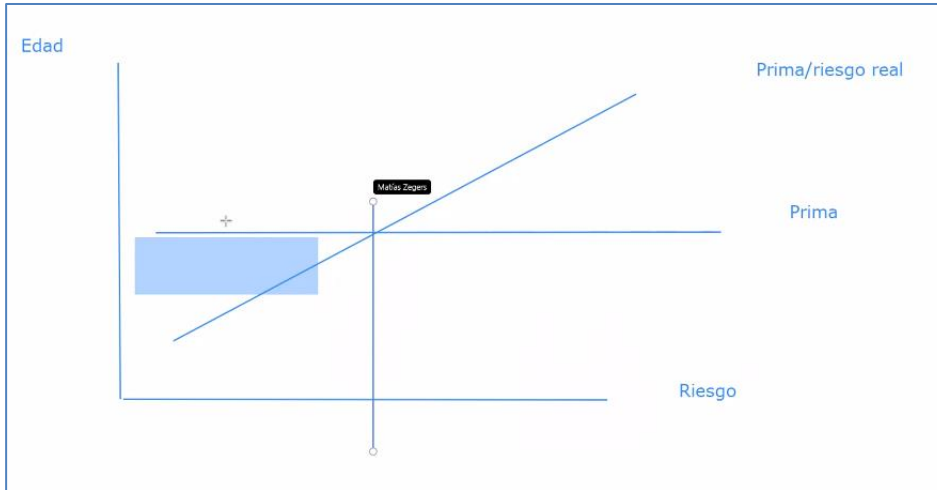
En este caso, el asegurado puede exigir la devolución de la reserva matemática, porque si termino anticipadamente el contrato, “pagué de más” (ver cuadrado celeste en el siguiente gráfico).

9.11 Derechos del asegurado en relación con la reserva matemática

La reserva matemática es el diferencial del pago de primas (como pago un promedio, al ser joven pago mucho y al ser vieja pago poco).

Conforme a las tablas de mortalidad, el riesgo de muerte aumenta con la edad. En consecuencia, el asegurador debería cobrar primas cada vez más altas durante la vigencia del seguro de vida. Esta solución, sin embargo, no es práctica ni justa porque, precisamente, a medida que el asegurado envejece, sus ingresos tienden a disminuir y, por consiguiente, el pago de primas cada vez más altas le resultaría un gravamen insoportable. ***Por este motivo, el asegurador cobra una***

prima uniforme y constante (en términos reales) durante toda la vigencia del seguro. Esta prima equivale al promedio de las diversas primas que estadísticamente debería cobrar. Esto determina que en un primer período las primas cobradas sean mayores que el precio del riesgo y que, más tarde, ocurra el fenómeno inverso. Los excesos de primas cobrados en los primeros años constituyen la reserva matemática que es una de las llamadas “reservas técnicas” (La otra reserva técnica es la de “riesgos en curso”, que deben formar las compañías del primer grupo, o sea, los aseguradores de daños. La reserva de riesgos en curso dice relación con el hecho de que no todos los seguros se contratan en una misma fecha durante el año calendario).



Con la reserva matemática se cubren los déficits de prima de los últimos años de vigencia del seguro. La reserva matemática es de propiedad del asegurador. Los asegurados no tienen, por naturaleza, derechos sobre ella, sin embargo, las pólizas acostumbran a conferir ciertos derechos a los asegurados sobre esta reserva y entre estos derechos cabe mencionar:

- El rescate

Si el asegurado deja de pagar las primas después de haberlas estado pagando durante cierto tiempo, el seguro termina, pero el asegurado tiene derecho a que se le devuelva una parte de las primas pagadas. Esta parte corresponde a la reserva matemática.

- La reducción

En la misma hipótesis anterior, el asegurado puede optar por que se le reduzca la suma asegurada, aplicándose el rescate al pago de las primas atrasadas. El asegurado, en este caso, debe continuar pagando primas, en la proporción correspondiente al nuevo monto asegurado, durante la vigencia del seguro.

- La póliza saldada.

En el mismo supuesto, el asegurado puede optar por que la suma destinada a rescate se aplique al pago de una prima única, contra la cual se le entregará una póliza saldada, esto es, un seguro totalmente pagado, pero por una suma menor.

- Avances sobre póliza (una especie de “crédito”).

El asegurador puede convenir en hacer préstamos al asegurado, con cargo a la reserva matemática. Estos préstamos devengan interés. En caso de no pago del préstamo, el asegurador queda autorizado para rescatar la póliza, o sea, para devolver al asegurado la reserva, con deducción del capital prestado e intereses, poniendo término al seguro. En caso de sobrevenir la muerte del asegurado antes de haber reembolsado el préstamo, el asegurador queda autorizado para deducir de la indemnización el saldo insoluto del préstamo e intereses. El DFL 251 contempla la posibilidad de estos préstamos, previa autorización de la CMF.

9.12. El Seguro de Desgravamen

Hoy en día se usa mucho (ej. pago de matrícula de Universidad), porque normalmente lo exigen los acreedores de obligaciones amortizables a largo plazo. En virtud de este seguro, el asegurador se compromete a pagar el saldo insoluto que se encuentre pendiente a la muerte del asegurado, de la obligación a que el seguro se refiera. El beneficiario en este seguro es siempre el acreedor. El asegurado es el deudor y el riesgo es su muerte dentro del plazo de amortización de la correspondiente obligación.

9.13. Normas tributarias

De acuerdo al Art 17 de la Ley de Impuesto a la Renta, no constituye renta las sumas percibidas por el beneficiario o asegurado en cumplimiento de seguros de vida, por tanto, no están afectas a tributos de renta.

CAPÍTULO III: Derecho concursal

1. Introducción

1.1 Generalidades

El proceso concursal busca darle solución a los problemas de la insolvencia y cesación de pago, y muchas veces la consecuencia es que se de término a la actividad mercantil que desarrolla ese comerciante, por eso esta materia siempre ha formado parte del Derecho Comercial. Todas estas normas impactan no solo en la actividad del comerciante sino en la autonomía de la voluntad y en la libertad contractual.

Hay un legítimo interés de invasión de otras áreas del derecho en esta materia porque pesar de que el DConcursal es una rama del Dcomercial, confluyen acá otras materias.

- a) Derecho Procesal, todo el tema de los concursos supone procedimientos (una especie de juicio ejecutivo colectivo) e intervención del poder judicial.
- b) Derecho Público por la injerencia de un organismo público fiscalizador. Además, el derecho concursal viene a solucionar un problema público del funcionamiento del mercado, por lo tanto aparecen funcionarios públicos (ej. veedores).
- c) Derecho Civil porque hay instituciones civiles que se afectan:
 - Las garantías (especialmente el derecho general de prenda); hay algunos cambios en la importancia de las garantías en función de un comerciante que está esta situación.

- Además, se afecta la capacidad de ejercicio de una persona.
 - Libertad contractual.
 - Prelación de créditos.
 - Eventual ineficacia de actos y contratos realizados incluso antes de la fecha del inicio del concurso.
 - Subordinación de créditos.
 - Cuando termina la liquidación se termina una obligación aunque no se haya satisfecho completamente.
- d) Derecho penal. Hay delitos asociados a una situación de insolvencia.
- e) Derecho Laboral y Seguridad Social.
- f) Materias corporativas y societarias: ¿cómo se administra una sociedad bajo un concurso?
- g) Materias de financiamiento.

Por lo tanto, el DConcursal sirve para mirar la situación del comerciante de manera genérica porque cruza distintas actividades y presupuestos normativos.

Se denomina **“quiebra” o “bancarrota”** esta situación porque en la época post medieval, en Venecia, comienza el trabajo de los primeros prestamistas legales. Los prestamistas funcionaban en las plazas (a la luz del público), e instalaban escritorios en las bancas de las plazas. Cuando a un prestamista le iba mal, venía un funcionario público y le rompía la banca para que no siguiera desarrollando su negocio (y todos lo supieran) porque se producía un efecto negativo en el mercado. *Por lo tanto, es una señal a la comunidad de que el comerciante está en desgracia.*

Como la insolvencia supone el fracaso financiero de una empresa o de una persona natural (normalmente un comerciante), tiene **socialmente una connotación de reproche**. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico y económico, no debemos asociar necesariamente la ocurrencia de una quiebra a factores negativos. Curiosamente, la quiebra tiene también **aspectos positivos** para los acreedores, pues se trata de un proceso de liquidación ordenada de los activos: el DConcursal no es castigador sino que reparador o busca dar otras oportunidades; se busca el bien no del acreedor sino del mercado general porque esto es una “enfermedad” en el mercado que se puede expandir.

Tenemos la noción de que la quiebra es algo malo, es un fracaso. Eso ha hecho que las personas que caen en esta situación sean tratados como ciudadanos de segunda clase o parias mercantiles. De hecho, en muchas actividades (ej. bancaria o seguros) en que se administran fondos de terceros, el hecho de que alguien haya quebrado lo hace inhábil para administrar esas compañías. En ese sentido, la nueva ley viene a hacer una derogación formal y cultural de la palabra quiebra, porque se **cambia la palabra quiebra por liquidación** en todo el ámbito normativo.

Además, hay elementos disuasivos, tales como sanciones especiales, para que el deudor evite la quiebra o amortigüe sus efectos.

Desde un punto de vista económico, existen ciertos hechos y presupuestos que hacen **necesaria la regulación de la quiebra**:

1º El dinero es indispensable para la empresa y el comercio, pero eventualmente puede ser fuente de graves problemas. Sirve para financiar la actividad mercantil.

2º El endeudamiento no es –como puede creerse- de suyo malo. Sirve para el desarrollo económico. Sí es negativo el endeudamiento excesivo, que impide devolver a tiempo el dinero a los acreedores.

3º Ilíquidez. Este es el gran presupuesto de la regulación de los concursos, pues la imposibilidad de dar cumplimiento a las obligaciones dinerarias es la que hace nacer la necesidad de un tratamiento ordenado de los activos y pasivos del deudor, para defender la posición igualitaria de los acreedores.

Que una empresa no tenga liquidez no significa que haya tenido pérdidas en su operación o que el negocio que realiza sea malo. Habitualmente, la iliquidez dice relación con la administración de sus flujos de caja. *La iliquidez (falta de liquidez necesaria para cumplir obligaciones) se puede producir porque el deudor:*

- Tiene muchos activos
- No vende lo suficiente
- No le pagan
- Vende a plazo

Si se prolonga este problema en el tiempo, podría derivar en una situación financieramente insostenible, que requiera la intervención estatal (sea mediante un procedimiento de reorganización o uno de liquidación de sus activos).

Capital de trabajo

Para operar, las empresas necesitan capital de trabajo (dinero que se necesita sí o sí), por ejemplo, para poder pagar los sueldos de sus trabajadores y demás gastos operacionales, pagar impuestos, suministros, arriendos, etc. Por distintas circunstancias, puede ser que la empresa no reciba oportunamente los retornos para financiarse. Razones:

- Muchos clientes no le pagan
- Concede mucho plazo
- Debe bajar precios para hacer frente a la competencia
- Malas negociaciones colectivas con los trabajadores, etc.
- Casos fortuitos (ej. pandemia, cambios tecnológicos)

Es muy habitual financiar el capital de trabajo con líneas de crédito u otras formas de financiamiento, porque este es el origen de los problemas financieros y de la iliquidez. El tema es cuando esto se prolonga en el tiempo, porque se van generando de forma imperceptible y gradual.

Los problemas financieros se van originando normalmente en forma fortuita o por simples errores comerciales. Pero, al tratar de solucionar las dificultades, el deudor normalmente comienza a incurrir en conductas reprochables.

No actúa necesariamente de mala fe, sino que el comerciante probablemente confía que al mes siguiente va a poder empezar a cumplir bien sus obligaciones entonces. Pero después el dinero que obtiene lo usa para tapar hoyos y no para producir, entonces entra en un bucle, y comienza a realizar tonteras graves e irracionales que van contra su propio interés:

- Compensaciones por deudas inexistentes
- Otorgamiento de garantías por deudas preexistentes
- Ocultamiento de bienes
- Desviación de bienes
- Simulación de contratos
- Preferencias a acreedores

Por eso entre el Estado, porque hay un peligro o riesgo de que el deudor insolvente e ilíquido comience a afectar no solo su propio entorno sino el mercado en términos generales (la economía del comerciante está ligada o vinculada con otras economías particulares). Ej. si quiebra LAN y no paga sus deudas se afectan todos sus proveedores, como el proveedor de comida.

Entonces, el Estado entra para proteger el mercado y evitar que se siga agudizando el problema, mediante el procedimiento concursal (de liquidación o de reorganización/negociación). La palabra crédito viene de la fe, entonces el impago rompe una confianza.

En tanto, el acreedor puede estar en dos posiciones:

- Negativa: si comete ilícitos, se confabula con el deudor.
- Positiva: si quiere que le paguen todo lo que le deben, o por lo menos, lo máximo posible.

Su situación varía según tenga o no garantías.

Es normal que los acreedores busquen cobrarse algún tipo de revancha como una reacción personal y no institucional. En general el acreedor toma una postura “sicológica” ante el no pago, porque se siente engañado entonces reacciona normalmente en forma emocional y poco racional. Por lo tanto, el DConcursal busca eliminar lo emocional que hace ineficiente la solución de problemas.

A esto se suma el **efecto que produce este estado en los bancos**. Ellos prestan plata entonces las colocaciones son su negocio (diferencia de tasa de lo que captan y colocan), por lo tanto el activo del banco con las cuentas por cobrar. Cuando el activo del deudor se deteriora porque baja la posibilidad de que le pague el deudor en insolvencia (“corte de pelo”: si me deben 100, voy a recuperar solo 80), el banco tiene que hacer dos cosas: 1) baja su capacidad de prestar más plata porque la ley lo obliga a tener una relación entre patrimonio efectivo y activos y 2) tiene que empezar a hacer reservas adicionales o incluso provisiones (entonces tiene menos capital y se afectan los resultados del banco).

Como se produce este efecto el banco se molesta cada vez que un activo se deteriora. El tema es que la relación entre el banco y el cliente se da a través del ejecutivo, entonces si el ejecutivo

convence al comité de riesgo prestarle plata al cliente pero al deudor le va mal, el que queda peor es el ejecutivo. Y todo esto provoca una cadena de actitudes por parte del acreedor.

Económicamente, el acreedor puede querer:

- 1º Que la empresa siga funcionando, pero en otras condiciones, para que puedan pagarse ordenadamente todos los créditos (reorganización).
- 2º Que se venda la empresa como un todo (liquidación).
- 3º Que se vendan los bienes separadamente (una especie de liquidación).

En la práctica, el acreedor no sigue esto racionalmente, sino que muchas veces sólo quiere castigar al deudor que le ha hecho incurrir en pérdidas por la falta de pago oportuno o íntegro de sus acreencias.

Por estas razones la Ley de Reorganización y Liquidación prevé varias situaciones:

- 1) Cuándo hay insolvencia
- 2) Bajo qué condiciones procede una reorganización del deudor
- 3) Cuándo procede la liquidación de los activos del deudor
- 4) Quién administra la insolvente y con qué facultades
- 5) Cómo mejorar el patrimonio del deudor (ej. bienes enajenados de mala fe)
- 6) Qué conviene más a los acreedores
- 7) La insolvencia transfronteriza
- 8) Sanciones (sobre todo penales)

Concepto de comercio y de Derecho Concursal

El DConcursal es una especie de remedio para esta enfermedad que es la insolvencia (cesación de pagos).

El llamado Derecho Concursal descansa sobre el concepto de comercio:

Comercio: *intrincado sistema circulatorio de bienes y servicios, en el cual el crédito actúa como un lubricante acelerador.*

Si un agente de este sistema entraba dicho tráfico por sobrevenirle una crisis patrimonial tal que le impida atender sus compromisos, todo el sistema se resiente, distorsionándose. El deudor:

- Dejará a otros con sus patrimonios mermados
- Entorpecerá la circulación de sus propios bienes
- En algunos casos recurrirá a expedientes fraudulentos para salvar su situación

Por ello, en toda sociedad avanzada se contemplan mecanismos para sanear la situación constituida por un patrimonio en insolvencia y para restablecer el normal funcionamiento del sistema.

*El conjunto de esos mecanismos jurídicos es el que constituye el **Derecho Concursal**.*

En nuestro sistema, la *enfermedad* que pretende erradicar el Derecho Concursal se ha denominado tradicionalmente “**cesación de pagos**”, enfermedad que puede transformarse en pandemia. Es la *base material* de todo el Derecho Concursal.

Por su parte, los **remedios** diseñados para salvar la cesación de pagos son:

- La reorganización (antes llamada “convenio”).
- La liquidación (antes llamada “quiebra”).

Por otro lado, desde siempre la insolvencia debido a culpa o dolo del deudor ha sido objeto de persecución criminal, dando lugar a los delitos concursales.

En otras palabras, el Derecho Concursal es *aquél que se constituye por un conjunto de normas jurídicas que crean, organizan y desarrollan un sistema de procedimientos –de naturaleza convencional, adjetiva y jurisdiccional– cuya finalidad genérica es la de erradicar la insolvencia de la vida de las transacciones económicas* (Prof. Carlos Concha).

Para el Prof. **Juan Esteban Puga**, es más bien el conjunto de normas jurídicas sustantivas y adjetivas, formales y materiales, que tienden a regular, reprimir y aun evitar las secuelas de la insolvencia.

1.2 Aspectos introductorios

A) Derecho Concursal

Comiéncese esbozando unas pocas palabras respecto a la noción de la rama objeto del presente estudio. El derecho concursal comprende a todas las instituciones jurídicas relacionadas con la cesación de pagos y crisis económica de un deudor. De este modo la concursalidad viene a ser el género y las demás instituciones, en particular la liquidación, la especie de un enorme material jurídico acumulado en la legislación, la doctrina y la jurisprudencia bajo la antigua denominación de “quiebra”.

Esta concursalidad propia de los procedimientos que componen esta materia implica, dice Satta, *que la consecuencia de la crisis económica de la empresa –o del deudor no calificado, agregamos nosotros-, esto es, la insatisfacción de los acreedores, sea reparada mediante una regulación de todas las relaciones, y no solamente esto, sino con una regulación igual para todas las relaciones (par conditio creditorum), salvo naturalmente las causas legítimas de prelación, es decir, que las relaciones se presenten ya al concurso como desiguales”.*

Ahora bien, existen quienes intentan señalar que el derecho concursal es una disciplina autónoma de carácter sui generis; sin embargo, ello no pareciera ser admisible: por el contrario, el derecho concursal se compone de elementos que son tomados de distintas ramas del derecho, sea público o privado, de forma que no es una disciplina autónoma. Es sólo que el elemento definitorio y aglutinador de dichas normas o principios, es una situación jurídica de facto, la cesación de pagos, que, como muchos hechos jurídicos sociales, es objeto de atención de variadas disciplinas jurídicas. Así el derecho concursal es parte integrante del derecho mercantil, aunque al contener y

afectar al derecho civil, procesal, laboral, penal, tributario, internacional y otros, se pretenda incorrectamente constituirlo en disciplina autónoma.

De tal manera, pareciera acertada la definición que Sandoval da del concepto de derecho concursal, definiéndolo como *“el conjunto de normas que regulan la cesación de pagos, velando por el tratamiento igualitario de los acreedores, por los legítimos derechos y por los intereses de la comunidad, a través de su triple contenido sustantivo, procesal y penal.”*

B) Marco Legal

Hasta la dictación de la Ley N° 20.720 sobre Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas en enero de 2014, cuyo texto comenzó a estar vigente en octubre de ese mismo año, la legislación concursal estaba comprendida en Libro IV del Código de Comercio y en la Ley N° 18.175. Hoy en día, las normas orgánicas, sustantivas y adjetivas del derecho concursal se contienen en la referida Ley N° 20.720.

Sin embargo, no puede desconocerse el hecho que diversas disposiciones diseminadas por el ordenamiento jurídico hacen referencia a los diversos concursos. Así por ejemplo, el Código Civil trata la Cesión de Bienes, la Prelación de Créditos o el efecto que produce el procedimiento concursal de liquidación en ciertos actos o contratos. Además existen otras muchas referencias normativas en un sinnúmero de leyes especiales.

C) Noción de Quiebra

La expresión “quiebra” se utiliza para referirse a los *desarreglos patrimoniales que puede experimentar una persona*. Se alude, en mayor o menor medida, a un estado patrimonial en crisis que le impide a un deudor, actual o potencialmente, cumplir con sus compromisos pecuniarios.

La noción de quiebras es equívoco por cuanto existen diversas acepciones; y para determinar su correcto sentido y alcance, es necesario adentrarse en su naturaleza jurídica. Así, podemos entenderla:

- 1) Como sinónimo de insolvencia y cesación de pagos.
- 2) Como equivalente al derecho concursal, es decir, rama del Derecho Comercial.
- 3) Como proceso o juicio de quiebras (procedimiento contenido en la Ley Concursal).
- 4) Como un estado del deudor (estado de desarreglo patrimonial que no permite que el deudor cumpla sus obligaciones).

Sin embargo, hoy en día la expresión “quiebra” se encuentra desterrada de nuestra legislación, toda vez que la Ley 20.720 la reemplazó en todos los cuerpos legales en que se hacía referencia a ella por la de “liquidación”. Lo anterior se hizo para dejar de lado su uso y su connotación negativa. Además, lo que antes se llamaba “convenios” hoy se llama “procedimiento de reorganización”.

D) Incumplimiento y Cesación de Pagos

La cesación de pagos se puede visualizar a partir de incumplimientos pero a veces se tiende a confundir el concepto de incumplimiento (particular e individual en la relación contractual/legal entre dos partes) con la cesación de pagos. El tema es que para descubrir la cesación deben haber incumplimientos, al menos como la ley lo establece.

Puede ocurrir que, en determinados casos, el incumplimiento de una obligación coincida o sea indiciario del estado de cesación de pagos; pero ello no quiere decir que sean conceptos sinónimos, por cuanto no todo incumplimiento constituye cesación de pagos y esta última puede manifestarse de formas distintas a aquella (hay otros hechos indiciarios de insolvencia).

El incumplimiento puede entenderse como *“el hecho antijurídico que afecta principalmente al acreedor insatisfecho cuando el deudor no cumple en integridad y oportunidad con la prestación adeudada.”*

Presenta, respecto de la cesación de pagos, principalmente las siguientes **diferencias**:

1. Naturaleza Jurídica: mientras el incumplimiento es un hecho o conducta concreta del deudor, la cesación de pago es un estado patrimonial o una situación que en mayor o menor medida, tiene un carácter permanente y estructural que impide que el deudor pueda pagar.

Ahora, la causa de la insolvencia no tiene por qué ser permanente sino que los efectos que esta provoca deben ser permanentes (ej. COVID probablemente se va a acabar pero el efecto en el mercado es desastroso, lo mismo con un terremoto).

¿Cuándo la cesación de pago es suficiente para la reorganización? En ese caso el estado es permanente pero eventualmente salvable: si no se hace nada el estado va a permanecer pero el remedio es el acuerdo de reorganización (salvataje mercantil).

2. Licitud: mientras el incumplimiento constituye un hecho antijurídico (no necesariamente culpable) por sí mismo, la cesación de pagos no es de suyo ilícito, salvo que sea culpable o fraudulenta.

3. Tutelas Procesales: el incumplimiento faculta al acreedor para obtener el pago compulsivamente por medio del juicio ejecutivo, al tiempo que la cesación de pagos faculta para requerir de la justicia alguno de las tutelas concursales (una para salvar la empresa y otra para liquidarla).

Ahora, si bien las tutelas concursales tienen elementos parecidos al JE, son procedimientos distintos, a saber, los concursos son colectivos y el JE es individual además de que en los concursos hay más intervinientes que el mero juez (sobre todo en la reorganización) como lo son el veedor y el liquidador.

4. Principio Rector: los procedimientos tutelares referidos al incumplimiento tienen fundamentalmente como norma rectora el principio *“prior in tempore, prior in iure”* (el que llega primero a cobrar toma la delantera); mientras que el principio rector de todos los procedimientos concursales es la *“par conditio creditorum”*, que busca que todos los acreedores que se encuentran en la misma situación se traten igual, es más, mediante acciones revocatorias pueden

anularse actos realizados antes del inicio del procedimiento para devolver la igualdad entre acreedores lo que no existe en la ejecución del incumplimiento individual.

La par conditio busca que no se prefiera artificialmente a algunos acreedores sobre otros. Ahora, esto no quiere decir que se eliminan las preferencias, sino que entre los acreedores de una misma clase todos reciben el mismo trato. De hecho, eventualmente pueden haber propuestas para las distintas clases.

5. Bien Jurídico Lesionado: en el incumplimiento el bien jurídico que se lesiona es el derecho personal del acreedor insatisfecho, pero en la cesación de pagos el bien que se ve amenazado o derechamente lesionado sería el crédito considerado colectivamente. La cesación protege el sistema mismo de pagos, es decir, la circulación del crédito.

6. Intereses Comprometidos: en el incumplimiento estaría principalmente comprometido el interés particular del acreedor insatisfecho, pero en la cesación de pago coexistirían múltiples intereses, a saber:

- **Deudor**: el será el primer interesado, por las consecuencias que esta trae en su actividad económica y situación jurídica. No quiere agravar su situación o incluso va a querer volver a empezar.
- **Acreedores**: por cuanto, cuando el deudor llega a esta crisis patrimonial, requieren de un mecanismo como la liquidación para obtener un pago equitativo –aunque sea proporcional- de sus acreencias, y así ver cumplidas sus obligaciones. Ahora, al participar colectivamente, buscan recibir lo mismo que el resto (interés de justicia e igualdad).
- **Los Terceros**: aun cuando no son directamente afectados por tal estado, en caso de declararse la liquidación del deudor como consecuencia de este estado patrimonial, podrían verse afectados por el ejercicio de las acciones revocatorias respecto de las relaciones jurídicas entabladas con el deudor.
- **Los trabajadores**.
- **Toda la Comunidad**: en virtud del fenómeno denominado concatenación de patrimonios, en caso de cesación de pagos toda la cadena crediticia es entorpecida por la interdependencia económica que existe entre los diversos agentes crediticios (ello legitima el interés que tiene la autoridad pública de intervenir frente a la constatación de dicho estado patrimonial). Ej. quiebra de empresas de carbón en Lota, en que miles de familias vivían de esa actividad de forma directa o indirecta.

Todas estas diferencias entre un mero incumplimiento y una cesación de pagos justifica que el estado entre a regular e intervenga en este último caso. Por lo tanto se afecta la libertad contractual, la capacidad jurídica, etc.

E) Insolvencia y Cesación de Pagos

Insolvencia y cesación de pagos, son conceptos distintos, constituyendo la primera la causa genérica de la situación concursal. La insolvencia es un estado económico financiero pero la cesación de pago, al menos en nuestro derecho, supone una exteriorización de la insolvencia (se

manifiesta a través de hechos comprobables señorialmente que justifican la intervención estatal y que esta no sea arbitraria).

Hay autores como Sandoval o Eyzaguirre Smart que no distinguen entre ambos conceptos, por considerarlos sinónimos, siendo que no necesariamente pueden coincidir; y es que –como dice Contreras- insolvencia y cesación de pagos, se tratan de “*conceptos y situaciones económicas y jurídicas distintas*”. De ahí que sea errada la jurisprudencia de los tribunales al señalar que “*la cesación de pago de una obligación mercantil debe obedecer a lo que civilmente se entiende por insolvencia.*”⁴ Y es que en diversas disposiciones legales se distingue entre ambos conceptos, al tratarse de situaciones o estados patrimoniales distintos. Así por ejemplo, el artículo 1496 número 1 del Código Civil distingue entre *el deudor en un procedimiento concursal de liquidación* del que *se halla en notoria insolvencia*.

La diferencia estaría, según Osvaldo Contreras, en que mientras la insolvencia sería *la situación de incapacidad, potencial o efectiva, que tiene una persona, natural o jurídica, de hacer frente a sus obligaciones*, la cesación de pagos sería *la simple incapacidad del deudor, actual y efectiva, para pagar las deudas que van venciendo*. Para nosotros, la insolvencia sería la incapacidad de pago por el estado de crisis patrimonial, mientras que la cesación de pago sería la forma como esta insolvencia se exteriorizaría en forma efectiva dentro del tráfico jurídico comercial.

Para Sandoval, la cesación de pagos sería:

- “*situación de impotencia de pagar, que en forma generalizada y permanente, afecta al patrimonio del deudor, lo que va más allá del incumplimiento efectivo de las obligaciones*”
- “*estado patrimonial crítico, generalizado y permanente que impide al deudor pagar sus obligaciones*”

La notoriedad de la insolvencia es la cesación de pago. Nuestra legislación trata la cesación de pago en las causales pero lo que está detrás es la insolvencia.

La insolvencia es un estado patrimonial en que se encuentra el deudor entonces un incumplimiento aislado no refleja un estado patrimonial potencial o actual. Pero en esto ha ido variando la ley: antes, para graficar el estado patrimonial se apelaba a una serie de condiciones o presupuestos que hacían concluir que existía este estado.

Hoy en día la base es preguntarnos cómo arreglar un estado patrimonial, en base a una situación potencial (ej. LATAM todavía tiene dinero en caja, pero se encuentra en un concurso porque a pesar de que no hay incumplimientos se prevé que eventualmente se puede alcanzar un estado de insolvencia).

La cesación de pagos es un presupuesto que genera una parte de la regulación concursal. Es un estado económico que exige una regulación específica dentro del ordenamiento jurídico, y motiva que se abran dos caminos: estructural y dinámico.

⁴ Corte de Apelaciones de Santiago, 16/07/1997; la razón de la confusión se produciría porque, mientras en el Código Civil se utiliza la expresión insolvencia, en la Ley de Quiebras se habla de cesación de pago.

1.3 Cesación de pagos

A) Generalidades

La cesación de pagos es el estado económico que demanda el nacimiento del derecho concursal como una reglamentación relativamente autónoma dentro del ordenamiento jurídico.

La cesación de pagos es el antecedente tanto *estructural* como *dinámico* del Derecho Concursal:

- Estructural: porque los concursos tienen por objeto soslayar los males de la insolvencia. Por esta vía, se pueden regular efectos para el deudor/acreedores/terceros de manera ordenada y con objetivo claro (que el deudor salga de ese estado).
- Dinámico: porque, una vez constatada, debe ponerse en movimiento alguno de los concursos alternativos.

Cuando se compra una empresa el gran problema es que ella sigue produciendo, vendiendo, asumiendo obligaciones, etc. Acá pasa lo mismo porque el deudor sigue participando en la vida del derecho: ej. LATAM podría estar en un concurso pero debe seguir actuando. No hay un deudor que se queda inmóvil, y esto genera que una vez que hay un estado de insolvencia declarado hay que ponerse en marcha para seguir administrando al deudor y que siga funcionando.

B) Bien Jurídico Protegido

La cesación de pagos irrumpe cuando el deudor aún conserva plena capacidad jurídica sobre su patrimonio, lo que constituye un fermento para que el insolvente recurra a expedientes torcidos o maquinaciones dudosas o ruinosas, a fin de mantener viva su empresa en forma artificial.

Por otra parte, en razón de lo anterior, los acreedores sufren una alteración en sus posiciones relativas frente al deudor, pues los acreedores más poderosos tendrán mejores oportunidades de tomar ventaja frente a los demás acreedores.

Además, todo este conjunto de irregularidades, tratándose de un deudor de entidad de relativa importancia en la economía, puede incidir negativamente en el funcionamiento macroeconómico, poniendo en jaque al sistema crediticio en particular y al mercado en general.

De lo anterior se deduce que los tres principales bienes resentidos por la insolvencia son:

- 1) La seguridad del crédito público.
- 2) La igualdad jurídica de los acreedores (par conditio creditorum).
- 3) El adecuado funcionamiento del mercado en general y del sistema crediticio en particular.

1.4 ¿Por qué se necesitan leyes concursales?

Para entenderlo debemos hablar de la insolvencia, y una forma de aproximarse sería por el balance de una **empresa donde si los pasivos son superiores a los activos se puede generar una situación incómoda, pero no es necesariamente insolvencia**, pues esta también atiende a temas de fecha de vencimiento de las deudas. Pues puede darse la situación de que yo tenga muchos

pasivos y pocos activos pero que los pasivos no sean exigibles al corto plazo, de tal modo se tiene tiempo para obtener activos para pagar los pasivos cuando estos vencen.

Por ello tener más pasivos que activos no es sinónimo de insolvencia y existe el concepto de cesación de pagos, que tiene que ver con el incumplimiento de obligaciones cuando estas vencen.

Pero se puede dar la situación de que una persona no pueda pagar pese a que tenga altos activos, como ocurre cuando se tiene una parte importante de activos ilíquidos (como sucede con los agricultores que solo pueden vender sus productos luego de la cosecha y por ello puede darse que ellos tengan que pagar antes de la cosecha por lo que pese a tener activos no puede pagar). Y en este caso estamos frente a una situación de iliquidez y no de insolvencia y debemos proceder a una reorganización de los activos y pasivos.

Volviendo a la pregunta podemos decir que se dan las siguientes justificaciones a la legislación concursal:

- a) Masividad de acreedores: Las relaciones son tan altas que se da una multiplicidad de acreedores que hacen necesarias normas más estrictas que las normas comunes de prelación de créditos.
- b) Concatenación de actos: Las relaciones comerciales se mueven entre comerciantes y por ende sin normas estrictas de cumplimiento de las obligaciones se puede caer el comercio de forma estructural.
- c) Protección de los acreedores y de la *par conditio creditorum*: Pues se entiende la quiebra como un juicio ejecutivo general, y de esta manera se deben ver normas especiales que permitan proteger este principio.
- d) Protección del propio deudor: Si bien nuestra legislación no ve muy bien a la persona del deudor, la nueva legislación busca darle un tinte de protección al deudor al establecer la figura del reemprendimiento.

Por ello decimos que los bien jurídicos protegidos por las normas concursales son:

- 1. Adecuado funcionamiento del mercado en general (por la concatenación de actos)
- 2. Seguridad del crédito público
- 3. Necesidad de solucionar la insolvencia
- 4. Igualdad de los acreedores.

Nuestra legislación para referirse a los desarreglos patrimoniales utiliza una multiplicidad de conceptos (insolvencia, cesación de pagos, mal estado de negocios), pero esto cambia con la nueva ley de quiebras.

1.5 ¿A quién le interesa la existencia de una legislación concursal?

- 1) A los acreedores: Pues la ley concursal persigue pagar a los acreedores, y en una liquidación los acreedores se pagan luego de un proceso de liquidación universal de los bienes del deudor

- 2) Al propio deudor: Pese a que en nuestro país se ve la quiebra de forma punitiva, al hablar del fallido, pues de no existir legislación concursal se vería expuesto a una serie de juicios ejecutivos lo cual genera un desorden. Por eso los procedimientos de liquidación permiten la extinción de las obligaciones/deudas del deudor que no fueron satisfechas luego de la liquidación. La ventaja es que permite liberar al deudor, limita el monto de sus deudas.

Es una forma de solucionar este estado patrimonial de forma ordenada.

- 3) Interés social: Desde el punto de vista del funcionamiento de la economía es eficiente que las empresas insolventes sean liquidadas para que sus activos pasen a fines más eficientes. Esto por cuanto la quiebra tiene como supuesto el fracaso financiero.

1.6 Insuficiencia del derecho común al tratar la insolvencia.

¿Por qué existen los procedimientos concursales? Esto es el analizar cuáles son las insuficiencias del derecho común al tratar la insolvencia:

Algunos podrían decir que no es necesario tener regulación especial pues, por una parte el derecho común tiene normas tanto de efectos de las obligaciones (en caso de incumplimiento de obligaciones) como de prelación de créditos.

¿Por qué el derecho común es insuficiente?

- 1) Primero por cuanto los acreedores tendrían que estar monitoreando a sus deudores de forma más rigurosa, pues cada acreedor podría iniciar juicios ejecutivos y los demás tendrían que ejercer tercerías de prelación entre otras herramientas. Por ello se requiere de un juicio ejecutivo universal donde la liquidación sea llevada de forma ordenada para que se pueda dar respeto a las normas de derecho común.
- 2) Por un tema de quienes se ven afectados por la quiebra, donde por ejemplo la quiebra de un supermercado afecta a acreedores, proveedores, trabajadores. Por ello la quiebra en su forma original solo era aplicable a los comerciantes, luego se modificó haciendo aplicable la legislación concursal a toda persona y se distinguió entre 2 tipos de deudores:
 - a) Deudores del art 41 que son quienes ejercen actividades mercantiles y otras actividades relevantes como la industrial, agrícola o minera. Y era importante el ser o no deudor del art 41 pues variaba: (1) causales de quiebra; (2) Delitos cometidos en el contexto de una quiebra; (3) Acciones Paulianas especiales.
 - b) Deudores Comunes.

La nueva ley ahora distingue en cambio entre empresas deudoras y personas deudoras. Las empresas deudoras pueden ser personas jurídicas ya sea con o sin fines de lucro, pero también puede existir empresa deudora que sea persona natural (en razón de las actividades).

En resumen, los concursos eliminan las relaciones bilaterales acreedor deudor que son inmanejables en estos casos.

1.7 Principios Formativos de la Ley N° 20.720

A) Principio de Bilateralidad de la Audiencia

La bilateralidad de la audiencia aparece como una de las tantas concreciones de la garantía constitucional del debido proceso.

La reorganización requiere siempre el consentimiento del deudor

En concreto, este principio se encuentra presente por el denominado Juicio de Oposición, el que por cierto constituye un litigio eventual o hipotético, a través del cual el demandado de Liquidación Forzosa manifiesta por escrito su voluntad de controvertir el mérito del libelo, invocando en beneficio propio una o más de las excepciones a la ejecución previstas en el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil⁵.

Naturalmente que esta opción tiene lugar con anterioridad a la Resolución de Liquidación, permitiendo una tramitación más acorde a los principios más básicos de la relación jurídico-procesal, la que además de ser expedita, favorece el pronunciamiento de la sentencia que fuere del caso en plazos más acotados, en beneficio de todos los intervinientes y del sistema en sí mismo.

Naturalmente, existen otras manifestaciones de bilateralidad y que vienen a ratificar la importancia que el mencionado principio tiene para el legislador a la hora de evaluar o estudiar modificaciones normativas incidentes en tramitaciones judiciales.

B) Principio de Inmediación

Inmediación significa que el juicio y la práctica de la prueba han de transcurrir ante la presencia directa del órgano jurisdiccional competente. Si bien es cierto que existen excepciones incluso legales a este principio (ej. la tramitación de exhortos) lo medular es que la participación personal del juez llamado a resolver el conflicto ha ido adquiriendo cada vez más relevancia.

C) Preeminencia de la Función Jurisdiccional

En principio, podemos abordar esta vertiente desde la óptica del concepto de jurisdicción, o sea, determinando la mayor o menor incidencia estatal que una legislación concursal podría consagrar.

En un primer minuto parecería que nos encontramos en un debate un tanto artificial o derechamente inútil: sería evidente que si la bancarrota como tal es un juicio, es hasta cierto punto obvio que tal litigio deba ser conocido por un órgano dotado de jurisdicción. Sin embargo, hubo efectivamente diferentes opciones a la hora de decidir ante quién se sustanciarían y resolverían los asuntos falenciales, convirtiéndose esta especificación en un elemento determinante del Proyecto de Ley, en el entendido que la normativa debía variar en la medida que el procedimiento estuviere confiado a uno u otro sentenciador.

Veamos:

⁵ El profesor cree que si se analiza la prueba por medio de la sana crítica puede eventualmente probarse que no hay un estado de insolvencia, pero efectivamente las excepciones del 464 limitan al deudor. El tema es que el juez no puede abstraerse del tipo de procedimiento (concursal): por lo tanto va a tener que considerar este elemento al momento de fallar las excepciones.

- a) Una primera aproximación defendía la radicación de las causas concursales, cualquiera fuere su formulación, en un ente administrativo o más prolijamente, íntegramente de la Administración del Estado en los términos del artículo 1° de la Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Así, el servicio público llamado a resolver este tipo de litigios o tramitaciones sería, por definición, la Superintendencia de Quiebras.
- b) Una segunda vía viene dada por la preferencia del arbitraje como sede para sustanciar la insolvencia.

Sobre el particular, parece incuestionable que la selección del arbitraje como método de resolución de conflictos ha experimentado un crecimiento sostenido, tanto a nivel nacional como internacional, máxime en lo referido de índole económica y, ciertamente, conviene que así sea.

Sin embargo, tratándose de la concursalidad, la natural conveniencia del arbitraje como método general de resolución de conflictos debe ser cuidadosamente tratada, ya que, Inicialmente, es difícil de concebir un régimen de insolvencia forzosa efectivo y eficiente si la potestad de imperio está sujeta a múltiples requerimientos. Sabemos que dicha potestad se encuentra confiada al Estado, a través de diversas formas, las que básicamente se reconducen a la instrucción u orden que emiten los Tribunales de Justicia para que el brazo de la ley ejecute en los hechos una o más medidas de apremio contra una persona y/o sus bienes.

El ámbito concursal no está ajeno a la necesidad del uso de la fuerza para garantizar su funcionalidad y, en tal sentido, es conceptualmente complejo justificar el otorgamiento o derivación de esta potestad a privados.

Se prefiere que el procedimiento lo lleve un juez y no un árbitro porque esto permite que haya auxilio de fuerza pública, facultad de imperio. Sin embargo, eventualmente puede haber arbitraje en ciertos temas.

- c) Otra visión pertinente y que manifiesta el sentir predominante de los encargados del estudio y redacción del Proyecto de Ley fue la referida a mantener la intervención de los Tribunales Ordinarios de Justicia en materias concursales.

D) Justicia Especializada

La especialización se dirige a promover que los jueces que conocen y resuelven causas civiles dentro de la judicatura ordinaria puedan recibir una completa formación, capacitación y perfeccionamiento en áreas, materias y aspectos centrales, no solamente respecto del sentido y alcance de las disposiciones de la Ley N° 20.720, sino que, además, en relación a la concursalidad propiamente tal; su evolución en el tiempo, su estado actual y las perspectivas o proyecciones sobre su porvenir.

Esta especialización sucede en comunas asientos de Corte.

En conclusión, el propósito final del principio que abordamos en esta letra es instar por una permanente voluntad de ir incorporando los desarrollos y evoluciones doctrinales nacionales e

internacionales, a efectos que los llamados a conocer y resolver la concursabilidad entreguen plenas garantías de adecuación y conocimiento de las contiendas sometidas a ellos.

E) Economía Procesal y Celeridad

Se busca evitar que el proceso se vaya dilatando lo que se verifica en las formas de notificaciones, en los plazos (fatales), etc. Además, el procedimiento de reorganización se debe realizar en 30 días (solo alargable hasta 90 días con el apoyo de acreedores).

En lo referido a la celeridad, este principio se presenta en forma diseminada a lo largo del proceso, por medio de normas impeditivas y sancionadoras a la dilación innecesaria, así como a través de mecanismos que permiten el avance del proceso con prescindencia de la actividad de las partes. El hecho trascendente e indiscutible es que una justicia tardía no es justicia.

En cuanto a la economía procesal y sin perjuicio de la gran calidad de definiciones doctrinales existentes, nos quedamos con aquella que lo orienta a conseguir los resultados del proceso (el establecimiento de la verdad como medio para lograr la realización del derecho sustancial), con el empleo del mínimo de actividad procesal, naturalmente sin violar el derecho fundamental al debido proceso, consagrado expresamente en el artículo 19 de la Constitución.

Al discutirse la ley, se consideró insoslayable ratificar e insistir en la trascendencia del principio de fatalidad de los plazos, es decir, que la preclusión para interponer las actuaciones que fueren del caso se configura con el solo vencimiento del término correspondiente, sin necesidad de validación alguna.

En el mismo orden de ideas, se incorporó un conjunto de audiencias verbales destinadas a conocer y resolver casi inmediatamente las controversias administrativas que nacieren durante la tramitación de un Procedimiento Concursal de Liquidación. En ellas, ciertamente, el empleo de recursos humanos, materiales y técnicos, así como el tiempo general asociado, debería reducirse dramáticamente.

1.8 Normativa General del Procedimiento Concursal

En Chile se “copia” un poco la legislación modelo de UNIDROIT.

A) Ámbito de Aplicación de la Ley

El esfuerzo del legislador ha pretendido satisfacer un conjunto de necesidades propias del régimen concursal. En efecto, tal como lo menciona su artículo 1°, una primera pretensión ha sido *proporcionar un sistema **global, integral**, que se **baste a sí mismo** y en donde pueda distinguirse un **tratamiento** del fenómeno falencial que organice un conocimiento accesible para toda la comunidad.*

Este objetivo se muestra aún más necesario en su consecución cuando recordamos que en una economía de mercado abierta, siempre habrá compañías que estarán en insolvencia. Es totalmente normal, inclusive en tiempos de prosperidad económica, que algunos sectores y algunas empresas tengan dificultades que se deban al entorno, pero también a la forma como han sido manejadas y cómo tienen su estructura financiera con el producto que se está desarrollando.

Son muchas las razones. El proceso lo que busca es que se le dé una oportunidad a la empresa para que pueda refinanciar el pasivo con el visto bueno de los acreedores y se conserve la fuente de pago, y en consecuencia, el empleo.

Si las personas afectadas por situaciones de insolvencia sufren, como usualmente sucede, una serie de síntomas anexos a su estado, sean legales (ejecuciones, demandas declarativas; gestiones preparatorias, etc.) o paralegales (cobranzas extrajudiciales, presiones, exigencias desmedidas, etc.), que ponen en entredicho su disposición de mantener la calma en procesos críticos, el legislador viene en ayuda del falente disponiendo medios idóneos en un texto único.

En este sentido, la orientación legal intenta situar en un **primer escalón a la Reorganización/Renegociación**, vale decir, incentivar que el ente deudor ponga en conocimiento de sus acreedores un conjunto de medidas tendientes a mitigar su estado de incumplimiento financiero generalizado, siempre sobre la base de una valoración de viabilidad empresarial que en definitiva recae en los acreedores (por medio del voto favorable o adverso a la Propuesta), pero también en el mismo proponente (aceptando o no los cambios a la oferta original según sus capacidades), el administrador concursal –fuere Veedor o Liquidador-, el tribunal (velando por la observancia de las disposiciones legales pertinentes) e incluso terceros absolutos (interesados en adquirir la empresa).

Este ideario no excluye en absoluto las **hipótesis de liquidación** o realización ordenada de activos, en el entendido que si bien existe un innegable propósito liquidatorio, es perfectamente posible y coherente con el espíritu del legislador que puedan acordarse formas eficientes que, en mayor o menor medida, puedan, si no asegurar, al menos promover el mantenimiento total o parcial de la compañía. Ahora, no es necesario que haya un procedimiento de reorganización antes.

Asimismo, la Liquidación se entiende como una consecuencia residual o de última ratio: el sistema propenderá a sugerir e instar por las fórmulas reestructurales y por ello entrega incentivos directos como el Suministro Asegurado o la Protección Financiera Concursal, en el entendido que los efectos negativos de todo procedimiento de insolvencia se pueden ver morigerados en escenarios de continuidad empresarial que derechamente liquidatorios.

Todo esto no obsta que obviamente pueda haber, antes del procedimiento propiamente tal, un **acuerdo entre el deudor y sus propios acreedores**. En algunos países hay procedimientos preliminares, pero Zegers cree que si bien en algunos casos eso puede ser exitoso, en otros solo aumenta la “agonía”, además de que en realidad van a terminar habiendo más relaciones bilaterales que generales entre todos los acreedores y el deudor.

Lo anterior no excluye la opción de ingresar a escenarios de ejecución en forma directa o inmediata, básicamente porque, en primer lugar, la primacía de la voluntad juega un rol preponderante en la primera fase del procedimiento (ej.: la Liquidación Voluntaria), o bien porque la realidad del deudor demandado de Liquidación Forzosa mostró que la presunción del sistema creada a su respectivo era verdaderamente indiciaria de una incapacidad general.

Tratándose de personas deudoras, el panorama no cambia en los principios basales y solo lo hace guardando las necesarias diferencias entre personas jurídicas y personas físicas, por un lado, y dentro de las personas físicas, distinguiendo entre aquellas que realizan actividades económicas, grosso modo, independientes, a cuenta propia o en la figura del empresario individual, de aquellas sujetas a un régimen de subordinación y dependencia o que por sus particularidades no realizan actividades productivas propiamente tales.

El legislador, en resumen, incentiva que los individuos ofrezcan a sus acreedores alternativas serias y razonadas para el tratamiento de su insolvencia, con miras a evitar los nocivos efectos de un sobreendeudamiento, pero también para promover evaluaciones crediticias más simétricas con las facultades y fuerzas patrimoniales del deudor.

B) Definiciones

La ley en su artículo 2°, nos entrega una serie de definiciones legales que buscan evitar discusiones o más bien delimitar los ámbitos de aplicación de términos dotados de varias o múltiples acepciones.

C) Objetivos del procedimiento y celeridad procesal

El objetivo final de los concursos es obtener el **mayor recupero posible**, es decir, limitar pérdidas. Además, el estado financiero del deudor produce **efectos negativos** también para sus acreedores o terceros. Por último, los procedimientos concursales son tan **complejos**, que ello también suma a que haya una necesidad de celeridad procesal.

D) Aspectos Procesales

En su artículo 3°, el legislador busca solucionar un aspecto primordial en el Derecho Concursal: la necesidad de contar con juzgadores versados en estas materias y que, además, cuenten con el imprescindible interés en conocer y resolver procedimientos asociados a insolvencias.

En la práctica, no hay tribunales especiales pero sí especializados, sobre todo en comunas asiento de corte.

Atendido el constante y manifiesto desarrollo o progreso en las diferentes formas de contratación, así como la aparición de escenarios internacionales cada vez más exigentes, se estima imprescindible una constante labor de actualización y perfeccionamiento.

d.1) Competencia

El citado artículo 3° establece que será competente para conocer los Procedimientos Concuriales contemplados en esta ley, el juzgado de letras que corresponda al domicilio del deudor, facultándose siempre al acreedor para interponer el incidente de incompetencia del tribunal, de acuerdo a las reglas generales.

Sin perjuicio de la judicatura ordinaria, el Capítulo VII de la ley regula la participación de los denominados **Árbitros Concuriales**, señalando en su artículo 295 que podrán ser sometidos a arbitraje los Procedimientos Concuriales de Reorganización y Liquidación.

- i) Tratándose de los Procedimientos de Reorganización, el deudor puede someterse a arbitraje, acompañando al tribunal competente, junto con los antecedentes singularizados en el artículo 56 de esta ley, las cartas de apoyo suscritas por acreedores que representen a lo menos la mayoría absoluta del pasivo del deudor, las cuales indicarán el nombre de los árbitros titular y suplente designados por los acreedores y sus honorarios.
- ii) Respecto del Procedimiento de Liquidación, este cambio de judicatura lo puede acordar la Junta Constitutiva referida en el artículo 193 de esta ley; también podrá acordar este cambio en cualquier Junta posterior; en ambos casos la ley exige un quórum especial. No es lo normal en procedimientos de liquidación.

En todos los casos, el nombramiento de los árbitros titular y suplente debe recaer en uno vigente de la Nómina de Árbitros Concursales. El árbitro que establece estas normas es de derecho y unipersonal y éste designará a un secretario, cargo que deberá ser ejercido por un abogado.

La competencia del árbitro se extiende a todo cuanto sea necesario para la tramitación de los Procedimientos Concursales de Reorganización o de Liquidación y a los incidentes que se promuevan durante ellos; en especial y conforme lo dispone el artículo 298, tendrá las siguientes facultades:

1) Podrá admitir, además de los medios probatorios establecidos en el Código de Procedimiento Civil, cualquier otra clase de prueba y decretar de oficio las diligencias probatorias que estime conveniente, con citación a las partes. Tendrá, además, en todo momento, acceso a los libros, documentos y medios de cualquier clase en los cuales estén contenidas las operaciones, actos y contratos del deudor, y

2) Apreciará la prueba de acuerdo con las normas de la sana crítica y deberá consignar en la respectiva resolución y los fundamentos de dicha apreciación.

d.2) Recursos

El artículo 4° contempla el régimen de recursos:

- Reposición: Según las reglas generales. Plazo de 3 días desde su notificación. Lo resuelve el tribunal sin posibilidad de que se pueda interponer un nuevo recurso, lo que demuestra la rapidez procesal.
- Apelación: Para las resoluciones que la Ley 20.720 señala expresamente. Plazo de 5 días desde su notificación. Se concede en solo efecto devolutivo (salvo excepciones que señala la Ley 20.720) y goza de preferencia para su vista.

En caso que la resolución respectiva sea susceptible de los recursos de reposición y de apelación, se debe interponer la apelación en subsidio de la reposición.

- Casación: Procede según las reglas generales.
- ¿Qué pasa con la queja? Eventualmente se podría interponer, a pesar de que la ley no lo dice porque es un recurso extraordinario de carácter disciplinario.

Como vemos, hay una gran limitación a los recursos en aras de la celeridad.

d.3) Emplazamientos o notificaciones

En cuanto al régimen de notificaciones, se contiene un par de novedades en su artículo 6°.

1) Boletín Concursal

Este Boletín es una plataforma electrónica que permite un conocimiento inmediato, fácil y expedito respecto de lo obrado por los diferentes partícipes en los procedimientos de insolvencia, constituyéndose en una fuente de consulta permanente mucho más accesible y amistosa que el Diario Oficial. Asimismo, es gratuito, aspecto especialmente conveniente tratándose de procesos vinculados a deudores sin bienes, circunstancia que indirecta pero efectivamente fomentará el mayor uso del sistema concursal nacional.

Es una especie de Estado Diario, y publicada la resolución comienzan a correr plazo para todas las partes. Ahora, normalmente además de la publicación en general se envían correos electrónicos a las partes.

2) Correos Electrónicos

La Ley 20.720 contiene varias disposiciones que señalan que una determinada resolución o medida debe notificarse por correo electrónico y ha entregado a la Superintendencia la facultad de reglamentar este tipo de notificaciones mediante norma de carácter general.

Para posibilitar este tipo de notificaciones, se exige al deudor, a los acreedores y terceros interesados que **señalen una dirección de correo electrónico** válida.

Asimismo, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento dispone que si **nuevo acreedor o un tercero interesado** efectuase alguna gestión o presentación ante la SIR, deberá indicar una dirección de correo electrónico válido, personal o de su representante legal, para efectos de su notificación (art 11, inc. 8° NGC N°3).

Estas notificaciones son válidas si se envían a la dirección señalada por el notificado, aun cuando no se encuentre vigente, esté en desuso o no permita la recepción por parte del destinatario. Todo esto se explica por la necesidad de celeridad.

Si no se puede notificar por esta vía, se permite hacerlo por medio de carta certificada, en cuyo caso la notificación se entiende efectuada al tercer día siguiente al de su recepción en la oficina de correos. En algunos casos podrán disponerse otras formas de notificación, pero a falta de determinación la ley dice que procede el correo.

Estas notificaciones se encuentran reguladas a través de la Norma de Carácter General N°3 de la SIR.

d.4) Incidentes

El artículo 5° nos entrega el tratamiento incidental, el que se encuentra reducido a aquellas materias en que la Ley 20.720 lo permita expresamente, señalando que, salvo disposición en contrario, no suspende el procedimiento concursal de que se trate.

d.5) Cómputo de Plazos

Finalmente, el artículo 7° de la ley contempla no el criterio general en materia de plazos sino el régimen único: todos los términos previstos en la ley son de días hábiles.

2. El procedimiento concursal de reorganización

También se le denomina salvataje y busca reestructurar el negocio para darle viabilidad. Es una herramienta que está en manos del deudor porque no se le puede obligar de ninguna forma a presentar la solicitud de reorganización.

2.1 Ámbito de Aplicación

El Procedimiento de Reorganización se aplica a las empresas deudoras, con el objeto que puedan proponer a sus acreedores distintas fórmulas de reestructuración, tanto de sus pasivos como de sus activos, para el pago de sus obligaciones. Los acreedores analizarán en este procedimiento si la empresa deudora es viable; es decir, si su flujo operacional permite sostener sin problemas el desarrollo normal de los negocios; su plan de gastos y eventualmente inversiones; rentabilidad y, principalmente, aquella sustentabilidad necesaria para el pago de las deudas en los términos que se acuerde.

El artículo 54 señala que **este procedimiento** se aplica a la “empresa deudora”, es decir, a *toda persona jurídica privada, con o sin fines de lucro, y toda persona natural contribuyente de primera categoría o del número 2) del artículo 42 del decreto ley N° 824⁶, del Ministerio de Hacienda, de 1974, que aprueba la Ley sobre Impuesto a la Renta, por oposición al Procedimiento de Renegociación* que se aplica SOLO a la persona deudora; *es decir a aquella persona natural, que no se encuentra en la situación antes descrita, como lo es el empleado, la dueña de casa, el estudiante, etc.* Para ellos, la ley consagra procedimientos concursales especiales que se analizan más adelante.

Esta diferenciación de procedimientos constituye una de las novedades más importantes de la Ley N° 20.720.

El Procedimiento de Reorganización establecido para la empresa deudora, responde al nuevo tratamiento sistémico de los antiguamente denominados “convenios”.

⁶ Empresario individual, que es quien tributa en primera categoría. La persona natural (no constituida como EIRL), respecto a su actividad mercantil, debe actuar como empresa y tributar como tal, además de llevar contabilidad de comerciante. En resumen, hay una ficción tributaria en virtud de la cual la persona natural por un lado tributa como tal, y por otro como comerciante como si hubiese una separación en su patrimonio.

El propósito de la nueva legislación, incluso desde el punto de vista estructural y de lectura, es hacer prevalecer el régimen de salvataje institucional por sobre el esquema liquidatorio predominante, cambiando el eje desde la extinción empresarial a la reorganización eficiente.

2.2 Inicio del Procedimiento

El procedimiento se puede iniciar en cualquier momento y no contiene requisitos de admisión; incluso durante la apertura del Procedimiento de Liquidación, el deudor puede acogerse a este procedimiento.

2.2.1 Solicitud de Reorganización

Para dar inicio a este procedimiento, el artículo 54 señala que la empresa deudora debe presentar una solicitud al tribunal competente correspondiente a su domicilio.

El modelo de solicitud está contenido en la Norma de Carácter General N°4 dictada por la Superintendencia.

Realizada esta primera presentación judicial, la empresa deudora debe requerir a la Superintendencia la nominación del veedor titular y suplente; es decir, de los *entes concursales cuya misión principal es propiciar los acuerdos entre el deudor y sus acreedores, facilitar la proposición de estos acuerdos y resguardar los intereses de los acreedores.*

2.2.2 Nominación del Veedor

A) Para la nominación del veedor, el artículo 55 señala que el deudor debe presentar a la Superintendencia, los siguientes antecedentes:

A.1) Una copia de la solicitud de reorganización, con el respectivo cargo del tribunal competente o de la Corte de Apelaciones correspondiente, en su caso, en la que puede incluirse una terna de veedores (debe tener un timbre de que se ingresó la solicitud al sistema de causas).

A.2) Un certificado emitido por un auditor independiente al deudor, inscrito en el Registro de Auditores Externos de la CMF, que se extenderá conforme a la información disponible suministrada por el deudor y debe contener:

A.2.1 Un estado de sus deudas, con expresión del nombre, domicilio y correo electrónico de los acreedores o de sus representantes legales.

A.2.2 La indicación de la naturaleza de las obligaciones contenidas en los respectivos títulos, y del monto de sus créditos; indicando el porcentaje que cada uno representa en el total del pasivo.

A.2.3 La nómina de los tres mayores acreedores, excluidas las personas relacionadas al deudor.

No es una auditoría.

B) Conforme se establece en el artículo 22, la Superintendencia debe notificar a los tres mayores acreedores del deudor, dentro del día siguiente y por el medio más expedito. Esta notificación será certificada por el ministro de fe de la Superintendencia para todos los efectos legales.

B.1) Cada acreedor debe proponer por escrito o por correo electrónico a un veedor titular y a un veedor suplente, ambos vigentes en la Nómina de Veedores, dentro del segundo día siguiente a la referida notificación.

Para estos efectos, cada acreedor será individualmente considerado sin distinción del monto de su crédito.

B.2) Al día siguiente al plazo señalado anteriormente, la Superintendencia debe nominar como veedor titular al que hubiere obtenido la primera mayoría de entre los propuestos para el cargo de titular por los acreedores, y como veedor suplente a aquel que hubiere obtenido la primera mayoría de entre los propuestos para ese cargo.

B.3) Si sólo respondiere un acreedor, se debe estar a su propuesta. Si respondieren todos o dos de ellos y la propuesta recayere en personas diversas, se estará a aquella del acreedor cuyo crédito sea superior.

B.4) En caso que no se reciban propuestas, la nominación se hace mediante sorteo ante la Superintendencia, en el que participarán aquellos veedores que integren la terna propuesta por el deudor en la solicitud de reorganización o, en su defecto, todos aquellos veedores vigentes en la nómina de veedores a esa fecha.

C) Como puede darse el caso que respecto de una empresa deudora, su pasivo se encuentre mayoritariamente concentrado en un solo acreedor y si éste representa más del 50% del pasivo del deudor, la Superintendencia nominará al veedor titular y al veedor suplente propuesto por ese acreedor. En este caso la consulta respectiva recaerá únicamente en este acreedor.

En caso que dicho acreedor no propusiere al veedor titular y al veedor suplente, la nominación se hace mediante sorteo ante la Superintendencia.

2.2.3 Notificación del Veedor. Aceptación y certificado de nominación

El veedor titular y el veedor suplente se notifican por la Superintendencia por el medio más expedito.

A) Aceptación de Cargo: Notificado el veedor titular nominado debe manifestar ante la Superintendencia si acepta el cargo a más tardar al día siguiente a su notificación y deberá jurar o prometer desempeñarlo fielmente.

Al aceptar el cargo, debe declarar sus relaciones con el deudor o con los acreedores de éste, si las tuviere, y que no tiene impedimento o inhabilidad alguna para desempeñar el cargo.

B) Excusa: El veedor puede excusarse de aceptar una nominación ante la Superintendencia, debiendo expresar fundadamente y por escrito su justificación al día siguiente de su

notificación. La Superintendencia resolverá dentro de los dos días siguientes con los antecedentes aportados por el veedor y sin ulterior recurso.

- 1) Si la excusa es desestimada, el veedor debe asumir como tal en el Procedimiento Concursal, entendiéndose legalmente aceptado el cargo desde que se resuelva y se emita el correspondiente Certificado de Nominación.
- 2) Si la excusa es aceptada, la Superintendencia debe nominar al veedor suplente como titular, nominándose a un nuevo veedor suplente mediante sorteo.

Para ser veedor él tiene que estar inscrito en un registro por eso no es normal que se acepten excusas salvo razones poderosas.

- C) Certificado de Nominación del Veedor: Aceptado el cargo, la Superintendencia debe emitir el Certificado de Nominación del Veedor, el cual debe ser remitido directamente al tribunal competente, dentro del día siguiente a su emisión, para que éste designe al veedor nominado en la Resolución de Reorganización.

Entonces, tenemos casi una semana en que solo se designa al veedor.

2.2.4 Apertura del Proceso

Extendido el certificado de nominación del veedor, le corresponde al tribunal dar curso al procedimiento de reorganización.

A) Antecedentes que debe acompañar el Deudor

Para dar curso progresivo al procedimiento, paralelamente con el envío del certificado de nominación del veedor por parte de la Superintendencia al tribunal, el deudor debe acompañar los siguientes antecedentes que se indican el artículo 56:

- 1) Relación de todos sus bienes, con expresión de su avalúo comercial, del lugar en que se encuentren y de los gravámenes que los afecten. Debe señalar, además, cuáles de estos bienes tienen la calidad de esenciales para el giro de la empresa deudora.
 - a) El avalúo comercial es muy importante, por cuanto más adelante veremos que en el caso de los acreedores que tienen sus créditos garantizados con prenda o hipotecas, el artículo 78 señala que su votación para acordar la reorganización se efectuará conforme al valor de su garantía, salvo que ésta exceda del monto de su crédito (sucede normalmente en casos de hipoteca en que el crédito se sobregarantiza), en cuyo caso se realizará hasta el monto de éste.

Por otra parte, si este acreedor garantizado no se encuentra de acuerdo con la evaluación que conforme a esta disposición presenta el deudor, puede solicitar que se rectifique este monto en el procedimiento de determinación del pasivo, que señala el artículo 70.

- b) La indicación que tanto los bienes propios o como de terceros que se indican en el numeral siguiente “tienen la calidad de esenciales para el giro de la empresa deudora” es muy relevante, porque de conformidad a lo dispuesto en el artículo 94 –en el plazo

de ocho días siguientes a la publicación de la Resolución de Reorganización que más adelante se indica— el acreedor cuyo crédito se encuentre garantizado con prenda o hipoteca puede solicitar fundadamente al tribunal competente que declare que el bien sobre el que recae su garantía no es esencial para el giro de la empresa deudora.

Para resolver lo anterior, el tribunal puede solicitar al veedor un informe que contendrá la calificación de si el bien es o no esencial para el giro de la empresa deudora y el avalúo comercial del bien sobre el que recaen las referidas garantías.

El tribunal debe resolver dicha calificación en única instancia, a más tardar el segundo día anterior a la fecha de celebración de la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre las proposiciones de Acuerdo de Reorganización Judicial.

Esto es importante porque si el bien es esencial entonces en el acuerdo de reorganización no voy a poder quitarle ese bien al deudor. Solo se va poder oponer a la esencialidad, o presentar solicitud de declaración de no esencialidad el acreedor garantizado con prenda/hipoteca.

- 2) Relación de todos aquellos bienes de terceros constituidos en garantía en favor del deudor. Debe señalar, además, cuáles de estos bienes tienen la calidad de esenciales para el giro de la empresa deudora.

Esta indicación sobre la calidad de esencial para el giro de la empresa deudora que pueda tener el bien del tercero que otorgó en garantía, es determinante por las mismas razones que se explican anteriormente.

- 3) Relación de todos aquellos bienes que se encuentren en poder del deudor en una calidad distinta a la del dueño.

Acá estamos en presencia de bienes dados en arrendamiento, leasing, comodato y en general, de los bienes se poseen a título de mera tenencia o administración. Importa, por lo tanto, proteger a los terceros dueños de estos bienes.

- 4) El certificado a que hace referencia el artículo 55, para la determinación del pasivo afecto a los Acuerdos de Reorganización Judicial.

Es un certificado que realiza un auditor independiente que contiene el estado de las deudas (instrumento privado). Esto no es una revisión de mérito de la insolvencia, sino verificación de cumplirse la condición de los pasivos. Se listan, entonces, todas las deudas y quiénes son los acreedores de cada una, además de su naturaleza, monto, etc.

El pasivo que se establezca en este certificado debe considerar el estado de deudas del deudor, con una fecha de cierre no superior a 45 días anteriores a esta presentación, con indicación expresa de los créditos que se encuentren garantizados con prenda o hipoteca y el avalúo comercial de los bienes sobre los que recaen las garantías.

Este certificado sirve de base para determinar todos los quórum de acreedores que se necesiten en la adopción de cualquier acuerdo, hasta que se confeccione la nómina de créditos reconocidos,

conforme al procedimiento establecido en el Párrafo 2 del Título I del Capítulo III de la ley; con sus respectivas ampliaciones o modificaciones, si existieren.

- 5) Si el deudor lleva contabilidad completa⁷, debe presentar el balance correspondiente a su último ejercicio y un balance provisorio que contenga la información financiera y contable, con una fecha de cierre no superior a cuarenta y cinco días anteriores a esa presentación. Si se trata de una persona jurídica, los documentos referidos deben ser firmados por sus representantes legales.

Lo que se busca es que el deudor presente un estado de su situación financiera lo más ajustada a la realidad para tomar las decisiones correctas. El plazo de 45 días en realidad es muy corto sobre todo para realizar la contabilidad de grandes empresas, por lo tanto si alguien está pensando presentar la solicitud debe preparar esta documentación con mucha anticipación.

- El objetivo final de este procedimiento es que el deudor pueda presentar una propuesta de reorganización aprobada por los deducidos que propenda a la viabilidad de la empresa. Por eso es importante que señale sus deudas/bienes, porque van a ser elementos que los acreedores van a tener que tener presentes al aceptar o rechazar la propuesta.
- Además, esto le va a servir para ordenarse y presentar una buena propuesta, respaldada por su real situación.
- Como el deudor se va a seguir endeudando, las limitaciones de endeudamiento y venta de activos se predica respecto de las deudas ya existentes.

En realidad no hay mucho incentivo para que el deudor no señale la información concreta porque por un lado hay delitos concursales pero por el otro este procedimiento está en pos de su beneficio entonces no va a mentir. Por último, es importante tener consideración también que los acreedores van interviniendo en estos casos porque están en constante contacto con el deudor, que requiere de su posterior aceptación. Por lo demás, existe un período de impugnación de los acuerdos si el presupuesto por los que se acordaron no eran correctos.

Por todo lo anterior no es conveniente que la reorganización se presente de forma abrupta. Para logar el objetivo final hay que prepararse (sobre todo en esta etapa) con mucha anticipación.

Cabe destacar que la exigencia normativa de los artículos 55 y 56 N°4 son necesarias por las siguientes consideraciones adicionales:

- (i) La norma solamente exige un certificado contable, donde se consigne el estado de las deudas de la empresa deudora, con expresión del nombre, domicilio y correo electrónico de los acreedores o de sus representantes legales y la indicación de cuáles son los tres acreedores mayoritarios, para los efectos de la nominación de los veedores titulares y suplentes.

Este certificado no es una auditoría a los estados contables del deudor y solamente se extiende “conforme a la información disponible suministrada” por éste.

⁷ Si es PJ naturalmente va a llevar esta contabilidad.

(ii) El Deudor que formule una propuesta de reorganización económica y financiera a sus acreedores, necesariamente debe contar con esta información contable para respaldar los flujos operacionales que serán los sustentos de las proposiciones de amortización de sus deudas.

Si la propuesta de reorganización consiste en una liquidación ordenada de activos, o la venta de éstos para que un nuevo operador tome el control de la Compañía, la información contable también resulta indispensable.

(iii) Cuando el citado artículo 55 señala que el certificado contable “se extenderá conforme a la información disponible suministrada por el deudor”, deja de manifiesto la obligación que pesa sobre el deudor respecto de las informaciones que tiene que entregar o brindar en los procedimientos concursales y eleva a la categoría de bien jurídico protegido la entrega de ésta con el carácter de fidedigna. En efecto, el **artículo 463 ter del Código Penal** señala:

“Será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio el deudor que realizare alguna de las siguientes conductas:

1° Si durante el procedimiento concursal de reorganización o liquidación proporcionare al veedor o liquidador, en su caso, o a sus acreedores, información o antecedentes falsos o incompletos, en términos que no reflejen la verdadera situación de su activo o pasivo.

2° Si no hubiese llevado o conservado los libros de contabilidad y sus respaldos exigidos por la ley que deben ser puestos a disposición del liquidador una vez dictada la resolución de liquidación, o si hubiese ocultado, inutilizado, destruido o falseado en términos que no reflejen la situación verdadera su activo y pasivo”.

B) **Resolución del tribunal:** Efectuada la presentación de la empresa deudora, con todos los antecedentes que exige el artículo 56, el tribunal dentro de quinto día debe dictar la primera resolución con la cual se abre el Procedimiento de Reorganización, de acuerdo a lo que se señala en el artículo 57.

En esta resolución el tribunal designa a los veedores titular y suplente nominados en la forma establecida anteriormente y con ella comienza la denominada “*Protección Financiera Concursal*”, herramienta indispensable para procurar el salvataje de la empresa deudora.

No se hace una valoración de fondo de los estados del negocio. Solo se verifica si se cumplen los requisitos formales.

En dicha resolución, el tribunal debe disponer lo siguiente:

1) Que durante el plazo de 30 días contado desde la notificación de esta resolución el deudor goza de una Protección Financiera Concursal.

La Protección Financiera se establece para que la empresa deudora pueda iniciar el proceso de negociación con sus acreedores sin que se vea expuesta a cobros ejecutivos o procedimientos compulsivos que puedan significar la pérdida de la unidad productiva.

La idea es que desde que se inicia la apertura del procedimiento de reorganización, ningún acreedor pueda beneficiarse en perjuicio de los demás, lográndose con ello una de las máximas del Derecho Concursal: la *“par conditio creditorum”* o posición de igualdad entre los acreedores frente al deudor. Asimismo, se persigue que los bienes que forman parte del activo del deudor queden protegidos durante ese período y que no puedan efectuarse cambios significativos a la estructura societaria, ni a la administración del deudor, todo ello bajo la supervigilancia del veedor.

Duración de la Protección Financiera:

La regla general es que la Protección Financiera dure el plazo de 30 días contado desde la notificación de la resolución que abre el procedimiento de reorganización. El profesor cree que es un período demasiado corto, de hecho esto se saca de la ley de quiebra de USA y ahí el período es de 180 días; lo más probable es que se haya buscado evitar abusos por parte del deudor y favorecer la celeridad procesal.

De conformidad al artículo 58, el plazo de 30 días regulado para la protección concursal que de pleno derecho se le otorga al deudor cuando se inicia el procedimiento de reorganización, puede prorrogarse.

a) Plazo de la prórroga:

- Por 30 días, si el deudor obtiene el apoyo de dos o más acreedores, que representen más del 30% del total del pasivo, excluidos los créditos de las personas relacionadas con el deudor.
- Por otros 30 días si obtiene el apoyo de dos o más acreedores que representen más del 50% del total del pasivo, excluidos los mismos acreedores antes señalados.

b) Solicitud de prórroga: La prórroga puede solicitarse hasta el décimo día anterior al vencimiento del plazo respectivo. Además, la prórroga se puede solicitar desde un comienzo hasta por 60 días si el deudor obtiene el apoyo de dos o más acreedores que representen más del 50% del total del pasivo, excluidos los mismos acreedores personas relacionadas.

Todos estos son incentivos positivos para que el deudor presente información verídica en la solicitud, para asegurar el apoyo de los acreedores. De lo contrario, si no tiene su apoyo, va a terminar en liquidación.

c) Situación de los acreedores preferentes: Los acreedores hipotecarios y prendarios que presten su apoyo para la prórroga de la Protección Financiera no pierden su preferencia y pueden impetrar las medidas conservativas que procedan. Antiguamente los acreedores preferentes nunca participaban justamente para no perder esta preferencia.

d) Situación de los cesionarios de créditos: El artículo 58 nada dice si los cesionarios de créditos adquiridos dentro de los 30 días anteriores a la fecha de inicio del procedimiento de reorganización, pueden concurrir a otorgar la prórroga de la protección financiera concursal. Recordemos que ellos no participan de la votación porque antiguamente se solían generar

acreedores nuevos amigables que pudieran apoyar el deudor, y eso se hacía por la vía de acreedores que compraban créditos a otros acreedores antes de iniciar los Convenios.

En nuestro concepto no podrían porque, sin perjuicio que son acreedores, el legislador limita el ejercicio de sus derechos en prevención a que por la vía de la cesión de créditos se manejen los quórum. Por esta razón, el inciso tercero del artículo 79 les priva su derecho a votar en los acuerdos de reorganización.

En consecuencia, al no considerarse estos acreedores en la prórroga de la Protección Financiera, sus créditos no deben computarse para el cálculo del porcentaje de apoyo que se requiere para obtenerla.

Efectos de la Protección Financiera:

Se busca que la empresa pueda seguir funcionando durante la presentación de la propuesta y con posterioridad a su aceptación.

a) No puede declararse ni iniciarse en contra del deudor un procedimiento concursal de liquidación, ni iniciarse en su contra juicios ejecutivos, ejecuciones de cualquier clase o restituciones en juicios de arrendamiento.

Lo anterior no se aplica a los juicios laborales sobre obligaciones que gocen de preferencia de primera clase, suspendiéndose en este caso sólo la ejecución y realización de bienes del deudor, salvo que se trate de juicios laborales de este tipo que el deudor tuviere en tal carácter a favor de su cónyuge, de sus parientes, o de los gerentes, administradores, apoderados con poder general de administración u otras personas que tengan injerencia en la administración de sus negocios.

Para estos efectos, se entiende por “parientes” del deudor o de sus representantes legales los ascendientes, descendientes y los colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y afinidad, inclusive.

Esto le da la tranquilidad al deudor para preocuparse solo de la reorganización y el arreglo del negocio y de nada más. Además, es una señal para los acreedores, en protección de la par conditio creditorum. En ese sentido, se incluyen los contratos de arrendamiento porque ellos son parte de la explotación del giro lo que es necesario para la viabilidad de la empresa.

b) Se suspende la tramitación de los procedimientos señalados en la letra a) precedente y los plazos de prescripción extintiva.

c) Todos los contratos suscritos por el deudor mantienen su vigencia y condiciones de pago. En consecuencia, los acreedores no pueden, invocando como causal el inicio de un procedimiento de reorganización:

- Terminarlos anticipadamente en forma unilateral
- Exigir anticipadamente su cumplimiento
- Hacer efectivas las garantías contratadas

Esto busca evitar el flujo de pagos hacia el deudor, pero también busca que se mantengan los suministros. En relación este efecto especial de la protección financiera concursal, es necesario hacer una precisión:

Cuando el citado artículo 57 N° 1 letra a) señala que los contratos no pueden terminarse anticipadamente en forma unilateral, podría pensarse que si las partes estipulan previamente que la apertura de un procedimiento de reorganización es causal de término de éste, estaría primando la voluntad de ambas partes y no de una de ellas; en consecuencia, siendo esta estipulación una ley para los contratantes, nada obstaría para poner término al contrato cuando se abre un procedimiento de esta especie, porque no se estaría actuando “unilateralmente” sino que se está dando cumplimiento a lo pactado, es decir, a la ley del contrato.

Este argumento no sería válido, porque la norma es de carácter prohibitiva, conlleva una sanción y está inserta dentro de un conjunto de normas que si bien corresponden a un estatuto de carácter privado, donde teóricamente la voluntad de las partes es soberana para determinar el alcance y sus efectos, tienen un contenido público donde prima la tutela de legislador, al igual que las normas de prelación de créditos que se establecen en los artículos 2472 y siguientes del Código Civil y otras de la misma especie, donde les está vedado a las partes alterar su mandato y menos sus efectos. En consecuencia, de pactarse una cláusula de esta naturaleza, debe entenderse por no escrita.

El crédito del acreedor que contraviene esta prohibición queda pospuesto hasta que se pague a la totalidad de los acreedores a quienes les afectare el Acuerdo de reorganización (se pierde toda preferencia), incluidos los acreedores personas relacionadas del deudor. Para hacer efectiva la postergación señalada, debe solicitarse su declaración en forma incidental ante el tribunal que conoce del procedimiento de reorganización.

¿Por qué no puedo terminar un contrato si sé que la otra parte tiene incapacidad de cumplir? ¿No es excesivamente oneroso para la parte diligente? Es más importante proteger a todos los actores del procedimiento de reorganización y asegurar que nadie pueda ponerle término a los contratos por el solo hecho de estar en estado de insolvencia/cesación. OJO que no solo dice relación con contratos de suministro.

d) Si el deudor forma parte de algún registro público como contratista o prestador de cualquier servicio, y siempre que se encuentre al día en sus obligaciones contractuales con el respectivo mandante, no puede ser eliminado ni se le puede privar de participar en procesos de licitación fundado en el inicio de un procedimiento de reorganización.

Si la entidad pública lo elimina de sus registros o discrimina su participación, fundado en la apertura de un procedimiento de reorganización, a pesar de encontrarse al día en sus obligaciones con el respectivo mandante, deberá indemnizar los perjuicios que dicha discriminación o eliminación le provoquen al deudor.

Nada dice que el deudor sea escogido, pero la idea es no prohibir a priori su participación en las licitaciones, lo que es importante para asegurar la viabilidad de la empresa (ej. constructora).

e) El deudor queda sujeto a la intervención del veedor titular designado en la misma resolución, quien queda en una posición de garante frente a los acreedores y que tiene los deberes y facultades (artículo 25):

- Imponerse de los libros, documentos y operaciones del deudor.
- Incorporar y publicar en el Boletín Concursal copia de todos los antecedentes y resoluciones que esta ley ordene.
- Realizar las inscripciones y notificaciones que disponga la resolución de reorganización.
- Realizar las labores de fiscalización y valorización que se le imponen en los artículos 71 y siguientes, referidas a la continuidad del suministro, a la venta necesaria de activos y a la obtención de nuevos recursos.
- Arbitrar las medidas necesarias en el procedimiento de determinación del pasivo establecido en los artículos 70 y 71.
- Realizar la calificación de los poderes para comparecer en las juntas de acreedores e informar al tribunal competente sobre la legalidad de éstos, cuando corresponda.
- Impetrar las medidas precautorias y de conservación de los activos del deudor que sean necesarias para resguardar los intereses de los acreedores, sin perjuicio de los acuerdos que éstos puedan adoptar.
- Dar cuenta al tribunal competente y a la Superintendencia de cualquier acto o conducta del deudor que signifique una administración negligente o dolosa de sus negocios y, con la autorización de dicho tribunal, adoptar las medidas necesarias para mantener la integridad de los activos, cuando corresponda.
- Rendir mensualmente cuenta de su actuación y de los negocios del deudor a la Superintendencia, y presentar las observaciones que le merezca la administración de aquél.
- Esta cuenta debe ser enviada, además, por correo electrónico a cada uno de los acreedores.
- Ejecutar todos los actos que le encomiende la ley.

El veedor no supone una labor de coadministración.

f) Tratándose de personas jurídicas, éstas no pueden modificar sus pactos, estatutos sociales o régimen de poderes.

Esta medida de restricción obedece a la necesidad de mantener las estructuras sociales intactas, para evitar que por la vía de cualquier reforma (divisiones, fusiones por creación o absorción,

disminuciones de capital o emisiones de acciones preferentes, etc.) se disminuya el patrimonio de la compañía.

Para hacer más efectiva la cautela que la ley impone durante la tramitación del Procedimiento de reorganización, el artículo 57, N° 2) letra c) agrega que la inscripción de cualquier transferencia de acciones de la empresa deudora en los registros sociales pertinentes requerirá la autorización del veedor, que la extenderá en la medida que ella no altere o afecte los derechos de los acreedores.

Lo anterior no rige respecto de las sociedades anónimas abiertas que hagan oferta pública de sus valores.

¿Por qué esto es relevante? A pesar de que algunas modificaciones pueden ser más beneficiosas para los acreedores (ej. fusión con una empresa con muchos activos), la idea es mantener la empresa deudora y el patrimonio sujeto a reorganización. Si hay una modificación que sea beneficiosa, eso podrá proponerse en el acuerdo de reorganización.

Se trata de que sea una especie de “congelamiento” de la estructura societaria a nivel de propiedad y a nivel de administración. De hecho solo se pueden transferir acciones si el veedor lo permite, salvo el caso de las SA abiertas que cotizan en bolsa.

Muchas veces se convierte deuda en capital en procesos de reorganización (acciones), como en el caso de LAN. Pero esto lo voy a hacer solo si dicha conversión le conviene a la empresa porque le va a rendir.

g) Continuidad del Suministro, Venta de Activos y Nuevos Recursos durante la Protección Financiera Concursal

La empresa deudora necesita seguir desarrollando su giro para generar flujos.

g.1) Continuidad del suministro o “abastecimiento asegurado”

Una empresa sin abastecimiento es poco lo que puede ofrecer; aunque logre el mejor acuerdo de pago con sus acreedores; si no tiene flujos, el convenio está destinado al fracaso.

La ley tiene entre sus objetivos establecer las herramientas que sean **necesarias** para que empresas viables puedan reorganizar sus activos y pasivos con el concurso de sus acreedores; en consecuencia, es fundamental lograr una regulación normativa para abordar el tema del abastecimiento durante el período de presentación, discusión y aprobación de las propuestas de reorganización que la empresa deudora hace a sus acreedores.

El artículo 72 permite el **pago preferente** de las facturas por suministros de bienes o servicios (por el hecho de suministrar, se le paga inmediatamente), bajo ciertas condiciones:

- Debe tratarse de proveedores de bienes y servicios que sean necesarios para el funcionamiento de la empresa deudora.
- La fecha de emisión de las facturas debe ser no menos de ocho días anteriores a la fecha de la resolución de reorganización. Esto porque las facturas se objetan en 8 días.

La factura y la boleta son documentos tributarios que acreditan la venta de un bien o servicio.

- El monto total de la facturación que quedará sujeta a este régimen de pago especial, no puede superar el 20% del pasivo señalado en la certificación contable referida en el artículo 55.
- El proveedor debe mantener el suministro de bienes o servicios a la empresa deudora similar al que se otorgaba hasta antes de la apertura del procedimiento de reorganización

Es decir, no se trata de pagar facturas morosas o que éstas reciban un pago preferente porque el proveedor circunstancial o deliberadamente reanuda la prestación de los servicios o la entrega de mercaderías.

g.2) Operaciones de comercio exterior

Si a una compañía se le priva el financiamiento de sus operaciones de comercio exterior, o bien, no se le endosan las cartas de crédito para proceder a desaduanar las mercaderías importadas, se produce el mismo problema de la falta de abastecimiento que es letal, por cuanto afecta al flujo operacional que es necesario para afrontar las obligaciones acordadas con los acreedores en el convenio; si el abastecimiento de bienes y servicio se paraliza, no hay nada que ofrecer a los acreedores en una propuesta de reorganización que comprenda la continuidad del giro para el pago de los créditos.

Con el propósito de enmendar esto, el artículo 73 establece que quienes financien operaciones de comercio exterior de la empresa deudora se pagarán preferentemente en las fechas originalmente convenidas, siempre que:

- Mantengan las líneas de financiamiento, u
- Otorguen nuevos créditos para este tipo de operaciones.

De esta forma, recibirán en términos preferentes y como pago de obligaciones del giro, el importe de los financiamientos antes otorgados.

g.3) Venta de activos

Como muchas veces es necesario realizar ventas de activos inmovilizados (ej. bien raíz que no estoy usando), en especial si se trata de activos que no participan en la fase de producción o comercialización de la empresa deudora, el artículo 74 autoriza este tipo de ventas durante la protección financiera concursal, siempre que:

- El valor de los bienes a liquidar no superen 20% de su activo fijo contable.
- El producto de la venta ingrese efectivamente a la caja de la empresa deudora (artículo 76).
- El producto de la venta se destine única y exclusivamente a financiar su giro.

La limitación del 20% es para asegurar que igual queden activos para después, pero la idea es también fortalecer el giro para ir generando flujo.

Esta operación de venta tiene que ser visada por el veedor, quien debe valorizar los bienes destinados a la venta o enajenación y, por cierto, deberá acreditar el ingreso y destino operacional de los fondos antes señalados.

La venta o enajenación de bienes que excedan los montos antes señalados y la venta que se haga a de estos activos a personas relacionadas con la empresa deudora, requiere la autorización de los acreedores que representen más del 50% del pasivo del deudor.

Si estos activos garantizan créditos, voy a tener que cumplir las condiciones de la garantía entonces lo más probable es que no los toque.

g.4) Créditos operacionales

Con el propósito de potenciar la entrega de recursos frescos que muchas veces son indispensables para financiar el giro operacional las empresas deudoras que inician sus reestructuraciones dentro del proceso de reorganización, el artículo 74 establece que durante la protección financiera concursal, se pueden adquirir préstamos con tal objetivo, siempre que éstos no superen el 20% de su pasivo señalado en la certificación contable referida en el artículo 55.

Si los préstamos exceden del monto antes señalado, o bien, si estos recursos provienen de personas relacionadas con la empresa deudora, se requiere la autorización de los acreedores que representen más del 50% del pasivo del deudor.

Efectos:

Los préstamos contratados por la empresa deudora en virtud de este artículo no se consideran en las nóminas de créditos y se pagan preferentemente en las fechas convenidas, siempre que se utilicen para el financiamiento de sus operaciones, circunstancia que debe acreditar el veedor.

Los créditos nuevos son solo un pasivo operacional con preferencia en el pago pero no participan del acuerdo de reorganización.

2) La fecha en que expira la Protección Financiera.

Esta indicación es relevante porque se establece con claridad los siguientes hechos o actuaciones jurídicas:

- i) El plazo a partir del cual los acreedores recobran su derecho para deducir las acciones en contra del deudor, o bien continuar los procedimientos que fueron suspendidos;
- ii) La fecha de la junta de acreedores llamada a pronunciarse sobre las proposiciones de reorganización, fecha que sin perjuicio de establecerse en el numeral 5) del citado artículo 57, coincide con el término de la protección financiera concursal,
- iii) El plazo que tiene el deudor para requerir las ampliaciones del período de protección concursal que se regulan en los artículos 58 y 59, y

- iv) La determinación de un nuevo período de protección financiera, cuando el deudor formule una nueva propuesta de reorganización, en los términos que regula el artículo 88.

Si termina la PFC hay un juego más libre respecto de los acreedores en relación al patrimonio del deudor.

- 3) La orden al deudor para que a través del veedor publique en el Boletín Concursal y acompañe al tribunal competente, a lo menos 10 días antes de la fecha fijada para la junta de acreedores, su propuesta de Acuerdo de reorganización.

Esto busca que los acreedores lleguen informados a la junta.

Si el deudor no da cumplimiento a esta orden, el veedor debe certificar esta circunstancia y el tribunal competente debe dictar la resolución de liquidación, sin más trámite. Con ello, se inicia un procedimiento de liquidación concursal.

Esta orden impone la obligación a deudor para que de curso progresivo al procedimiento de reorganización; para estos efectos debe hacer entrega formal al veedor de su propuesta de Acuerdo de reorganización, con la anticipación necesaria para que éste la presente al tribunal y la publique en el Boletín Concursal.

Este trámite es esencial, por cuanto desde que se notifica la resolución de apertura que estamos analizando, el procedimiento no puede paralizarse.

Una vez que se ha otorgado de pleno derecho la protección financiera concursal con todos los efectos jurídicos que hemos analizado, el deudor no puede dilatar este procedimiento mediante el expediente de no presentar su propuesta de reorganización; si no lo hace, se presume que utilizó este procedimiento para obtener ventajas indebidas.

En consecuencia, certificado por el veedor la circunstancia de no haber dado cumplimiento a esta orden, el tribunal sin más trámite tiene que dictar la resolución de liquidación.

- 4) La fecha, lugar y hora en que debe efectuarse la junta de acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo de reorganización que presente el deudor.

La fecha de dicha Junta será aquella en la que expire la Protección Financiera (eventualmente se puede celebrar la junta dentro de la PCF). Es el momento en que los acreedores ejercen sus derechos aprobando o rechazando. En caso de rechazo, inicia la liquidación.

- a) Importancia:

a.1 Establece el momento procesal donde los acreedores ejercerán sus derechos en junta, ya sean aprobando o rechazando la propuesta de reorganización del deudor.

a.2 Marca el término de la protección financiera concursal y sus efectos, de modo que si los acreedores no acuerdan la reorganización, se producirá la liquidación del deudor, debiendo el

tribunal dictar de oficio y sin más trámite la resolución respectiva, salvo que la referida junta disponga lo contrario por quórum especial.

b) Suspensión:

La junta de acreedores puede acordar con quórum calificado, su suspensión por no más 10 días, fijando al efecto nuevo día y hora para su reanudación; en este caso, el deudor conserva la Protección Financiera hasta la celebración de dicha junta.

c) Comparecencia del Deudor:

Si el deudor no comparece a la junta de acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de acuerdo, el tribunal competente debe dictar la resolución de liquidación en la misma junta.

- 5) Que dentro de 15 días contados desde la notificación de la resolución, todos los acreedores deben acreditar ante el tribunal competente su personería para actuar en el procedimiento de reorganización, con indicación expresa de la facultad que le confieren a sus apoderados para conocer, modificar y aceptar el Acuerdo.

Esta mención de la resolución impone una obligación a los acreedores de acreditar ante el tribunal competente su personería. El poder debe otorgarse con expresa indicación que se confieren al apoderado las facultades de ***“conocer, modificar y adoptar el Acuerdo de Reorganización Judicial”***.

De lo contrario, este acuerdo podría impugnarse por la causal que señala el N° 3

Esta personería y el poder conferido deben ser analizadas por el veedor, para emitir su informe de calificación de poderes.

Esta exigencia hay que relacionarla con el artículo 78, que tienen derecho a concurrir y votar en las juntas de acreedores aquellos acreedores cuyos créditos se encuentren en la nómina de créditos reconocidos para lo cual debe darse cumplimiento a lo ordenado en el número 6) del artículo 57, relativo a la acreditación de personerías.

a) Nómina de Acreedores:

De acuerdo a lo previsto en el inciso final del citado artículo 70, el veedor debe confeccionar esta nómina, señalando:

- El monto de los créditos.
- Si se encuentran garantizados con prenda o hipoteca. Esto para determinar su derecho a voto que va a depender del valor de la garantía pero si el valor comercial sobrepasa el del crédito se estará al valor de este.
- El avalúo comercial de los bienes sobre los que recaen las garantías.

Esta nómina se confecciona sobre la base de:

i) Los créditos que figuran en el estado de deudas del deudor a que se refiere el número 4) del artículo 56, y

ii) Los créditos que debieron verificar los acreedores que no están de acuerdo con lo señalado en el estado de deudas antes referido y, en ambos casos, que no hayan sido impugnados (esto se denomina verificación de créditos). El acreedor tiene que asumir una actitud activa al verificar el crédito cuando presenta la personería.

Puede que lo que está en el listado del artículo 56 no corresponda a lo que diga el acreedor (ej. una deuda generó intereses porque hubo incumplimiento).

(iii) Adicionalmente, se requiere que los acreedores hayan dado cumplimiento a la obligación de haber acreditado su personería. Si no cumple con acreditar su personería, pierde derecho a voto en la junta.

b) Incumplimiento del Acreedor

Si el acreedor no da cumplimiento a su obligación de acreditar su personería ante el tribunal dentro del lapso antes señalado, su derecho a votar precluye, aunque su crédito figure en el certificado contable emitido por el auditor.

Consecuencialmente, la nómina de créditos reconocidos y su ampliación, que el veedor tiene que confeccionar y presentar al tribunal, no puede comprender a estos acreedores, porque la disposición del citado artículo 71, establece que para ejercer su derecho a voto debe haber dado cumplimiento “a lo ordenado en el número 6) del artículo 57, relativo a la acreditación de personerías”.

Al no formar parte estos acreedores de la nómina con derecho a voto, necesariamente el monto de sus créditos se debe deducir del pasivo, al momento de calcular el quórum que fija el inciso segundo del artículo 79, para acordar la propuesta de reorganización. Sin perjuicio de lo anterior, los acreedores excluidos para votar nunca pierden sus derechos y los efectos del acuerdo de reorganización, les son aplicables conforme lo dispone el artículo 91 (siempre que estén dentro de la nómina de acreedores lógicamente).

Ej. si se conviene que se van a pagar todos los créditos en 24 meses con 15% de descuento, eso le afecta al acreedor que no presenta poderes/verifica sus créditos.

6) La orden para el veedor inscriba copia de esta resolución en los conservadores de bienes raíces correspondientes al margen de la inscripción de propiedad de cada uno de los inmuebles que pertenecen al deudor.

Esta instrucción que es de carácter tutelar y que tiene por objeto la protección del derecho de garantía general de los acreedores frente al deudor, se enmarca dentro de la normativa de equilibrio frente al concurso que debe existir entre deudores y acreedores.

El artículo 57 en su numeral 2° letra b) señala que el deudor no puede gravar o enajenar sus bienes, salvo aquellos cuya enajenación o venta sea propia de su giro o que resulten estrictamente necesarios para el normal desenvolvimiento de su actividad (pero como ya vimos, los bienes no

tienen que ser esenciales, no superar 20% del activo fijo disponible, y el activo debe entrar a la caja de la empresa deudora para financiar sus operaciones).

Entonces, la inscripción es meramente una medida de publicidad pero no obsta que en ciertos casos sí voy a poder gravar o enajenar los bienes si se cumple con los requisitos que hemos ya estudiado.

En consecuencia, para mantener la integridad del patrimonio de la empresa deudora, se establece esta inscripción por vía de publicidad e inoponibilidad, para que los terceros conozcan la situación del deudor, siéndoles oponible este procedimiento frente a cualquier iniciativa de adquisición de bienes raíces del deudor. En resumen, se efectúa esta inscripción en el CBR para que los terceros sepan que esos bienes son objeto de un procedimiento de reorganización.

Todo lo anterior, es sin perjuicio de la facultad que el artículo 74 le confiere a éste para vender o enajenar activos cuyo valor no exceda el 20% de su activo fijo contable, conforme a la valorización que al efecto realice el veedor.

- 7) La orden al veedor para que acompañe al tribunal competente y publique en el Boletín Concursal su informe sobre la propuesta de Acuerdo de reorganización, a lo menos 3 días antes de la fecha fijada para la celebración de la junta de acreedores que votará dicho acuerdo.

Esta orden que se imparte al veedor dice relación con la necesaria y completa información que deben tener los acreedores para conocer y pronunciarse sobre la propuesta de reorganización que formule el deudor.

Se trata de un informe que debe emitir el veedor sobre la base de la totalidad de los antecedentes que por ley le debe proporcionar el deudor, basándose además en el análisis de la empresa deudora que ha realizado durante su intervención.

La ley le requiere en este informe al veedor un triple análisis para entregar a los acreedores una opinión objetiva. Recordemos que el artículo 25 establece como su misión principal:

- Propiciar los acuerdos entre el deudor y sus acreedores. Esto se facilita mientras más información se tenga.
- Facilitar la proposición de estos acuerdos.
- Resguardar los intereses de los acreedores y la par conditio creditorum.

a) Contenido del Informe:

Este informe del veedor debe contener la calificación fundada acerca de:

a.1 Si la propuesta es susceptible de ser cumplida, habida consideración de las condiciones del deudor.

a.2 El monto probable de recuperación que le correspondería a cada acreedor en sus respectivas categorías, en caso de un procedimiento de liquidación (cuánto obtendrían de su crédito en ese caso, lo que es importante para la decisión que van a tomar los acreedores).

a.3 Si la propuesta de determinación de los créditos y su preferencia indicada por el deudor se ajustan a la ley.

b) Incumplimiento del Veedor:

Si el veedor no presenta el informe dentro del plazo indicado, el deudor, cualquiera de los acreedores o el tribunal competente informará a la Superintendencia para que se apliquen las sanciones pertinentes.

En este caso, el Acuerdo se vota con prescindencia del informe, por lo tanto no se paraliza el procedimiento.

- 8) Que dentro de quinto día de efectuada la notificación de la resolución, deben asistir a una audiencia el deudor y los tres mayores acreedores indicados en la certificación del contador auditor independiente referida en el artículo 55.

Esta diligencia se efectúa con los que concurran y trata sobre la **proposición de honorarios** que formule el veedor. Si en ella no se arriba a acuerdo sobre el monto de los honorarios y su forma de pago, o no asiste ninguno de los citados, dichos honorarios se fijarán por el tribunal competente sin ulterior recurso.

Esta propuesta debe ser analizada en la audiencia por los 3 mayores acreedores y se efectúa con los que concurran.

Aunque la ley no fija un quórum especial para adoptar el acuerdo, debemos entender que éste es de quórum simple tomado sobre la suma de los créditos de los acreedores que efectivamente asistan a esta audiencia. Si no se llega a acuerdo, el tribunal fija los honorarios.

Los honorarios son parte de los gastos propios del acuerdo con cargo al deudor.

- 9) La orden al deudor para que proporcione al veedor copia de todos los antecedentes acompañados conforme al artículo 56.

Estos antecedentes y la copia de la resolución deben ser publicados por el veedor en el Boletín Concursal dentro del plazo de 3 días contado desde su dictación.

2.3 Objeto de la Propuesta de Acuerdo de Reorganización

El objeto de la propuesta dice relación con las *distintas formas de reorganización tanto de los pasivos como de los activos que puede presentar la empresa deudora, con el objeto de obtener de sus acreedores el consentimiento necesario para modificar su actual situación de endeudamiento que afecta el normal desarrollo de sus operaciones.*

2.3.1 Objeto de la Propuesta

El artículo 60 señala que la propuesta puede versar sobre **cualquier objeto tendiente a reestructurar los pasivos y activos de una empresa deudora.**

Depende de la creatividad del deudor y los acreedores. Así, por ejemplo, se puede proponer:

- 1) Una continuación total o parcial del giro de las actividades económicas de la empresa para el pago del pasivo, sobre la base del establecimiento o no de un periodo de gracia para el servicio del capital, que pueda comprender o no el pago de intereses durante este plazo. Ej. pagar los créditos a 3 años en un plazo de 6 meses para poder generar caja.
- 2) Un calendario de amortización periódica para el pago del capital y los intereses, por el plazo que sea necesario para mantener la viabilidad de la empresa y con ello asegurar que las obligaciones de pago se cumplan íntegramente.
- 3) Una deducción o no de una parte del capital/intereses por vía de remisión o condonación aceptada por los acreedores, que en este caso podrán acceder al beneficio tributario que se señala más adelante (esto es una novedad de la ley que antes no existía, porque incluso había multa en caso de condonación o remisión, por ser gasto rechazado).
- 4) Cambios en las tasas de intereses originalmente pactadas.

En el ámbito de la reestructuración de activos, el acuerdo de pago puede comprender además formas de ventas de activos prescindibles, o bien la venta ordenada de éstos para que el producto de la liquidación se destine al pago de los créditos.

Las formas de reorganización no se agotan en las modalidades de reestructuración de pasivos y activos antes señalada; en efecto, si el citado artículo 60 habla de "*cualquier objeto*", debemos entender que queda abierta a la empresa deudora, formular propuestas no contrarias a la ley que tiendan a la extinción total o parcial de sus obligaciones.

Normalmente estas propuestas ya tienen una conversación previa con los acreedores, para asegurar que sea un acuerdo que eventualmente pueda ser aprobado.

2.3.2 Propuestas Diferenciadas

A) Diferencias entre clases o categorías de acreedores: preferentes o valistas

El artículo 61 señala que la propuesta de Acuerdo puede separarse en clases o categorías de acreedores y que se puede formular una propuesta para los acreedores valistas y otra para los acreedores hipotecarios y prendarios cuyos créditos se encuentren garantizados con bienes de propiedad del deudor o de terceros.

Esta norma señala que los acreedores hipotecarios y prendarios que voten la propuesta del Acuerdo conservan sus preferencias (antes si se votaba en el acuerdo se perdía la preferencia, lo que los incentiva a participar). De esta forma, la reorganización de la empresa deudora se logrará sobre la base de un universo mayor de acreedores, quienes conocerán perfectamente cuál será el tipo de acuerdo que se le propone a los acreedores de distintas clases o categorías.

Además, el inciso final del artículo 79 establece que el acuerdo sobre la propuesta de una clase o categoría se debe adoptar bajo la condición suspensiva de que se acuerde la propuesta de la otra clase o categoría en la misma junta de acreedores. De esta manera, la propuesta de reorganización que se formulen a los acreedores, solo se puede acordar si se logra el acuerdo en ambas clases o categorías de éstos.

La norma del artículo 61 no exige que las propuestas de reorganización que se formulen a los acreedores valistas y a los acreedores hipotecarios y prendarios sean similares, porque la composición de estos créditos generalmente es distinta. Normalmente, los créditos garantizados tienen plazos más extensos para el servicio de la deuda que los créditos valistas, siendo también diferentes los períodos de amortización y las tasas de intereses asociadas a estos créditos. En consecuencia, lo normal será que la propuesta de reorganización que se ofrezca sea distinta.

Con todo, la propuesta de reorganización debe ser **igualitaria para todos los acreedores de una misma clase o categoría**, salvo que medie acuerdo en contrario.

El inciso tercero del artículo 61 señala que los acreedores hipotecarios y prendarios cuyos créditos se encuentren garantizados con bienes de propiedad del deudor o de terceros, pueden votar la propuesta de acuerdo que se formule para acreedores valistas, si renuncian a la preferencia de sus créditos.

Efectos: Si los acreedores hipotecarios y prendarios optan por esta modalidad para formular su voto:

- a) No pueden votar en la propuesta de acuerdo que se formule para la clase o categoría de los acreedores hipotecarios o prendarios, salvo que dicha renuncia sea parcial y se manifieste expresamente.
- b) Los montos de los créditos de estos acreedores preferentes se descuentan del pasivo de su clase o categoría y se incluyen en el pasivo de la clase o categoría de los acreedores valistas, para los efectos de determinar el quórum de aprobación del acuerdo de reorganización.

B) Diferencias entre acreedores de igual clase o categoría

Cuando resulte necesario establecer propuestas diferentes para algunos acreedores que tienen características especiales, es posible acordar condiciones más favorables para alguno de ellos.

El artículo 64 establece que estos acuerdos se pueden tomar para los acreedores de una misma clase o categoría, siempre que los demás acreedores de la respectiva clase o categoría lo acuerden con quórum especial (2/3 del pasivo total con derecho a voto), el cual se calculará únicamente sobre el monto de los créditos de estos últimos.

Es decir, para adoptar el acuerdo respectivo, se excluye de la votación al acreedor que se beneficiará y su crédito no se computa en el monto del pasivo para el cálculo del quórum especial.

Esto podría suceder, por ejemplo, en casos de proyect finance en que hay un gran acreedor.

2.3.3 Propuestas alternativas

El acuerdo de reorganización que se proponga, puede contener distintas alternativas para cada clase o categorías de acreedores.

El artículo 62 regula esta modalidad, señalando que cuando se formulen y aprueben propuestas alternativas, el acreedor debe optar por regirse por alguna de ellas, dentro de los 10 días

siguientes a la fecha de la junta de acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo.

Esta norma no señala la forma en qué se debe expresar la voluntad del acreedor. Sin embargo, lo propio es que esta voluntad deba manifestarse en forma clara y expresa ante el mismo tribunal que conoció la propuesta de reorganización, mediante una presentación que se debe agregar al expediente respectivo y, al término del plazo señalado para ejercer la opción, el veedor debe publicar en el Boletín Concursal el ejercicio de las opciones formuladas por los acreedores.

Tampoco la norma regula el silencio de los acreedores frente a las propuestas alternativas. Sin embargo, como se habla de una propuesta principal y una o varias alternativas, debe entenderse que el acreedor que no manifiesta dentro de plazo su opción (acepta pero no dice qué propuesta acepta), prefiere la propuesta principal.

Cada clase vota el acuerdo o las alternativas de acuerdo que les son aplicable. Pero en caso de aprobarse el acuerdo, hay que tener certeza de quién elige qué alternativa (cada uno elige lo que más le conviene).

Hasta ahora, ¿cómo es la línea de tiempo? Primero el tribunal dicta la resolución de reorganización y hay 30 días de PFC.

- Si asumimos que la junta de acreedores se celebra el último día del plazo, a lo menos 10 días antes el deudor tiene que haber hecho la propuesta de reorganización.
- En los primeros 15 días debieron los acreedores haber verificado su crédito.
- En los primeros 3 días se fijan los honorarios.
- 10 días antes de la fecha de la junta el veedor tiene que haber emitido su opinión.
- Finalmente, en la junta se vota y decide y empiezan a correr los efectos del acuerdo.

2.3.4 Constitución de garantías

La constitución de garantías para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que asume la empresa deudora.

Bienes que no estaban antes dados en garantía, se constituyen en garantía frente a ciertos acreedores respecto de, por ejemplo, obligaciones que se asumen durante el concurso (ej. Caso LAN y deep financing en el tranch A y B).

¿Esto no afecta el par conditio creditorum? Si no se pudieran dar garantías a quienes aportan capital fresco, va a ser difícil que alguien se arriesgue a prestar dinero a la empresa deudora.

Pueden establecerse:

- a) En el mismo Acuerdo de reorganización.
- b) En instrumento separado. Esto hace más fácil alzar la garantía.

Lo normal es que se estipule en el acuerdo la constitución de garantías y se fije la forma y plazo para constituir las, pudiéndose designar al efecto uno o más acreedores para que en representación de los demás concurren a la celebración de acto jurídico (eventualmente también

puede ser el veedor), conjuntamente con el o los garantes, todo ello según lo dispone el artículo 65.

Las garantías que se constituyan, dejan de tener valor si se produce la declaración de nulidad del Acuerdo, porque todas las estipulaciones de éste quedan sin efecto cuando se acoge esta acción especial, que únicamente debe estar fundada en la ocultación o exageración del activo o del pasivo que se tomó conocimiento, después de haber vencido el plazo establecido en el artículo 86 para impugnar el acuerdo.

Declarada la nulidad del acuerdo por sentencia ejecutoriada, se produce la liquidación de la empresa deudora (ha habido fraude) y no obstante que el artículo 99 señala que la declaración de nulidad o incumplimiento del Acuerdo no tiene efecto retroactivo y no afecta la validez de los actos o contratos debidamente celebrados en el *tiempo que media* entre la resolución que aprueba el Acuerdo y la que declare la nulidad o el incumplimiento (tiempo de vigencia del acuerdo), las garantías otorgadas para asegurar el *cumplimiento del acuerdo* y que normalmente se constituyen con posterioridad a su aprobación, se extinguen de pleno derecho según lo señala el inciso segundo del artículo 97.

Entonces los acuerdos que se van celebrando durante la vigencia del acuerdo de reorganización tienen un tratamiento distinto a las garantías que buscan asegurar el acuerdo mismo. Este tipo de actos/contratos que se van celebrando durante la vigencia del acuerdo, aunque se den en un contexto de reorganización, no tienen su causa directa en el acuerdo como sí lo tiene el otorgamiento de la garantía. Ej. LAN busca dinero fuera del acuerdo de reorganización: en ese caso, vamos a estar ante un crédito subordinado. Si se pide la nulidad del acuerdo, en ese caso procedemos a la liquidación, pero el acreedor que prestó el dinero no puede alegar que su crédito queda sin efecto porque fue en un acto posterior al acuerdo.

2.3.5 Otros Efectos del Acuerdo de Reorganización / Posposición de Créditos Relacionados

Normalmente vamos a estar ante empresas deudoras que son personas jurídicas. Si los accionistas pasan plata como capital, ellos pasarían a tener un crédito muy subordinado entonces la alternativa es aportar dinero como un acreedor más. El problema es que normalmente no se hace un mutuo o un pagaré por una razón de costos: se busca evitar el impuesto de timbres y estampillas. Entonces, generalmente se pasa el dinero a través de cuentas y corrientes mercantiles que no paga impuesto sino hasta la liquidación.

La situación de los créditos relacionados siempre ha sido un tema de duda sobre su verdadera existencia y monto, todo ello porque normalmente su constancia figura en cuentas corrientes mercantiles que no han sido liquidadas al momento de iniciarse un procedimiento de liquidación o reorganización. Por ello, la regla general es que este tipo de créditos quedan pospuestos en su pago.

También aparecen problemas porque podrían haber sospechas sobre el interés real de ese acreedor que está relacionado.

No obstante, existen muchos casos en que los créditos provenientes de personas relacionadas tienen una existencia clara y no debieran ser discriminados. Para regular lo anterior, el artículo 63 señala las excepciones a dicha posposición:

a) Cuando se trate de créditos debidamente documentados

En este caso, se requiere que el documento se haya extendido con a lo menos 90 días de anticipación a la fecha de inicio del procedimiento de reorganización.

La ley no precisa la naturaleza del documento donde debe constar el crédito, para que no le afecte la posposición. Sin embargo, debemos entender que éste debe constar en algún título válido donde se exprese inequívocamente el monto y características del crédito.

Si este crédito consta en una cuenta corriente mercantil, ésta debe liquidarse antes de los 90 días contados desde el inicio del procedimiento de reorganización.

Aunque exista la debida acreditación documentaria del crédito relacionado, el acuerdo de reorganización puede establecer una posposición en el pago de estos créditos, previo informe del veedor, quien debe analizar, antes de emitir su informe fundado:

- La naturaleza de los créditos,
- Su debida existencia, y
- Su aplicación a los gastos o inversiones de la empresa deudora (destino de los recursos).

b) Créditos provenientes del abastecimiento asegurado

Se refiere a los créditos regulados en los artículos 72 y 73:

- Los créditos de proveedores que permiten la continuidad del suministro.
- Los créditos para financiar operaciones de comercio exterior.

c) Créditos para el financiamiento de sus operaciones

Se refiera a los créditos que regula el artículo 74, es decir, aquellos que no superen el 20% del pasivo.

2.3.6 Cláusula arbitral en Acuerdos de Reorganización Judicial

De acuerdo al artículo 68, los Acuerdos de Reorganización pueden establecer una cláusula compromisoria con el objeto que frente al caso que se produzcan diferencias entre el deudor y uno o más acreedores o entre éstos, con motivo de la aplicación, interpretación, cumplimiento, terminación o declaración de incumplimiento del Acuerdo, se someterán a arbitraje.

2.3.7 Intervención del Acuerdo y la participación de la Comisión de Acreedores

La participación del veedor no se agota en propiciar los acuerdos entre el deudor y sus acreedores, facilitando la aprobación de los Acuerdos de Reorganización, ni en el resguardo de los intereses de los acreedores durante el período en que este acuerdo se tramita.

El veedor opera como una especie de “amigable componedor” para propiciar acuerdo entre deudor y acreedores, pero eso no es todo.

a) Intervención

El artículo 69 establece que en estos Acuerdos se debe estipular el nombramiento de un interventor por al menos un año contado desde el Acuerdo, el que recaerá en un veedor vigente de la Nómina de Veedores.

Esta disposición nada dice respecto a la posibilidad de mantener o no como interventor al veedor que fue nominado por los acreedores para intervenir en el procedimiento de reorganización, por lo que el nombramiento puede recaer en este mismo o en cualquier veedor vigente de la Nómina de Veedores.

En el ejercicio de sus funciones, el interventor debe actuar representando los intereses de los acreedores durante la ejecución del Acuerdo, debiendo poner en conocimiento de éstos y de la Superintendencia, el eventual incumplimiento del acuerdo, para que se adopten las medidas que en derecho procedan.

El interventor nombrado tiene las atribuciones, deberes y remuneración que el acuerdo señale. Si ellas no se especifican, se entenderá que tendrá las señaladas en el artículo 294 del Código de Procedimiento Civil:

- Llevar cuenta de las entradas y gastos de los bienes sujetos a intervención
- Imponerse de los libros, papeles y operaciones del demandado
- Dar al interesado o al tribunal noticia de toda malversación o abuso que note en la administración de dichos bienes.

b) Comisión de Acreedores

Sin perjuicio de lo anterior, en el Acuerdo puede designarse a una comisión de acreedores (generalmente los acreedores más grandes de cada clase) para supervigilar el cumplimiento de sus estipulaciones, con las atribuciones, deberes y remuneración que, en su caso, señale el Acuerdo.

Normalmente, la composición de la Comisión de Acreedores se reserva para aquellos que tienen los mayores créditos reconocidos.

La ley no regula la composición de la Comisión de Acreedores ni señala sus atribuciones, limitándose a indicar que las atribuciones, deberes y remuneración son las que señale el Acuerdo. Es una cuestión esencialmente convencional.

2.4 Acreedores Comprendidos en los Acuerdos de Reorganización Judicial

La determinación de los acreedores a quienes afectarán las proposiciones del Acuerdo de reorganización es fundamental, porque son aquellos llamados a aprobar esta propuesta y a ejercer todos los derechos que la ley franquea para la protección de sus intereses.

A) Acreedores en la Masa

El artículo 66 fija un principio base en esta materia señalando que estos acuerdos sólo afectan a los acreedores *cuyos créditos se originen con anterioridad a la resolución de reorganización*. Es decir, los acreedores llamados “en la masa” son todos *aquellos cuyos créditos nacieron antes de la dictación de la resolución que abre el procedimiento de reorganización* y solamente a estos acreedores les afectan los acuerdos de reorganización.

B) Acreedores de la Masa

Todos los *acreedores cuyos créditos se originen con posterioridad a la dictación de la referida resolución*, se consideran como “de la masa” y sus créditos se deben pagar en los términos que normalmente se pacten.

Son los acreedores que se necesitan para seguir adelante con el comercio, y esos créditos se pagan como se han pactado. Esto se explica porque la empresa puede seguir funcionando en la vida del derecho, y su única limitación está en la función del interventor y de la comisión de acreedores.

No obstante lo anterior, para ejercer los derechos como acreedor dentro del procedimiento, es necesario que se determine el pasivo y que los créditos se encuentren reconocidos, conforme a la normativa sobre la determinación del pasivo.

2.4.1 Procedimiento de determinación del pasivo. Verificación y objeción de créditos

En primer término corresponde precisar que la nómina de acreedores que figuran en la certificación contable que la empresa deudora acompaña cuando solicita la apertura del procedimiento de reorganización constituye la información base para la determinación del pasivo.

Como esta información se acompaña al expediente y se publica en el Boletín Concursal, los acreedores pueden constatar si efectivamente ésta se ajusta a la realidad y corresponde a los valores que se les adeuda.

En el caso de los créditos garantizados con bienes de la empresa deudora o de terceros, como se señala en el avalúo comercial de éstos y la indicación si en concepto de la proponente del acuerdo, tienen la calidad de ser esenciales para el giro de la empresa deudora, también los acreedores pueden determinar si están o no de acuerdo con este avalúo y la calidad de esencial del bien.

Si existe conformidad respecto de todo, el acreedor no necesita verificar su crédito y, si nadie se lo objeta, queda comprendido en la nómina de créditos reconocidos y puede ejercer todos sus derechos en el procedimiento.

De lo contrario, debe proceder a la verificación de sus créditos en los términos siguientes:

2.4.1.1 La verificación de créditos

La ley busca evitar dilaciones y por lo tanto las partes y el juez tienen plazos acotados. Además, acá el veedor cobra un rol de relevancia a favor del deudor y del proceso.

El artículo 70 señala que los acreedores tienen un plazo de 8 días contado desde la notificación de la resolución de reorganización para verificar sus créditos ante el tribunal que conoce del procedimiento.

Es como un pequeño juicio declarativo dentro del proceso concursal. Entonces, tenemos personas interesadas en que los créditos sean reconocidos y personas interesadas en desconocer la existencia de esos créditos o desconocer la magnitud de los mismos o sus garantías. Por eso es un “juicio adversarial” que resuelve el juez. Es como si fuera una demanda que el acreedor hace para que se le acepte dentro del conjunto de acreencias.

Al verificar sus créditos, los acreedores deben acompañar ante el tribunal que conoce del procedimiento los títulos justificativos de éstos, señalando, en su caso, si se encuentran garantizados con prenda o hipoteca y el avalúo comercial de los bienes sobre los que recaen las garantías.

Esta es la forma por medio de la cual comparecen los acreedores; lo que no significa que un acreedor que no verifica el crédito no pueda participar eventualmente del concurso. La notificación de la resolución de reorganización impone una obligación a los acreedores que es de verificación de los créditos.

Expirado el plazo antes señalado, y dentro de los dos días siguientes, el veedor debe publicar en el Boletín Concursal todas las verificaciones presentadas, indicando los créditos que se encuentren garantizados con prenda o hipoteca y el avalúo comercial de los bienes sobre los que recaen las garantías.

Si el acreedor está de acuerdo con el crédito presentado por el certificado del art 55 en cuanto a quién es acreedor, monto, garantía, avalúo de los bienes garantizados y esencialidad, igual sabemos que tiene que acreditar personería.

2.4.1.2 La objeción de créditos

El artículo 70 establece la figura de la “objeción de los créditos” como gestión previa a la actuación jurisdiccional que deben resolver las impugnaciones.

Esta norma señala que en el plazo de 8 días siguientes a la publicación de las verificaciones efectuadas, el veedor, el deudor y los acreedores podrán deducir objeción fundada sobre:

- a) La falta de títulos justificativos de los créditos, sus montos y preferencias.
- b) El avalúo comercial de los bienes sobre los que recaen las garantías otorgadas por el deudor o terceros. Esto va a tener incidencia al momento de votar.

No se objeta el fondo sino principalmente la forma de la presentación.

Indistintamente, esta objeción se puede deducir (a) respecto de los créditos y avalúos comerciales que se indican en el estado de deudas que presenta el deudor o (b) en las verificaciones presentadas por los acreedores.

Estas objeciones deben presentarse ante el tribunal que conoce el procedimiento de reorganización y, vencido el plazo, el veedor debe publicar en el Boletín Concursal todas las objeciones presentadas dentro de los dos días siguientes a la expiración de dicho plazo.

Si no se presentan objeciones dentro de plazo, los créditos y el avalúo comercial de los bienes sobre los que recaen las garantías, quedan **reconocidos**.

Para estos efectos, el veedor debe confeccionar la nómina de los créditos reconocidos, la que deberá indicar:

- los montos de los créditos
- si éstos se encuentran garantizados con prenda o hipoteca
- el avalúo comercial de los bienes sobre los que recaen las garantías.

Esta nómina la debe acompañar al expediente dentro de quinto día de expirado el plazo para objetar y la debe además publicar en el Boletín Concursal.

Conforme se indica en el artículo 78, la nómina sirve como única nómina para la votación de las proposiciones del acuerdo de reorganización que presente la empresa deudora.

Esta nómina podrá ampliarse o modificarse de acuerdo a lo que se resuelva en el procedimiento de impugnación que analizamos más adelante.

2.4.2 Impugnación de créditos

Si hay objeciones, empieza el procedimiento de impugnación.

2.4.2.1 Rol de Veedor

El artículo 71 faculta al veedor para que arbitre las medidas necesarias de modo que se puedan subsanar las objeciones deducidas.

El veedor funciona como mediador o facilitador. En el fondo se trata que éste pueda servir como amigable componedor entre los acreedores que objetaron los créditos y/o montos de los avalúos comerciales de los bienes objeto de garantías y los acreedores respecto de los cuales se dedujeron estas objeciones.

En esta labor, el veedor puede también instar para que se subsanen defectos de forma en la verificación de los créditos objetados, tales como acompañar los títulos justificativos conforme a derecho u otro elemento formal que sirvió de base a la objeción.

Obviamente, la labor antes señalada no corresponde realizarla cuando es el veedor quien ha formulado la objeción.

Si no se subsanan las objeciones, los créditos y el avalúo comercial de los bienes sobre los que recaen las garantías en su caso, **se consideran impugnados**. Esto demuestra que el hecho de que haya objeción no supone un procedimiento adversarial sino hasta cuando no se puedan solucionar las objeciones.

En este caso, el veedor debe acompañar al tribunal:

- la nómina de créditos impugnados

- un informe donde debe indicar si existen o no fundamentos plausibles que avalen la objeción, y pronunciarse fundadamente sobre el avalúo comercial del bien sobre el que recae la garantía objetada.

Esta nómina y el informe deben publicarse en el Boletín Concursal.

2.4.2.2 Rol del Tribunal

A) Audiencia

Cuando se agregan al expediente la nómina de créditos impugnados y el informe del veedor, el tribunal debe citar a una audiencia única y verbal para el fallo de las impugnaciones.

Esta audiencia se debe celebrar dentro de tercero día contado desde la notificación de la resolución que tiene por acompañada la nómina de créditos reconocidos e impugnados.

A la audiencia pueden concurrir el veedor, el deudor, los impugnantes y los impugnados. En ésta deben resolverse las incidencias que promuevan las partes en relación a las impugnaciones.

El tribunal competente puede, si fuere estrictamente necesario, suspender y continuar la referida audiencia con posterioridad.

B) Fallo

Es muy importante que el fallo se dicte con el tiempo suficiente para que a la junta de acreedores puedan concurrir los acreedores que fueron impugnados y a los que el tribunal rechazó la impugnación

Por esta razón, la norma comentada señala que esta resolución debe dictarse a más tardar el segundo día anterior a la fecha de celebración de la junta de acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo.

Esta resolución debe ordenar:

- la incorporación del crédito impugnado a la nómina de créditos reconocidos si así lo resolviere o
- la modificación del avalúo comercial de los bienes sobre los que recaen las garantías, cuando corresponda

Este fallo es apelable en el solo efecto devolutivo.

C) Publicación de Nómina

El veedor debe publicar la nómina de créditos reconocidos según la resolución del tribunal en el Boletín Concursal a más tardar el día anterior a la fecha de celebración de la junta de acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo.

Esta norma que regula la determinación del pasivo y que se replica en el Procedimiento de Liquidación, constituye una de las principales innovaciones de la ley concursal, por cuanto incorpora a este proceso al veedor como un auxiliar calificado del Tribunal, que primeramente procura arbitrar las medidas necesarias para que amigablemente se subsanen las objeciones,

reservando al tribunal para conocer y fallar aquellas objeciones no subsanadas, para lo cual tendrá a la vista la opinión de este Veedor, sin perjuicio de escuchar las alegaciones que verbalmente formulen las partes, en una audiencia única de fallo, donde además se resolverán las incidencias que promuevan las partes en relación a las impugnaciones.

Algunas consideraciones

- Es importante que siempre habrá una verificación extraordinaria. No por dejar de participar en la verificación dejo de ser acreedora, pero eso me va a afectar en el ejercicio de algunos derechos.
- Por otro lado, también es importante que todos los plazos se cuentan desde la publicación en el BC.

2.4.3 Nómina de acreedores con derecho a voto

Determinado el pasivo, surge la nómina de los acreedores con derecho a voto en las juntas de acreedores llamada a pronunciarse sobre las proposiciones del Acuerdo de Reorganización que formule la empresa deudora.

Sobre el particular, el artículo 70 señala que solo tienen derecho a concurrir y votar los acreedores cuyos créditos se encuentren en la nómina de créditos reconocidos y su ampliación (efecto de impugnación o incorporación posterior de un acreedor), si existiere.

2.4.3.1 Acreditación de Personerías

No obstante lo anterior y para que los acreedores puedan votar en la junta, necesitan haber dado cumplimiento a lo ordenado en el número 6) del artículo 57, relativo a la acreditación de personerías. Para ello, el acreedor debe:

- A) Acreditar ante el tribunal su personería donde conste que tiene la capacidad suficiente, o representación legal en su caso, para obligarse u obligar a su representada en lo que se acuerde en el procedimiento de reorganización

De lo contrario, este acuerdo podría impugnarse por la causal que señala el N° 3 del artículo 85

- B) Conferir un poder especial a un apoderado judicial con expresa indicación que se le confieren las facultades de conocer, modificar y adoptar el Acuerdo de Reorganización Judicial.

Esta personería y el poder conferido debe ser analizado por el **veedor**, para emitir el informe que ordena el artículo 25 número 6): “Realizar la calificación de los poderes para comparecer en las Juntas de Acreedores e informar al tribunal competente sobre la legalidad de éstos, cuando corresponda”.

Si el acreedor no da cumplimiento a esta carga procesal, **su derecho a votar precluye**, aunque su crédito figure en el certificado contable emitido por el auditor.

Consecuencialmente, la nómina de créditos reconocidos y su ampliación, que el veedor tiene que confeccionar y presentar al tribunal no puede comprender a estos acreedores porque la

disposición del citado artículo 71, establece que para ejercer su derecho a voto debe haber dado cumplimiento a lo ordenado en el número 6) del artículo 57, relativo a la acreditación de personerías.

Al no formar parte estos acreedores de la nómina con derecho a voto, necesariamente el monto de sus créditos se debe deducir del pasivo al momento de calcular el quórum que fija el inciso segundo del artículo 79, para acordar la propuesta de reorganización.

Sin perjuicio de lo anterior, los acreedores excluidos para votar nunca perderán sus créditos y los efectos del acuerdo de reorganización, les serán aplicables.

2.4.3.2 Determinación del Quórum de Aprobación del Acuerdo

Para determinar el quórum de aprobación del Acuerdo de Reorganización, cada titular de un crédito se considera en términos individuales como acreedor presente en la junta y vota por el monto de su crédito.

2.4.3.3 Acreedores con Garantías

A) Cómo Votan

Tratándose de acreedores cuyos créditos se encuentren garantizados con prenda o hipoteca, el inciso segundo del artículo 78 señala que éstos votan de acuerdo al avalúo comercial de los bienes sobre los que recaen las garantías, conforme conste en la nómina de créditos reconocidos y en su ampliación o modificación, en su caso.

Si el crédito está sobre garantizado, los acreedores participan con el valor de su crédito.

B) Avalúo Comercial

Siendo determinante el avalúo comercial para el voto de este tipo de acreedores, es fundamental la forma en que se determina este avalúo y las incidencias que sobre esta materia se pueden dar, hasta que se establece la nómina de créditos reconocidos.

Cuando el avalúo comercial de los bienes sobre los que recaen las garantías excede el valor del crédito que garantizan, el acreedor correspondiente votar de acuerdo al monto de su crédito, según conste en la nómina de créditos reconocidos y en su ampliación o modificación, en su caso.

Esta norma se justifica porque pueden existir en la práctica créditos sobre garantizados, ya sea porque desde su origen el acreedor impuso la sobre garantía o por efecto de las amortizaciones periódicas efectuadas por la empresa deudora, que normalmente no obtiene la limitación a las garantías otorgadas sino hasta la extinción del crédito por efecto del pago.

2.5 Procedimiento de Aprobación del Acuerdo de Reorganización Judicial

2.5.1 La presentación de la propuesta y su retiro

2.5.1.1 Propuesta

El N° 4 del artículo 57 impone la obligación a la empresa deudora para que a través del veedor publique en el Boletín Concursal y acompañe al tribunal competente, a lo menos diez días antes de la fecha fijada para la junta de acreedores, su propuesta de Acuerdo de Reorganización.

Si el deudor no da cumplimiento a esta orden, el veedor debe certificar esta circunstancia y el tribunal competente debe dictar la resolución de liquidación sin más trámite.

2.5.1.2 Informe del Veedor

Por su parte, el N° 8 del citado artículo 57 dispone que el Veedor deberá acompañar al tribunal competente y publicar en el Boletín Concursal su informe sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización, a lo menos tres días antes de la fecha fijada para la celebración de la Junta de Acreedores que votará dicho acuerdo. Esto busca facilitarle el trabajo a los acreedores.

2.5.1.3 Retiro de la Propuesta

El artículo 71 señala que presentada la propuesta de acuerdo por la empresa deudora no puede retirarse, salvo que cuente con el apoyo de acreedores que representen a lo menos el 75% del pasivo y, si ésta se retira sin contar con este apoyo, el tribunal competente debe dictar la resolución de liquidación. Si hay acuerdo de los acreedores, se puede presentar otra propuesta.

2.5.2. Acuerdo de la junta de acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta

2.5.2.1 Forma de Pronunciarse

El artículo 79 señala que los acreedores llamados a pronunciarse sobre la propuesta de reorganización que presente la empresa deudora, lo deben hacer separadamente por clase o categorías. Si la propuesta fue una para todos, se vota esa propuesta y se resuelve en una votación pero si hubo propuesta diferenciada para los distintos tipos de acreedores, se votan las propuestas de forma separada y todas tienen que aprobarse.

2.5.2.2 Aprobación

La propuesta se entiende acordada si cuenta con el consentimiento del deudor y el voto conforme de los *dos tercios o más de los acreedores presentes, que representen al menos dos tercios del total del pasivo con derecho a voto correspondiente a su respectiva clase o categoría.*

- La norma antes citada prohíbe que concurran con su voto los acreedores que son personas relacionadas con el deudor y sus créditos no se considerarán en el pasivo.
- Lo mismo sucede con las personas que adquirieron créditos con una anticipación muy cercana a la fecha de la solicitud de reorganización.

El legislador sospecha que en estos casos se busca manipular los votos.

2.5.2.3 Aprobación por Clases

- A) Para que exista la debida protección a la posición de igualdad entre los acreedores del concurso y para que el consenso de éstos legitime el procedimiento, el acuerdo sobre la propuesta de una clase o categoría se adopta bajo la condición suspensiva de que se

acuerde la propuesta de la otra clase o categoría en la misma junta de acreedores, o en la que se realice de conformidad a lo previsto en el artículo 82.

Es decir, aunque se acepte la propuesta de una clase o categoría de acreedores, no hay acuerdo si la otra clase o categoría la rechaza.

Por esta vía se logra que una eventual posición mayoritaria de una clase o categoría de acreedores de créditos muy altos, imponga formas o modalidades de reorganización que les puede ser perjudicial a la otra clase o categoría de acreedores de créditos inferiores en su monto.

- B) Para impedir que se formen mayorías artificiales que incidan en los quórum de aprobación de los acuerdos, el artículo 79 señala que quienes hayan adquirido créditos dentro de los treinta días anteriores a la fecha de inicio del procedimiento reorganización, no pueden concurrir a la junta de acreedores para deliberar y votar el Acuerdo y tampoco pueden impugnarlo.

En este caso obviamente que el cedente tampoco tiene derecho a voto, porque dejó de ser acreedor con motivo de la cesión y el importe del crédito cedido tiene que rebajarse del pasivo para los efectos de realizar el cálculo de los quórum de aprobación que exige la ley.

2.5.2.4 Registro de Firmas para Votación

Es otra forma de realizar la votación respecto de acreedores que quieren participar pero no pueden o no quieren hacerlo físicamente. Ahora, de esta forma solo van a poder **aprobar** el acuerdo. Además, estos acreedores cuentan para los quórum de 2/3 que ya vimos (se los considera como acreedores presentes).

Para facilitar la participación de los acreedores en el procedimiento de reorganización y obtener las mayorías que exige 79, en el artículo 80 se faculta al veedor para recabar la votación de cualquier acreedor, mediante la suscripción de uno o más documentos ante un ministro de fe o mediante firma electrónica avanzada, en que conste su aceptación.

El procedimiento del registro de firma tiene que realizarse de una forma en que indubitadamente conste la aceptación de los acreedores. En consecuencia, si un acreedor se manifiesta en contra del acuerdo o quiera instar para que se efectúen modificaciones, necesariamente debe concurrir a la junta a expresar su parecer, reservándose este procedimiento de registro, sólo para los acreedores que están conformes con la propuesta de la empresa deudora.

Los votos que se obtengan mediante este sistema se consideran como votos de acreedores presentes en la junta de acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo, para los efectos del cómputo de las mayorías que señala el inciso segundo del artículo 79.

Finalmente, este procedimiento de registro de firmas debe llevarse a cabo mediante la suscripción de estos documentos desde la publicación de la propuesta de Acuerdo en el Boletín Concursal, y hasta tres días antes de la fecha fijada para la junta de acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre dicha propuesta.

2.5.3 Ausencia del Deudor en la Junta de Acreedores

Cuando se da inicio al procedimiento de reorganización, se producen los efectos que se establecen en la resolución judicial, cuyo contenido trata el artículo 57; en particular, la protección financiera concursal que de pleno derecho se le otorga a la empresa deudora. En consecuencia, existe un punto sin retorno desde que este procedimiento se inicia, razón por la cual el artículo 81 señala que si el deudor no comparece a la junta de acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo, el tribunal competente debe dictar la resolución de liquidación en la misma junta.

La doctrina está conteste en considerar que los acuerdos de reorganización participan de una naturaleza contractual, donde se unen las voluntades del deudor y sus acreedores para establecer nuevas condiciones de pagos de sus pasivos o la reorganización de sus activos.

En consecuencia, la ausencia del proponente del acuerdo hace imposible la formación del consentimiento; por esta razón y, además, para que el deudor no utilice este procedimiento para otros fines, es que el citado artículo 81 previene la declaración judicial de liquidación cuando no comparece a la junta de acreedores o no otorga poderes de representación al efecto.

Es importante que el deudor concurra personalmente o representado porque de lo contrario impide la formación del consentimiento (sobre todo porque acá pueden haber modificaciones a la propuesta). Se dicta resolución de liquidación porque la no presencia se mira como un ***desistimiento***.

2.5.4 Suspensión de la Junta de Acreedores

El artículo 82 señala que la junta de acreedores puede acordar, con quórum calificado, su suspensión por no más 10 días, fijando al efecto nuevo día y hora para su reanudación. Cualquiera puede pedir que la junta apruebe dicha suspensión.

Para que durante el período de suspensión de la junta no se reanuden las acciones de cobro individual u otras acciones en contra de la empresa deudora, agrega que el deudor conserva la Protección Financiera Concursal hasta la celebración de la junta (se prorroga la PFC).

2.5.5 Modificación y Notificación del Acuerdo

De la misma forma en que acuerdan las propuestas de reorganización que formula la empresa deudora, es posible hacerles modificaciones durante la ejecución de lo acordado.

2.5.5.1 Forma de Acordarlas

A) El artículo 83 establece que estas modificaciones se tienen que acordar con:

- los mismos acreedores que suscribieron el acuerdo, agrupados en sus respectivas clases o categorías.
- conforme al mismo procedimiento y mayorías exigidas en el artículo 79.
- sin la participación de los acreedores que tengan la calidad de personas relacionadas con el deudor.

- B) El artículo 83 señala que si el Acuerdo establece la participación de una Comisión de Acreedores, los acreedores pueden facultarla para modificar sus estipulaciones con el quórum de aprobación que el mismo Acuerdo determine, el que en ningún caso puede ser inferior al quórum simple del artículo 22 N°34.

Es frecuente que en los acuerdos de reorganización exista una comisión de acreedores, que en los procedimientos antiguo se formaba de hecho. Si esto está formalizado en el acuerdo, se puede facultar para que esta comisión modifique el acuerdo.

No obstante lo anterior y con el propósito de resguardar los derechos de los acreedores, esta norma señala que si bien la modificación puede recaer sobre todo o parte del contenido del Acuerdo, no se permite que se modifiquen aspectos relativos a:

- la calidad de acreedor
 - su clase o categoría
 - diferencias entre acreedores de igual clase o categoría
 - monto de sus créditos
 - sus preferencias
 - aquellas materias que el Acuerdo determine como no modificables
- C) Para evitar que los representantes en la Comisión de una clase o categoría, modifiquen las estipulaciones del acuerdo de la otra clase o categoría, se hace necesario que, sin perjuicio de una integración o composición paritaria, no pueda modificarse el acuerdo sin el consentimiento unánime de los miembros de la comisión a quienes estas modificaciones les puedan afectar. Esto busca proteger a las distintas clases.

2.5.5.2 Notificación

Para el debido conocimiento las partes y terceros, el artículo 84 indica que el texto íntegro del Acuerdo con sus modificaciones, en su caso, debe ser notificado por el veedor en el Boletín Concursal.

2.6 Impugnación del Acuerdo de Reorganización

La impugnación al acuerdo de reorganización que está tratada en el párrafo 2 del Título 2 de la Ley 20.720, es la facultad que se les otorga a los acreedores a quienes afecta este acuerdo para que fundándose en las causales que establece la ley, puedan solicitar al tribunal que lo deje sin efecto y, en algunos casos, proceda a dictar la resolución de liquidación de la empresa deudora.

2.6.1 Causales para Impugnar el Acuerdo

Hay causales formales o de fondo. El artículo 85 establece las siguientes causales de impugnación:

Causales de forma

- 1) Defectos en las formas establecidas para la convocatoria y celebración de la junta de acreedores, que hubieren impedido el ejercicio de los derechos de los acreedores o del deudor.

Se establece esta causal para proteger a los acreedores a quienes se les ha impedido actuar en el procedimiento de reorganización por haber existido defectos en la convocatoria y celebración de la junta.

Por ejemplo:

- no fue hecha en tiempo y forma
- no se publicó la resolución que cita a la junta
- se efectuó en un lugar distinto al señalado en la resolución que la convoca, etc.

Lo determinante es que estos vicios causen un **perjuicio** al acreedor en términos tales que con motivo de estos defectos de forma, él no pudo asistir a la junta y consecuentemente no pudo ejercer los derechos que la ley le confiere. En consecuencia, si el acreedor concurrió a la junta, habiendo participado o no en sus deliberaciones; propuesto o no modificaciones, no puede alegar esta causal de impugnación, aunque efectivamente estos defectos de forma se produzcan.

2) Error en el cómputo de las mayorías requeridas, siempre que incida sustancialmente en el quórum del Acuerdo

Esta causal apunta al correcto cómputo de las mayorías de aprobación de los acuerdos requeridas en los artículos 79 y 109, en su caso.

No cualquier error en el cómputo de las mayorías califica para la aplicación de la causal. Solo se puede dejar sin efecto el acuerdo si el error en el cómputo es **incidente en la determinación de los quórums de aprobación**. Si se contabilizó mal pero da lo mismo porque igual se habría aprobado, no procede esta causal, lo que demuestra que la ley busca que la reorganización sí se produzca.

Causales de fondo

3) Falsedad o exageración del crédito o incapacidad o falta de personería para votar de alguno de los acreedores que hayan concurrido con su voto a formar el quórum necesario para el Acuerdo, si excluido este acreedor o la parte falsa o exagerada del crédito, no se logra el quórum del Acuerdo.

- A) En la primera hipótesis de esta causal estamos en presencia de una acción deliberada, dolosa y hecha con el ánimo de obtener la aprobación del acuerdo (falsedad o exageración del crédito).

Si se verifica esta situación se atenta contra la buena fe de los acreedores y eventualmente el hecho puede ser constitutivo del delito concursal previsto y sancionado en el artículo 463 ter N° 1 del Código Penal.

Falsear o exagerar consiste en poner un monto distinto de un crédito en el estado de deudas que figura en los estados contables de la empresa deudora, ya sea modificando su monto o aumentando éste.

- B) Distinta es la situación comprendida en las hipótesis siguientes que se señala en esta causal (incapacidad o falta de personería para votar de alguno de los acreedores que hayan concurrido con su voto a formar el quórum necesario para el Acuerdo).

Recordemos que el acreedor cuando verifica tiene que presentar su personería y el veedor examina esas personerías.

En este caso, no se habría dado cumplimiento a las exigencias señaladas en los artículos 57 N° 6, que impone al acreedor acreditar ante el tribunal su personería donde conste que tiene la capacidad suficiente o, representación legal en su caso, para obligarse u obligar a su representada en lo que se acuerde en el procedimiento de reorganización y de conferir un poder especial a un apoderado judicial con expresa indicación que se le confieren las facultades de conocer, modificar y adoptar el Acuerdo y al artículo 25 N°6 que establece, como una de las obligaciones del veedor, realizar la calificación de los poderes para comparecer en las juntas de acreedores e informar al tribunal competente sobre la legalidad de éstos, cuando corresponda.

De prosperar esta causal, el acreedor no acreditó personería y si lo hizo y no tenía capacidad para obligarse u obligar a su representada, significa que el veedor no fue acucioso en su informe sobre calificación de poderes para comparecer en este procedimiento.

Solo puede acogerse la impugnación si estos vicios han sido **determinantes en la determinación de las mayorías** para obtener el quórum de aprobación del Acuerdo. Si vota alguien sin personería pero igual se habría aprobado, no se puede impugnar el acuerdo por este motivo.

- 4) Acuerdo entre uno o más acreedores y el deudor para votar a favor, abstenerse de votar o rechazar el Acuerdo, para obtener una ventaja indebida respecto de los demás acreedores.

Esto es raro porque muchas veces el deudor negocia antes con sus acreedores para asegurar que el acuerdo sea aceptable. Pero el tema no es que hayan habido conversaciones previas, sino que se hayan hecho con la intención de perjudicar a los demás acreedores.

Las conductas constitutivas de la primera parte de esta causal son poco factibles que se produzcan, porque supone una colusión entre uno o más acreedores y el deudor con cualquiera de los siguientes propósitos:

- A) Votar a favor del acuerdo: esta hipótesis de conducta es inocua porque lo natural es que la empresa deudora inste para que sus acreedores así lo hagan.
- B) Abstenerse de votar o rechazar el acuerdo: esta hipótesis también es inocua porque resulta incomprensible que exista una colusión de un grupo de acreedores con la propia empresa deudora con el objeto que no prospere el acuerdo y, consecuentemente, se dicte la resolución de liquidación; de ser así, no se habría justificado requerir la apertura de un procedimiento de reorganización, bastando que la propia empresa deudora voluntariamente requiera su propia liquidación.

- C) Colusión entre uno o más acreedores y el deudor, para obtener una ventaja indebida respecto de los demás acreedores: esta hipótesis sí constituiría una causal necesaria de mantener, por cuanto de producirse efectivamente este supuesto, se rompe la par *condictio creditorum* que constituye uno de los principios básicos que toda ley concursal debe proteger.

Quien impugna puede haber aprobado pero haberse dado cuenta después y ahí impugnarlo.

5) Ocultación o exageración del activo o pasivo.

La ocultación o exageración del activo o pasivo constituyen conductas que objetivamente atentan en contra de los intereses de los acreedores, quienes han llegado a prestar su consentimiento para que se acuerde una propuesta de reorganización, en el entendido que la hacienda del deudor es la informada en los antecedentes que conforme se establece en el artículo 56, debe acompañar la empresa deudora al tribunal, cuando requiere la apertura del procedimiento de reorganización.

- A) Ocultación del activo: consiste en que la empresa deudora deliberadamente no incorpora determinados bienes en su relación que debe hacer conforme se indica en el N°1 del artículo 56.

Al realizar esta conducta de ocultación, los bienes cuya existencia no se declaran, quedan fuera del patrimonio de la compañía y consecuentemente de su posibilidad de disposición para el giro operacional, con el consiguiente perjuicio para los acreedores.

Esto va a incidir obviamente en lo que el acreedor acepta como condiciones de la reorganización (ej. se habrían pactado plazos de amortiguación distintos).

- B) Exageración del pasivo: consiste en abultar el estado de deudas referido en el artículo 55, ya sea incorporando créditos inexistentes o aumentando el monto de los reales.

Esta conducta provoca una alteración en la situación de los pasivos, que es perjudicial para los acreedores por cuanto al efectuarse los pagos de los créditos conforme al acuerdo de reorganización, existirán acreedores supuestos que recibirán pagos, o acreedores verdaderos que recibirán pagos superiores a sus créditos, alterando la prorrata de los demás acreedores, con el consiguiente perjuicio para ellos.

Si se constata que efectivamente el deudor incurrió en las conductas que señala esta causal, obviamente debe acogerse la impugnación, dejándose sin efecto el acuerdo de reorganización, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad penal atribuible al deudor, por la eventual comisión de los delitos concursales que se describen y sancionan en los artículos 463 N°1 y 463 ter N°1 del Código Penal.

6) Por contener una o más estipulaciones contrarias a lo dispuesto en la ley 20.720.

Esta causal se refiere al objeto o contenido de las propuestas del acuerdo de reorganización y a las modalidades que se estipulen para el cumplimiento del mismo. Es una causal genérica que apunta al OP.

El artículo 60 señala que la propuesta puede versar sobre cualquier objeto tendiente a reestructurar los pasivos y activos de una empresa deudora. No obstante ser amplio el objeto o contenido del acuerdo, existen distintas normas que regulan su implementación las cuales se deben cumplir para que no se califiquen sus estipulaciones como contrarias a lo dispuesto en la ley 20.720.

Sin ser limitativo en esta relación, existe una serie de disposiciones que tienen que observarse tanto en la determinación de la propuesta como en las cláusulas que regulan la ejecución del mismo; a saber:

- la clara determinación de los acuerdos por clase o categorías de acreedores que señala el artículo 61
- la correcta regulación de las propuestas alternativas que autoriza formular el artículo 62
- las diferencias entre acreedores de igual clase o categoría que se señalan en el artículo 64.

La causal en análisis es de orden público, porque ataca contenidos de acuerdos que no se ajustan a lo regulado por la ley, no obstante la libertad que tiene el deudor y sus acreedores para pactar lo que estimen más conveniente para sus intereses, conforme al principio de autonomía de la voluntad que es uno de los principios formativos del derecho privado, como lo es el derecho concursal. Podría la ley no haber dicho nada y en ese sentido el acuerdo adolecería de objeto ilícito.

No obstante lo anterior, cabe indicar que existen normas de contenido público como son las relativas a la prelación de créditos; la competencia para conocer de estos procesos; las que regulan las relaciones laborales en el procedimiento de liquidación y las penales que establecen los delitos concursales, solo por nombrar algunas de ellas, que necesariamente se deben cumplir.

Algunas precisiones

¿Son taxativas estas causales? Sí, pero la última en realidad es muy genérica.

CUALQUIER interesado puede impugnar el acuerdo. Eventualmente en casos muy claros quizás podría el tribunal impugnarlo de oficio.

2.6.2 Plazo para Impugnar el Acuerdo

Conforme se establece en el artículo 86, el acuerdo de reorganización se puede impugnar dentro del plazo de 5 días contado desde su publicación en el Boletín Concursal y deben ser rechazadas de plano las impugnaciones presentadas fuera de plazo.

2.6.3 Audiencia Única de Resolución de Impugnaciones

Las impugnaciones las resuelve el tribunal en un procedimiento bastante expedito. Pero por el solo hecho de impugnar el acuerdo este no deja de tener efectos.

- A) Audiencia Única: El tribunal debe conocer y fallar en una audiencia única las impugnaciones deducidas a los acuerdos de organización; si son varias, se deben tramitar en un solo incidente.
- B) Plazo: El artículo 87 señala que el tribunal debe citar a esta audiencia dentro de los 10 días de vencido el plazo para impugnar.
- C) Forma: Esta audiencia es verbal y se debe llevar a cabo con los que asistan y en ella deben resolverse las incidencias que promuevan las partes.
- D) Suspensión: El tribunal queda facultado para suspender y continuar la referida audiencia con posterioridad.
- E) Resolución: El artículo 87 señala que la resolución que se pronuncie sobre las impugnaciones al Acuerdo debe dictarse a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha de celebración de la audiencia y se debe publicar en el Boletín Concursal. En el intertanto, el acuerdo sigue produciendo efectos.
- F) Apelación: Esta resolución es apelable en el solo efecto devolutivo.

2.6.4 Nueva Propuesta de Acuerdo

- A) Causales: El artículo 88 regula la forma en que se puede presentar nuevamente un acuerdo de reorganización que haya sido impugnado y se haya acogido esta impugnación por las causales establecidas en los números 1), 2), 3) y 6) del artículo 85.
- B) Plazo: En estos casos, el deudor puede presentar una nueva propuesta de Acuerdo dentro de los 10 días siguientes desde que se notifique la resolución que tuvo por acogida la impugnación.
- C) Apoyo: En este caso, la nueva propuesta debe ser presentada con el apoyo de dos o más acreedores que representen, a lo menos, un 66% del pasivo total con derecho a voto.
- D) Efectos: Presentada la nueva propuesta, el deudor goza de Protección Financiera Concursal hasta la celebración de la junta llamada a conocer y pronunciarse sobre ella.
- E) Resolución: En la resolución del tribunal que tenga por presentada la nueva propuesta de acuerdo se debe fijar la fecha de la junta de acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre dicha nueva propuesta, la que deberá celebrarse dentro de los 10 días siguientes contados desde que el deudor la presentó.
- F) Impugnación por Otras Causales: Si se acoge una impugnación al Acuerdo por las causales establecidas en los números 4) y 5) del artículo 85, el tribunal, de oficio y sin más trámite, debe ordenar el inicio del procedimiento de liquidación en la misma resolución que acoge la impugnación, y el deudor no puede presentar nuevamente una propuesta de acuerdo.

2.7 Vigencia del Acuerdo de Reorganización

2.7.1 Efectos Inmediatos

Para evitar que impugnaciones instrumentales paralicen los efectos de un acuerdo reorganización, la ley fija una modalidad especial de aprobación y vigencia, que impide que algunos acreedores utilicen la impugnación como herramienta para exigir el pago de sus créditos.

- A) Vigencia del Acuerdo: El artículo 89 señala que el acuerdo rige no obstante las impugnaciones que se hubieren interpuesto en su contra, **salvo que** éstas se presenten por acreedores de una determinada clase o categoría, que representen en su conjunto a lo menos el 30% del pasivo con derecho a voto de su respectiva clase o categoría. En este caso el Acuerdo no empieza a regir hasta que dichas impugnaciones sean desestimadas por sentencia firme y ejecutoriada.

Si el porcentaje es significativo no es una impugnación de un solo acreedor para obtener alguna ventaja sino que efectivamente hay cláusulas que deben ser impugnadas, o que el acuerdo no se aprobó de la manera que debió haberse hecho.

- B) Validez de Actos y Contratos: Los actos y contratos suscritos o celebrados por la empresa deudora en el tiempo que medie entre el Acuerdo y la fecha en que quede ejecutoriada la resolución que acoja las impugnaciones, no pueden dejarse sin efecto.

La razón de esta disposición es la seguridad jurídica que debe darse a todas las actuaciones del deudor en este tiempo intermedio. De lo contrario, la sola impugnación provocaría en el hecho la paralización del acuerdo de reorganización. Imaginemos, por ejemplo, el caso de que en este período se han adquirido créditos: si no fuese así la regulación, estos créditos caerían por ser “accesorios” al acuerdo.

Del mismo modo el inciso quinto del citado artículo 89 refuerza esta modalidad especial de vigencia al señalar que no obstante las impugnaciones deducidas, el recurso de casación deducido en contra de la resolución de segunda instancia que desecha la o las impugnaciones no suspenderá el cumplimiento de dicha resolución, incluso si la parte vencida solicita que se otorgue fianza de resultas por la parte vencedora.

- C) Efecto de Acogerse la Impugnación: Si en definitiva se acoge por sentencia ejecutoriada la impugnación al acuerdo de reorganización, todas las obligaciones y derechos existentes entre el deudor y sus acreedores con anterioridad a éste se rigen por sus respectivas convenciones.

2.7.2 Resolución Judicial

Para que el Acuerdo votado favorablemente por los acreedores entre en vigencia, es necesario que el tribunal dicte una resolución aprobándolo (esto porque el procedimiento de reorganización es judicial). Para determinar el tiempo en que comienza a estar vigente, es preciso distinguir dos situaciones:

- A) Si no hubo impugnación: Para que el acuerdo de reorganización entre a regir, tiene que expirar el plazo de impugnación que establece el artículo 86, sin que hubiere sido impugnado.

En este caso el tribunal debe declarar la aprobación del Acuerdo de oficio o a petición de cualquier interesado o del veedor.

- B) Si hubo impugnación: Si el acuerdo es impugnado y las impugnaciones se desechan, el tribunal lo debe declarar aprobado en la resolución que deseche la o las impugnaciones.

En este caso, el Acuerdo comienza a regir desde que la resolución cause ejecutoria.

Las resoluciones se notifican en el Boletín Concursal.

2.8 Efectos del Acuerdo de Reorganización

El artículo 91 señala que el Acuerdo debidamente aprobado obliga al deudor y a todos los acreedores de cada clase o categoría de éste, hayan o no concurrido a la junta que lo acuerde.

Mediante este principio, se respeta la voluntad mayoritaria de los acreedores que expresan su acuerdo con las proposiciones de reorganización de la empresa deudora. En consecuencia, el acuerdo aprobado, obliga no solo a los acreedores que concurrieron a la formación de éste sino que a la totalidad de los acreedores, incluso a aquellos que no concurrieron a la junta.

¿Por qué esto es así? Para evitar presiones indebidas por los demás acreedores. Si no les afectara el acuerdo, van a empezar a iniciar procedimientos compulsivos que afecten el activo del deudor, o a lo menos le van a quitar energía.

2.8.1 Efectos sobre los créditos

De acuerdo al artículo 93, los créditos que son parte del Acuerdo se entienden remitidos, novados o repactados, según corresponda, para todos los efectos legales.

El acreedor, contribuyente del impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta puede deducir como gasto necesario las cantidades que correspondan a la condonación o remisión de deudas, intereses, reajustes u otras cantidades que se hayan devengado en su favor, siempre y cuando cumpla con las siguientes condiciones copulativas:

- a) Que se trate de créditos otorgados o adquiridos con anterioridad al plazo de un año contado desde el Acuerdo de Reorganización.
- b) Que dicha condonación o remisión conste detalladamente en el referido Acuerdo o sus modificaciones.
- c) Que no correspondan a créditos de personas relacionadas con el deudor ni a créditos de acreedores personas relacionadas entre sí, cuando éstos, en su conjunto, representen el 50% o más del pasivo reconocido con derecho a voto. De lo contrario, habría posibilidad de que esto esconda donaciones encubiertas (ej. hijo le debe plata al padre, y el padre condona la deuda completa).

Esto último es una innovación de la ley. Antes, si habían remisiones o condonaciones, ellos se consideraban como gastos rechazados que pagan impuestos (lo mismo sucedía en casos de

transacciones, lo que era un incentivo a mejor seguir adelante con el juicio). Hoy en día se deducen como gastos las remisiones o condonaciones de deuda.

2.8.2 Efectos sobre las inscripciones

Otro de los efectos inmediatos a la aprobación del acuerdo de reorganización, es la cancelación de las inscripciones previstas en el número 7) del artículo 57, es decir, aquellas que ordena la resolución judicial que se dicta cuando se abre el procedimiento de reorganización y que practica el veedor al inscribir esta resolución, en los conservadores de bienes raíces correspondientes, al margen de la inscripción de propiedad de cada uno de los inmuebles que pertenecen al deudor.

2.8.3 Efectos sobre la intervención del veedor

Además, cesa la intervención que impone el N°2 letra a) del artículo 57, sin perjuicio que se mantiene la presencia del veedor en la empresa deudora por lo menos un año, con el objeto que supervise el cumplimiento del Acuerdo, con las facultades y deberes que al efecto determinen los acreedores.

2.8.4 Prohibición de repartos y de reducciones de capital

Durante la ejecución del Acuerdo, todos los recursos deben orientarse a mantener el giro de la compañía, de modo tal que se pueda desarrollar operativamente para cumplir con las obligaciones de pago establecidas en el acuerdo.

Por esta razón, el artículo 67 impone varias prohibiciones a la empresa deudora, salvo que los acreedores expresamente lo autoricen en la forma que lo determine el Acuerdo:

- a) Repartir dividendos o cualquier suma a sus accionistas o socios, bajo ningún concepto, ni directa ni indirectamente.
- b) Hacer modificaciones estatutarias ni actos en el ejercicio que importen una reducción del capital, para provocar alguna modalidad de reparto a los socios o accionistas de la empresa deudora.
- c) Condonar los préstamos otorgados.

Se trata es que no se produzcan alteraciones en el patrimonio distintas a las propias que se originen durante el giro de la empresa deudora, de modo tal de poder cumplir con las estipulaciones del Acuerdo.

2.8.5 Efectos tributarios

- a) Impuesto a las Ventas y Servicios - IVA

Con propósito de incentivar la participación de los acreedores en los acuerdos de reorganización, la ley establece en estos procedimientos una modalidad de recuperación del IVA.

Si la empresa deudora hace una factura, lo que está esperando es que quien pague al final pague y financie el 19% del IVA. Por lo tanto si alguien no paga ese 19%, la empresa deudora tiene que financiarlo. Antes, el procedimiento de recuperación del IVA en estos procedimientos era súper

lento, y esta ley buscó una modalidad de recuperación más rápida que no afectara el flujo de caja del acreedor (la empresa deudora).

b) Ley sobre Impuesto a la Renta

Con el propósito de incentivar la participación de los acreedores en los acuerdos de reorganización donde sea necesario establecer condonaciones o remisiones de parte del crédito, que muchas veces son necesarios para mantener la continuidad operacional de la empresa deudora, el artículo 93 establece que el acreedor, contribuyente del impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta puede deducir como gasto necesario las cantidades que correspondan a la condonación o remisión de deudas, intereses, reajustes u otras cantidades que se hayan devengado en su favor, siempre y cuando cumpla con las siguientes condiciones copulativas:

- Que se trate de créditos otorgados o adquiridos con anterioridad al plazo de un año contado desde el Acuerdo de Reorganización.
- Que dicha condonación o remisión conste detalladamente en el referido Acuerdo o sus modificaciones.
- Que no correspondan a créditos de personas relacionadas con el deudor ni a créditos de acreedores personas relacionadas entre sí, cuando éstos, en su conjunto, representen el 50% o más del pasivo reconocido con derecho a voto.

2.8.6 Efectos sobre los bienes

2.8.6.1 Determinación de si los bienes dados en garantía por el deudor son o no esenciales

Cuando la empresa deudora solicita la apertura del procedimiento de reorganización y hace la manifestación de su activo conforme lo ordena el artículo 56, debe señalar los bienes que son objeto de garantía real y que tienen la calidad de ser esenciales para el giro de la empresa deudora, para los efectos que el tribunal así lo declare y se pueda mantener la unidad productiva, necesaria para dar cumplimiento al acuerdo de reorganización.

Por su parte, el artículo 94 señala que en el plazo de ocho días siguientes a la publicación de la resolución de reorganización, el acreedor cuyo crédito se encuentre garantizado con prenda o hipoteca puede solicitar fundadamente al tribunal competente que declare que el bien sobre el que recae su garantía no es esencial para el giro de la empresa deudora.

La determinación de lo anterior produce efectos relevantes, porque **si se resuelve que el bien es esencial** para el giro de la empresa deudora, entonces no puede ser objeto de ejecución hipotecaria o prendaria y queda a disposición del deudor para los fines que el giro lo requiera.

Para resolver lo anterior, el artículo 94 señala que el tribunal puede solicitar al veedor un informe que contenga la calificación de si bien es o no esencial para el giro de la empresa deudora y el avalúo comercial del bien sobre el que recaen las garantías.

El tribunal debe resolver dicha calificación en única instancia, a más tardar el segundo día anterior a la fecha de celebración de la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre las

proposiciones de Acuerdo de Reorganización Judicial, resolución que produce los siguientes efectos:.

a) Si el tribunal resuelve que el bien no es esencial para el giro de la empresa deudora:

- i) El acreedor garantizado queda en libertad de acción de ejecutar su garantía fuera del concurso.
- ii) El acreedor garantizado concurre y vota en la clase de acreedores valistas, únicamente por el saldo del crédito no cubierto por la garantía; es decir, su voto corresponde al monto de su crédito, menos el valor comercial del bien sujeto a garantía.

Hay que recordar que el monto del crédito del acreedor hipotecario o prendario y el avalúo comercial del bien sujeto a garantía se conocen porque quedaron fijados en la fase de la determinación del pasivo que regulan los artículos 70 y siguientes.

- Si el valor de la garantía supera el monto del crédito, no puede concurrir ni votar en la clase de acreedores valistas.
 - Si al ejecutar su garantía su crédito no es enteramente cubierto por el valor de su liquidación, el acreedor puede solicitar que dicho Acuerdo se cumpla a su favor mientras no se encuentren prescritas las acciones que emanen de él.
 - Si al ejecutar su garantía queda un excedente a favor de la empresa deudora, éste se debe destinar al cumplimiento del Acuerdo, para lo cual el veedor debe velar para que los fondos efectivamente ingresen a la caja del Deudor.
- iii) Dado que el acreedor garantizado se margina inicialmente del concurso, el crédito que se encuentra cubierto por la garantía no se debe considerar en el pasivo de la clase o categoría de acreedores garantizados, para los efectos del cómputo de las mayorías.

b) Si el tribunal resuelve que el bien no es esencial para el giro de la empresa deudora y éste pertenece a terceros

- i) Conforme lo establece el artículo 95 N°3, si el respectivo acreedor vota a favor o en contra del Acuerdo, se debe sujetar a los términos y modalidades establecidas en éste y no puede perseguir su crédito en términos distintos a los estipulados.
- ii) Si este acreedor manifiesta su intención de no votar o no asiste a la junta de acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo:
 - Su crédito no se debe considerar en el pasivo con derecho a voto correspondiente a su clase o categoría
 - Puede cobrar su crédito respecto de las prendas o hipotecas otorgadas por terceros.

c) Si el tribunal resuelve que el bien es esencial para el giro de la empresa deudora

El artículo 95 señala que se deben aplicar los términos y modalidades establecidos en el Acuerdo, no pudiendo los acreedores ejecutar en forma separada los bienes hipotecados o pignorados.

Lo anterior no significa que el acreedor tiene que votar favorablemente el acuerdo de reorganización. Éste queda en libertad de acción para emitir su voto en los términos que resulten más convenientes para sus intereses.

En todo caso, el acreedor mantiene su garantía hipotecaria, la cual puede hacer efectiva conforme a las reglas generales del concurso, si como consecuencia de una declaración de incumplimiento del acuerdo, se produce la liquidación de la empresa deudora.

2.8.7 Efectos sobre las obligaciones garantizadas con cauciones personales

Respecto de los créditos garantizados con cauciones personales, el artículo 95 señala lo siguiente en su numeral cuarto:

- a) Si el respectivo acreedor vota en su clase o categoría de valista a favor del Acuerdo, se debe sujetar a los términos y modalidades establecidos en él y no puede cobrar su crédito en términos distintos a los estipulados.

Esto significa que el garante (avalista, fiador o codeudor solidario) se beneficia de los términos del Acuerdo y no se le puede exigir el cumplimiento de la obligación de una manera diferente.

Sin perjuicio de este beneficio, para mantener la caución, se debe exigir que el garante concurra a la suscripción del acuerdo de reorganización, porque si no lo hace se extingue su responsabilidad conforme lo establecen los artículos 1519 y 1645 del Código Civil. De lo contrario, se pierde la caución personal.

Una pregunta interesante es si ¿la aprobación del acuerdo de reorganización supone incumplimiento por parte del deudor principal?

- b) Si el respectivo acreedor manifiesta su intención de no votar o no asiste a la junta de acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta del Acuerdo:
 - b.1 Su crédito no se considera en el pasivo con derecho a voto correspondiente a su clase o categoría
 - b.2 Puede cobrar su crédito respecto de los fiadores o codeudores, solidarios o subsidiarios, o avalistas en los términos originalmente pactados.
- c) Finalmente, el fiador, codeudor, solidario o subsidiario, avalista, tercero poseedor de la finca hipotecada o propietario del bien prendado que hubiere pagado, puede ejercer según corresponda, su derecho de subrogación o reembolso, mediante un procedimiento incidental, ante el mismo tribunal que conoció y se pronunció sobre el Acuerdo, solicitando de éste se cumpla a su favor, mientras no se encuentren prescritas las acciones que de él resulten.

2.8.8 Mérito Ejecutivo

El artículo 90 establece que una copia del acta de la junta de acreedores en la que conste el voto favorable del Acuerdo y su texto íntegro, junto a la copia de la resolución judicial que lo aprueba y su certificado de ejecutoria, puede ser autorizada por un ministro de fe o protocolizarse ante un notario público.

Una vez autorizada o protocolizada, tiene mérito ejecutivo para todos los efectos legales.

2.9 El Rechazo del Acuerdo de Reorganización

2.9.1 Regla General

Si los acreedores llamados a aprobar el acuerdo de reorganización rechazan la propuesta de la empresa deudora, el artículo 96 señala que el tribunal debe dictar la resolución de liquidación de oficio y sin más trámite, en la misma junta de acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre el Acuerdo.

2.9.2 Excepción

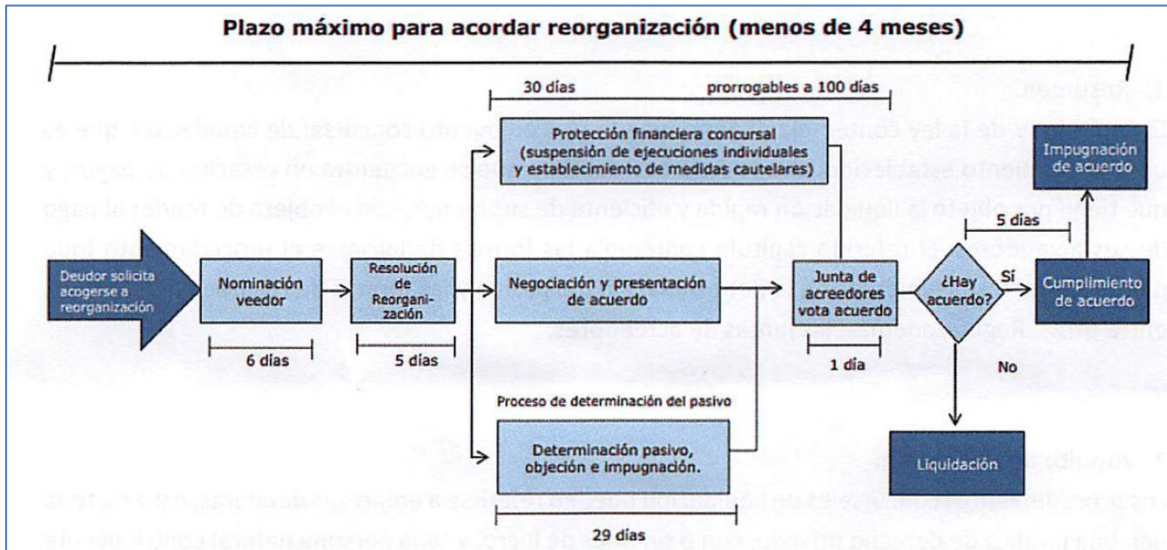
En todo caso, la referida junta puede disponer otra cosa, con quórum especial (2/3 del pasivo total), abriendo la posibilidad para que el deudor haga otra propuesta de reorganización.

- a) Si los acreedores acuerdan autorizar a la empresa deudora para que reformule su propuesta de reorganización que fue rechazada, se debe fijar una nueva fecha para la junta de acreedores que debe llevarse a cabo dentro de los 20 días siguientes a la fecha de la junta que rechazó el Acuerdo.
- b) En este caso la empresa deudora debe acompañar al tribunal su nueva propuesta de reorganización 10 días antes de la fecha fijada para la junta que tendrá por objeto pronunciarse sobre ésta.
- c) Además, el deudor debe a través del veedor, publicar una nueva propuesta de Acuerdo en el Boletín Concursal.
- d) Durante este período el deudor conserva la Protección Financiera.
- e) Si el deudor no presenta la nueva propuesta de Acuerdo dentro del plazo antes establecido, el tribunal debe dictar la resolución de liquidación de oficio y sin más trámite.

2.9.3 Nombramiento de Liquidador

Finalmente, el inciso final del citado artículo 96 previene que la junta de acreedores que rechace la primera o segunda propuesta de Acuerdo, en su caso, debe nominar a los liquidadores titular y suplente, a los que el tribunal competente debe designar con el carácter de definitivos.

Proceso de Reorganización – Resumen y Plazos:



2.10 La Nulidad y Declaración de Incumplimiento del Acuerdo de Reorganización

2.10.1 Acción de Nulidad

El convenio, como cualquier contrato, puede adolecer de un vicio que suponga su ineficacia total (nulidad). En materia concursal, la nulidad tiene un significado y un tratamiento distinto al señalado en los artículos 1681 y siguientes del Código Civil.

- a) Causales: Si con *posterioridad a la aprobación* del acuerdo de reorganización (antes de la aprobación solo hay impugnación) y después de vencido el plazo para impugnar éste, se descubre que la empresa deudora procedió a la **ocultación o exageración del activo o del pasivo**, los acreedores y cualquier interesado pueden deducir esta acción de nulidad del acuerdo. Esta causal lógicamente impide que haya un consentimiento libre de quienes aprobaron el convenio (al menos hay error).

El artículo 97 que regula la nulidad, señala que no se admiten otras acciones en contra del Acuerdo que las fundadas en la ocultación o exageración del activo o del pasivo.

Asimismo, la ocultación o exageración del activo o pasivo también es causal de impugnación del acuerdo de reorganización judicial (art. 85 N° 5).

- b) Efectos específicos:

- i) El inciso segundo señala que la declaración de nulidad del Acuerdo extingue de pleno derecho las cauciones que lo garantizan. Esto es porque los garantes no pueden verse perjudicados con motivo de las maniobras que realice la empresa deudora, para aprobar el Acuerdo de reorganización o modificar dolosamente sus efectos. En este caso, los terceros han actuado de buena fe y deben ser protegidos por la norma.
- ii) Siempre que la resolución que la dicte se encuentre a firme y ejecutoriada, el artículo 100 señala que se debe dictar la resolución de liquidación de la empresa deudora de *oficio y sin más trámite*.

- iii) Los acreedores y el liquidador en su caso, pueden interponer la acción para perseguir la responsabilidad penal atribuible al deudor, por la eventual comisión de los delitos concursales de los artículos 463 N°1 y 463 ter N°1 del Código Penal.
- c) Prescripción: La acción de nulidad prescribe en el plazo de un año contado desde la fecha en que el Acuerdo de reorganización comenzó a regir.

2.10.2 Acción de Incumplimiento

La acción de incumplimiento, por su parte, apunta a requerir que se deje sin efecto el Acuerdo de reorganización por no haberse dado cumplimiento a las estipulaciones contenidas en éste. Es el símil de la condición resolutoria tácita que va envuelta en todo contrato bilateral, no obstante que en la especie estamos frente a un acuerdo múltiple y de efectos especiales.

- a) Ejercicio de la Acción
 - i) El artículo 98 previene que esta acción puede ser deducida por cualquiera de los acreedores a los que les afecte por inobservancia de sus estipulaciones. Puede que el deudor esté cumpliendo para alguna clase de acreedores pero no para otra, y solo un acreedor de esa clase puede ejercer la acción.
 - ii) Puede también declararse incumplido si se hubiere agravado el mal estado de los negocios del deudor de forma que haga temer un perjuicio para dichos acreedores; es decir, por las mismas razones que el artículo 1496 del Código Civil habilita la caducidad del plazo en materia de obligaciones.
 - iii) No obstante lo anterior el artículo 98 admite una modalidad para enervar la acción, únicamente cuando se deduce sólo por la inobservancia de las estipulaciones de una de las clases o categorías de acreedores

En este caso, el deudor puede enervar la acción cumpliendo dichas estipulaciones dentro del plazo de 60 días contado desde la notificación de la acción. También puede un tercero cumplir por el deudor.

Expirado este plazo sin que se verifique el pago o la prestación debida, el tribunal debe dictar la resolución de incumplimiento y debe procederse a la apertura del procedimiento de liquidación (por eso es causal de incumplimiento).

El deudor puede enervar la acción de incumplimiento por una sola vez, para cada categoría o clase del Acuerdo.

Esto se explica porque cuando hay distintos acuerdos, y un acreedor perjudicado por el incumplimiento solicita que se declare el incumplimiento y que se deje sin efecto el acuerdo, la ley permite solucionar el problema de esos acreedores sin perjudicar a los demás acreedores.

- b) Efectos
 - i) Si se dicta la resolución de incumplimiento se deja sin efecto el Acuerdo.

- ii) Sin embargo no se extinguen las cauciones que hubieren garantizado la ejecución total o parcial del Acuerdo, porque precisamente éstas se constituyen para asegurar el cumplimiento del mismo; en otras palabras, a partir de la declaración de incumplimiento, nace el ejercicio de las acciones en contra de los garantes y de las personas obligadas por las cauciones personales que no se extinguen y los terceros poseedores de los bienes gravados con las mismas, quienes según sea el caso, deben ser oídos en el juicio de declaración de incumplimiento y pueden impedir la continuación de éste enervando la acción mediante el cumplimiento del Acuerdo dentro de los 3 días siguientes a la citación.
- iii) Las cantidades pagadas por el deudor antes de la declaración de incumplimiento del Acuerdo y el producto obtenido durante el procedimiento de liquidación sirven de abono a la deuda en caso que la caución se extienda a toda la suma estipulada.

Pero si comprende únicamente una parte de ella sólo servirá para imputarla a la parte que reste de la cuota no caucionada.

- iv) Siempre que la resolución que dicte el incumplimiento se encuentre a firme y ejecutoriada, el artículo 100 señala que se debe dictar la resolución de liquidación de la empresa deudora de oficio y sin más trámite

c) Prescripción

Las acciones de incumplimiento del Acuerdo prescriben en el plazo de un año contado desde que se produce el incumplimiento.

2.10.3 Procedimiento de Declaración de Nulidad e Incumplimiento del Acuerdo

- a) Tipo de Procedimiento: Conforme lo indica el artículo 99, la declaración de nulidad o incumplimiento se conoce en juicio sumario
- b) Tribunal competente: es competente para conocer estas acciones el tribunal ante el cual se tramitó el Acuerdo.
- c) Recurso de apelación: Si el tribunal acoge las acciones de nulidad o incumplimiento del Acuerdo, esta resolución es apelable y la apelación se otorga en ambos efectos, pero el deudor queda de inmediato sujeto a la intervención de un veedor con las facultades de interventor contenidas en los números 1), 7), 8) y 9) del artículo 25.
- d) Efectos:
 - i) La declaración de nulidad o incumplimiento del Acuerdo no tiene efecto retroactivo y no afecta a la validez de los actos o contratos debidamente celebrados en el tiempo que media entre la resolución que aprueba el Acuerdo y la que declare la nulidad o el incumplimiento.

Lo anterior se establece para dar seguridad jurídica a los actos o contratos que han celebrado los terceros con la empresa deudora, a quienes no les empece la circunstancia de haberse declarado nulo o incumplido un determinado acuerdo de reorganización.

- ii) Las consecuencias que trae consigo la declaración de nulidad o incumplimiento de un acuerdo de reorganización es la liquidación refleja de la empresa deudora.

En efecto, el artículo 100 señala que una vez firme y ejecutoriada la resolución que declare la nulidad o el incumplimiento del Acuerdo, el mismo tribunal debe dictar la resolución de liquidación de la empresa deudora de oficio y sin más trámite.

Para los efectos de la designación de los liquidadores, al artículo 101 señala que en la demanda de nulidad o de incumplimiento del Acuerdo, el demandante debe proponer a un liquidador titular y a uno suplente de la Nómina de Liquidadores vigente, debiendo el tribunal designarlos en la resolución de liquidación y si se interpusiere más de una demanda de nulidad o de incumplimiento del Acuerdo, el tribunal competente debe designar a los liquidadores titular y suplente nominados en la primera demanda que se acoja.

2.11 Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado

La Ley N° 20.720 estableció los Acuerdos de Reorganización Extrajudicial o simplificados, para regular aquellos casos en que no existe una multiplicidad de acreedores y el pasivo se encuentra concentrado mayoritariamente solo en algunos. La ley ha realizado un gran esfuerzo para destigmatizar el procedimiento concursal otorgando herramientas jurídicas a la empresa deudora que siendo viable, pueda lograr nuevas condiciones con sus acreedores para el servicio de sus deudas o para la reorganización de sus activos.

Se busca un procedimiento aún más rápido del que ya hemos estudiado. Vienen a reemplazar los convenios extrajudiciales que eran muy débiles (era muy fácil que se cayeran). Ahora, aunque es extrajudicial igual requiere de aprobación por parte del juez: la única diferencia es que las partes van a llegar con la propuesta lista.

Sin embargo, y por mucho que se haya establecido un nuevo procedimiento de reorganización, la sola circunstancia que éste se inicie desde el primer momento en sede jurisdiccional hace que de una u otra manera se tensione la relación de la empresa deudora con sus acreedores y, en especial, con los proveedores de bienes y servicios, quienes normalmente son más sensibles a estos procesos por su capacidad económica y respaldo financiero.

En estos casos la ley estableció un procedimiento especial y simplificado que se inicia en el ámbito extrajudicial, donde se recaban las mayorías necesarias para el acuerdo de reorganización y se lleva a la sede jurisdiccional para ser refrendado y legitimado por todos los acreedores.

2.11.1 Legitimación y Competencia

El artículo 102 establece que toda empresa deudora puede celebrar un Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o simplificado con sus acreedores y someterlo a aprobación judicial, siempre que se dé cumplimiento a las normas de esta modalidad especial de acuerdo.

Para estos efectos, es competente para aprobarlo el tribunal competente para conocer de un procedimiento de reorganización del deudor.

2.11.2 Formalidades y Objeto del Acuerdo

- a) Formalidades: El acuerdo simplificado debe otorgarse ante un ministro de fe o ante un ministro de fe de la Superintendencia, quien debe certificar, además, la personería de los representantes que concurran al otorgamiento de este instrumento, cuyas copias autorizadas deberán agregarse al Acuerdo respectivo.

Recordemos la importancia de las personerías en tanto en este caso la empresa deudora se obliga de manera distinta a como originalmente se había pactado.

- b) Objeto: Al igual que el acuerdo de reorganización judicial, este Acuerdo simplificado puede versar sobre cualquier objeto tendiente a reestructurar los activos y pasivos del deudor.

2.11.3 Normas Aplicables y Requisitos para la Apertura de este Procedimiento

- a) Normas aplicables: De acuerdo al artículo 106, las normas que le son aplicables son las que corresponda conforme a la naturaleza de este especial procedimiento y aquellas que están contenidas los Títulos 1 y 2 del Capítulo III, en lo relativo a:

1. Los acuerdos por clases o categorías de acreedores
2. La determinación del pasivo
3. Propuestas alternativas
4. Diferencias entre acreedores de igual clase o categoría
5. Condonación o remisión de créditos
6. Constitución de garantías
7. Cláusulas de arbitraje
8. Nombramiento del interventor y designación de la comisión de acreedores

- b) Quórum del Acuerdo Simplificado

Para que se entienda acordado el acuerdo extrajudicial o simplificado, el artículo 109 señala que el Acuerdo Simplificado debe ser suscrito por el deudor y por dos o más acreedores que representen al menos tres cuartas partes del total de su pasivo, correspondiente a su respectiva clase o categoría.

Este quórum es superior a los dos tercios del total pasivo que exige el inciso segundo del artículo 79 para la aprobación de los acuerdos de reorganización. El legislador ha querido hacer esta diferenciación para que un acuerdo no tomado en esfera jurisdiccional cuente con un respaldo mayor de acreedores.

Al igual que en los acuerdos de reorganización, las personas relacionadas con el deudor no pueden suscribir un Acuerdo Simplificado, ni sus créditos se consideran en el monto del pasivo para los

efectos de la determinación del quórum de aprobación del referido Acuerdo y los cesionarios de créditos adquiridos dentro de los treinta días anteriores a la fecha de la presentación a aprobación judicial del Acuerdo Simplificado tampoco se consideran para dicho quórum.

- c) Requisitos: El artículo 107 señala que para la aprobación judicial del Acuerdo Simplificado, éste debe presentarse ante el tribunal competente junto con:
 - i) Los antecedentes singularizados en el artículo 56
 - ii) Un listado de todos los juicios y procesos administrativos seguidos contra el deudor que tengan efectos patrimoniales, con indicación del tribunal, órgano de la Administración del Estado, rol o número de identificación y materias sobre las que tratan estos procesos.
 - iii) Un informe de un veedor de la nómina de veedores elegido por el deudor y sus dos principales acreedores, que debe contener la calificación fundada sobre lo siguiente:
 - Si la propuesta es susceptible de ser cumplida habida consideración de las condiciones del deudor
 - El monto probable de recuperación que le correspondería a cada acreedor en sus respectivas categorías en caso de un procedimiento de liquidación
 - Si la determinación de los créditos y su preferencia presentada por el deudor se ajusta a la ley

2.11.4 Actuación del Tribunal

- a) Protección financiera concursal: Presentado el acuerdo simplificado para su aprobación, el tribunal debe dictar una resolución judicial similar a la establecida en el artículo 54 donde se otorga una protección financiera concursal a la empresa deudora, hasta que culmine el procedimiento de aprobación judicial de este acuerdo.

El artículo 108 señala que una vez que se ha presentado la solicitud de aprobación judicial del Acuerdo Simplificado y hasta su aprobación judicial, el tribunal debe disponer:

- i) La prohibición de solicitar la liquidación forzosa del deudor y de iniciarse en su contra juicios ejecutivos, ejecuciones de cualquier clase o restitución en los juicios de arrendamiento.

Lo anterior no se aplica a los juicios laborales sobre obligaciones que gocen de preferencia de primera clase, suspendiéndose en ese caso sólo la ejecución y realización de bienes del deudor, excepto los que el deudor tuviere en tal carácter a favor de su cónyuge o de sus parientes o de los gerentes, administradores, apoderados con poder general de administración u otras personas que hayan tenido o tengan injerencia en la administración de sus negocios.

Para estos efectos, se entiende por parientes a los ascendientes y descendientes y los colaterales por consanguinidad y afinidad hasta el cuarto grado, inclusive.

- ii) La suspensión de la tramitación de los procedimientos ya iniciados y la suspensión de los plazos de prescripción extintiva.
- b) Restricciones para la empresa deudora: A diferencia del procedimiento de reorganización, el deudor no queda sujeto a la intervención de un veedor y tampoco se le restringe la facultad de la modificar sus pactos, estatutos sociales o régimen de poderes, como lo ordena el citado artículo 57 N° 2 letra c).

No obstante lo anterior, la resolución antes referida impone:

- i) La prohibición al deudor de gravar o enajenar sus bienes, salvo los que resulten estrictamente necesarios para la continuación de su giro.
- ii) En cuanto a la venta de sus activos, aunque el artículo 108 nada dice, es perfectamente posible que la empresa deudora pueda vender o enajenar activos cuyo valor no exceda el 20% de su activo fijo contable y si requiere una venta que supere la limitación anterior, se requiere la autorización de los acreedores, conforme lo dispone el artículo 74.

2.11.5 Publicidad, Impugnación, Aprobación Judicial del Acuerdo y sus Efectos

- i) Publicidad: Para los efectos de dar a conocer a los acreedores el Acuerdo Simplificado, el artículo 110 establece que junto con presentar al tribunal este acuerdo con los antecedentes señalados en el artículo 107, el deudor debe acompañar al veedor una copia para que los publique en el Boletín Concursal y los acompañe a los acreedores por medio de correos electrónicos, si los tiene.
- ii) Junta de acreedores: De acuerdo al artículo 112, dentro de los 10 días siguientes a la publicación del Acuerdo Simplificado, el tribunal **puede** citar a todos los acreedores a quienes afecte el acuerdo para su aceptación ante el tribunal.
- iii) Impugnación: Dentro de los 10 días siguientes a la publicación del Acuerdo Simplificado, los acreedores disidentes y aquellos que demuestren haber sido omitidos de los antecedentes previstos en el artículo 107 pueden impugnar este acuerdo.

El artículo 111 señala que la impugnación debe fundarse en:

- A) Las causales del artículo 85 respecto de los acuerdos de reorganización.

Para un correcto análisis de esta norma, es necesario repasar nuevamente las causales de impugnación que se indican en el artículo 85 de modo de ver cuáles de ellas son aplicables o pueden ser consideradas como válidas para fundar una impugnación al Acuerdo Simplificado.

Este artículo señala las siguientes causales de impugnación:

- i) Defectos en las formas establecidas para la convocatoria y celebración de la junta de acreedores, que hubieren impedido el ejercicio de los derechos de los acreedores o del deudor.

Esta causal no podría invocarse porque se establece para proteger a los acreedores a quienes se les ha impedido actuar en el procedimiento de Reorganización por haber existido defectos en la convocatoria y celebración de la junta:

En los Acuerdos Extrajudiciales no hay junta de acreedores, salvo que en términos muy excepcionales el Tribunal haga uso de la facultad contenida en el artículo 112 de citar a una junta para estos efectos. En este caso excepcional, podría invocarse esta causal de impugnación del acuerdo.

Si fuere este el caso, se aplicaría lo mismo que en los Acuerdos de reorganización, en el sentido que lo determinante es que estos vicios causen un perjuicio al acreedor en términos tales que con motivo de estos defectos de forma, él no hubiera podido asistir a la junta que citó el tribunal y consecuentemente no hubiera podido ejercer los derechos que la ley le confiere.

- ii) El error en el cómputo de las mayorías requeridas, siempre que incida sustancialmente en el quórum del Acuerdo.

Esta causal apunta al correcto cómputo de las mayorías de aprobación requerida en el artículo 109.

Este error puede estar en cualquier componente del quórum compuesto que se señalan en estas disposiciones:

- De números de acreedores concurrentes a la suscripción del acuerdo (dos o más).
- Sobre el monto de los créditos que determinan el universo del pasivo.

Solo se puede dejar sin efecto el Acuerdo si el error en el cómputo es incidente en la determinación de los quórum de aprobación.

- iii) Otras causales (causales de fonfo).

Las siguientes causales también son plenamente aplicables a los Acuerdos Extrajudiciales.

- 1) Falsedad o exageración del crédito.
- 2) Incapacidad o falta de personería para votar de alguno de los acreedores que hayan concurrido con su voto a formar el quórum necesario para el Acuerdo, si excluido este acreedor o la parte falsa o exagerada del crédito, no se logra el quórum del Acuerdo.
- 3) Ocultación o exageración del activo o pasivo.
- 4) Por contener una o más estipulaciones contrarias a lo dispuesto en la ley.

- B) La existencia, los montos y las preferencias de los créditos.

- iv) Notificación: Una copia de la impugnación y de los antecedentes que la fundan debe ser publicada en el Boletín Concursal por el veedor.
- v) Tramitación: El artículo 111 agrega que las impugnaciones al Acuerdo Simplificado se tramitan como incidente y se deben fallarse conjuntamente en una audiencia única, que el

tribunal debe citar para tal efecto y que se debe celebrarse dentro de los 10 días siguientes de vencido el plazo para impugnar.

Esta audiencia es verbal y se lleva a cabo con los que asistan.

- vi) Recurso: La resolución que se pronuncie sobre las impugnaciones se debe publicar en el Boletín Concursal y es apelable en el solo efecto devolutivo.
- vii) Aprobación judicial: El artículo 112 indica que una vez aceptado el Acuerdo Simplificado y vencido el plazo para presentar impugnaciones sin que se hayan interpuesto o si, deducidas, se han rechazado por resolución que se encuentre firme y ejecutoriada, el tribunal competente, previa verificación del cumplimiento de requisitos legales, debe dictar la correspondiente resolución aprobando el Acuerdo Simplificado, debiendo el veedor publicarla en el Boletín Concursal.
- viii) Efectos: Una vez que aprueba judicialmente el acuerdo extrajudicial o simplificado, se producen todos los efectos previstos en los artículos 91 y siguientes, en cuanto les fueren aplicables.

2.11.7 Nulidad e Incumplimiento del Acuerdo Simplificado

Como el acuerdo extrajudicial o simplificado, participa de la misma naturaleza jurídica que el acuerdo de reorganización, les son aplicables todas las normas que regulan la nulidad y declaración de incumplimientos del mismo.

En la práctica, no se ha usado mucho este acuerdo simplificado, porque da más seguridad el acuerdo normal en cuanto a su procedimiento. Obviamente al deudor le conviene este acuerdo, pero el acreedor prefiere el otro porque hay más posibilidades de participación.

3. El procedimiento concursal de liquidación

Como ya hemos señalado anteriormente, frente a una situación de insolvencia el deudor o los acreedores pueden intentar llegar a un acuerdo para acordar la reorganización de la persona jurídica, como una primera opción que busca evitar la disrupción que supone en definitiva la desaparición de un comerciante.

Sin embargo, indudablemente existen situaciones en que el daño que se produce a la actividad mercantil es superior si es que se mantiene la existencia de un comerciante que no es y no va a ser capaz de cumplir con sus obligaciones, lo que impide el normal funcionamiento en el tiempo de toda la cadena de producción, intermediación y consumo de todo tipo de bienes y servicios.

Hay deudores que hagamos lo que hagamos no van a poder salir de esa situación de cesación de pago y el perjuicio que se produce se mantiene el pie al deudor es mayor a el perjuicio que se produce con su liquidación.

Es en estas situaciones donde la legislación concursal se ve en la necesidad de regular la liquidación y disolución de dichas empresas insolventes, ya sea porque per se lo son – y así queda

demostrado en el origen o en el transcurso del procedimiento concursal – o ya sea porque no han sido capaces de cumplir con los acuerdos exigidos en un proceso de reorganización.

Tenemos un procedimiento voluntario y uno forzoso, y este último recoge varias de las causales de quiebra que existían antiguamente en la Ley de Quiebras (bajo esta ley, se declaraba la quiebra si procedía la causal).

3.1 Inicio del Procedimiento de Liquidación

3.1.1 Liquidación Voluntaria

3.1.1.1 Iniciativa para solicitarla

Operacionalmente, el procedimiento de liquidación voluntaria depende de la voluntad del deudor, art. 115.

Por ello, es el deudor el que realiza la solicitud al tribunal al respecto. En este sentido, no es que existan causales de liquidación voluntaria sino que es el mismo deudor el que considera que se encuentra en un estado de cesación de pagos que, además, considera insalvable y que por lo tanto, estima adecuado someterse a un régimen universal de liquidación de sus bienes para el pago ordenado de tales deudas ante la imposibilidad de reorganizarse como una manera de cumplir con sus obligaciones.

Se parte del supuesto de que es el propio deudor quien conoce de mejor forma su estado patrimonial. Por eso en la reorganización se requiere participación activa del deudor, porque si él no está convencido de que pueda salir a flote, entonces no tiene sentido este procedimiento.

3.1.1.2 Rol de tribunal

Sin perjuicio de las formalidades y requisitos al respecto, la doctrina ha discutido el rol del tribunal en un proceso de liquidación voluntaria, y en específico si el tribunal puede negar lugar a la solicitud sobre la base de presumir que el deudor es solvente, o que puede someterse al Procedimiento de Reorganización, o que sus dificultades son transitorias o temporales.

En general la respuesta es derechamente negativa, o sea, el régimen se ha construido bajo la premisa del pleno respeto a la voluntad expresada por el deudor. Esta conclusión, por lo demás, no es nueva ni tampoco constituye una variación en el sistema imperante antes de la Ley 20.720, que así lo disponía.

Asimismo, existen otras razones particulares para ello:

- a) El sometimiento al Procedimiento Concursal de Liquidación integra el ámbito de decisiones propias de la autonomía de la voluntad, por lo que si el deudor es libre para obligarse válidamente, también lo será para efectuar declaraciones de voluntad que den cuenta de su situación patrimonial;
- b) El conocimiento acerca del mal estado de los negocios propios descansa, por cierto, en el mismo deudor, y nadie conoce mejor la realidad financiera personal que el propio deudor. No es lógico que el tribunal opte por indagar si efectivamente el solicitante presenta una

situación económica desmedrada, fundamentalmente, porque le será complejísimo acceder a tal conocimiento y porque, tal como señala Contador, siempre es conducente recordar que el régimen concursal no escapa del criterio general aplicable en tramitaciones civiles conocido como principio dispositivo, entendido, desde su perspectiva procesal. Cualquier potestad judicial que interfiriera en alguna de las vías expuestas importaría una intromisión estatal ilegítima, en contra de la libertad individual y titularidad de derechos;

- c) A mayor abundamiento, un sistema concursal como el chileno, construido en base a la cesación de pagos como cimiento intelectual, no admite que la autoridad jurisdiccional intervenga a la hora de efectuar una valoración subjetiva del fenómeno que genera la insolvencia, atribuyéndolo a circunstancias transitorias que considere superables y que por lo tanto podrían hacerle creer que la empresa deudora es viable.

Por último, también tenemos que tener en consideración que el procedimiento de liquidación concursal busca proteger la par conditio creditorum. De esta manera, se evita que el deudor privilegie a ciertos acreedores.

3.1.1.3 Antecedentes que se deben acompañar para solicitar la liquidación voluntaria

A la hora de discutir los antecedentes necesarios para que el deudor solicitara su liquidación en forma voluntaria, el legislador ponderó por una parte exigir los antecedentes mínimos indispensables para que el deudor pudiera concluir una situación traumática, pero por otro lado aquellos antecedentes que fueran necesarios para asegurar que dicha solicitud no estaba motivada por una intención fraudulenta en perjuicio de sus acreedores.

Por ello, la ley exige en el Art. 115 los siguientes antecedentes:

1) Lista de Bienes de la empresa deudora, con indicación del lugar en que se encuentren y los gravámenes que le afecten.

El propósito del legislador fue que el deudor incluyera una lista con los bienes que integran su patrimonio a título referencial o sujeta a modificaciones o complementos, en el entendido que los derechos y prerrogativas de acreedores y terceros se verán amparados en la labor incautadora que en su momento ejecutará el liquidador designado.

De esta forma, siempre sobre la base de la buena fe como elemento formativo, se permite una relación quizá no tan precisa o determinada para iniciar rápidamente el procedimiento. Si esto no se cumple de buena fe, tratándose de bienes no sujetos a registro, podrían haber sido fraudulentamente omitidos y, en ese caso, procedería la persecución penal.

A diferencia de la antigua legislación concursal, la ley vigente no exige que el deudor declare el avalúo de los bienes. Esto tiene sentido por cuanto antiguamente las consecuencias eran otras, siendo además que el hacer un avalúo de buena fé va a exigir la actuación de un tercero con el costo y tiempo que esto demanda, siendo que su utilidad es mínima por cuanto finalmente lo que

importará es el valor de liquidación efectiva percibida y no el valor en que el deudor estimó ex ante que dicho bien estaba valorizado.

El mencionar el lugar es una disposición práctica que precisamente tiene por objeto colaborar con la incautación del liquidador.

Por último, el señalar los gravámenes que les afectan responde a la lógica de determinar lo antes posible la posible existencia de preferencias sobre ellos por parte de algunos de los acreedores.

2) Lista de bienes legalmente excluidos de la liquidación

Corresponden a aquellos bienes que tienen tal condición según señala la ley.

3) Relación de sus juicios pendientes

Viene de la legislación antigua al respecto, ya que permite saber qué acciones judiciales se han iniciado para exigir el cumplimiento de las obligaciones del deudor, por cuanto – como se verá más adelante – sus efectos son distintos según el tipo de juicios de que se trate y la etapa procesal en que se encuentren.

Lo anterior adquiere relevancia ya que procede la acumulación de autos respecto a todos los juicios civiles y ejecutivos pendientes (arts. 142, 144 y 145 y art. 93 CPC).

4) Estado de deudas con nombre, domicilio y datos de contacto de los acreedores, así como la naturaleza de sus créditos

Si con las dos primeras letras la intención del legislador es tener una visión lo más completa posible de los activos del deudor y de la situación de los mismos, en esta letra la idea es tener un conocimiento concreto del nivel de pasivos existentes, sus créditos y el nivel de preferencias que dichos acreedores o créditos conllevan.

5) Nómina de trabajadores, cualquiera sea su situación contractual, con indicación de las prestaciones laborales y previsionales adeudadas y fueros en su caso.

Antiguamente, los contratos de trabajo se mantenían vigentes, no podían acceder a un finiquito y entonces no podían buscar otra pega. Entonces, al final en teoría quienes eran acreedores suprapreferentes (trabajadores) terminaban en una maraña administrativa. Pero hoy en día, termina la relación laboral cuando comienza la liquidación.

El legislador exige que el deudor identifique a las personas naturales con las que detenta una relación laboral en los términos del artículo 7° del Código del Trabajo. Lo expuesto no es más que una prueba de la intención de dar protección a los trabajadores con pleno respeto a sus garantías y derechos.

Desde la perspectiva concursal, es notorio que son los trabajadores del deudor afectado quienes resienten de inmediato y con graves consecuencias económicas, familiares y sociales, los efectos de una insolvencia judicialmente declarada. Entre otros muchos sucesos podemos destacar lo dispuesto en el Mensaje del Presidente de la República al señalar que la “falta de certeza sobre la continuidad de la situación contractual laboral, demoras en la obtención de los pagos que se les

adeudan, y trabas para la reinserción laboral, situaciones que usualmente conducen a interponer demandas judiciales y a requerir asistencia jurídica especializada”.

Para estos efectos, tanto el liquidador como los acreedores interesados podrán conocer a ciencia cierta las personas naturales que verán concluida su relación laboral con la empresa deudora con el solo mérito de la observancia de este requisito, fomentándose la rápida reinserción laboral; permitirá al liquidador advertir el tipo o clase de vínculo existente entre las partes, es decir, indefinido, por obra o faena, a plazo fijo, entre otros, a propósito de esclarecer las prestaciones que pudieren encontrarse adeudadas.

Además, nuestra legislación concursal ha previsto que esta nómina debe venir complementada con las deudas de naturaleza previsional que pudieren existir.

La importancia de esto radica en que la relación laboral termina cuando el empleador es sometido a un procedimiento concursal de liquidación. En este sentido los trabajadores quedan libres para volver a emplearse a partir de la dictación de la resolución de liquidación, sin perjuicio de ciertas obligaciones que debe cumplir el liquidador para con los trabajadores (art. 163 bis del C. del Trabajo).

6) Si el deudor llevar contabilidad completa presentará, además, su último balance.

Este antecedente no supone tampoco una carga mayor para el deudor, por cuanto es obligación propia de los comerciantes –salvo algunas excepciones– llevar contabilidad completa y presentar un balance como parte de sus obligaciones tributarias.

3.1.1.4 Tramitación

El tribunal revisa formalmente el cumplimiento de la entrega de los antecedentes antes mencionados, y de estar conformes debe:

- Nombrar un liquidador, según dispone el art. 37.
- Dictar la resolución de liquidación, según señala el art. 129.

3.1.2 Liquidación Forzosa.

3.1.2.1 Causales

Estas causales están concebidas como la forma en que uno o más acreedores, convencidos en que el deudor se encuentra en una situación de insolvencia (o intentando hacer ver de acuerdo a su conveniencia particular que el deudor se encuentra en dicha situación), solicitan la liquidación del deudor.

Son situaciones que son presupuestos objetivos de la situación de cesación de pagos.

Por lo tanto, ya no es el deudor quien tiene la iniciativa, sino que serán los acreedores quienes podrán solicitarla.

1) Artículo 117 N° 1:

“Si cesa en el pago de una obligación que conste en título ejecutivo con el acreedor solicitante”.

El acreedor interesado en solicitar la liquidación de su deudor sólo debe certificar la concurrencia genérica de dos aspectos: que ese deudor se encuentre dentro de la definición de empresa deudora -lo que debiera ser la regla general- y que la obligación que sustenta la acción conste en título ejecutivo.

Puede generar abusos por parte de los acreedores que amenazan con pedir la liquidación. En este caso como es difícil controvertir la causal, o bien me opongo con las excepciones del 464 CPC, o bien pago (incluso aunque el acreedor fuera valista y no tuviese preferencia) o bien inicio un procedimiento de reorganización.

En esto hay grandes diferencias con la antigua causal del art. 43, N° 1 de la ley antigua, que exigía que el deudor ejerciera una actividad comercial, industrial, agrícola o minera y que cesara en el pago de una obligación mercantil que constara en título ejecutivo, haciendo más simple, real y objetiva el ejercicio de esta causal.

En este sentido, la exigencia de que la obligación conste en un título ejecutivo solo eleva el umbral de responsabilidad del acreedor a la hora de invocar esta causal. En efecto, no podrá utilizar cualquier título sino que solo aquellos que tengan el carácter de ejecutivo, lo que indica que tuvo un tratamiento especial por las partes al momento de otorgarlo, dándole una dimensión distinta a la generalidad de obligaciones que no constan en dichos instrumentos por parte del deudor.

Tratamiento de las garantías personales

El inciso segundo del artículo 117 N° 1 señala lo siguiente:

"Esta causal no podrá invocarse para solicitar el inicio del Procedimiento Concursal de Liquidación respecto de los fiadores, codeudores solidarios o subsidiarios, o avalistas de la empresa deudora que ha cesado en el pago de las obligaciones garantizadas por éstos".

El hecho que no pueda iniciarse el Procedimiento Concursal de Liquidación respecto de fiadores, codeudores solidarios o subsidiarios o avalistas de la empresa deudora sólo es invocable, procedente o jurídicamente pertinente respecto de la exclusiva y excluyente causal ya descrita:

- Fiador: Se ve perjudicado ya que pierde el beneficio de excusión;
- Aval: Aplicable en títulos de crédito para garantizar obligaciones cambiarias manteniendo la acción de reembolso;
- Codeudor solidario: Pareciera que la norma se refiere más bien a la solidaridad pasiva, y no a generar una especie de quiebra consecuencial que iría mucho más allá de la intención del legislador al respecto, con el consiguiente efecto negativo para la actividad mercantil. Sin embargo, esta no es una interpretación unánime.
- Codeudor subsidiario: Caso más claro que el anterior.

2) Artículo 117 N° 2

"Cuando el deudor contra el cual existieren dos o más títulos ejecutivos y vencidos, provenientes de obligaciones diversas, y estuvieren iniciadas, a lo menos, dos ejecuciones, no hubiere presentado

en todas éstas, dentro de los cuatro días siguientes a los respectivos requerimientos, bienes bastantes para responder a la prestación que adeude y las costas”.

Esta causal no exige que la obligación ejecutiva se le adeude al peticionario, pudiendo cualquier acreedor iniciar el procedimiento de liquidación haciendo valer títulos ejecutivos ajenos.

Existe bastante consenso en la doctrina en cuanto a que si bien la redacción del artículo indica que estén iniciadas las ejecuciones, tal descripción debe entenderse suponiendo el **requerimiento de pago al demandado**.

Sin embargo, es evidente que difícilmente puede el deudor efectuar consignación alguna si no conoce legalmente de la existencia del litigio, menos aún cuando la misma norma le impone un plazo que se cuenta precisamente desde el requerimiento de pago.

Existen varias situaciones que se derivan de lo anterior:

a) Demanda de Liquidación Forzosa y excepciones opuestas

Deudor ha sido notificado y requerido de pago, dentro de plazo ha opuesto excepciones conforme al artículo 464 del CPC.

Según la ley, pareciera que se configura la causal, toda vez que la norma es clara a la hora de indicar que la única causal para excluir a un juicio ejecutivo de esta valoración es haber presentado bienes suficientes para responder de la prestación que adeude las costas.

Sin embargo, de la redacción del articulado, da la impresión que el legislador considera, en su análisis intelectual, que las obligaciones contenidas en el respectivo título ejecutivo son perfectas. En otras palabras, da a entender que el deudor no tiene nada que decir, toda vez que el instrumento se encuentra vencido, ha sido necesario llegar a juicio para perseguir el pago y ni siquiera se han presentado bienes suficientes para responder de él.

Pero, es perfectamente posible que el deudor no haya dado cumplimiento a la obligación descrita en el título por razones válidas y vinculantes, o bien que haya dado cumplimiento en tiempo y forma a la misma pero el acreedor igualmente lo demanda.

Dicho de otra manera: la sola circunstancia de haber sido notificado de un juicio ejecutivo no importa que la suma reclamada se adeude efectivamente o sea actualmente exigible, por lo que se configurará la causal en la medida en que se desechen las excepciones.

Asimismo, y en estricta relación al principio que convierte a la liquidación en ultima ratio, lo cierto es que la configuración de la ejecución para el efecto señalado en la norma, reclama que el título se encuentre libre de cuestionamientos, es decir, que efectivamente dé cuenta de una obligación líquida, actualmente exigible y que la acción que le sirve de fundamento no se encuentra prescrita extintivamente desde su ámbito ejecutivo.

b) Demanda de Liquidación Forzosa, excepciones opuestas rechazadas, con recursos pendientes.

En una aproximación preliminar, podríamos valorar que el escenario es idéntico al reseñado en el punto anterior: el mérito del título o de la acción ejecutiva ha sido puesto en tela de juicio por el demandado.

No obstante, en este caso, converge un elemento normativo que podría alterar la conclusión ya expuesta: tratándose de la sentencia de pago la situación sería distinta ya que el demandado sí habría consignado fondos suficientes, discutiendo la procedencia del pago reclamado.

Pero si la sentencia es de remate, la situación tiende a dificultarse, ya que el artículo 481 del CPC establece que una vez notificado ese fallo, se debe proceder a la venta de los bienes embargados.

La apelación tiene lugar en el solo efecto devolutivo, el que más bien tiene una incidencia ejecutiva, en el entendido que la interposición de la apelación no suspende ni paraliza necesariamente el cumplimiento efectivo de lo resuelto.

Por ello, el título ejecutivo y más propiamente la ejecución han recibido un reconocimiento o un espaldarazo jurisdiccional que habilita al actor a continuar con los actos propios del procedimiento de apremio. De hecho, si la subasta tiene lugar antes del pronunciamiento de la sentencia de segunda instancia (sin perjuicio de las eventuales exclusiones para detener ese llamado a remate) y posteriormente el fallo del tribunal de alzada revoca lo resuelto, la única defensa efectiva que le quedaría al ejecutado sería demandar de perjuicios al actor, pero no reclamar la nulidad del acto procesal en estudio.

Por lo tanto, consideramos que habría que esperar a que se resuelvan las excepciones para poder dar lugar a esta causal. Zegers cree que se puede continuar pero sin que se realicen actos de disposición.

c) Demanda de Liquidación Forzosa y enervamiento parcial de la causal

Supone que el deudor ha sido notificado de la demanda de Liquidación Forzosa, invocándose en su contra la causal que hemos venido tratando y, con el fin de destruir sus fundamentos, realiza consignaciones o presenta bienes suficientes en ambos juicios ejecutivos, aunque con el plazo de 4 días sobradamente vencido.

Si nos atenemos a una interpretación rigorista, este comportamiento del deudor no serviría para enervar la acción de Liquidación Forzosa, por cuanto la norma es clara al momento de consagrar un término legal para el señalamiento de bienes.

Sin embargo, nuestro régimen concursal descansa sobre la base de presunciones de insolvencia. La causal de Liquidación Forzosa en análisis responde al mismo criterio ya que si una empresa deudora mantiene dos ejecuciones provenientes de dos títulos ejecutivos vencidos y provenientes de obligaciones diversas, se entenderá que se encuentra en la incapacidad de sustentar el pago de sus deudas o débitos.

Esa presunción puede ser destruida o enervada de diversas formas, pero la más directa y atingente es, precisamente, evidenciando la solvencia. Esa prueba se materializa pagando las obligaciones demandadas judicialmente. Estimamos que el plazo previsto en la norma es referencial, busca

otorgar más certeza en el tribunal llamado a conocer de la demanda de Liquidación Forzosa a propósito de la falta de capacidad financiera del deudor, pero siempre bajo el prisma de hacer prevalecer, aun tardíamente, una manifestación palpable de la capacidad económica del demandado, siendo el pago la más explícita.

En razón de lo expuesto, pareciera ser más coherente con el espíritu de la legislación el permitir tener por no configurada la causal en estudio si la consignación o el señalamiento de bienes tienen lugar incluso después de los 4 días siguientes al requerimiento.

3) Artículo 117 N° 3

“Cuando la empresa deudora o sus administradores no sean habidos, y se hayan dejado cerradas sus oficinas o establecimientos sin haber nombrado mandatario con facultades suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones y contestar nuevas demandas. En este caso, el demandante podrá invocar como crédito incluso aquel que se encuentre sujeto a un plazo o a una condición suspensiva”.

Es conocido como “fuga del deudor”. En esta materia, pueden darse casos bastante habituales, en que la documentación da cuenta de la voluntad del deudor en cuanto proceder al pago de una obligación en tiempo y forma, deudor que a la vez se muestra frente a la sociedad con un domicilio conocido y con una estructura organizacional sólida y en funcionamiento.

Pero, no obstante, la realidad puede ser también muy distinta. Llegada la época de vencimiento, esa organización empresarial se esfuma, no se responden los llamados, el supuesto domicilio aparece abandonado, sin uso u ocupado por personas que ignoran absolutamente quién es el deudor y/o el representante legal de la empresa deudora tiene paradero desconocido. Es una especie de “señal de humo”, porque en general es indicio de un problema de insolvencia.

En materia concursal se dan casos donde el representante legal de la empresa deudora está derechamente inubicable, exigiendo al acreedor persecutor la realización de una serie de infructuosas y frecuentemente caras gestiones destinadas a encontrar la actual ubicación de ese representante.

Al final, cuando es habido, las personas de ese domicilio niegan al apoderado y, entonces, toda esa investigación se frustra, a menos que se opte por solicitar del ministro de fe una vigilancia permanente con la finalidad de notificar en forma literalmente personal al representante de la empresa deudora.

En este ejercicio, el sistema debe reaccionar, toda vez que puede advertirse que la ventaja procedimental la lleva el deudor, demandado que, en nuestra hipótesis, no tiene mayores inconvenientes para alejarse progresivamente del alcance de sus acreedores. Por medio de la disposición contenida en la Ley N° 20.720, se permite válidamente invocar la causal de ausencia y cierre en caso que, certificándose esta última circunstancia, también se constate la falta no solamente del representante legal sino también de los administradores de la empresa deudora.

En otras palabras, si efectivamente las dependencias del deudor se encuentran cerradas, el representante no ha sido habido, pero sí se tiene conocimiento certero de la presencia de administradores de la empresa deudora, la causal en análisis no habilitaría al tribunal para declarar la Liquidación, en base a la causal invocada, en el entendido que no se ha producido el abandono, huida o alejamiento de la empresa deudora de la esfera de sus acreedores.

En este caso se pueden invocar incluso créditos no vencidos.

¿Cómo se defiende el deudor?

Las defensas que se pueden oponer a estas causales son: pagar o demostrar que el título es falso, entonces el marco de maniobra es bajo. Entonces, esta herramienta puede prestarse para abuso del deudor. De hecho, hay un proyecto de ley para otorgarle al deudor mayores defensas frente a la invocación de estas causales, pero esto también puede ser negativo porque en realidad mientras antes se dicte la liquidación es mejor para todos (si la empresa está en insolvencia).

3.1.2.2 Presentación de demanda

La demanda se presenta ante el tribunal competente y, además de cumplir con los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, debe señalar:

- Causal invocada.
- Hechos justificativos.

Esto es importante por la forma que resuelve el tribunal (audiencias), entonces se busca que en la demanda se acompañen todos los antecedentes para que el juez resuelva rápidamente con lo que tiene a la vista.

Adicionalmente, debe acompañar los siguientes antecedentes:

- a) Documentos o antecedentes escritos que acreditan la causal invocada;
- b) Vale vista o boleta bancaria a la orden del tribunal por 100UF, para los gastos iniciales de la Liquidación. Si se acoge la demanda y se decreta la liquidación, gozará de la preferencia establecida en el artículo 2472 N°4 del Código Civil;
- c) Designación de Veedor de la nómina existente.

Algunas funciones:

- Supervigila las actividades del deudor mientras dure el juicio de oposición (hasta que no se dicte la resolución de liquidación), con facultades de interventor;
- Demandante puede solicitar medidas prejudiciales y precautorias;
- Veedor está facultado para solicitar las medidas cautelares que estime necesarias con cargo al acreedor demandante.

Los honorarios del veedor no podrán ser superiores a 100 UF y serán de cargo al acreedor peticionario.

d) Nombre de liquidadores titulares y suplente

El tribunal revisa en un plazo de 3 días que se cumplan los requisitos señalados en la ley (Art 119). El tribunal no entra al fondo del asunto (ej. si la deuda está vencida o no).

Si están cumplidos:

- La tiene por presentada;
- Ordena su publicación en el Boletín Concursal
- Cita a audiencia (audiencia inicial) al 5° día contado desde notificación personal o por art. 44.

Si no lo están:

- Ordena al demandante su corrección;
- Fija plazo de 3 días para subsanarlo, bajo apercibimiento de tenerla por no presentada.

3.1.2.3 Audiencia Inicial

Tiene un procedimiento reglado en el art. 120, en que se describe la forma en que el tribunal debe conducir la audiencia.

- 1) Tribunal informa al deudor de la demanda y de los efectos de un eventual Procedimiento Concursal de Liquidación;

Primera parte un tanto inocua, por cuanto el deudor ya sabe el contenido de la demanda una vez que ya le ha sido notificada.

- 2) Deudor reacciona frente a la demanda, ya sea verbalmente o por escrito, debiendo:

2.1 Señalar nombre o razón social, domicilio y correo electrónico de sus 3 mayores acreedores que figuren como tales en la contabilidad. La sanción por su incumplimiento es que el tribunal debe dictar la resolución de Liquidación, nombrando liquidadores titulares y suplente que el acreedor hubiere designado en la demanda en carácter de provisionales.

2.2 Opciones del Deudor en la Audiencia Inicial (Art. 117):

- a) Consignar fondos suficientes (deuda + costas).

Bastante evidente como forma de solucionar la solicitud de liquidación. Basta recordar que, en este escenario, la única discusión o la única materia que ha sido objeto de la pretensión judicial es la materialización que el demandante cree ver de algunas de las causales de Liquidación Forzosa del artículo 117.

De hecho, la norma es clara en cuanto la posibilidad de pagar el crédito demandado, descripción que nos conduce con facilidad a la primera causal de la norma citada.

En esta fórmula, el legislador comienza respaldando al acreedor, al demandante que lleva al deudor a tribunales indicando que el monto adeudado no es un mero incumplimiento ni un simple título ejecutivo impago, sino que tal moratoria evidencia una situación patrimonial compleja de insolvencia que va más allá de la simple imposibilidad de afrontar a un acreedor sino que a la generalidad de las obligaciones.

Entonces, si la finalidad del actor es levantar el velo de una potencial insolvencia, a fin de mostrar que se trata de un deudor insolvente, el método lógicamente más pertinente y al alcance del deudor para desvirtuar esa presunción es pagando, ya que la mejor vía para probar la solvencia y/o destruir la insolvencia construida, es solucionando lo reclamado, purgando la mora, en fin, exhibiendo que en verdad es un deudor solvente.

b) Allanamiento.

En este caso, el ordenamiento concursal no hace otra cosa que ratificar un comportamiento procesal general, conforme al cual el demandado se muestra de acuerdo con las pretensiones del acreedor, ratificando la presunción construida en su contra y dando pie al pronunciamiento de la Resolución de Liquidación.

c) Acogerse expresamente al Procedimiento Concursal de Reorganización.

Esta posibilidad es uno de los más significativos avances en materia concursal en nuestro país.

En efecto permitir que el deudor reconozca que la causal de Liquidación Forzosa hecha valer de contrario se configura efectivamente pero que, aun así, es capaz o se considera capaz de entregar una solución global a sus acreedores, responde a la necesidad de instar concretamente a mantener el principio de conservación de la empresa, ese es, aquel que tiene por fin no sólo salvaguardar los intereses privados convergentes en ésta, sino también los intereses colectivos que representa, objeto que se manifiesta en el derecho concursal a través de mecanismos jurídicos que buscan evitar la declaración de quiebra de la empresa o producir el alzamiento de dicha declaración, manteniéndola íntegra en su conjunto.

Operativamente, atendido lo previsto en el inciso segundo del artículo 54 y tratándose de una diligencia de enorme simpleza y facilidad, para cuya ejecución el interesado ha tenido cinco días hábiles desde el emplazamiento de la demanda de Liquidación Forzosa, es razonable concluir que el demandado debe exhibir en la Audiencia Inicial la copia de la Solicitud mencionada en la norma ya indicada, sin perjuicio de las medidas complementarias que pudiera decretar el tribunal.

d) Asumir una conducta pasiva.

Sea mediante la rebeldía o cualquier otra forma en que asistiendo a la Audiencia Inicial, no manifieste su voluntad en sentido alguno. En ambos casos deberá procederse a dictar la Resolución de Liquidación.

e) Oponerse.

El criterio inspirador de la nueva legislación es la preservación de empresas viables, instando por la consecución de un conjunto de objetivos que, en relación con el derecho comparado, podríamos

situarlos en línea con la flexibilización de las normas concursales para favorecer las soluciones preventivas sobre las liquidatorias, preservar la empresa en crisis como fuente de empleo y producción y el hecho de que debe primar la solución más favorable a la continuación de la empresa.

No obstante, es perfectamente posible que el deudor piense que existen causales suficientes para cuestionar la validez o legitimidad del proceso concursal que se ha iniciado en su contra al solicitar la liquidación forzosa.

Surge, entonces, la posibilidad de oponerse a la demanda de Liquidación Forzosa. Teóricamente, la empresa deudora que se opone a alguna de las dos primeras causales del artículo 117, asume una tarea compleja. Tratándose de un título ejecutivo, éste tiene una naturaleza análoga a la de una prueba privilegiada, en términos tales que el acreedor dotado de él goza de la garantía jurisdiccional de solicitar el embargo de bienes suficientes del deudor y todo el peso de la prueba recae sobre este último. El ejecutado debe desvanecer la presunción de autenticidad y veracidad que el título supone.

3) Tribunal levanta acta firmada por los comparecientes y el secretario del tribunal.

3.1.2.4 Juicio de Oposición

a) Aspectos generales sobre la tramitación de la oposición como defensa

Tanto la Audiencia Inicial como la de Prueba y la de Fallo responden en su creación a los principios propios del Derecho del Trabajo es su esfera jurisdiccional.

Así, la primera audiencia concursal es asimilable a la Audiencia Preparatoria, mientras que la de Prueba lo es a la de Juicio y finalmente la de Fallo a la denominada De Lectura de Fallo.

Pensamos que tal fórmula ha mostrado una aplicación certera y eficaz, permitiendo la concreción de los principios que informaron tal legislación. Asimismo, constituye un aporte, a nuestro juicio, la incorporación de un régimen decisorio basado en la sana crítica en lo que a las excepciones se refiere.

En efecto, nuestro legislador concursal ha considerado oportuno prever que la oposición hecha valer por el demandado de Liquidación Forzosa debe ser resuelta invocando un método en que el “sistema de valoración en que se confía al juez valorar la prueba, pero siempre de acuerdo a criterios racionales”.

El sistema de la sana crítica es una alternativa intermedia entre el sistema de prueba legal tasada y el de íntima convicción, al constituir un término medio entre una valoración a espaldas de la realidad y la mera subjetividad del juzgador.

En cuanto a las defensas en sí mismas, si bien el desenvolvimiento de la Audiencia Inicial es ciertamente verbal u oral, la oposición propiamente tal, en los términos del artículo 121 de la ley, se realiza mediante una presentación escrita.

El predominio de la verbalidad también se nota en el desarrollo de las Audiencias, tanto así que, de conformidad al artículo 125 de la ley, todas las controversias referidas a las pruebas se tramitarán oralmente y en la misma Audiencia Inicial, incluida la reposición en contra de la sentencia interlocutoria de prueba.

Finalmente, en un aspecto que es novedoso en nuestro país, la sentencia acerca de las excepciones o más bien la época de celebración de la Audiencia de Fallo al tenor del artículo 127 de la Ley N° 20.720 queda determinada de pleno derecho y en forma indisponible para las partes desde el término de la Audiencia de Prueba, quedando al arbitrio del tribunal únicamente la fijación de la hora.

De este modo, se evitan los conocidos detrimentos que la marcada extensión en el pronunciamiento del sentenciador acarrea para todos y cada uno de los partícipes presentes o futuros del concurso.

b) Forma de deducir la oposición

Oportunidad procesal: audiencia inicial.

El artículo 121 lo hace muy similar a la tramitación del juicio ejecutivo, ya que solo podrá fundarse en las excepciones contempladas en el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil y en el escrito de oposición el deudor debe:

- a. Señalar excepciones opuestas y defensas invocadas,
- b. Ofrecer todos los medios de prueba de que pretenda valerse,
- c. Acompañar la prueba documental

En el fondo, va a probar principalmente que la obligación no existe porque obró alguna de los modos de extinción de obligaciones, o que es nula. También puede atacar defectos formales respecto del juicio mismo (ej. incompetencia del tribunal).

Para probar sus excepciones, el deudor puede rendir:

- 1) Prueba testimonial: Individualización de los testigos y razones de su comparecencia;
- 2) Prueba confesional: Acompañar pliego de posiciones. Si el acreedor es persona jurídica, puede comparecer cualquier representante en que se le haya delegado facultades por escritura pública con facultes expresas de absolver posiciones.
- 3) Prueba pericial: Deudor debe justificar la diligencia, aplican las normas de los arts. 409, 410 y 411 CPC.
- 4) Prueba documental: Solo pueden acompañarse en el escrito de oposición.

Eventualmente pueden acompañarse en forma posterior si se acredita que se agregaron con posterioridad a la Audiencia Inicial o que no pudieron acompañarse por causas ajenas a su voluntad. El tribunal resuelve de plano en base a dichos antecedentes, y la resolución no admite recurso alguno.

c) Actitud del Tribunal

Si el tribunal acredita por cumplidos los requisitos legales, tendrá por opuestos al deudor y acompañados los documentos. De lo contrario se aplica el art. 120 y dicta la resolución de Liquidación.

Con lo anterior, si le da curso al juicio de oposición, el tribunal determina los trámites probatorios existentes:

1. Si existen hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, recibe la causa a prueba y dicta el auto de prueba, sujeto a recurso de reposición en el plazo de 3 días.
2. Recibida la causa a prueba y fijados los hechos a probarse:
 - a) Se pronuncia sobre admisibilidad y pertinencia de las pruebas ofrecidas;
 - b) En prueba pericial, determina la calidad del perito y los puntos, instando a llegar a acuerdo en el nombre, sino el tribunal lo designa debiendo evacuar el informe en plazo de 7 días.
 - c) El acreedor podrá ofrecer prueba, singularizada y acompañada al día siguiente, debiendo el tribunal calificar su pertinencia. Está sujeto a recurso de reposición.
3. Cita a audiencia de prueba, al 5° día siguiente, indicando fecha y hora de celebración.

Los recursos contra las resoluciones que se adopten en la Audiencia Inicial será el de reposición, debiendo deducirse y fallarse en la misma audiencia.

3.1.2.5 Audiencia de Prueba

Concentra toda la prueba, debiendo rendirse primero la confesional, y la testimonial (máximo 2 testigos por punto de prueba) del deudor.

Una vez concluida, deben hacer observaciones a la prueba verbalmente, debiendo firmarse el acta y quedando citados para la audiencia de fallo, debiendo celebrarse el 10° día, quedando o no diligencias pendientes.

La prueba se aprecia de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

3.1.2.6 Audiencia de Fallo

Una vez concluida la Audiencia de Prueba se celebrará la Audiencia de Fallo dentro de **décimo día**, todas las partes se entenderán citadas y notificadas de pleno derecho aún cuando no hayan asistido a la Audiencia de Prueba.

La Audiencia de Fallo se celebra con quienes asisten y se notifica el fallo.

La sentencia:

a) Que acoge excepciones:

Requisitos del art. 170 del CPC, cesa en sus funciones al Veedor.

Contra este fallo procede la apelación en ambos efectos y tiene preferencia para sus vista y fallo. No proceden otros recursos.

En este caso, el deudor podrá demandar los perjuicios si se demandó dolosa o culpablemente.

b) Rechaza excepciones:

Ordena la liquidación según el art. 129, y una vez notificada hace que el Veedor cese en su puesto.

3.1.2.7 Resolución de Liquidación

Además de los requisitos del art. 169 y 170 del CPC, debe contener lo siguiente:

1. Consideraciones de hecho y derecho para rechazar la oposición;
2. Determinación de si el deudor es empresa deudora, individualizándola (esto es relevante para todos los demás acreedores);
3. Designación de liquidador titular y suplente en carácter de provisionales, y la orden al liquidador de incautación de todos los bienes del deudor, libros y documentos, pudiendo pedir auxilio de la fuerza pública.
4. Orden de que oficinas de correos entreguen la correspondencia al liquidador;
5. Orden de acumular juicios pendientes que pueden afectar los bienes, de cualquier jurisdicción y estado, salvo excepciones legales.

Los juicios deben:

- estar pendientes
 - tener al fallido como demandado
 - poder afectar sus bienes
6. Advertencia al público de no pagar ni entregar mercaderías al fallido so pena de nulidad de los pagos y entregas, y la orden a personas que tengan bienes o papeles de éste, de entregarlos al liquidador, dentro de 3º día.
 7. Orden de comunicar a todos los acreedores residentes en el país que deben presentarse dentro de 30 días, con los documentos justificativos de sus créditos, plazo contado desde la publicación de la sentencia.

Si no concurren, el apercibimiento es que se entenderán afectados por los resultados del juicio sin necesidad de citación.

8. Orden de notificar por la forma más expedita posible a los acreedores que estén fuera de Chile.
9. Orden de inscribir la Resolución de Liquidación en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar del Conservador de Bienes Raíces competente, y al margen de la inscripción social en el Registro de Comercio.
10. Indicación del lugar, día y hora en que se celebrará la primera junta de acreedores.

La Resolución de Liquidación se notifica mediante publicación en el Boletín Concursal y contra ella procede solo el recurso de apelación en el solo efecto devolutivo.

3.1.3 Liquidación Refleja

Son casos que la ley establece una obligación al juez de proceder a la apertura del procedimiento de liquidación sin petición de algún acreedor o de la empresa deudora.

3.1.3.1 Casos:

- a) Retiro de la propuesta de Acuerdo de Reorganización una vez notificada a los acreedores y sin contar con el apoyo de a lo menos el 75% del pasivo (art 77).
- b) Ausencia del deudor en la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización (art. 81).
- c) Si se acoge la impugnación del Acuerdo de Reorganización por las causales establecidas en los numerales 1), 2), 3) y 6) del artículo 85 y el deudor no presentare una nueva propuesta de Acuerdo bajo las condiciones impuestas por el artículo 88.
- d) Si se acoge la impugnación del Acuerdo de Reorganización por las causales establecidas en los numerales 4) y 5) del artículo 85 (art. 88, inc. final).
- e) Rechazo del Acuerdo de Reorganización por parte de la junta de acreedores (art. 96).
- f) Incumplimiento o declaración de nulidad del Acuerdo de Reorganización (art. 100).

3.2 Efectos de la Resolución de Liquidación

Firme la resolución, los efectos inmediatos son:

Artículo 130 ley 20.720.- Administración de bienes. Desde la dictación de la Resolución de Liquidación se producirán los siguientes efectos en relación al Deudor y a sus bienes:

1) Quedará inhibido de pleno derecho de la administración de todos sus bienes presentes, esto es, aquellos sujetos al Procedimiento Concursal de Liquidación y existentes en su patrimonio a la época de la dictación de esta resolución, excluidos aquellos que la ley declare inembargables. Su administración pasará de pleno derecho al Liquidador.

En consecuencia, serán nulos los actos y contratos posteriores que el Deudor ejecute o celebre en relación a estos bienes.

2) No perderá el dominio sobre sus bienes, sino sólo la facultad de disposición sobre ellos y sobre sus frutos.

3) No podrá comparecer en juicio como demandante ni como demandado, en lo relativo a los bienes objeto del Procedimiento Concursal de Liquidación, pero podrá actuar como coadyuvante.

4) Podrá interponer por sí todas las acciones que se refieran exclusivamente a su persona y que tengan por objeto derechos inherentes a ella. Tampoco será privado del ejercicio de sus derechos civiles, ni se le impondrán inhabilidades especiales sino en los casos expresamente determinados por las leyes.

5) En caso de negligencia del Liquidador, podrá solicitar al tribunal que ordene la ejecución de las providencias conservativas que fueren pertinentes.

Esto ha dado pie a lo que se denomina el “**desasimiento**”.

3.2.1 Introducción

La resolución que declara la quiebra –dice Puelma-, al crear o constituir un estado jurídico nuevo, el estado de quiebra, produce múltiples efectos que reglamenta la ley⁸. Así –agrega Sandoval- se originan un conjunto de efectos o consecuencias en el plano jurídico-económico sobre la persona y bienes del fallido.⁹

La generalidad de la doctrina clasifica los efectos de la declaración de la liquidación (antes de la quiebra) en “efectos inmediatos” y “efectos revocatorios”. Desde un punto de vista doctrinal, podría ser más pertinente hacer una clasificación distinta, es decir, distinguir entre los efectos “inherentes al estado de cesación de pagos” y los efectos “inherentes a la declaración de liquidación”.

Sin perjuicio de lo anterior, existen distintos criterios que sirven para agrupar los efectos que produce el estado de liquidación:

I. Primer criterio:

1. Efectos sobre la persona del fallido:

Representados por ciertas inhabilidades que la ley establece respecto del fallido y por el proceso de calificación penal del concurso.

2. Efectos sobre los bienes del fallido:

Debe distinguirse:

a) Bienes del deudor: respecto de los cuales todo el sistema de la liquidación producirá sus efectos especiales.

b) Derechos de los acreedores: la quiebra producirá la desaparición de algunos derechos de los acreedores y el nacimiento de otros nuevos.

II. Criterio de Álvaro Puelma Accorsi¹⁰:

1. Aquellos que se refieren a los acreedores o a sus créditos

Ellos son:

a) Determinación de sus créditos: artículo 66.

b) Suspensión del derecho de ejecución individual de los acreedores.

c) Efectos sobre la competencia de los tribunales.

d) Formación de la masa de acreedores.

e) Órganos de la masa: se originan dos nuevos entes:

⁸ Puelma Accorsi, Álvaro: Curso de Derecho de Quiebras (página 57).

⁹ Sandoval López, Ricardo: Derecho Comercial tomo IV (página 82).

¹⁰ Puelma, ibid.

- Junta de Acreedores
- Síndico

2. Aquellos que se refieren al deudor en su persona, bienes y relaciones pendientes.

Se distingue:

- a) Efectos sobre la persona:
 - a.1 No genera una incapacidad legal sobreviniente
 - a.2 Inhabilidades
 - a.3 Penas Corporales, en caso de ser condenado por delitos concursales
- b) Efectos sobre los bienes:
 - b.1 Desasimiento
 - b.2 Derecho del fallido a demandar alimentos
- c) Efectos sobre relaciones jurídicas:
 - c.1 Sobre actos o contratos pendientes del deudor
 - c.2 En determinados contratos.

3. Acciones de reintegración o recuperación del patrimonio del deudor.

III. Criterio seguido por el legislador¹¹:

1. Efectos inmediatos: *son los que se producen con posterioridad a la declaración de liquidación.*

Ellos son:

- a) Pérdida de administración de sus bienes: Art. 130.
- b) La fijación irrevocable y definitiva de todos los derechos de los acreedores: artículo 134.
- c) La exigibilidad anticipada de todas las obligaciones del fallido. Art. 136
- d) La suspensión del derecho a ejecutar individualmente al quebrado: artículo 135
- e) La acumulación de juicios: artículo 142.

2. Efectos Retroactivos: *aquellos que afectan las relaciones jurídicas celebradas con anterioridad a la declaración de quiebra. Se verán más adelante, art. 287*

IV. Criterio seguido por nosotros:

1. Efectos Inherentes a la Cesación de Pagos:

Ellos son:

¹¹ Seguido también por Sandoval López.

- a) Vencimiento anticipado de todas las obligaciones patrimoniales del deudor en liquidación, art. 136
- b) Las inhabilidades.
- c) La fijación irrevocable de los derechos de los acreedores: artículo 134.
- d) Efectos penales.
- e) Efectos retroactivos.
- f) Derecho de alimentos del deudor

2. Efectos inherentes a la Resolución de Liquidación:

Ellos son:

- a) El desasimiento
- b) La prohibición de que operen compensaciones: artículo 140
- c) Suspensión del derecho de ejecutar separadamente: artículo 135
- d) Acumulación de Juicios: artículo 142

3.2.2 Efectos en la capacidad del Deudor

La Resolución de Liquidación no causa la Incapacidad del Deudor, de hecho el Art. 1447 CC no los incluye.

Esto implica que el deudor podrá administrar los bienes inembargables de igual forma que lo hacía antes de la resolución de liquidación. Asimismo, el deudor conserva la administración de los bienes sobre los cuales tiene el usufructo legal

A consecuencia de lo anterior, el deudor:

- Sigue interactuando en el proceso de liquidación
- Puede impetrar medidas conservativas
- Puede impugnar créditos en proceso de verificación
- Puede interponer todas las acciones que se refieran a cuestiones inherentes a su persona

3.2.3 Razón Social del Deudor

El nombre o razón social del Deudor sujeto a un Procedimiento Concursal de Liquidación será complementado con la frase final “en Procedimiento Concursal de Liquidación”.

Su uso deberá ser precedido por la firma del liquidador y demás habilitados.

En caso de incumplimiento serán solidariamente responsables tanto el liquidador como los que hubieren celebrado o ejecutado el acto o contrato respectivo.

3.2.4 El Desasimiento

A) Naturaleza Jurídica

a) Teoría de la Incapacidad Jurídica

Esta teoría pretende explicar el desasimiento como una incapacidad especial que sufre el fallido con ocasión de la resolución de liquidación.

Consecuente con ella, se sancionan los actos del fallido con la nulidad relativa o absoluta (art 130). Es un efecto más personal que patrimonial de la resolución de liquidación.

Esta teoría está fundada en la sanción aparejada a los actos celebrados por el fallido respecto de los bienes de la masa. Él pasa a ser incapaz de administrar su patrimonio.

Por otra parte, el fallido conserva plena capacidad de contratación respecto de bienes no comprendidos en la liquidación y bienes inembargables. Esta teoría no se sustenta porque en lo único que se parece es en el efecto de realización del acto: el fallido puede impugnar créditos, solicitar que se impetren medidas conservativas, y otras actuaciones de esa naturaleza entonces es una figura extraña porque sería “parcialmente incapaz” respecto de algunos bienes.

b) Teoría de la Expropiación del Patrimonio

Una segunda teoría aspira a explicar el desasimiento como una suerte de expropiación del patrimonio sujeto a concurso. El deudor no es ya privado de la capacidad sino de la propiedad sobre su haber concursado.

Una teoría más elaborada pero en el mismo sentido, sostiene que la expropiación no es ya del derecho de dominio, sino de la facultad de disposición aneja a este derecho real, facultad que entendemos se transferiría a los acreedores en cuanto colectividad.

Tampoco convenimos con esta variante, porque el fallido puede, válidamente, al menos en principio, enajenar sus bienes concursados. Dicha enajenación es válida, aunque ineficaz en lo que atañe a la masa pasiva, de forma quealzada la quiebra queda firme dicho acto de disposición, sin que resulte objetable bajo ningún respecto.

No existe, por lo tanto, al menos en nuestra ley, ni expropiación de dominio, ni de su facultad inherente de disposición. Existe, por la apertura, una verdadera creación de una facultad dispositiva, jerárquicamente superior a la del fallido, que la ley deposita en los órganos concursales (liquidador o junta de acreedores), facultad que les pertenece a éstos por derecho propio, es decir, originariamente.

Refuerza lo anterior el hecho de que el artículo 130 N°2 dispone que el deudor no pierde el dominio sobre sus bienes, sino sólo la facultad de disposición sobre ellos y sus frutos.

c) Teoría de la Personalidad Jurídica

Emana del hecho de que la razón social del deudor en liquidación debe expresar esta circunstancia.

Esta teoría sostiene que la antigua sentencia de quiebra viene a constituir una persona jurídica sui géneris; un ente jurídico que actúa representado judicial y extrajudicialmente sea por la asamblea de acreedores, sea por el síndico o curador.

Hoy por hoy, sostener esta tesis, no sólo en Chile sino en la generalidad de las legislaciones del grupo latino, es “trabajo de astrónomos”, ya que esta persona jurídica:

- Carecería de patrimonio, pues el haber de la quiebra permanece bajo el dominio del quebrado
- Constituiría un ente jurídico cuyo único objeto sería su liquidación, lo que no se aviene con la intención tenida por el legislador al instituir estos entes ficticios. Sería una PJ que “nace para morir”.
- Además, todos los actos celebrados por los supuestos “representantes” de este ente jurídico se radicarían en un patrimonio diverso al suyo, pues todos afectan el patrimonio que permanece bajo la titularidad del fallido.

d) Teoría de la Prenda General

Esta tesis se afirma en que si bien el desasimiento no transfiere el dominio de los bienes del fallido, crea para los acreedores concursales un derecho real universal sobre dicho patrimonio; una prenda general en garantía de los créditos de los acreedores comprendidos en la falencia, por lo que estos acreedores tienen un derecho a enajenar y pagarse con el resultado de la misma con preferencia a los demás acreedores del fallido.

Se advierte que existe aquí una transposición de elementos. Las garantías tienden a asegurar el pago futuro de obligaciones presentes o futuras. Pero, cuando ya hay mora, es forzar mucho los conceptos hablar de garantía, a menos de novarse dicha obligación o prorrogar su vencimiento, lo que no sucede con la sentencia de declaración de quiebra.

Además, el derecho general de prenda ya existe respecto de cualquier acreedor.

e) Teoría Procesalista o del Embargo

Existe una correspondencia estructural entre la ejecución individual y la colectiva, modificada por su diferencia entitativa, por la singularidad que gobierna a una y la pluralidad que inspira a la otra.

Pues bien, manteniendo esa equivalencia jurídica entre ambos procesos, se concibe al desasimiento como una suerte de embargo, correlativo al de la ejecución singular.

Etimológicamente, la voz “embargo” proviene del latín *imparari*, que significa asegurar una cosa, poner mano en ella, secuestrarla.

Un primer elemento del embargo es el origen de la medida. El embargo siempre debe determinarse por el órgano jurisdiccional. Y esto no es pura causalidad; la potestad de ejecutar el derecho les corresponde siempre, en forma suprema, a los representantes del Poder Judicial.

El segundo elemento propio del embargo es su manifestación jurídica: la privación al deudor de las facultades de disposición, uso y goce de sus bienes; facultades que son “transferidas” a la autoridad judicial.

Un tercer elemento del embargo estaría en la privación, consecuente con el anterior, de la administración de dichos bienes para su dueño; facultad que siempre se confía a un depositario (aunque éste puede ser el mismo dueño y deudor, pero no ya a título de dueño).

Por último, la finalidad de tal medida: el sujetar dichos bienes a ejecución, vale decir, al pago de las obligaciones ejecutadas.

Dicho lo anterior, nos parece que el desasimiento puede ser incluido en el género de las medidas procesales de que participa el embargo, aun cuando presenta **características que lo separen del estricto significado de éste**.

- El desasimiento es el resultado *inmediato* de una sentencia judicial dictada en un proceso de liquidación (la resolución de liquidación), dictada siempre por un órgano judicial).
- Si bien no sería adecuado decir que por el desasimiento el deudor es privado del uso, goce y disposición de sus bienes, sí podemos decir que la quiebra contempla un órgano (el liquidador y/o la junta de acreedores) al cual la ley atribuye tales facultades sobre el patrimonio concursado, pero no derivándolas del deudor, sino, originariamente, como facultades constitutivas de dichos órganos instituidos por la ley.

El deudor no es privado, al menos, de su poder de disposición; sí lo es del uso y goce de sus bienes, que pasan al órgano concursal depositario (el liquidador); en este sentido puede disponer de sus bienes, aunque las enajenaciones resultantes adolecen de un vicio de nulidad (art. 130 N°1, inc. 2°).

Por esto último es que se mantiene el elemento esencial del embargo, a saber, la afectación de los bienes sobre que dicha medida recae, a la satisfacción de las acreencias de los ejecutantes.

Tanto con el embargo como con el desasimiento, se fijan los bienes ejecutados destinados a desinteresar al o a los acreedores ejecutantes.

Por ello, no existe duda de que el embargo propio de la ejecución universal es el desasimiento o desapoderamiento de los bienes del fallido.

B) Diferencias entre el Embargo y el Desasimiento

Perteneciendo al mismo género procesal, se registran, entre el embargo y el desasimiento, múltiples diferencias:

- a) El embargo recae sobre bienes singulares, determinados individualmente. El desasimiento incide sobre una universalidad jurídica, sobre un conjunto de bienes que participan de un común status jurídico, sin que importe la especificación de los mismos.
- b) Por lo anterior, no es necesaria la actividad material de individualización del ministro de fe para formalizar el desasimiento, práctica o actuación procesal esencial para el embargo.

- c) Por el carácter universal del desapoderamiento, resulta jurídicamente imposible la reiteración de la misma medida sobre un mismo patrimonio, no obstante que se admita el reembolso en la ejecución singular.
- d) Las facultades de uso, goce y disposición sobre los bienes concursados se transmiten a los órganos ejecutivos de un modo diverso que las mismas facultades sobre los bienes embargados.

En el embargo, la facultad de disposición emerge en el órgano jurisdiccional y el uso y goce se traduce en la administración del bien singular confiada al depositario. Tratándose del desasimiento, la disponibilidad la detenta la colectividad de acreedores (“la masa de acreedores”), que actúa por el órgano junta de acreedores, y el uso y goce se convierte en la facultad orgánica de administración del liquidador.

- e) Por último, el desasimiento es una medida del género del embargo, pero jerárquicamente superior, pues aquél prima sobre éste considerando el carácter de orden público del bien jurídico involucrado en la ejecución donde opera, en contraste con el carácter privado de los intereses en conflicto en la ejecución singular.

C) Efectos del Desasimiento

- a) Deudor queda inhibido, de pleno derecho, de la administración de sus bienes (la administración la adquiere el liquidador).
- b) Entrega de correspondencia al liquidador: Por ser un embargo patrimonial, se justifica que el Nº 4 del ART. 129 ordene que la sentencia de apertura contenga “la orden de que las oficinas de correos entreguen al liquidador la correspondencia cuyo destinatario sea el deudor”. No es una medida de carácter personal, sino patrimonial, pues la detención de correspondencia opera sólo respecto de las misivas relacionadas con el patrimonio sujeto a concurso.
- c) Advertencia al público: La misma naturaleza del desasimiento explica que la sentencia de quiebra deba contener “la advertencia al público de que no debe pagar ni entregar mercadería al deudor, so pena de nulidad de los pagos y entregas”, pues no se pueden pagar obligaciones por créditos “embargados”, conforme lo señalan los Nºs 1 y 2 del ART. 1578 del Código Civil.

Además, dicha advertencia debe acompañarse por su contrapartida que indique “la orden a las personas que tengan bienes pertenecientes al deudor, para que los pongan, dentro de tercero día, a disposición del liquidador” (ART. 129 Nº 6).

- d) Registro de la declaración de quiebra: Un efecto igualmente de este desasimiento es que la sentencia declaratoria debe tener “la orden de inscribir la resolución de liquidación en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar del Conservador de Bienes Raíces correspondientes a cada uno de los inmuebles pertenecientes al deudor” y al margen de la inscripción social (ART. 129 Nº 9).

- e) Prohibición de compensaciones: Asimismo, la circunstancia de que “la dictación de la Resolución de Liquidación impide toda compensación que no hubiere operado antes por el ministerio de la ley, entre las obligaciones recíprocas del deudor y acreedores, salvo que se trate de obligaciones conexas, derivadas de un mismo contrato o de una misma negociación y aunque sean exigibles en diferentes plazos” (ART. 140), se justifica debido a que la compensación es un pago ficticio y que el desasimiento es un embargo sobre el patrimonio, lo que comprende, por lo tanto, los créditos que lo integran.

Son obligaciones conexas las del inciso 2° del art. 140, básicamente derivados.

D) Momento en que se Produce el Desasimiento

Para saber en qué momento se produce el desasimiento, hay que considerar los siguientes antecedentes:

- por un lado, recae sobre una universalidad jurídica, sobre **todos** los bienes embargables del deudor y no sobre bienes específicos y singulares.
- por el otro, estamos ante una ejecución en que el deudor no puede legítimamente pagar.

Ambas razones determinan la inutilidad, aquí, del instituto del requerimiento de pago, imprescindible en la ejecución singular, y que, además, no se precise de la aprehensión material de los bienes dado el carácter abstracto del objeto embargado (recae sobre la universalidad).

Entonces, no es necesaria, al menos teóricamente, actuación adicional alguna a la sentencia de apertura para que se produzca el embargo. Nada justifica aguardar a la notificación de esa resolución para que opere este acto de la autoridad judicial.

Por ello es que, perfeccionada/firme que sea la resolución de liquidación, en cuanto acto jurídico procesal, se produce “de pleno derecho” el desasimiento, conforme lo dispone el ART. 130, sin que sea menester aguardar a su notificación.

E) Objeto del Desasimiento

El objeto del desasimiento es el patrimonio del deudor estimado como el conjunto de cosas, corporales o no, susceptibles de apreciación pecuniaria y embargables.

Por tanto, se comprenden todos los bienes muebles, inmuebles e intangibles, los derechos personales, etc.

Para saber qué bienes integran este concepto de patrimonio, es común en la doctrina y en la ley distinguir entre bienes presentes y bienes futuros.

A los bienes pasados, esto es, aquellos que se sustrajeron de la esfera de dominio del deudor con antelación a la resolución de liquidación, por regla general no los afecta el desasimiento, sencillamente porque no son bienes del deudor. Sin embargo, si esos bienes devienen presentes, se extenderá el desasimiento sobre ellos; y devienen presentes si se obtiene la declaración de

inoponibilidad del acto por el que operó el desmembramiento, lo cual viene a significar que el bien en cuestión, para los efectos de la liquidación, nunca abandonó la esfera dominical del fallido.

Lo que es importante destacar es que, conforme al ART. 130, N° 1, **sólo los bienes embargables** ingresan a la masa. Resulta casi una tautología, porque el desasimiento es un embargo.

Según el art. 130, la resolución de liquidación produce los siguientes efectos respecto a la administración de bienes:

1. Queda inhibido de pleno derecho de la administración de los bienes presentes. La sanción es la nulidad.
2. No pierde el dominio, solo la facultad de disponer de ellos y de sus frutos.
3. No puede comparecer en juicio respecto a los bienes.
4. Puede interponer las acciones que se refieren solo a su persona y que tengan por objeto derechos inherentes a ella.
5. En caso de negligencia del liquidador puede pedir se tomen las providencias conservativas.

a) Bienes Presentes

La regla la proporciona el ART. 2465 del Código Civil. En virtud de ella, deberíamos concluir que ingresan a la quiebra todos los bienes de propiedad del quebrado al tiempo de dictarse la sentencia de apertura, a excepción de los inembargables.

(1) Situación de los bienes bajo usufructo legal del fallido

El ART. 132 da reglas especiales relativas a bienes que sin ser del dominio del fallido –en el supuesto de que éste es persona natural–, él los administre al tiempo de la quiebra y respecto de los cuales detente un derecho legal de usufructo o derecho legal de goce.

En concreto, se refiere a la situación especial de los bienes de la cónyuge casada en régimen de sociedad conyugal con el fallido o bienes del hijo de familia, que el marido o padre quebrado administre y usufructe.

Por lógica, dichos bienes no engruesan el activo concursado, porque no son del fallido.

Sin embargo, los frutos naturales o civiles que ellos generen sí ingresan a la masa ejecutada, porque dichos frutos, de conformidad al derecho común, sí que le pertenecen al deudor.

Sin embargo, como no se produce una privación del derecho legal de administración sobre estos bienes del hijo de familia o de la cónyuge y como los frutos de ellos son de interés de la masa, el ART. 132 admite que esta administración del fallido quede sujeta a intervención del liquidador, para velar por la ordenada y legítima administración y uso de los mismos.

El usufructo legal del marido, padre o madre de familia tiene un fin predominantemente alimentario; se entiende destinado a la mantención de la mujer o de los hijos de la familia. Esto justifica que la norma del ART. 132 prevenga que deben descontarse de los frutos emanados de dichos bienes los alimentos congruos y efectos de subsistencia, la de su mujer e hijos y, además,

por supuesto, las cargas legales y convencionales que los graven. La fijación de los alimentos, conforme al inc. 3° de dicho ART. 132, es tarea del tribunal, el que debe proceder con audiencia del síndico y del fallido.

(2) Situación de los bienes de terceros

Además de los bienes inembargables, tampoco ingresan al concurso los bienes de terceros.

Pero lo anterior no significa que no ingresen a la quiebra los derechos, reales o personales, que el fallido tiene sobre dichos bienes ajenos (ejemplo, arrendamiento, usufructo, hipoteca, comodato, leasing, etc.).

Sobre tales derechos los acreedores pueden subrogarse, si existe texto expreso que les autorice a ejercer la acción subrogatoria correspondiente (en el arrendamiento, conforme a los ARTS. 1965, 1968 y 2466 del C. Civil), o bien podrá actuar el síndico como “representante” legal del patrimonio del fallido.

b) Bienes Futuros

La ley distingue entre bienes futuros de adquisición gratuita y bienes futuros de adquisición onerosa, dado el régimen jurídico distinto bajo el que se arreglan; por eso los analizaremos por separado.

(1) Bienes futuros adquiridos a título gratuito

El desasimiento comprende también los bienes futuros adquiridos a título gratuito por el deudor, como ocurre, por ejemplo, con los bienes adquiridos por sucesión por causa de muerte, o por donación. Art. 133

Estos bienes se adquieren sin perjuicio de las cargas con que hayan sido transferidos o transmitidos y sin perjuicio de los derechos de los acreedores hereditarios.

Incorporados estos bienes al patrimonio del deudor mediante el correspondiente modo de adquirir, pasan a ser bienes concursados por el solo ministerio de la ley.

En el caso de que el deudor repudie una herencia o legado, los acreedores del que repudia en perjuicio de los derechos de ellos, pueden hacerse autorizar por el juez para aceptar por el deudor, caso en el cual la repudiación se invalida sólo a favor de los acreedores y hasta la concurrencia de sus créditos, quedando subsistente respecto del sobrante

(ART. 1238 del C. Civil).

(2) Bienes futuros adquiridos a título oneroso

El desasimiento no importa una incapacidad jurídica, ni de goce ni de ejercicio, por lo cual el fallido, en especial si es persona natural, puede reiniciar actividades y levantar su empresa u otra, lo que importará la celebración de múltiples actos jurídicos conmutativos onerosos.

A fin de incentivar al deudor para que trabaje, la ley da una reglamentación muy especial para la suerte de estos bienes en el concurso, rompiendo la regla general de que el objeto del desapoderamiento es el patrimonio del deudor.

Estos bienes, haciendo excepción a la regla general, no ingresan a la liquidación por el solo ministerio de la ley, como ocurre con las cosas de adquisición lucrativa. Respecto de estos bienes el deudor conserva la tenencia y administración.

El derecho que asiste al concurso sobre ellos es el de intervenir la administración del fallido, conforme a las normas de los ARTS. 290 y siguientes del CPC en cuanto corresponda (medida precautoria del N° 3° del ART. 290 del C.P.C.) y reclamar el ingreso a la masa de los “beneficios líquidos” que se obtengan de dichos bienes. Art. 133

Los beneficios líquidos resultan de deducir del valor de los bienes adquiridos, el importe de la contraprestación anexa a la adquisición y de las cargas legales que sobre ellos pesen.

c) Situación de los Bienes Pasados

Los bienes que se desmembraron de la hacienda del deudor antes de la dictación de la sentencia de apertura no son alcanzados, corrientemente, por el embargo general del juicio de quiebra.

Sin embargo, en el evento de desaparecer el título traslativo o el acto jurídico que sustenta la sustracción del bien, éste pasa a adquirir consecuentemente el carácter de bien presente y, por lo tanto, pasa a integrar el patrimonio en ejecución.

Los bienes pasados pueden devenir presentes por diversas circunstancias. Así resultaría de:

- la declaración de nulidad del acto traslativo sustentatorio (ej. cv nula)
- la resolución del mismo
- la declaración de simulación
- la revocación del acto jurídico en cuestión (ej. acción pauliana y revocatorias concursales)

Guerrero cree que siguen siendo pasados pero pueden ser recuperados por y para la masa de acreedores.

F) Efectos en los acreedores y sus créditos.

El vencimiento anticipado de todas las obligaciones patrimoniales del deudor (ART. 136).

El efecto primerísimo y fundamental de la declaración de liquidación es el vencimiento anticipado de todas las obligaciones que pesan sobre el deudor (caducidad del plazo).

Así lo dice el ART. 1496 N° 1 del C. Civil, que consagra como una de las causales de caducidad del plazo la notoria insolvencia, la cesación de pagos. Se anticipan o vencen los plazos pendientes, para que los acreedores puedan verificar sus créditos en el procedimiento concursal.

Este efecto no emana propiamente de la resolución de liquidación, sino del estado sustantivo que la sustenta, esto es, de la cesación de pagos o insolvencia del deudor. Es un efecto de la

insolencia “declarado” por la resolución declaratoria de la quiebra. En todo caso, esto supone que todas estas obligaciones se entienden líquidas y actualmente exigibles, por lo que los acreedores podrán verificarlas y exigir su pago, según las normas del concurso.

1. Determinación de créditos.

La declaratoria fija irrevocablemente los derechos de los acreedores al momento de su promulgamiento, por lo que, art. 134:

- Serán acreedores los que existían a dicha fecha,
- Los acreedores no pueden mejorar su derecho, aumentando el valor de sus créditos con posterioridad a la declaración,
- Quedan vencidos y exigibles todos sus derechos, e impide la compensación que no hubiere operado antes por el sólo ministerio de la ley.

2. Valorización de créditos.

La ley presume que los créditos del fallido son en dinero, y no se pone en el caso de las obligaciones de hacer o de especie o cuerpo cierto.

El problema de esto es como determinar el valor de estos créditos, especialmente en el caso de aquellos contratos que terminan por efecto de la declaratoria de liquidación, ¿Qué sucede con los perjuicios?

- Si pido la declaración al tribunal, el acreedor perderá el derecho a verificar ordinariamente, por los plazos existentes (ese juicio declarativo va a durar mucho tiempo).
- ¿Puede declararlo el tribunal de la liquidación?

Por ello, el art. 137 da ciertas reglas para determinar los créditos:

1. Si es un crédito reajutable en moneda nacional **no vencido** y con intereses, el crédito será el capital más reajustes e intereses hasta la fecha de la resolución, art. 137, N° 1
2. Si es un crédito reajutable en moneda nacional no vencido y sin intereses, el crédito será el capital más reajustes hasta la fecha de la resolución, art. 137 N° 2,
3. Si es un crédito no reajutable en moneda nacional no vencido y con intereses, el crédito será el capital más intereses hasta la fecha de la resolución, art 137, N° 3
4. Si es un crédito no reajutable en moneda nacional no vencido y sin intereses, el crédito será el capital menos los intereses corrientes de operaciones de crédito de dinero no reajutables desde el día de la declaratoria hasta el vencimiento, art. 137, N° 4 (*la ley presume que va implícito un interés corriente, por eso se descuenta el interés que supuestamente tendría esta deuda: se trae la deuda a valor presente sin intereses*)
5. Si no se puede aplicar índice de reajutabilidad, se aplica la regla de los créditos no reajutables en moneda nacional no vencido y con intereses, art. 137, N° 5

6. Si el crédito es en moneda extranjera, se pagará el capital más los intereses pactados en la convención, art. 139, inc. 2º,
7. **Si los créditos están vencidos**, el art. 139 da reglas respecto al cálculo de reajustes e intereses:
 - a) Se reajustan y devengan intereses según lo pactado, en el caso del Nº 1,
 - b) Se reajustan según lo pactado, en el caso del Nº 2,
 - c) Devengan intereses corrientes para operaciones de crédito de dinero no reajustables, en los números 3 y 4.
8. En el caso del fallido aceptante de letra, librador de letra no aceptada o suscriptor de pagaré, los demás obligados deberán pagar inmediatamente. Art. 138
9. El liquidador puede impugnar (ante el tribunal) el pago de intereses en caso de estimarlos excesivos (normalmente cuando excedan el interés corriente).

3. *Suspensión del derecho de ejecutar individualmente al deudor:*

Como ya hemos señalado, la liquidación es un juicio universal, por lo que todos los juicios existentes a la fecha de la declaratoria se acumulan a la liquidación, **excepto**:

Los acreedores hipotecarios o prendarios pueden perseguir sus créditos en los bienes hipotecados o prendados (art 135).

Los acreedores prendarios o retencionarios, pueden perseguir sus créditos en los bienes prendados o retenidos, sin embargo el liquidador podrá, si lo considera conveniente para la masa, exigir la entrega de dichos bienes, siempre que pague la deuda o deposite, a la orden del tribunal, su valor estimativo en dinero (art 242).

De todos modos, estos acreedores privilegiados tienen la facultad de actuar conjuntamente con el resto de los acreedores, renunciando a sus preferencias.

Sin embargo, si quieren percibir el producto de la venta de los bienes dados en garantía, deberán a su vez garantizar a los acreedores de primera clase que hayan sido verificados ordinariamente o antes de la fecha de la liquidación (para darles seguridad de que recibirán lo que les corresponde). En virtud de lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°6, son instrumentos de garantía suficiente, además de aquellos que reconozcan las leyes, los siguientes:

- Vale Vista o boleta bancaria, extendida de forma irrevocable a nombre del Deudor en liquidación, nominativa, a la vista, de una duración no inferior a dos años.
- Póliza de seguro de caución, en los términos expuestos en el artículo 582 del Código de Comercio, tomada por el acreedor en favor del Deudor.

4. *Acumulación de juicios:*

Se acumulan todos los juicios pendientes en que el deudor sea demandado, con la excepción general de aquellos juicios en que sea demandante y en que no esté clara la relación con la liquidación, p. ej. Juicio de alimentos, en que deberá verse caso a caso. Art. 142

En este sentido, la ley se refiere específicamente a todos los juicios civiles pendientes contra el deudor en otros tribunales, ya que se si se inician con posterioridad a la fecha de la liquidación, deben quedar radicados en el tribunal que conoció la liquidación, y debe continuar su tramitación según la naturaleza del procedimiento hasta que la sentencia definitiva quede ejecutoriada.

La acumulación supone que todos los procesos quedan radicados en el mismo tribunal, quien debe dictar tantas sentencias como juicios hay acumulados.

Las excepciones a la acumulación son:

- a) Juicios posesorios,
- b) Juicios de desahucio
- c) Juicios de terminación inmediata de contratos de arriendo
- d) Juicios arbitrales, o que estuvieren siendo conocidos por árbitros
- e) Compromisos
- f) Aquellos sometidos por ley a tribunales especiales (p. ej.: laborales)

Los juicios ordinarios y sumarios deben acumularse.

Respecto a los **juicios ejecutivos**, se debe distinguir:

- a) Obligaciones de dar:
 - (i) Si no hay excepciones opuestas: Se suspende la tramitación y se envían los antecedentes al tribunal que conoce de la liquidación, debiendo los acreedores verificar los créditos;
 - (ii) Si hay excepciones opuestas: También se acumulan, pero en este caso el liquidador asume la representación del deudor y los acreedores pueden verificar sus créditos provisoriamente.
- b) Obligaciones de hacer:
 - (i) Si los fondos estaban consignados, el tribunal de origen debe enviarlos al tribunal acumulado, quien debería continuar la tramitación hasta la inversión total de los fondos o realización de la obra.
 - (ii) En caso contrario, se acumulan y solo se pueden verificar una vez que el tribunal lo declare.
- c) Si existe más de un deudor, incluyendo el que es objeto de la liquidación:
 - (i) Suspender tramitación solo respecto al deudor;

- (ii) Acumular al tribunal de la liquidación la parte correspondiente al deudor, enviando copias autorizadas del expediente,
- (iii) Conservar el expediente original y continuar la liquidación respecto al resto de los deudores.

No van a preguntar mucho esto, pero es importante detectar que hay muchas posibilidades dependiendo del caso.

Materias especiales: (tampoco estudiar con tanta profundidad, no van a preguntar en detalle)

(a) Juicios sobre causales de Liquidación Forzosa:

Si el deudor es el demandante en juicios que tienen por objeto controvertir la validez, legitimidad o procedencia de créditos justificativos de la Liquidación Forzosa, se acumulan al procedimiento concursal.

Si en tales juicios sus alegatos son similares a los del juicio de oposición, deberá resolver el tribunal que conoció de la liquidación también conocer de este tema.

(b) Medidas cautelares:

Respecto a medidas cautelares, si afectan a bienes que quedan afectos a la resolución de liquidación, quedan sin efecto por dicha resolución.

En este escenario, al asumir el liquidador puede pedir que quede sin efecto dicho embargo o medida cautelar, y el tribunal debe emitir la resolución sin más trámite con el solo efecto de la resolución de liquidación.

Si estas medidas cautelares provienen de sede penal, quedan asimismo sin efecto y siguen básicamente la misma lógica, debiendo los acreedores de ellas verificar posteriormente créditos al respecto (indemnizaciones, multas o cualquier condena en dinero).

(c) Acciones reivindicatorias:

Asimismo, y respecto a acciones reivindicatorias, el art. 150 señala que pueden interponerse de acuerdo a las reglas generales.

Sin embargo, si son tercerías de dominio iniciadas antes de la resolución de liquidación, deben continuar tramitándose según el procedimiento que corresponda.

Si dicha reivindicación se refiere a efectos de comercio, deben existir y no estar pagados a la fecha de la declaración, en poder del deudor o de un tercero que los conserve a nombre de éste, siempre que el propietario los haya entregado o remitido al deudor por un título no traslativo de dominio.

Si la reivindicación se refiere a mercaderías, mientras puedan identificarse pueden ser reivindicadas, ya estén a título de depósito, comisión de venta o cualquier otro título que no sea traslativo de dominio.

Si se venden las mercaderías, el propietario puede reivindicar el precio o la parte del precio que no hubiera sido pagado o compensado entre el deudor y el comprador a la fecha de la liquidación.

Si se dan documentos de crédito no se entiende pagado el precio. Sin embargo, si existen tales documentos pueden reivindicarse siempre que se acredite el origen e identidad.

Todo lo anterior no obsta al derecho legal de retención o prenda que pueda tener el deudor. Art. 153

(d) Resolución de la compraventa:

Art. 154. En el caso de compraventas, puede resolverse el contrato por incumplimiento de las obligaciones del deudor comprador, a menos que se trate de cosas muebles que hayan llegado a su poder.

Si la compraventa se resuelve, el vendedor está obligado a restituir los abonos que se le hayan hecho (art 158).

(e) Mercaderías en tránsito:

La ley entiende que están las cosas muebles en tránsito desde que las recibe el encargado de su conducción hasta que quedan en poder del comprador deudor o de la persona que lo representa.

En este sentido, mientras las mercaderías estén en tránsito hacia el deudor, el vendedor al que no se le haya pagado puede dejar sin efecto el contrato, recuperar las mercaderías y pedir la resolución del contrato. Como medida alternativa, el vendedor puede retener las cosas hasta que se le haya pagado.

Si las mercaderías fueron vendidas en tránsito a un tercero de buena fe, el vendedor no tendrá estas acciones, a menos que el nuevo comprador no haya pagado el precio antes de la resolución de liquidación, en cuyo caso el vendedor primitivo puede demandar su entrega hasta el monto que se le deba.

(f) Comisión:

En el caso de comisión por cuenta propia, el comisionista que ha pagado o se ha obligado a pagar con fondos propios tiene las mismas acciones que el vendedor según señala el art. 156.

(g) Derecho legal de retención:

Este derecho legal de retención se aplica siempre que la persona que ha pagado o que se ha obligado a pagar por el deudor tenga en su poder mercaderías o valores de crédito que le pertenezcan, siempre que la tenencia nazca de un acto voluntario del deudor anterior al pago o a la obligación y que los bienes no hayan sido remitidos a destino determinado.

Sin perjuicio de lo anterior, el liquidador puede oponerse en estos casos y exigir que se le entregue la cosa vendida o retenida, previo pago de la deuda con sus intereses, costas y perjuicios o garantizando el pago.

3.2.5 Determinación del Activo: La Incautación e Inventario (ARTS. 163 y siguientes)

¿Cómo se determina el activo a partir de la resolución de liquidación? La incautación e inventario, obligaciones del liquidador, son un efecto de la resolución de liquidación y admiten un doble punto de vista para su análisis.

a) Desde la perspectiva del desasimiento

Si las observamos desde el desapoderamiento de los bienes del deudor, ellas son actuaciones destinadas a individualizar en concreto el patrimonio embargado y sujeto a ejecución; cumplen la función de una verdadera acta de embargo. Es la forma en que el liquidador toma posesión del patrimonio en concreto.

b) Como actividades inscritas en la administración del liquidador

Miradas desde la perspectiva de la administración del liquidador, son las primeras actividades de esa índole que debe cumplir el liquidador, una vez investido de su cargo. De hecho, desde la ejecución de dichas diligencias o actuaciones judiciales, el liquidador pasa a administrar el patrimonio concursado.

Por tanto, la incautación e inventario son aquellas actuaciones por las cuales se objetivizan los bienes embargados o desasidos y, por los mismo, los bienes sobre los que el liquidador tiene potestad administrativa.

Jurídicamente, el embargo general y la consecuencial administración del liquidador sobrevienen con el solo pronunciamiento de la liquidación; fácticamente, lo uno y lo otro se producen con la incautación e inventario.

Diferencias con el embargo individual

Hay, con todo, una gran diferencia entre estas actuaciones con las equivalentes del ministro de fe o del depositario en la ejecución singular con motivo del embargo.

- Actividad de administración. En el embargo singular, la actividad de administración es escasa (se nombra depositario) y sólo será compleja cuando el bien embargado sea un establecimiento comercial o industrial; en cambio, dada la naturaleza jurídica del patrimonio, en la liquidación siempre se impone una labor compleja de administración por parte del depositario. La actividad de administración, por lo mismo que es simple en la ejecución singular, es complicada en la colectiva. En ella no bastará con determinar e individualizar los bienes, sino que habrá, también, que hacerse cargo de la contabilidad, correspondencia y demás documentos del deudor, para obtener una idea más o menos cabal sobre el estado preciso de sus negocios.
- Objeto embargado. La diferencia sustancial del objeto embargado que existe en uno y otro tipo de ejecución, es que en la singular es un simple objeto individual, en tanto que en la colectiva es una sustancia viva y compleja (el patrimonio); por ello, la labor de administración es diversa. La incautación y el inventario de los

bienes del fallido que practique el liquidador tenderán, pues, a gratificar el contenido real de dicha esencia viviente que es el patrimonio concursado.

a) La incautación

El ART. 163 dispone que, asumido oficialmente el cargo, el liquidador deberá de inmediato, en presencia del secretario del tribunal o de otro ministro de fe designado por el juez:

- i) Adoptar las providencias necesarias para proteger y custodiar los bienes del deudor, si cree que corren riesgos en el lugar en que se encuentran; y
- ii) Practicar la diligencia de incautación y confección del inventario de bienes del deudor.

La incautación tiene por objeto la aprehensión material de los bienes **aparentes** del deudor; incluso el liquidador debe incautar todos los bienes que se encuentren en poder del deudor, aun aquellos que éste detenta con la obligación de restituirlos. Lo anterior proviene de la circunstancia de que el tenedor material de los bienes comporta su poseedor aparente y, en cuanto poseedor, el dueño de tales pertenencias (ART. 700 del C. Civil). Además, es frecuente que el deudor, sin ser dueño de dichas especies, sea titular de algún derecho real o personal sobre ellas.

En la diligencia de incautación debe estar presente el deudor, por cuanto la ley lo obliga “a indicar y a poner a disposición del liquidador todos sus bienes y antecedentes. Si el deudor se niega o no puede hacerlo, esta obligación incumbe a sus administradores. (ART. 169)

No debemos olvidar que, conforme al inciso segundo del ART. 169, para la práctica de esta diligencia puede auxiliarse de la fuerza pública, para lo cual le bastará la sola exhibición de un copia autorización de la sentencia reapertura, en la que, naturalmente, él debe aparecer designado liquidador.

Se debe levantar un acta de incautación, con las menciones descritas en el artículo 164, que incluye el inventario de bienes.

b) El inventario

El inventario es el documento que contiene la individualización y especificación del patrimonio del deudor, con la documentación pertinente e inclusive con la mención de las alegaciones y pretensiones formuladas por terceros en relación con los bienes inventariados, resultante de la o las operaciones de incautación. Esto obviamente va a servir para la posterior ejecución.

El inventario, asimismo, debe hacerse en presencia de alguno de los ministros de fe autorizados para la incautación. También, para su facción, puede el curador asesorarse de un perito pertinente al asunto.

Si aparecen nuevos bienes (lo que incluye a los bienes reincorporados en mérito de las revocatorias), también deben ser inventariados conforme a las formalidades precedentes y acompañarse a los autos en complemento del inventario original. (ART. 164)

En el inventario se deben hacer al menos las siguientes menciones:

1. Registro e indicación de libros, registros, correspondencia y documentos del deudor;
2. Individualización de los bienes, indicando especialmente su estado;
3. Identificación de bienes respecto a los cuales se constate la existencia de contratos de arrendamiento con opción de compra, y de todos aquellos que se encuentren en poder del deudor en calidad distinta a la de dueño.

El liquidador debe agregar el acta al expediente y publicarla en el boletín concursal a más tardar el 5° día hábil contado desde la última diligencia efectuada. Lo mismo sucede con incautaciones y ampliaciones posteriores.

El liquidador puede requerir y contratar los servicios de un especialista en el giro del deudor para que lo asesore en este proceso, debiendo señalar los antecedentes de su idoneidad técnica, cuyos honorarios vienen de los gastos generales de administración. Este nombramiento y los honorarios deben ser ratificados por la Junta. Art. 167.

Asimismo, el liquidador puede realizar la diligencia acompañado de sus dependientes o asesores de confianza, sin embargo sus honorarios serán de cargo del liquidador (art 168).

En todo este proceso, existe un **deber de colaboración** del deudor (o sus administradores) quien debe indicar y poner a disposición del liquidador todos sus bienes y antecedentes, art. 169.

¿Por qué es tan engorrosa la determinación de activos?

Por que así se protege la par conditio creditorum.

3.2.6 La determinación del pasivo.

Es el acreedor quien va a tener que demostrar que lo es y con qué preferencia.

Desde el prisma de la determinación del pasivo, el escrito de verificación de créditos y alegación de preferencias constituye un instrumento idóneo. Es por ello que no debería extrañar que la Ley sobre Insolvencia y Reemprendimiento contenga, a partir del artículo 170, un tratamiento bastante similar al existente en su antecesor, el Libro IV del Código de Comercio.

En efecto, la única modificación que se constata en una primera lectura es meramente formal y dice relación con la necesidad que le asiste al verificador de indicar una dirección válida de correo electrónico para recibir las notificaciones que fueren pertinentes.

a) Verificación Ordinaria

Los cambios, que los hay, tienen un sustrato eminentemente práctico y quizá en ello radica el eventual mérito que pudiere atribuírseles. El primero de ellos es, en una primera mirada, casi imperceptible al tenor del artículo 170 de la ley: una vez notificada en el Boletín Concursal la Resolución de Liquidación comienza a correr el plazo de 30 días hábiles para verificar créditos y alegar preferencias, o sea, el período de verificación ordinario. Este período está liderado por la idea de preclusión procesal, que “puede ser examinada desde diversos enfoques (como mecanismo, principio, institución o técnica procesal). Lo variado de sus supuestos operativos, hace

a la preclusión reconducible a una gran variedad de razones, las cuales son difíciles de reducir a una sola. Sin embargo, es posible identificar que todas las versiones de la preclusión tienen que ver con la necesidad de velar por la disposición con que se presentan los actos y resoluciones en el proceso, desde el punto de vista cronológico (por ejemplo, la presentación en cierto tiempo o la procedencia de un acto luego de agotada una etapa)".

El artículo 172 indica que una vez transcurrido el plazo legal, el período ordinario de verificación se entiende cerrado de pleno derecho, sin necesidad de resolución ni notificación alguna (eventualmente van a poder verificar extraordinariamente). Esta consagración del principio de fatalidad de los plazos, muy unido a la preclusión, permitirá agilizar un aspecto que empíricamente estaba convertido en un relevante atasco procesal concursal.

Para estos efectos, el art. 170 señala que los acreedores tienen un plazo de 30 días desde la notificación de la resolución de liquidación para verificar estos créditos y alegar su preferencia ante el tribunal que conoce el procedimiento, además, de como ya hemos señalado, deben acompañar los títulos justificativos de su crédito y señalar una dirección de e-mail.

Una vez vencido el plazo de verificación ordinaria el liquidador tiene que publicar en el Boletín Concursal todas las verificaciones presentadas en el plazo de los dos días siguientes.

El vencimiento del plazo de verificación ordinaria se produce de pleno derecho por el vencimiento del plazo, sin necesidad de resolución alguna.

También la ley regula la situación de los **prestadores de servicios de utilidad pública** en el art. 171:

- En esos casos, estos prestadores también deben verificar sus créditos, pero no pueden suspender sus servicios *a menos que el tribunal lo autorice*. Si lo hacen sin previa autorización están sujetos a una multa sumaria de entre 1 a 200 UTM, debiendo restablecer el servicio.
- Los servicios prestados con posterioridad a la resolución de liquidación, tienen la preferencia del art. 2472, N° 4 del CC
- Si a la fecha de la resolución de liquidación los servicios están suspendidos, el liquidador puede solicitar su reposición inmediata. El costo de reposición es de cargo del prestador, pero cualquier crédito que nazca de ellos tiene también la preferencia del art. 2472 N° 4 del CC.

Una vez vencido entonces el periodo de verificación ordinaria, el liquidador debe examinar todos los créditos verificados y las preferencias alegadas. Para esto debe verificar, con especial consideración **si son créditos de partes relacionadas**:

- Origen
- Cuantía
- Legitimidad
- Si están garantizados

A continuación, el artículo 174 incluye una importante novedad en el tratamiento de los reparos que pudiere tener el liquidador, la empresa deudora o los restantes acreedores en relación a un determinado crédito y/o preferencia.

1. En efecto, la primera etapa o fase dentro del concepto de impugnación es la objeción.

Podemos singularizarla como aquel *acto jurídico procesal escrito interpuesto por el liquidador, uno o más acreedores o la empresa deudora y en virtud del cual controvierten, atacan o ponen en tela de juicio la idoneidad y verosimilitud del crédito verificado y/o la preferencia alegada por un determinado acreedor*. Las objeciones se presentan por el deudor/acreedores/liquidador ante el tribunal que conoce de la liquidación.

Si no hay objeción dentro de 10 días hábiles contados desde el término del período de verificación ordinario se da por reconocido el crédito y/o la preferencia, y dentro de los 3 días siguientes el liquidador debe publicar en el Boletín Concursal la nómina de créditos reconocidos y las objeciones, y acompañarlas al expediente.

Si hay objeción, nace un deber propio del liquidador, consistente en propender a alcanzar acuerdos que permitan superar los defectos que justificaron deducir la objeción.

El liquidador, entonces, asume un rol proactivo que no está dirigido a derrotar al acreedor o inventar toda una serie de argumentos para ir rebajando el pasivo del deudor, sino que la única motivación de su accionar es o debiera ser obtener la certidumbre necesaria para que el crédito pueda realmente estimarse como reconocido o como bien alegada la preferencia.

Esta primera etapa es útil para alivianar la carga de nuestros tribunales, precisamente en aquellas situaciones en que el fundamento de la objeción, descansan en aspectos formales o de corrección más accesible. Con todo, el éxito de la gestión descansará, por cierto, en la voluntad del acreedor objetado. En efecto, conforme al artículo 175 de la Ley N° 20.720, el acreedor podrá estar conforme con las modificaciones sugeridas por el liquidador y, en tal caso, existirá la legitimidad pertinente para reconocer el crédito.

De ahí que el acreedor recibe la visión del liquidador como una *recomendación*, un mero consejo que de ningún modo invade sus márgenes de libertad, manteniéndose en plena capacidad de decidir aceptar dicha sugerencia o perseverar en su propia, personal y autónoma percepción del crédito y/o la preferencia, dejando que sea el tribunal del concurso quien resuelva los pareceres en oposición.

- 2. Si el acreedor no accede a la objeción, en esta última situación, la objeción se transformará automáticamente en impugnación**, pudiendo ser conceptualizada señalando que se trata de *aquella consecuencia jurídica prevista por el legislador en caso que el acreedor objetado manifieste su disconformidad, rechazo o no aceptación de la sugerencia planteada por el liquidador en el plazo legal y en orden a la corrección de los defectos que este último estima concurrentes en el crédito verificado y/o en la preferencia alegada*.

Este período de perfeccionamiento es corto: dentro de los 10 días hábiles siguientes al término del plazo para objetar el liquidador debe entregar los resultados de sus gestiones:

a) Nómina de los Créditos Impugnados:

En otras palabras, aquellos acreedores que no aceptaron, por cualquier causa, la vía correctiva o de subsanación sugerida por el liquidador, pasan a integrar una lista con fines de orden y publicidad.

b) Informe sobre Créditos Impugnados.

El liquidador debe entregar al tribunal que conoce del concurso un Informe acerca de los créditos impugnados. El legislador no ha señalado el contenido específico de tal documento. Así, el liquidador deberá remitir al juez del concurso el “dictamen, asesoramiento o consejo emitido por un perito o por una repartición pública competente, a fin de esclarecer los hechos que interesan a la causa” (una especie de relación).

Idealmente, el liquidador debería instar por confeccionar un documento que contuviera una razonable descripción de los hechos en orden a facilitar la resolución del tribunal. En ese sentido, sería esperable que el esfuerzo del administrador concursal junto con el de sus asesores, hiciera hincapié en coordinar armónicamente tanto los argumentos vertidos por el propio liquidador y equipo asesor para sustentar la objeción/impugnación, así como los razonamientos invocados por el acreedor cuyo crédito o preferencia han sido objetados para defender su resistencia a la sugerencia del liquidador.

Bajo esta perspectiva, será un esencial deber del liquidador aportar la mayor información disponible a efectos de ilustrar al tribunal acerca de las materias a resolver, no sólo para justificar la responsabilidad que el legislador y la Junta de Acreedores le ha confiado sino también para dar seguridad al acreedor objetado en cuanto sus descargos o razones para mantener su postura han sido debidamente reflejadas.

La expresión “motivos plausibles” que contiene el artículo 175, inc. 1°, debe entenderse como argumentaciones tendientes a reforzar el planteamiento del liquidador que sustentó la objeción, pero también los raciocinios del acreedor objetado para fortalecer su decisión de perseverar en la forma inicial en que verificó su crédito o alegó su preferencia. Por cierto que, como buen complemento, el liquidador podrá adjuntar a su Informe, copias simples tanto de los escritos de verificación de créditos como de objeción, junto con las presentaciones que los interesados le hubieren hecho llegar en apoyo de sus particulares puntos de vista.

c) Resolución:

Las impugnaciones deben ser resueltas por el tribunal que conoce del concurso en una Audiencia Verbal, la que debe tener lugar dentro de décimo día contado desde la notificación por aviso en el Boletín Concursal de la resolución que tuvo por acompañada la Nómina de Créditos Impugnados, a la que pueden asistir tanto impugnantes como impugnados.

Conforme a lo previsto en el artículo 177 de la Ley N° 20.720, la resolución que se pronuncie sobre las impugnaciones es apelable en el solo efecto devolutivo, gozando tal recurso de preferencia para su inclusión en Tabla, su vista y su fallo.

b) Verificación Extraordinaria.

Básicamente se produce respecto a los acreedores que no hayan verificado sus créditos en el proceso de verificación ordinaria, quienes pueden verificar sus créditos mientras no esté firme y ejecutoriada la Cuenta Final de Administración del Liquidador (Art. 179).

El objeto de esta verificación extraordinaria es ser considerados en repartos futuros y deben aceptar todo lo obrado con anterioridad. No tiene efectos retroactivos entonces todos los repartos y actuaciones previas son válidas.

Estos créditos también pueden ser objetados o impugnados según el procedimiento de los art. 174 y 175 dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación de su verificación en el Boletín Concursal.

3.3 Juntas de Acreedores

Existen 3 tipos de juntas, art. 180:

- Junta constitutiva
- Junta ordinaria
- Junta extraordinaria

A) Publicidad

a) Las juntas son de carácter público, aunque puede ser de acceso limitado por razones de seguridad previa autorización judicial. En ellas tienen derecho a voz:

- Todos los acreedores que hayan verificado sus créditos, con o sin derecho a voto
- El deudor
- El liquidador
- Superintendente de Insolvencia y Emprendimiento, o quien este designe.

b) El acta de la junta se publica en Boletín Concursal, debiendo ser suscrita por el liquidador, los acreedores designados y el deudor si así lo quiere.

B) Quórum

1) El quórum es común a todas las juntas para sesionar:

- Uno o más de los acreedores que representen al menos el 25% del pasivo con derecho a voto, salvo que la ley exija un quorum distinto.
- Para tomar acuerdos, quorum simple.

- A falta de quorum, el liquidador lo certifica y se publica en el Boletín Concursal al día siguiente del que debió celebrarse la junta.
- Los acreedores pueden asistir personalmente o representados mediante el mandato judicial en los términos del art. 187.

2) Suspensión: En caso que por abstención de acreedores presentes no se tomen acuerdos, el liquidador podrá suspenderla para conseguir el quorum necesario para aprobarlo. Para ello la Junta se reanuda al segundo día y debe seguir el procedimiento del art. 186.

3) Prohibición de Fraccionar Créditos: los acreedores están impedidos de fraccionar los créditos después de dictada la resolución de liquidación (Art. 188). Su justificación viene dada para evitar fraudes que generen artificiosamente quórum que de otra forma no se generarían.

- Sanción para todos esos acreedores: Pérdida de derecho a asistir a la junta
- Fraccionamiento del crédito 30 días antes de la resolución de liquidación: Los acreedores se cuentan como una sola persona y pueden emitir un solo voto, debiendo designar a un representante.

Obviamente esto no se aplica en caso de liquidaciones de sociedad o particiones de comunidad.

C) Derecho a Voto

- a) Acreedores por créditos reconocidos y no pagados (art. 189) (se mantiene derecho a voto por el saldo insoluto, art. 192).
- b) Acreedores por créditos no reconocidos autorizados especialmente por el tribunal (Art. 190), se refiriere principalmente a créditos que se encuentran impugnados.
- c) Personas Relacionadas no tienen derecho a voto ni se cuentan en el quórum, art. 191.
- d) Acreedores con conflicto de interés se deben abstener de votar un acuerdo, art. 191.

El derecho a voto de los acreedores se extingue en caso que los créditos que tenían hayan sido totalmente pagados en un reparto, por pago administrativo o de cualquier otra forma.

D) Comisión de Acreedores

Las Juntas de acreedores pueden acordar con quórum calificado (mayoría absoluta del pasivo con derecho a voto) la constitución de una comisión de acreedores para adoptar acuerdos dentro de la órbita de su competencia, según la composición, facultades, duración y procedimientos que fije la misma Junta. (Art. 202)

E) Tipos de Juntas

a) Junta Constitutiva:

(1) Es la primera junta de acreedores, y tiene lugar al día 32° desde la publicación de la Resolución de Liquidación en el Boletín Concursal.

(2) Se realiza en el tribunal o en el lugar que se indique para tales efectos, es presidida por el juez y actúa como ministro de fe el secretario del tribunal.

Si no se celebra a la primera citación, debe efectuarse el segundo día, en el mismo lugar y hora. Para estos efectos, el secretario del tribunal levantará acta y desde entonces los acreedores entenderán legalmente notificados de esta segunda citación, se celebra con los que asistan, y las decisiones se toman con quórum simple.

Si a la segunda citación no asiste nadie, se certifica esta situación y se producen de pleno derecho los siguientes efectos:

- i) Se ratifican los liquidadores
- ii) Liquidador publica en el boletín comercial dentro de 3° día:
 - (a) Referencia a la certificación hecha por el secretario
 - (b) Cuenta sobre el estado de los negocios del deudor, activo y pasivo y lo realizado por él,
 - (c) Lugar, día y hora de juntas ordinarias
- iii) Inicio a liquidación sumaria.

(3) Materias de la Junta Constitutiva:

- i) Cuenta del liquidador:
 - Estado preciso de los negocios del deudor, activo y pasivo
 - Si realización del activo será inferior o no a 5.000 UF
- ii) Ratificación del liquidador o designación de reemplazante
- iii) Determinación de juntas ordinarias (a lo menos semestralmente)
- iv) Designación del presidente y secretario entre los acreedores
- v) Plan o propuesta de realización de los bienes del deudor, o continuación de las actividades económicas, si procede
- vi) Acuerdos relacionados con la vigencia de contratos de arrendamiento con opción de compra celebrados por la empresa deudora (arts. 225 y 227). Eventualmente puede ser más beneficioso pagar las cuotas de leasing y obtener el inmueble para venderlo.
- vii) Otros acuerdos, salvo materias propias de juntas extraordinarias de acreedores

b) Junta Ordinaria: Art. 198

Lo normal es que sean una vez al mes (ellos lo determinan) y las materias de este tipo de juntas son:

- i) Informe acerca del activo y pasivo, especialmente las variaciones experimentadas desde la junta constitutiva;

- ii) Plan o propuesta de realización de bienes del deudor;
- iii) Estimación de principales gastos del concurso
- iv) Continuación de actividades económicas del deudor
- v) Eventualmente, con quórum especial (2/3 del pasivo), la no celebración de juntas ordinarias por un periodo determinado

c) Junta Extraordinaria:

Tiene lugar cuando la pide/ordene:

- El Tribunal competente, el liquidador o la Superintendencia
- Acreedor/es que representen 25% del pasivo con derecho a voto
- Acuerdo de acreedores en junta ordinaria (quórum simple)

Sus materias son *todas las que no sean propias de la Junta Constitutiva u Ordinaria*, y especialmente (solo pueden ser resueltas en junta extraordinaria):

- i) Revocación del Liquidador
- ii) Presentación de proposiciones de Acuerdo de Reorganización Judicial
- iii) Contrataciones especializadas del Liquidador (él las propone, y deben ser aprobadas porque suponen gastos lógicamente)
- iv) Anticipos de honorarios del liquidador

Para estos efectos, la ley exige ciertas formalidades de citación, descritas en el art. 201.

Normalmente las juntas ordinarias son informativas, mientras que las extraordinarias son aquellas en virtud de las cuales se toman decisiones claves.

3.4 Realización de bienes

La ley prevé varias formas de realización, porque puede el deudor encontrarse en diversas circunstancias (ej. hay deudores que tienen pocos bienes o poca actividad y no es razonable someterlos a procedimientos extensos// otros deudores pueden tener muchos negocios pendientes, y no es práctico terminar con ellos que pueden servir para pagar a acreedores).

A) Realización sumaria/simplificada. Es expedita, para casos que lo ameritan.

Se aplica en los casos descritos en el art. 203:

- a) Deudor microempresa (art. 2° Ley 20.416*). Lo debe certificar el liquidador.
- b) Si el liquidador informa en la Junta Constitutiva que el producto probable de la realización del activo no excederá de las 5.000 UF. En ese sentido, este es un efecto importante de la

Son microempresas aquellas empresas cuyos ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro no hayan superado las 2.400 unidades de fomento en el último año calendario (ap. \$70 millones).

realización de inventario y el valor de realización de los bienes que lo componen. Estos montos hacen referencia a liquidaciones chicas.

Si el deudor o algún acreedor opina lo contrario, puede oponerse en la misma Junta Constitutiva, debiendo el tribunal resolverla en la misma Junta.

- c) Si no se celebra por segunda vez la Junta Constitutiva por falta de quórum. Acá en el fondo hay falta de interés de los acreedores, entonces amerita una liquidación rápida.
- d) Si se celebra en segunda citación la Junta Constitutiva con asistencia igual o inferior al 20% del pasivo total con derecho a voto.
- e) Si lo acuerda la junta de acreedores.
- f) Si aplica el art. 210 (falta de acuerdo en la forma de enajenación dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la Junta Constitutiva).

Para estos efectos se debe seguir el procedimiento descrito en el art. 204, en que básicamente:

- Los valores mobiliarios con presencia bursátil se venden en remate en bolsa.
- Los demás bienes muebles e inmuebles se venden al martillo.

Si no se pueden cumplir con los plazos de realización descritos en el art. 204 letra (h) (4 meses siguientes a la celebración de la Junta Constitutiva o de su segunda citación), el liquidador debe informar al tribunal al menos con 15 días de anticipación al vencimiento del plazo explicando las razones. Debe seguir informando cada 30 días.

Los acreedores pueden acordar en la Junta Constitutiva una fórmula distinta, pero que igualmente debe ejecutarse en el plazo de 4 meses antes señalado.

B) Realización ordinaria

Por regla general, la forma de realización ordinaria, plazos, condiciones y demás características la determina la junta de acreedores (art. 207). Lo que hace la ley es suplir la voluntad de los acreedores.

Las formas son (art. 208):

- Venta al martillo de bienes muebles e inmuebles (Art. 213 y siguientes). Se venden por unidades los bienes, las cosas se venden a medida que se puedan vender.
- Remate en bolsa (valores con presencia bursátil).
- Otras (venta como unidad económica u oferta de compra directa).

Para estos efectos, los plazos deben ser los **menores posibles**, pero se cuentan desde la Junta Constitutiva o desde que debió celebrarse en segunda citación (art. 209):

- Máximo 4 meses para bienes muebles
- Máximo 7 meses para bienes inmuebles

Se pueden acordar extensiones fundadas con quorum calificado antes del vencimiento por 4 meses más. Esto puede asimismo prorrogarse con el mismo quorum y autorización de la Superintendencia. Esta extensión puede referirse a bienes específicos o procede en términos generales.

Si el liquidador estima que no se podrá dar cumplimiento a los plazos de realización establecidos en el artículo 209 deberá comunicarlo a la Superintendencia, explicando las razones del retraso. Esta comunicación deberá efectuarse a lo menos quince días antes del vencimiento del plazo de realización ordinaria (art. 211).

En caso de silencio de los acreedores sobre la forma de realizarlos, debe hacerse sumariamente (art. 210).

En caso de bienes muebles expuestos a deterioro o desvalorización inminente o exijan conservación dispendiosa, el liquidador podrá realizarla en cualquier tiempo, debiendo informarlo en la siguiente Junta (art 212).

Formas especiales de realización ordinaria:

C) Venta como unidad económica

Aplica principalmente a las empresas en marcha, que tienen negocios en curso. Probablemente tienen bienes que no deben liquidarse como tales, sino que están destinados, por ejemplo, a ser transformados. Además, para esa transformación se requiere de cierta maquinaria o estructura. En estos casos no es razonable vender la estructura y el inventario por separado, sino que es mejor seguir produciendo para que haya mayor recuperación.

También puede ser que la empresa se encuentre en una etapa de madurez muy temprana y sea mejor esperar a que madure para venderla como un todo. Por último, puede que la empresa valga más como un todo que como un conjunto de bienes.

a) La Junta puede acordar la venta como unidad económica, según lo siguiente (art. 217):

El acuerdo debe incluir el conjunto de bienes sujetos a la venta, cualquiera sea su naturaleza. Si se incluyen bienes existentes en un bien raíz de terceros, se incluyen los derechos respectivos sobre el mismo (ej. derechos personales que emanan del contrato de arriendo// comodato// derecho real de uso); esto es para facilitar la venta y evitar rebajas de precio por cuestiones externas a los bienes y su capacidad para producir flujos.

El acuerdo debe contener el precio mínimo de venta, forma de pago y garantías, así como las demás modalidades.

b) Efectos

Si se acuerda la venta como unidad económica, se suspende el derecho de los acreedores hipotecarios, prendarios o retencionarios para iniciar o continuar con sus acciones de realización (art. 218). Esto para mantener la continuidad de la unidad económica.

Para estos efectos, la Junta debe indicar la parte del precio de la venta que le corresponde a dichos acreedores, tanto respecto al precio mínimo como al precio que se obtengan, como una forma de fijar sus derechos. Todo esto busca que estos acreedores aprueben la venta de unidad económica. Pero si votaron en contra de la venta como unidad económica pueden oponerse también al precio y pedir su rectificación, pudiendo pedir un informe pericial. Art. 219.

La venta como unidad económica no califica como venta de establecimiento comercial (Art. 220). Entonces, no se paga IVA.

c) Formalidad (art 221)

Posteriormente, se deja constancia en escritura pública el cumplimiento de todas las formalidades, la que debe ser aprobada por el tribunal, que a su vez debe ordenar el alzamiento de todos los gravámenes y prohibiciones.

Sin embargo, se entienden dados en prenda o hipoteca los bienes vendidos para el solo efecto de garantizar el pago del saldo de precio si correspondiere, salvo que se haya excluido este efecto. Son casos de prenda/hipoteca legal.

D) Venta directa

El liquidador busca directamente al comprador, porque así puede encontrar mejores precios. Lo que generalmente ocurre es que el liquidador, creyendo que va a encontrar mejores precios que en pública subasta (por el tipo de activo), le pide a los interesados una oferta que se presenta a la junta.

Las ofertas de compra directa deben realizarse al liquidador quien debe exponerlas en la siguiente junta de acreedores (art. 222).

La oferta requiere de quorum especial (dos tercios) para ser aprobada. Si no se logra este quorum, por quorum calificado puede acordarse su venta al martillo, informando al oferente, en el precio originalmente ofrecido por el oferente. Si no hay postores, se puede vender al oferente en el precio ofrecido (art. 223).

*** Hasta acá hemos visto cómo este procedimiento es mucho más estricto y regulado que el de reorganización, porque acá hay una protección mayor de la par conditio dado que hay mayores peligros para los acreedores, sin embargo, dentro de esta rigidez hay algunos brotes de flexibilidad como la venta directa o como unidad económica ***

E) Leasing (art 227)

No es una forma de realización propiamente tal, pero ¿qué pasa con los bienes dados en leasing? Recordemos que dictada la resolución de liquidación el arrendador no puede ponerle término unilateral al contrato de leasing

La gracia de un leasing es que del mismo flujo de operaciones se paga el arrendamiento y no se inmoviliza capital; además, la renta que se paga es gasto (por lo que se pagan menos impuestos) y

por último otra ventaja es que luego de cierto período se puede pedir sustitución del bien. En conclusión, da la posibilidad de acceder a bienes sin necesidad de inmovilizar capital.

Si una compañía que entra en liquidación tiene leasing de una flota de aviones, eso da la posibilidad de: (1) terminar los contratos anticipadamente, y si existen cuotas impagas el arrendador es acreedor valista y deberá verificar créditos, (2) mantener la vigencia respecto de algunos aviones para seguir produciendo caja (en ese caso se sigue pagando ese crédito no obstante la resolución de liquidación), (3) ejercer opción de compra.

El arrendamiento con opción de compra es una “operación financiera integrada generalmente por el contrato de compraventa de un bien de capital productivo, que se celebra entre la empresa de leasing y el fabricante o proveedor del mismo y el contrato de leasing propiamente tal, que une a la empresa de leasing con el usuario”, donde, por un lado, concurre un arrendamiento sujeto a ciertas condiciones especiales y, por otro, la posibilidad que le asiste al arrendatario de adquirir el dominio de la cosa por medio de una compraventa. También concurren convenciones complementarias, como por ejemplo, contratos de seguro, suscripción de pagarés, asunción de obligaciones expresas de mantenimiento de la cosa, entre otras.

El método de financiamiento, consiste en facilitar que el empresario logre acceder a bienes de producción que efectivamente pueda incorporar en sus actividades económicas, acentuando que el interés más relevante ***no es adquirir necesariamente el dominio de la cosa sino únicamente detentar su materialidad***, situarla dentro de la esfera de cuidado propio, tener, en suma, las facultades de uso y goce. Si, al final del período, el empresario concluye que es conveniente celebrar un contrato de compraventa respecto del bien, lo manifestará así o, en caso contrario, lo restituirá al arrendador.

En síntesis, atendidas las ventajas contractuales que esta figura presenta (tratamiento tributario, menor valor de cuota en relación al financiamiento directo, posibilidad de renovación de la cosa según condiciones pactadas, etc.) convierten al leasing en una fórmula prácticamente omnipresente en los procedimientos concursales nacionales. De ahí la necesidad, sumada a complejidades específicas de entregar una legislación concursal adecuada a la importancia de esta clase de contratos.

En primer lugar es oportuno evidenciar que hay consagración legal expresa de una estructura vinculante.

Ese es, en consecuencia, un primer punto a favor de la ley: hacerse cargo de entregar una regulación del leasing en materia falencial (la antigua ley no regulaba esta materia). En esta visión, las partes interesadas en celebrar esta clase de acuerdos podrán saber de antemano las opciones en casos de concursalidad y, por ende, prevenir sus alcances y actuar en consecuencia, disminuyendo el riesgo de incertidumbre, de interpretaciones forzadas y resultados inesperados y/o inexplicables.

En segundo lugar, el legislador estimó conducente entregar un cuerpo legal que es conducente a un escenario más equilibrado entre todos los intereses que confluyen en la insolvencia.

a) Necesidad de incautar

El legislador ha impuesto al liquidador el deber jurídico de amparar los bienes objeto de un leasing, manteniéndolos dentro de su esfera de cuidado. En otras palabras, aun sabiendo que no se trata de bienes que la empresa deudora tenga en dominio, que no son bienes del deudor, igualmente forman parte del inventario y el administrador del concurso se ve obligado a darles la misma protección que a los bienes estrictamente propios del concursado.

Esta innovación normativa busca entregar mayor tranquilidad y certeza al arrendador: con prescindencia del futuro del contrato, los bienes objeto de él estarán cuidados y resguardados, igual como los activos del deudor. Pero, además, los gastos, como lo expresa la norma del artículo 224, de conservación, custodia y/o bodegaje de los bienes Leasing serán de cargo de la masa y en caso de desacuerdo en su monto resolverá el tribunal que conoce de la liquidación. Este deber de protección o cuidado tiene una duración limitada: hasta la fecha de celebración de Junta Constitutiva, sin perjuicio que, ciertas hipótesis que veremos más adelante, esa obligación podría extenderse.

b) Efecto de la Resolución de Liquidación

Con bastante frecuencia, se ha puesto en tela de juicio la efectividad de las estipulaciones de un leasing en lo relativo a que la declaración de quiebra ocasiona su inmediata terminación. En este sentido, si la bancarrota no es causal de término que opere de pleno derecho, forzoso es esclarecer qué pasa con el Leasing, aspecto que, a nuestro juicio, debería someterse a los mismos parámetros intelectuales que los restantes contratos suscritos por el deudor. En suma, el primer paso sería determinar su conveniencia, vale decir, si perseverar en la ejecución del acuerdo podría reportar beneficios concursales que, finalmente, redundarían en **mayor proyección de recuperación**. Temporalmente, esta calificación recaería directamente en el liquidador, ya que representa a los acreedores pero también a los derechos del fallido en todo lo que pueda interesar a la masa, especialmente en quiebras de mayor envergadura y/o donde existieran importantes dificultades prácticas para delimitar la existencia o la extensión del Leasing.

En la nueva ley, esas incertidumbres terminan: la resolución de liquidación NO constituye causal de término del Leasing y su único efecto palpable será el deber del liquidador de incautar los bienes sobre los cuales recae ese arrendamiento, darles el cuidado debido y esperar. Esperar que tenga lugar la Junta Constitutiva, ya que en ella deberá discutirse acerca del futuro del leasing: (1) continuar con el contrato en los términos originalmente pactados, (2) ejercer opción de compra porque ya ha llegado el plazo para hacerlo, o bien adelantar la opción de compra (porque el retorno esperable de venderlo será más alto) y (3) terminar el contrato y devolver el bien.

c) Opciones de la Junta de Acreedores

Durante el tiempo que media entre la resolución de liquidación, su asunción al cargo y la Junta Constitutiva, el liquidador ha tenido tiempo suficiente para conocer los contratos de leasing suscritos por la empresa deudora y, también, ha podido esclarecer si la perseverancia en ellos reportaría beneficios a la masa. En otros términos, puede dar cuenta circunstanciada a los

acreedores acerca de la conveniencia o no de seguir adelante en el leasing. El artículo 225 entrega expresamente las posibilidades que tiene el órgano decisorio del concurso:

- i) Continuar con el leasing en los términos originalmente pactados. El propósito del legislador fue permitir que la Junta concluyera acerca de su interés en perseverar en el contrato. Ese interés se presume concurrente en casos donde el bien dado en leasing tenga gran importancia en la actividad del deudor o simplemente se trate de un contrato que ha venido cumpliéndose durante bastante tiempo, bastando poco tiempo relativo para alcanzar la opción de compra. En cuanto a términos originalmente pactados, nos referimos a que las cuotas que se devenguen con posterioridad al acuerdo de la Junta Constitutiva deberán pagarse oportunamente, omitiéndose, en todo caso, cualquier adición o incremento que tenga como base la mora previa a la resolución de liquidación.
- ii) Ejercer anticipadamente la opción de compra, en los términos establecidos en el respectivo contrato. Esta posibilidad requiere que la empresa deudora deba pagar todas las cuotas necesarias para ejercer la opción de compra, de modo tal que en realidad existe una suerte de aceleración a la inversa, donde la Junta opta por el pago directo y total a cambio de incorporar el bien dado en leasing al patrimonio del deudor.
- iii) Terminar anticipadamente el contrato, restituyendo el bien. Es perfectamente posible que la Junta valore que el bien dado en arrendamiento es prescindible, o sea, que el deudor puede desprenderse de él sin grave detrimento al giro o a las posibilidades reales de recuperación del crédito. En este caso, no quedará más que proceder a la restitución del bien al acreedor, sin perjuicio de, eventualmente, invocar de común acuerdo alguna de las formas negociadoras que implícitamente prevé el artículo 227.

Cabe hacer presente que, en caso que la Junta Constitutiva no se celebre o no se pronuncia respecto del leasing, el legislador consagró un efecto particular, a saber, entender que se ha optado por continuar con el leasing en los términos originalmente pactados. Tampoco debemos olvidar la descripción final del artículo 225, que nos indica la inexistencia de cualquier cláusula acordada en el Leasing que contraría lo previsto en la norma en estudio.

d) Verificación

La ley concursal busca someter al acreedor del leasing a un tratamiento similar al de los demás acreedores. Por ello, conforme lo dispone el artículo 226, puede verificar las cuotas devengadas e impagas hasta la fecha de la resolución de liquidación.

Estas son sumas que se someten íntegramente al concurso y se pagan conforme a las resultas del mismo. Con todo, las cuotas o rentas que se devenguen entre la resolución de liquidación y la Junta Constitutiva -período de “tregua” en que el bien dado en leasing ha sido incautado a efectos de permitir una decisión informada de la junta a su respecto, serán asumidas por la masa. Probablemente, nos encontraremos con que esas cuotas serán una sola, que ya es dable presumir

que la época de devengamiento coincidirá con la fecha de celebración de la junta (1 mes aproximadamente).

El mismo artículo 226 se encarga de aclarar la forma en que se pagarán las sumas posteriores a la resolución de liquidación. En cuanto a las multas, expresamente el legislador ha consagrado un desincentivo concursal: es perfectamente posible y válido verificarlas pero no en virtud del leasing como título, sino de una sentencia firme o ejecutoriada que las conceda y por el monto en ella señalada, en procedimiento sumario.

e) Finalmente, el artículo 227 permite que la Junta Constitutiva, con quórum calificado, pueda acordar una forma de realización de los bienes de la empresa deudora que incluya al bien dado en leasing (ej. venta como unidad económica). Pareciera un acto de disposición de bienes ajenos pero en realidad se ceden los derechos que emanan del contrato de leasing.

F) Reglas complementarias a la realización

a) Créditos morosos (cuentas por cobrar) y activos de difícil realización:

La junta puede decidir venderlos en las condiciones que libremente acuerden, siempre que la decisión se tome por quorum calificado (mayoría absoluta del pasivo total con derecho a voto verificado/reconocido según corresponda).

Adicionalmente, se exige que:

- No se haya realizado oferta anterior alguna en venta al martillo sin mínimo; o
- Que el liquidador ha hecho gestiones con al menos 3 martilleros y ninguna ha querido tomar el encargo por el bajo monto esperado.

b) No perseverar en la persecución de bienes:

También es una decisión que se toma por quorum calificado, ya que el costo estimado es superior al beneficio esperado de su realización.

G) Realización de los activos

a) Bienes Raíces

En materia de bienes inmuebles, su realización podríamos calificar como la más simple y directa, siendo su objetivo fomentar que la realización de bienes raíces en procedimientos concursales tenga lugar en la forma particular y autónoma acordada por la junta de acreedores. En otras palabras, confiando la concurrencia copulativa de dos aristas: que si el análisis fáctico efectuado por el legislador es verdadero, es decir, la enajenación de inmuebles ante el tribunal que conoce de la quiebra presenta desventajas que aminoran la recuperación del crédito, la Junta de Acreedores optará por un método diverso y que esa decisión adoptada por el órgano concursal será racional, o sea, dispondrá de los medios orientados a la consecución de lo que se entiende un objetivo común, cual es, alcanzar el máximo recupero posible de lo adeudado por el concursado.

Nuestra nueva ley concursal, ha consagrado efectivamente el principio rector de la actividad falencial en lo que a realización de bienes interesa: **el activo del deudor se venderá en la forma que determine la junta de acreedores**. Sólo por defecto o, más bien, en casos de silencio de la Junta u otros supuestos legales, el liquidador se encontrará habilitado para actuar de un modo independiente y autónomo, aplicando su propio criterio para obtener el resultado más beneficioso para todos los intervinientes, entre los cuales se encuentra él mismo, en el entendido que mientras mayor sea la recuperación efectiva y los repartos que tengan lugar, más alta será la retribución económica que percibirá.

Junto a lo expuesto, la existencia de un régimen en que la realización de los bienes se impone en cuanto a sus medios por el legislador, incide en los denominados costos de la quiebra. En la literatura financiera se mencionan dos tipos de costos de quiebra; costos directos y costos indirectos. El primero de ellos se refiere a los costos reales que nacen del *distress* financiero de la propia empresa, dentro de los cuales podemos encontrar honorarios de profesionales externos a la empresa quebrada, específicamente abogados, contadores, tasadores, actuarios y síndicos. Además, en esta misma categoría de costos encontramos los gastos correspondientes a los recursos internos que la empresa en situación de quiebra invierte en términos de tiempo y esfuerzo de su staff de personal involucrado en evaluar y tratar con las implicaciones de la quiebra. En efecto, tratándose de subastas efectuadas al martillo, usualmente la tramitación ya se encuentra internalizada por todos los intervinientes, quienes conocen en forma anticipada su desarrollo y pueden decidir en forma cabal la conveniencia o no de concurrir al llamado. No pasa lo mismo en las subastas públicas efectuadas ante el tribunal que conoce de la quiebra: el gasto en personal, tiempo y recursos para intentar atenuar el impacto de las argucias para evitar el llamado a remate y la necesidad de contar con asesores de punto fijo con cierta antelación a la hora señalada para la subasta en un escenario lleno de incertidumbres y riesgos, aun en el entendido que, como ya se dijo, nuestra judicatura suele entregar remedios eficaces para una primera fase del proceso.

Con todo, los **acreedores pueden optar por la fórmula legalmente entendida como licitación pública** cuyas bases deberán ser aprobadas por la junta de acreedores. Es, precisamente, esta vía la utilizada por el órgano decisorio concursal para eludir la pública subasta, tratándose de bienes raíces del fallido. A su turno, esta estructura presenta numerosas dificultades entre las cuales podemos enumerar las que siguen:

- i) No existe una definición explícita de “licitación pública” para efectos concursales. Una referencia indirecta podemos encontrarla en el ámbito de la contratación pública: importa la existencia de un concurso de proveedores para adjudicarse la adquisición o contratación de un bien o servicio requerido por una organización. En el ámbito público, los proveedores deben formular sus propuestas sujetándose a las bases fijadas por los organismos públicos, de entre las cuales se seleccionarán y aceptarán la (s) oferta (s) más conveniente (s). Por cierto que esta conceptualización no concuerda con la imagen que el foro tiende a formar cuando se habla de licitación pública en el ámbito de una quiebra. En esta última situación, nos referimos más bien a una subasta

como cualquier otra en que el bien a rematar es inmueble y donde, además, concurre un martillero público. En rigor y dejando fuera prevenciones de cualquier índole no es más que el andamiaje jurídico para lograr que un bien raíz sea subastado al martillo, a través de mecanismos en que técnicamente la adjudicación no la realiza tal auxiliar, sino el Síndico o bien algún otro partícipe según lo prescriban las bases (de ahí el conocido término "Licitación - Remate"), y

- ii) Desde la órbita concursal, la Superintendencia de Quiebras dictó un Instructivo que buscó dar un parámetro más objetivo y concreto a la licitación pública en esta clase de materias. Sin embargo, es necesario reconocer que tal normativa administrativa rara vez ha sido invocada, sobre todo en virtud que, bajo la perspectiva de los acreedores, carece de una naturaleza vinculante u obligatoria, operando como un mero consejo o sugerencia.

En resumen, se debe usar una fórmula para buscar el precio más alto. En ese sentido, puede efectuarse un remate holandés en que en vez de ir subiendo el precio, se parte del más alto.

b) Formas de Realización

El Art. 207 entregó expresamente a la junta de acreedores la determinación de la forma de realización de los bienes del deudor, sus plazos, condiciones y demás características. A continuación, en el artículo 208, nuestra ley buscó facilitar, como en la totalidad de su texto, el acceso a una descripción clara e ilustrativa, señalando los medios que por antonomasia tienen lugar en procedimientos concursales en la esfera de la liquidación: ventas al martillo; remate en bolsa de valores y otra forma distinta de realización de bienes, que ya hemos tratado.

i) Ventas al Martillo:

En la nueva ley no se ha puesto en duda que el martillo sea una fórmula de realización eficiente. Así, se permitió expresamente que la actividad del martillo pueda incluir, en materias concursales, el remate de inmuebles.

La creación de la figura de los martilleros concursales, o sea, aquel martillero público que voluntariamente decide incorporarse a la nómina respectiva a cargo de la Superintendencia, quedando dentro de los fiscalizados de dicho órgano o bajo su esfera de control. Sólo ellos pueden participar como subastadores en los procedimientos concursales que tengan lugar, debiendo hacerse presente que, a pesar que su tratamiento orgánico se encuentra en el artículo 213, o sea, dentro del ámbito del procedimiento de liquidación, su intervención como subastadores también puede tener lugar, en los mismos términos expuestos, en el procedimiento de reorganización.

ii) Remate en bolsa de valores de valores mobiliarios con presencia bursátil.

iii) Otras formas de realización de bienes, si así lo acuerda la junta.

H) Continuación de actividades económicas

a) Concepto

La continuación del giro del deudor no significa otra cosa que la no paralización de las actividades de la empresa.

El objeto de la continuación de giro es, mirado desde el punto de vista de la ejecución, *pagar a los acreedores no ya con la venta del activo, sino con los frutos, productos o rentas que provengan del ejercicio de la actividad del deudor.*

b) Clases de Continuación de Giro

La ley permite dos grupos definidos de continuación de giro: la provisional y la definitiva.

Diferencias:

- La decisión de continuación provisional es un atributo exclusivo del liquidador, mientras que la definitiva es decisión de la junta de acreedores, o del liquidador con autorización del tribunal.
- La continuación provisional dura sólo hasta la Junta Constitutiva, mientras que la continuación definitiva se puede prolongar por un año renovable por otro más, con quorum especial.
- La continuación provisional puede tender sólo a aumentar el porcentaje de recupero, facilitar la ejecución de prestaciones pendientes beneficiosas para la masa y propender a la venta como unidad económica (ART. 231), mientras que la continuación definitiva justamente intenta evitar la liquidación de dichos bienes y pagar con los frutos.

i) Continuación provisional de actividades (ART. 232)

Una vez que el liquidador toma la administración de los bienes del deudor, éste puede determinar la continuación provisional del giro de aquél mientras no se constituya la junta constitutiva de acreedores que se pronunciará por la suerte final de los bienes embargados.

Para estos efectos:

- El liquidador debe informar las razones que lo justifiquen y los bienes adscritos.
- La administración recae exclusivamente en el liquidador, quien tiene derecho a una remuneración adicional determinado por la junta o por el tribunal en caso de desacuerdo.
- En la Junta Constitutiva el liquidador debe presentar informe pormenorizado de las operaciones, ingresos, egresos y un resumen de la situación tributaria.

ii) Continuación definitiva de las actividades (ART. 233)

- (1) Esta medida importa mantener viva la unidad económica que compone el activo del fallido, sin recurrir a su enajenación pura y simple, para sólo pagarse mediante lo que se obtenga de dicha gestión.

Para estos efectos el acta de la junta de acreedores que lo acuerde debe contener:

- Actividades específicas a desarrollar.
- Bienes adscritos (para desarrollar esa actividad). Si existen acreedores hipotecarios, prendarios o retencionarios, éstos pueden perseguir los bienes que les correspondan, a menos que hayan consentido expresamente en la continuación.
- Identificación del administrador si fuere distinto al liquidador.
- Honorarios totales y fórmula de pago.
- Plazo: No superior a un año contado desde el acuerdo, prorrogable por otro año con quorum especial previo acuerdo de la junta de acreedores ordinaria o extraordinaria celebrada 10 días antes del vencimiento. Si hay prórroga, el tribunal debe nombrar un administrador que no puede ser el liquidador.

Si la junta acuerda la venta como unidad económica, puede también acordar con quorum especial que se continúe hasta concretar la venta, aunque se exceda ese plazo.

(2) Efectos

El efecto principal de la continuación efectiva es que ella impide la realización de los bienes comprendidos en dicha medida y, como contrapartida, que los acreedores se irán pagando preferentemente *con lo producido* por la actividad continuada de la empresa.

Si la continuación es parcial, los bienes no incorporados siguen el procedimiento normal de realización. Por ejemplo, mi negocio principal tengo una flota de camionetas y por otro lado tengo un servicio de mantención de camionetas, puedo liquidar las camionetas pero quedarme con el servicio de mantención para luego venderlo como unidad económica.

(3) Administración

Si recae en una persona distinta al liquidador:

- Respecto a los bienes no adscritos, se mantiene el liquidador.
- Respecto de bienes adscritos, se aplica el art. 294 del CPC.
- Cualquier controversia entre ambos la resuelve el tribunal en audiencia verbal al efecto.
- La Superintendencia tiene igual tuición sobre el administrador como si fuera liquidador.

Los administradores distintos del liquidador responden por culpa levísima (ART. 238) hasta rendir cuenta final de su gestión.

La junta puede siempre solicitar el término anticipado de la continuación definitiva con quorum especial, con lo que a su vez los honorarios pueden reducirse proporcionalmente (ART. 237).

En los actos que el liquidador o los administradores celebren como gestores de la empresa continuada, deben firmar en representación del fallido y agregar la expresión “en continuación de actividades económicas”, precedida de las respectivas firmas, sin lo cual dichos administradores son solidariamente responsables de las obligaciones contraídas (ART. 236).

(4) Créditos provenientes de la Continuación de Actividades Económicas

Los créditos que provienen de la explotación del giro durante la continuación de actividades económicas del deudor se pueden perseguir solo en los bienes comprendidos en dicha continuación, y gozan de la preferencia del Art. 2472 N° 4 del Código Civil.

Estos créditos prefieren a los de los acreedores hipotecarios, prendarios y retencionarios que dieron su aprobación a la continuación de actividades, solo en el caso que los bienes no gravados que se comprenden en esa continuación no sean suficientes para el pago y la diferencia la deben soportar esos acreedores a prorrata de sus respectivos créditos en el procedimiento de liquidación de los bienes dados en garantía de sus respectivos créditos (ART. 239).

(5) Remanente

En caso que en la continuación de actividades se obtengan excedentes, primero deben pagarse los acreedores que corresponda pagar en el procedimiento de liquidación y, si hay un remanente, pertenece al deudor (ART. 239, inciso final). Si sobra plata, los socios/accionistas se llevan la plata por efecto de restitución del capital.

3.5 Pago del pasivo

Las dos preguntas son: en qué orden pago y cuánto voy pagando a cada acreedor (no es que voy a pagar cuando ya liquidé todo, sino que voy pagando mientras voy teniendo caja).

A) Generalidades

a) Orden en que se hacen los pagos.

Las ideas básicas acerca del orden en que se pagan los créditos en el procedimiento concursal de liquidación, están previstas en los artículos 241, 242 y 243 de la Ley.

- i) El principio general es que los acreedores se pagan conforme al Título XLI, del Libro IV del Código Civil y, en el caso de los acreedores valistas, con pleno respeto a la subordinación de créditos establecida en dicha normativa.

Para su eficacia, la subordinación debe ser alegada al momento de la verificación del crédito por parte del acreedor beneficiario o bien debe notificarse al liquidador si se establece en una fecha posterior.

- ii) Asimismo, se dispone que los créditos de la primera clase prefieren a todo los otros créditos con privilegio establecidos en leyes especiales.
- iii) Por último, los acreedores personas relacionadas del deudor, cuyos créditos no estén debidamente documentados 90 días antes de la resolución de liquidación, son pospuestos en el pago de sus créditos aun después de los acreedores valistas. La ley mira estos créditos con sospecha, porque podría ser una forma para los accionistas de sacar plata con una preferencia inventada.

b) Ejecución Individual de Acreedores Prendarios y Retencionarios (derecho legal de retención).

El artículo 242 establece que los acreedores prendarios y los retencionarios pueden optar por ejecutar individualmente los bienes gravados, en cuyo caso deben iniciar ante el tribunal que conoce del procedimiento de liquidación los juicios que correspondan, o continuarlos en él previa acumulación, **debiendo siempre asegurar los créditos de mejor derecho.**

En este mismo orden de materia, el liquidador puede, si lo estima conveniente para los acreedores, exigir la entrega de la cosa dada en prenda o retenida, siempre que pague la deuda o deposite, a la orden del tribunal, su valor estimativo en dinero, sobre el cual se hará efectiva la preferencia.

c) Acreedores Hipotecarios.

El artículo 243 señala que los acreedores hipotecarios se pagan en la forma que determinan los artículos 2477, 2478, 2479 y 2480 del Código Civil.

B) Pagos Administrativos

a) Concepto.

El pago administrativo se opone al pago judicial y se lleva a cabo sin necesidad de verificación, con cargo de los primeros fondos del deudor de que se pueda disponer.

En efecto, tan pronto como existan fondos suficientes para ello y precaviendo que el activo remanente sea suficiente para asegurar los gastos del procedimiento de liquidación, como así también el pago de los créditos de mejor derecho, pueden pagarse por el liquidador los créditos contenidos en el artículo 2472 del Código Civil, de acuerdo con las normas contenidas en el Art. 244.

b) Casos.

- i) Los descritos en los números 1 y 4 pueden pagarse sin necesidad de verificación.

Se trata de:

- las costas judiciales que se causen en interés general de los acreedores
- los gastos para poner a disposición de la masa los bienes del deudor
- los gastos de administración del procedimiento de liquidación

- los gastos de realización del activo
- los préstamos contratados por el liquidador para esos fines.

Son los créditos denominados “de la masa”, que se generan después de la resolución de liquidación y que tienen que estar premunidos de esta preferencia y ser pagados en este orden, porque de lo contrario ningún acreedor concedería los créditos para atender a los gastos ni haría los préstamos ya mencionados.

- ii) Los incluidos en el número 5 pueden pagarse previa revisión de los documentos que les sirven de fundamento, sin necesidad de verificación ni acuerdo de la junta de acreedores que apruebe el pago.

Se trata de:

- las remuneraciones de los trabajadores
 - las asignaciones familiares
 - las cotizaciones adeudadas a las instituciones de seguridad social o que se recauden por su intermedio, para ser destinadas a ese fin
- iii) Los establecidos en el número 8 se pagan en los mismos términos que los indicados en el número precedente.

Se trata de:

- las indemnizaciones convencionales de origen laboral
- las indemnizaciones laborales por término del contrato de trabajo debido a la resolución de liquidación del empleador

En ambos casos, la indemnización que tiene preferencia es hasta el límite equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicio y fracción superior a 6 meses con un límite de 90 unidades de fomento.

Las restantes indemnizaciones de origen laboral, así como la que es consecuencia del reclamo del trabajador, según el artículo 168 del Código del Trabajo, se pagan con el solo mérito de la sentencia definitiva firme o ejecutoriada que así lo ordene. Se busca evitar afecar la par conditio mejorando la posición de un determinado acreedor, aunque suene raro que ya existiendo un contrato se exija una sentencia definitiva por el delta que excede del máximo legal de indemnización.

Sin embargo, pueden verificarse condicionalmente los créditos que gocen de las preferencias de los números 5 y 8 del artículo 2472 del Código Civil, con el solo mérito de la demanda interpuesta con anterioridad al inicio del procedimiento de liquidación o con la notificación al liquidador de la demanda interpuesta con posterioridad al aludido inicio.

En este caso, el liquidador debe reservar fondos para el evento de que se acoja la demanda, sin perjuicio de los pagos administrativos que procedan, según los números precedentes del artículo 244.

Por otra parte, el artículo 246 admite expresamente la renunciabilidad de los montos y preferencias de los aludidos créditos, en los siguientes casos:

- 1) Mediante conciliación celebrada ante el Juzgado del Trabajo, la que puede tener lugar en la audiencia preparatoria o de juicio y debe constar en la expresa aprobación del juez.
 - 2) En virtud de transacción judicial o extrajudicial que se celebre con posterioridad a la notificación de la sentencia definitiva de primera instancia del juicio laboral respectivo.
- iv) El artículo 245 regula el pago de las costas personales:
- 1) Liquidación forzosa: sólo proceden las costas personales correspondientes al acreedor petionario, que benefician de la preferencia del número 1 del artículo 2472 del Código Civil.
 - 2) Liquidación voluntaria: las costas personales del solicitante gozan de la preferencia indicada en el número 4 del artículo 2472 del Código Civil.

Tanto en uno como en el otro caso se aplican las siguientes limitaciones para el cálculo de dichas costas:

- El 2% del crédito invocado, si éste no excede de 10.000 UF
 - El 1% en lo que exceda de 10.000 UF.
- v) Con respecto a los demás créditos de la primera clase, que no se mencionan en el artículo 244, hay que atenerse al texto del artículo 2472 del Código Civil.

En resumen, a todas estas personas se les paga primero a medida de que exista caja.

C) Los Repartos de Fondos para el Pago de los Créditos

Lo que va a hacer el liquidador es alternar varios pagos al mismo tiempo de forma paralela: le va a pagar a acreedores de la masa, va a pagar deudas provisionales, va a pagar finiquitos, etc. Pero como todo esto es móvil, el liquidador tiene que tener ciertos resguardos para pagar a los preferentes a que no se haya pagado en un 100%.

a) Propuesta del Liquidador.

El liquidador está obligado a proponer a los acreedores un reparto de fondos, concurriendo los siguientes requisitos copulativos:

- i) Disponibilidad de fondos para abonar a los acreedores reconocidos una cantidad no inferior al 5% de sus acreencias.

- ii) Reserva previa de los dineros suficientes para sufragar los gastos del procedimiento de liquidación y los créditos de igual o mejor derecho cuya impugnación se encuentra pendiente. Se reserva dinero para pagarle, por ejemplo, a acreedores de la masa que hayan pactado pagos a plazo.
- iii) Reserva para responder a los acreedores residentes en el extranjero que no hayan alcanzado a comparecer, según los plazos previstos en el artículo 252, y
- iv) Debe sujetarse el liquidador al procedimiento fijado en el artículo 248.

b) Procedimiento para el reparto de fondos.

El liquidador tiene que observar las siguientes reglas (Art. 248):

- i) La propuesta se presenta al tribunal conjuntamente con un detalle completo del reparto que se pretende realizar, sus montos, fórmula del cálculo utilizada y acreedores a quienes se va a pagar;
- ii) El tribunal, al día siguiente de la presentación de la proposición, debe tener por propuesto el reparto y ordena al liquidador publicarlo en el Boletín Concursal.
- iii) Los acreedores que conjunta o separadamente representen al menos el 20% del pasivo con derecho a voto, pueden objetar el reparto propuesto, dentro del plazo de 3 días, contado desde la notificación de resolución que lo tiene por propuesto.
 - Si la objeción planteada afecta la totalidad del reparto, éste no puede llevarse a cabo mientras la oposición no sea resuelta en primera instancia.
 - Si la objeción formulada es parcial, el reparto puede ejecutarse en la parte no disputada;
- iv) El tribunal confiere traslado al liquidador de todas las objeciones planteadas, el que tiene que evacuarlo dentro de tercero día.
- v) Transcurrido el plazo de 3 días, haya o no evacuado el liquidador el traslado conferido, el tribunal resuelve sin más trámite la objeción.

La resolución que se dicte al respecto no es susceptible de recurso alguno.

- vi) El objetante vencido es condenado al pago de las costas, las que se calculan sobre la base del monto objetado, salvo que haya tenido motivo plausible para litigar.

En el caso en que la objeción sea deducida por dos o más acreedores conjuntamente, y fuese rechazada, todos ellos son solidariamente responsables del pago de las costas.

El liquidador debe perseguir en beneficio de la comunidad de acreedores el cobro de las costas por cuerda separada ante el mismo tribunal que conoce del procedimiento concursal de que se trata y puede solicitar que las fijadas sean descontadas del reparto presente o futuro que les correspondería al o a los objetantes vencidos.

- vii) La resolución que acoja la impugnación debe ordenar la confección de una nueva propuesta de reparto.
- viii) En el caso de que no se formulen objeciones, rechazadas las interpuestas o modificado el reparto en la forma decretada por el juez, éste debe ordenar al liquidador la distribución del reparto dentro del plazo de 3 días, contado desde la expiración de término para objetar.
- ix) La resolución que ordene la distribución del reparto se notifica en el Boletín Concursal y a partir de ese instante los acreedores incluidos en el reparto pueden reclamar al liquidador el pago de las sumas respectivas.

Tratándose de créditos afectos a subordinación, el o los acreedores subordinados contribuyen al pago de sus respectivos acreedores beneficiarios, a prorrata, con lo que les corresponda en dicho reparto de su crédito subordinado.

D) La Situación Especial de Algunos Acreedores

a) Acreedor condicional.

Se entiende por acreedor condicional aquel cuyo crédito está sujeto a la ocurrencia de un hecho futuro e incierto del cual depende su nacimiento o extinción.

- i) Si el crédito pende de una condición suspensiva, en principio no tendría, de acuerdo con el artículo 1485 del Código Civil, derecho a invocarlo en la liquidación (solo hay germen de derecho). Sin embargo, el Art. 249 contempla una situación especial respecto del pago de un crédito sujeto a este tipo de condición, conforme a la cual el *acreedor condicional puede solicitar al tribunal que ordene la reserva de los fondos que le corresponderían cumplida la condición, o su entrega bajo caución suficiente de restituirlos a la masa, con el interés corriente para operaciones reajustables*, para el caso de que la condición no se verifique.

La consignación señalada debe constar en boleta de garantía bancaria o póliza de seguro, la cual tiene que ser reemplazada o renovada sucesivamente hasta que se cumpla la condición a la que está sujeta la acreencia de que se trata.

Para el ejercicio del derecho que el artículo 249 de la ley del ramo acuerda al acreedor condicional se requiere la iniciativa del interesado, pues el liquidador no está obligado sino a realizar la reserva de fondos cuando el tribunal así lo ordene. La ley tampoco señala un plazo para hacer valer la reserva de fondos, pero se subentiende que para solicitarla es preciso que el crédito haya sido verificado ordinaria o extraordinariamente.

- ii) El acreedor condicional resolutorio, cuyo crédito ha nacido a vida del derecho, puede verificarlo.

Una vez reconocido este crédito, puede reclamar su pago en la forma ordinaria, sin perjuicio del derecho de la masa a repetir, en caso de cumplirse el hecho previsto como condición resolutoria.

b) Acreedor que es a la vez deudor del concursado.

Puede ocurrir en la práctica que el acreedor que verifica sea a la vez deudor del sujeto pasivo sometido al procedimiento de liquidación, sin que hubiere operado la compensación.

En ese caso, las sumas que le correspondan a este acreedor se aplican al pago de la deuda que tiene con el concursado, aunque no esté vencida (Art. 250).

c) Acreedor que ha verificado extraordinariamente (acreedor no concurrente).

El problema que aquí se presenta consiste en saber cómo se va a pagar al acreedor que ha hecho uso del derecho a verificar extraordinariamente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 251, la verificación morosa o extraordinaria no suspende la realización de los repartos, pero si al encontrarse pendiente el reconocimiento de estos nuevos créditos (ej. se impugnan) se ordena otro reparto, estos acreedores son comprendidos en él por la suma que corresponda, manteniéndose en depósito las sumas que se invocan hasta que tales créditos sean reconocidos en el procedimiento concursal.

Una vez reconocidos los créditos verificados fuera del período ordinario, sus titulares tienen derecho a exigir que los fondos objeto del reparto que les haya correspondido en las distribuciones precedentes sean cubiertos de preferencia con los fondos no repartidos, *pero no pueden demandar a los acreedores pagados en los repartos anteriores la devolución de ninguna cantidad*, aun cuando el activo sujeto al procedimiento de liquidación no alcance a cubrir íntegramente sus dividendos impagos.

d) Acreedores residentes en el extranjero.

De conformidad con el artículo 252, la cantidad reservada para acreedores residentes fuera del territorio de la República debe permanecer en depósito hasta el vencimiento del duplo del término de emplazamiento que les corresponda y, vencido este plazo, se aplicará al pago de los créditos reconocidos.

e) Acreedor que no comparece a recibir dividendo.

El artículo 253 indica que si algún acreedor comprendido en la nómina de distribución no comparece a recibir lo que le corresponda 3 meses después de la notificación del reparto, el liquidador debe depositar su importe en arcas fiscales a la orden de dicho acreedor.

Asimismo, transcurridos 3 años desde la fecha de dicho depósito sin que se haya cobrado su monto, la Tesorería General de la República lo debe destinar en su totalidad al Cuerpo de Bomberos.

3.6 Término del Procedimiento

A) Resolución de Término: Los artículos 254 y siguientes consagran la resolución de término, la cual importa un hito concreto para situar la finalización del procedimiento, sea de oficio por el tribunal, a petición de uno o más acreedores o de la Superintendencia. Esto ocurre luego de que el liquidador presenta la cuenta final y esta se aprueba.

B) Efectos

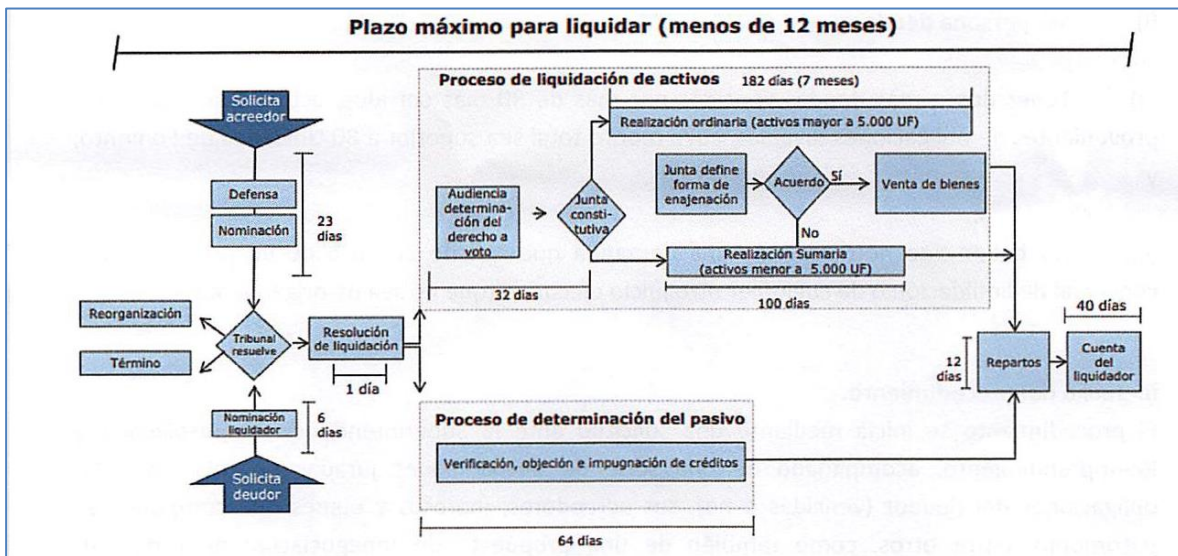
- a) El deudor recupera la libre administración de sus bienes. Termina la intervención del liquidador.
- b) Por el solo ministerio de la ley se entienden extinguidos los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por la empresa deudora antes del inicio del procedimiento de liquidación. Guerrero cree que es una forma de extinguir las obligaciones.

En otras palabras muchas veces, por no decir que en la gran mayoría de los casos, los acreedores no pueden ver solucionada la totalidad de su crédito.

- c) El deudor se entiende **rehabilitado** para todos los efectos legales.

C) Recursos: Procede el recurso de apelación, que se concede en el solo efecto devolutivo.

3.7 Proceso de Liquidación – Resumen y Plazos



En general, el procedimiento va a durar aproximadamente 1 año.

4. Procedimientos concursales de una persona deudora

4.1 Procedimiento Renegociación de una Persona Deudora

A) Ámbito de aplicación.

a) Concepto.

El artículo 2 N° 25 señala que “persona deudora” es “toda persona natural no comprendida en la definición de empresa deudora”.

La idea de persona deudora debió ser definida pura y simplemente como una persona natural que no ejerce actividad constitutiva de empresa, prescindiendo de la referencia a la legislación tributaria.

b) Causal.

Para que la persona deudora pueda someterse **voluntariamente** al procedimiento de renegociación, se requiere que concurra el hecho revelador de cesación de pagos descrito por el artículo 260, es decir:

- i) Cuando tenga dos o más obligaciones vencidas por más de 90 días corridos
- ii) Que sean actualmente exigibles
- iii) Que provengan de obligaciones diversas
- iv) Cuyo monto total sea superior a 80 UF
- v) Que no haya sido notificada de una demanda que solicite el inicio del procedimiento de liquidación o cualquier otro juicio ejecutivo iniciado en su contra que no sea de origen laboral.

Se busca beneficiar con este procedimiento expedito a deudores que se encuentren en situaciones de insolvencia, de las que puedan salir.

c) Órgano competente.

Este procedimiento se ventila al margen de los tribunales ordinarios de justicia, porque corresponde su conocimiento y resolución a la **Superintendencia**.

B) Inicio del procedimiento.

Comienza a iniciativa de la persona deudora mediante la presentación ante la Superintendencia de una solicitud cuyo formato está disponible en el sitio web y en las dependencias de esa entidad.

a) Presentación del Deudor.

Esta petición debe ser presentada por la persona deudora o quien la represente, acompañando los documentos que se indican a continuación:

- i) Declaración jurada con una lista de las obligaciones del deudor, vencidas o no, sean o no actualmente exigibles, y de todos sus acreedores con indicación del monto de lo adeudado cada uno, o su saldo, según corresponda, indicando el nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico del acreedor y su representante legal, en su caso, y si lo conociera, y cualquier otro dato de contacto de cada uno de ellos.
- ii) Declaración jurada con la determinación de todos los ingresos que perciba, por cualquier causa, sean éstos fijos o esporádicos, acompañando los antecedentes que los acreditan.
- iii) Declaración jurada con el listado completo de sus bienes, con indicación de aquellos que las leyes declaran inembargables y de los gravámenes y prohibiciones que les afectan.
- iv) Una propuesta de renegociación de todas sus obligaciones vigentes.

- v) Una declaración jurada en que consta que es persona deudora o que, habiendo iniciado actividades comerciales, no haya prestado servicios por tales actividades durante los 24 meses anteriores a la presentación de su solicitud.
- vi) Una declaración jurada en la que consta que no ha sido notificado de una demanda de liquidación o de cualquier juicio ejecutivo iniciado en su contra que no sea de carácter laboral.

b) Actuación de la Superintendencia.

La Superintendencia, dentro de los 5 días siguientes a la presentación de la solicitud de inicio de este procedimiento puede adoptar las siguientes decisiones (Art. 262):

- i) Declarar admisible la solicitud.
- ii) Ordenar a la persona deudora que rectifique sus antecedentes o entregue información adicional, caso en el cual ésta debe subsanar los defectos o proporcionar los antecedentes complementarios que le son solicitados, según corresponda, en el término que la entidad supervisora le indique, contado desde la respectiva resolución. Si la persona deudora no cumple lo exigido, la petición se declara inadmisibile.
- iii) Declarar inadmisibile la solicitud por resolución fundada, cuya inadmisibilidat sólo puede basarse en que:
 - la petición de inicio del procedimiento de que se trata no cumple los requisitos legales
 - por haber transcurrido los plazos legales para subsanar los defectos indicados por la Superintendencia sin que hayan sido reparados.

c) Resolución de admisibilidat.

La resolución de la Superintendencia que declara admisible la solicitud de inicio del procedimiento de renegociación debe contener las enunciaciões establecidas por el artículo 263:

- i) Nombre y número de cédula de identidad de la persona deudora.
- ii) El listado inicial de los acreedores informado por la persona deudora solicitante, con indicación de los montos adeudados por concepto de capital e intereses y sus preferencias.
- iii) El listado de los bienes de la persona deudora informados por ella, con indicación expresa de aquellos que son inembargables y los gravámenes y prohibiciones que los afectan, si los hay, individualizando a los beneficiarios de estos últimos.
- iv) La comunicaciòn a los acreedores y a los terceros acerca del inicio del procedimiento concursal de renegociación y de la fecha de celebraciòn de la audiencia de determinaciòn del pasivo.

Dicha audiencia se celebra no antes de 15 ni después de 30 días, contados desde la publicación de la resolución de admisibilidad en el Boletín Concursal.

La resolución de admisibilidad y los antecedentes que se acompañan a ella se publican en el Boletín Concursal. Los acreedores individualizados en el listado inicial contenido en la resolución de admisibilidad se consideran legalmente notificados en virtud de la publicación, sin perjuicio de que se les envíe copia de dicha resolución por correo electrónico, si éste ha sido indicado en los documentos presentados por la persona deudora.

d) Efectos de la resolución de admisibilidad.

Las consecuencias jurídicas que produce la resolución de admisibilidad, desde su publicación hasta el término del procedimiento concursal de renegociación, según lo previsto en el artículo 264, son las siguientes:

- i) No puede solicitarse la liquidación forzosa ni puede tener lugar la liquidación voluntaria de la persona deudora, ni iniciarse en su contra juicios ejecutivos o ejecuciones de cualquier clase o restituciones en juicios de arrendamiento desde la publicación de la resolución de admisibilidad hasta el término del procedimiento concursal de que se trata.

Para oponerse al inicio de las ejecuciones, la persona deudora debe acompañar al tribunal que conoce de ellas copia autorizada de la resolución de admisibilidad, la que puede hacer valer sólo como una excepción y, para tales fines, puede comparecer personalmente, sin necesidad de patrocinio de abogado.

Lo que el legislador pretende es brindar una “protección financiera concursal” a la persona deudora, cuya solicitud de inicio de procedimiento de renegociación ha sido declarada admisible, manteniendo así la desjudicialización propia de dicho procedimiento concursal.

- ii) Se suspenden los plazos de prescripción extintiva de las obligaciones de la persona deudora.

Esta suspensión del curso de la prescripción extintiva es un aspecto que sin duda favorece a los acreedores.

- iii) No se continúan devengando los **intereses moratorios** que se hayan pactado en los respectivos actos o contratos vigentes ejecutados o celebrados por la persona deudora.

Esta medida es consecuente con el estado patrimonial crítico que lleva la persona deudora a solicitar el inicio del procedimiento que estamos tratando y se justifica tan sólo porque el sujeto pasivo no ejerce actividades empresariales, de manera que se beneficia con una suerte de “congelación” de su pasivo;

- iv) Todos los contratos celebrados por la persona deudora mantienen su vigencia y condiciones de pago, en su caso, y no es posible hacer efectivas cláusulas de resolución o caducidad fundadas en el inicio del procedimiento de renegociación, con

la sola excepción de suspender las líneas de crédito o de sobregiro que se hayan convenido.

En caso de que el co-contratante de la persona deudora realice cualquier acción que importe el término de los contratos o exija anticipadamente el pago de su crédito, dicha acreencia queda pospuesta en su pago hasta que se paguen la totalidad de los acreedores a quienes afecta el acuerdo de renegociación.

- v) Cualquier interesado puede observar u objetar los créditos comprendidos en el listado indicado en la resolución de admisibilidad, como así también el listado de bienes señalado en esa resolución, hasta 3 días antes de la celebración de la audiencia de determinación del pasivo, pudiendo concurrir a esa audiencia con derecho a voz y a voto.
- vi) La persona deudora no puede ejecutar actos ni celebrar contratos relativos a sus bienes embargables que forman parte del procedimiento de renegociación, bajo apercibimiento de considerársele como “depositario alzado” en los términos del artículo 444 del Código Penal.

Esto equivale a una suerte de **desasimiento reducido**, atendida la circunstancia que la cesación de pagos que afecta a este individuo que no ejerce actividad empresarial tiene consecuencias más limitadas que aquella en la cual el sujeto pasivo es una empresa deudora.

En general, las consecuencias jurídicas establecidas por el artículo 264, de la ley concursal, se extinguen con la publicación en el Boletín Concursal, del acta que contiene el acuerdo de renegociación o el acuerdo de ejecución, según corresponda.

e) Audiencia de determinación del pasivo.

Una vez notificada la resolución de admisibilidad, tiene lugar la audiencia de determinación del pasivo, a la cual deben comparecer, obligatoriamente, todos los acreedores individualizados en la referida resolución que hayan sido notificados legalmente mediante la publicación de la misma en el Boletín Concursal, bajo apercibimiento de proseguirse la tramitación sin volver a notificar a los acreedores ausentes y asumiendo lo obrado durante dicha audiencia.

- i) Ante quién se celebra: La audiencia se celebra ante el Superintendente o ante quien éste designe, con los acreedores que asistan y la persona deudora, compareciendo personalmente o legalmente representada.
- ii) Rol facilitador: En el desarrollo de esta audiencia, el Superintendente o quien designe actúa como facilitador, ayudando a las partes a adoptar una solución satisfactoria. Para determinar esta suerte de facilitación, la Superintendencia debe regularla a través de una norma de carácter general (NCG N° 8).
- iii) Propuesta de nómina: En esta audiencia, la Superintendencia presenta una propuesta de nómina de pasivo, teniendo en cuenta el listado acompañado por la persona

deudora, lo indicado por quienes hayan observado u objetado ese listado, y las observaciones que la misma entidad pueda sugerir.

- iv) Determinación del pasivo: Con el consentimiento de la persona deudora y el voto de la mayoría absoluta del pasivo señalado en la propuesta de la Superintendencia, se determina el pasivo con derecho a voto de este concurso de renegociación, sin considerar los créditos de las personas relacionadas con el sujeto pasivo, que no se toman en cuenta a los fines de establecer el quórum ni para las votaciones a que haya lugar.

- En caso de que no se llegue a un acuerdo, la Superintendencia puede suspender la audiencia por una vez, hasta por 5 días, con el objeto de lograr la adopción de dicho acuerdo. Si no obstante la medida de suspensión, tampoco se arriba al acuerdo, el Superintendente debe citar a una audiencia de ejecución, que debe tener lugar no antes de 15 ni después de 30 días, contados desde la publicación de la resolución de admisibilidad en el Boletín Concursal.

Esta decisión de citar a una audiencia de ejecución que adopta el Superintendente o quien él haya designado para actuar en la audiencia de determinación del pasivo, comporta el fracaso del procedimiento de renegociación y el paso a una ejecución diferente.

- Si se acuerda la determinación del pasivo, la Superintendencia debe dictar la resolución correspondiente, que contiene el acta con la nómina de créditos y la citación a todos los acreedores cuyos créditos hayan sido reconocidos, a la audiencia de renegociación.

El acta que contiene la nómina de créditos se publica en el Boletín Concursal dentro del segundo día siguiente. La audiencia de renegociación debe tener lugar no antes de 15 ni después de 30 días, contados de la publicación recién indicada.

f) Audiencia de renegociación (Art. 266)

- i) Ante quién se celebra: La audiencia de renegociación se lleva a cabo ante el Superintendente o a quien éste designe, que actúa como si fuera tribunal, con los acreedores que asistan o los representantes legales en su caso y la persona deudora, personal y debidamente representada.
- ii) Rol facilitador: Tal como en el caso de la audiencia de determinación del pasivo, el Superintendente o quien lo reemplaza, debe actuar en la audiencia de renegociación, como facilitador para lograr los acuerdos entre las partes.
- iii) Quorum: Para lograr el acuerdo de renegociación se requiere el voto conforme de la persona deudora y el voto favorable de 2 o más acreedores que en conjunto representen más del 50% del pasivo reconocido.

No se consideran para los efectos de esta mayoría ni para las votaciones que haya lugar, los créditos de las personas relacionadas con el sujeto pasivo de este procedimiento ni el de los acreedores garantizados que asistan y voten en contra del acuerdo de renegociación propuesto en la audiencia.

g) Acuerdo de renegociación

- i) Objeto: Este acuerdo puede versar sobre cualquier objeto que propenda a repactar, novar o remitir las obligaciones de la persona deudora y no puede ser revocado con posterioridad conforme a lo previsto en el artículo 290, relativo a las acciones revocatorias de la persona deudora, si ella es sometida a un procedimiento concursal de liquidación.
- ii) Resolución: En el caso en que se acuerde la renegociación, la Superintendencia dicta una resolución que contiene el acta con el acuerdo de renegociación, suscrito por la persona deudora, los acreedores presentes y el Superintendente o quien él haya designado.
- iii) Acta: El acta con el acuerdo de renegociación que se confecciona en la indicada audiencia, se publica en el Boletín Concursal dentro de los 2 días siguientes.

h) Efectos

- i) A quién afecta: El acuerdo de renegociación afecta únicamente a los acreedores que figuren en la nómina de créditos reconocidos, según lo previsto en el artículo 265, hayan o no concurrido a la audiencia de renegociación.
- ii) Créditos caucionados con garantías personales: Tratándose de los acreedores cuyos créditos están caucionados con garantías personales, la ley dispone que haya que distinguir las siguientes situaciones:
 - (1) Si el acreedor vota a favor del acuerdo de renegociación, o no asiste a la audiencia, su crédito se sujeta a los términos y modalidades estipulados en el referido acuerdo y no puede cobrarlo en otros términos ni modalidades.
 - (2) Si el acreedor vota en contra del acuerdo de renegociación propuesto, su crédito no se considera en el referido pasivo y puede perseguirlo respecto de fiadores, avalistas o codeudores solidarios o subsidiarios, en las condiciones originalmente pactadas.

Al fiador, avalista o codeudor solidario o subsidiario que haya pagado le afectan los términos y condiciones del acuerdo de renegociación celebrado.

- iii) Créditos caucionados con prenda e hipoteca: En el caso de los acreedores cuyos créditos están garantizados con prenda e hipoteca, es preciso hacer la distinción siguiente:

- (1) Si el acreedor vota a favor del acuerdo de renegociación o no asiste a la audiencia de que se trata, queda sujeto a los términos y condiciones del referido acuerdo y no puede cobrarlo en términos distintos de los estipulados.
- (2) Si el acreedor asiste y vota en contra del acuerdo de renegociación, su crédito no se considera dentro del pasivo y puede ejecutar su garantía únicamente para el pago del crédito caucionado con la garantía específica.

Tratándose de los demás créditos que tenga el mismo acreedor en contra de la persona deudora, en su caso, y que no se encuentren caucionados con garantías específicas, quedan sujetos a los términos y condiciones pactados en el referido acuerdo y no pueden ser cobrados en condiciones distintas a las convenidas.

- (3) En el evento de que la obligación de la persona deudora está garantizada con prenda o hipoteca sobre bienes de propiedad de terceros, y el respectivo acreedor asiste y vota en contra del acuerdo de renegociación propuesto, su crédito no se considera en el pasivo y puede cobrarlo respecto de las prendas e hipotecas otorgadas por terceros.

Al poseedor de la finca hipotecada o propietario del bien pignorado que haya pagado de acuerdo a lo anteriormente señalado, le afectan los términos y condiciones del acuerdo de renegociación convenido.

i) Rechazo de la renegociación.

Si no se acuerda la renegociación, la Superintendencia puede suspender la audiencia, por una sola vez y hasta por 5 días, con el objeto de propender al acuerdo.

Si no logra acuerdo en la primera o segunda audiencia de renegociación, la Superintendencia debe citar a una audiencia de ejecución, la que debe tener lugar no antes de 15 ni después de 30 días contados desde la publicación en el Boletín Concursal.

j) Audiencia de ejecución.

Cuando no se logra acuerdo acerca de la persona deudora o respecto de la renegociación de sus obligaciones, la Superintendencia cita a los acreedores a una audiencia de ejecución.

- i) Ante quien se celebra: La audiencia de ejecución se celebra ante el Superintendente, o ante quien éste designe, con los acreedores que asistan o sus representantes legales, y la persona deudora, personalmente o debidamente representada
- ii) Propuesta de realización: En la audiencia de ejecución, la Superintendencia presenta una propuesta de realización del activo del deudor.
- iii) Quorum: La persona deudora y dos o más acreedores que representen a lo menos el 50% del pasivo reconocido con derecho a voto o más del 50% del pasivo que consta en la propuesta de la Superintendencia, acuerdan la fórmula de realización del activo del deudor (Art. 267, inciso 3).

No se consideran para los efectos del quórum ni para las votaciones a que haya lugar los créditos de las personas relacionadas con la persona deudora.

- iv) Acuerdo: Si se llega a un acuerdo sobre la propuesta de realización del activo de la persona deudora, la Superintendencia **remite los antecedentes al tribunal (única intervención judicial)** competente, el que debe pronunciar la respectiva resolución de liquidación.
- v) Pago a los acreedores: Vencido el plazo señalado en el acuerdo para la realización de los bienes, el liquidador, debe proceder al reparto de fondos.
- vi) Objeciones: Toda objeción o incidencia respecto de la gestión de liquidador en este reparto de fondos debe interponerse por los acreedores ante la Superintendencia, la que resuelve administrativamente, en única instancia y sin ulterior recurso.
- vii) Plazo: El plazo para la realización del activo y para el reparto de fondos contenido en el acuerdo de ejecución no puede ser superior a 6 meses, contados desde la publicación del acuerdo referido en el Boletín Concursal.

El acta del acuerdo de ejecución se publica en el Boletín Concursal dentro de los dos días siguientes de su adopción por la audiencia respectiva.

k) Terminación del procedimiento de renegociación y de ejecución

- i) Declaración: Una vez vencido el plazo para impugnar el acuerdo de renegociación o el acuerdo de ejecución, según corresponda, o bien una vez resuelta y rechazada la impugnación, la Superintendencia declara finalizado el procedimiento de renegociación de la persona deudora.
- ii) Efectos:
 - (1) En el evento en que el procedimiento haya finalizado mediante un acuerdo de ejecución, se consideran extinguidos, por el solo ministerio de la ley, los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por la persona deudora respecto de los créditos que forman parte de dicho acuerdo, a contar de la publicación de la resolución de terminación en el Boletín Concursal.
 - (2) Cuando el procedimiento finaliza por un acuerdo de renegociación, las obligaciones respecto de los créditos que forman parte de ese acuerdo se consideran extinguidas, novadas o repactadas, según lo acordado, y la persona deudora se entiende rehabilitada para todos los fines legales.

A este último propósito, la Superintendencia emite un certificado de incobrabilidad a solicitud de los acreedores titulares de las deudas remitidas, que les permita castigar sus créditos.

l) Término anticipado del procedimiento de renegociación y efectos.

- i) Causales: La Superintendencia debe declarar anticipadamente el término del procedimiento de renegociación, en las situaciones previstas en el artículo 269, a saber:
 - (1) Cuando la persona deudora infringe la prohibición de celebrar actos y contratos respecto de los bienes que forman parte del activo del procedimiento, prevista en el número 6 del artículo 264, sin perjuicio de la sanción propia establecida para el depositario alzado, en el artículo 444, del CPC;
 - (2) Si la persona deudora deja de cumplir alguno de los requisitos previstos en el artículo 260 referente a las causales que justifican la procedencia del procedimiento de renegociación;
 - (3) Si no se llega a acuerdo en la audiencia de ejecución, y
 - (4) Cuando con posterioridad al inicio del procedimiento aparecen bienes no declarados por la persona deudora en los antecedentes que acompañó a su solicitud, a los que se refiere el artículo 261.
- ii) Efectos: Una vez que se declara el término anticipado del procedimiento de renegociación, finalizan las consecuencias jurídicas que se originaron con la resolución de admisibilidad, previstos en el artículo 264.
- iii) Resolución: Vencido el plazo para interponer el recurso de reposición administrativo, sin que se haya presentado un recurso de esta naturaleza o habiéndose presentado se haya rechazado, la Superintendencia remite los antecedentes al tribunal competente, el que pronuncia la respectiva resolución de liquidación de los bienes de la persona deudora.

m) Recursos contra la resolución de terminación.

Respecto de la resolución que declara terminado el procedimiento concursal de renegociación o que lo declare concluido anticipadamente, procede el recurso de reposición administrativa.

Tratándose de la resolución que rechaza la reposición administrativa interpuesta, procede el recurso de reclamación en los términos previstos por el artículo 341, en cuanto sea aplicable. El hecho de interponer el recurso de reclamación no suspende los efectos del procedimiento de renegociación, el que sigue tramitándose de acuerdo a las normas de la ley.

n) Impugnación del acuerdo de renegociación o del acuerdo de ejecución.

- i) Causales: Estos acuerdos pueden ser impugnados por los acreedores a quienes les afecte, con tal que esta impugnación se base en algunas de las siguientes causales que establece el artículo 272:
 - (1) Error en el cómputo de las mayorías requeridas por la ley de la materia, siempre que incida en el quórum necesario para el acuerdo;

- (2) Falsedad o exageración del crédito de alguno de los acreedores que haya concurrido con su voto a formar la mayoría necesaria para adoptar el respectivo acuerdo y si, excluida la parte falsa o exagerada del crédito, no se logra el quórum necesario para el acuerdo;
 - (3) Concierto entre uno o más acreedores y el deudor para votar a favor, abstenerse de votar o rechazar el acuerdo de renegociación o el acuerdo de ejecución, falseando, omitiendo o adulterando información para obtener una ventaja indebida respecto de los demás acreedores;
 - (4) Si con posterioridad a la celebración de un acuerdo aparecieran bienes, se entiende que han de ser de la persona deudora y de carácter embargable.
- ii) Tribunal competente y procedimiento: La impugnación de los acuerdos se formula ante el tribunal al que corresponde conocer del procedimiento de liquidación de los bienes de la persona deudora, dentro del plazo de 10 días, contado desde la publicación del acuerdo respectivo en el Boletín Concursal.

Esta impugnación se tramita según las reglas del procedimiento sumario y contra la resolución que pronuncia respecto de ella, no procede recurso.

iii) Impugnación:

- (1) En el caso que se haga lugar a la impugnación de los acuerdos de renegociación o de ejecución, el tribunal de oficio y sin más trámite dicta la resolución de liquidación de los bienes de persona deudora, en la misma resolución que acoge la impugnación.
- (2) En el evento en que las impugnaciones sean impugnaciones rechazadas, la Superintendencia declara terminado el procedimiento de renegociación de la persona deudora (Art. 268).

Los acuerdos de renegociación o de ejecución rigen no obstante las impugnaciones formuladas en su contra. Con todo, si ellas fueron deducidas por acreedores que representan en su conjunto a lo menos el 30% del pasivo, el acuerdo impugnado no produce efectos hasta que la impugnación sea rechazada por sentencia firme y ejecutoriada.

- iv) Validez de los actos: Los actos y contratos ejecutados o celebrados por la persona deudora en el tiempo que transcurre entre el acuerdo de renegociación o de ejecución y la fecha en que queda ejecutoriada la resolución que acoja las impugnaciones, no pueden dejarse sin efecto por vía de acciones revocatorias en el procedimiento de liquidación de bienes que se siga en contra de este deudor.

o) Limitación.

La persona deudora cuya solicitud de aplicación del procedimiento concursal de renegociación es declarada admisible, no puede pedirla nuevamente, sino una vez transcurridos 5 años contados desde la fecha de la publicación de la resolución de admisibilidad.

4.2 Procedimiento de Liquidación de los Bienes de una Persona Deudora

A) Liquidación Voluntaria de Bienes de la Persona Deudora.

i) Procedencia y requisitos.

Este procedimiento concursal se ventila ante los tribunales de la jurisdicción ordinaria. En efecto, toda persona deudora tal como se entiende en el concepto definido en el artículo 2° N° 25, puede solicitar ante el tribunal de su domicilio la liquidación voluntaria de sus bienes, para cuyo fin acompaña los documentos enumerados en el artículo 273:

- i) Lista de sus bienes, lugar en que encuentran los gravámenes que les afectan;
- ii) Lista de bienes legalmente excluidos de la liquidación de bienes de la persona deudora;
- iii) Relación de los juicios pendientes con efectos patrimoniales, y
- iv) Estado de deudas, con nombre, domicilio y datos de contacto de los acreedores, como así también la naturaleza de sus créditos.

ii) Tramitación de la solicitud de liquidación de bienes y decisión.

Junto con los antecedentes que debe acompañar la persona deudora a su petición de liquidación voluntaria de bienes, debe solicitar asimismo la nominación de un liquidador en conformidad con lo previsto en el artículo 37.

Una vez recibido el certificado de nombramiento del liquidador, el tribunal debe pronunciar la resolución de liquidación de los bienes de la persona deudora, que debe contener las enunciaciones establecidas por el artículo 129, la que es publicada en el Boletín Concursal.

iii) Consecuencias de la resolución de liquidación de bienes de una persona deudora.

Al tenor del artículo 275, se aplican al procedimiento de liquidación lo dispuesto en los Párrafos 4 y 5 del Título I del Capítulo IV, de la ley, en todo aquello que no sea contrario con la naturaleza de este sujeto pasivo, persona deudora (ver Arts. 130 y siguientes).

iv) Límite a la inembargabilidad de bienes.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el N°2 del artículo 445 del CPC, sólo puede embargarse la remuneración de la persona deudora hasta por 3 meses después de dictada la resolución de liquidación de sus bienes.

En el evento en que la persona deudora se encuentre casada, se aplican a la realización de sus bienes, cuando sea procedente, las normas establecidas en los artículos pertinentes del Código Civil y en leyes especiales, atendido el régimen de bienes que hayan convenido los cónyuges.

v) La determinación del pasivo.

A estos fines se aplican supletoriamente a este procedimiento concursal, lo establecido en el Párrafo 6 del Título I del Capítulo IV de la ley (ver Arts. 170 y siguientes).

vi) Las juntas de acreedores en este procedimiento.

En virtud de lo previsto en el artículo 278, la junta constitutiva tiene lugar en la sede del tribunal o en el lugar que éste determine y se celebra el 32° día de la publicación de la resolución de liquidación de los bienes de la persona deudora.

Esta junta constitutiva tiene competencia para deliberar y decidir sobre las siguientes materias:

- i) El liquidador titular provisional debe informar respecto de
 - los activos de la persona deudora
 - efectuar una propuesta de realización de los mismos
 - efectuar una estimación de los gastos
- ii) La ratificación de los liquidadores titular y suplente provisionales o el nombramiento de sus reemplazantes.

Los liquidadores no ratificados continúan en sus cargos hasta que asumen los definitivos.

Entre el liquidador no ratificado y el que lo reemplace debe firmarse un acta de traspaso, dentro de 10 días contados desde la nueva designación, en la cual conste el estado preciso de los bienes de la persona deudora y cualquier otro aspecto relevante para una adecuada continuación del procedimiento concursal de liquidación, debiendo entregarse todos los antecedentes, documentos y otros instrumentos del deudor que se encuentren en poder del primero nombrado.

Una copia de esta acta tiene que ser enviada a la Superintendencia;

- iii) El nombramiento de un presidente y de un secretario titulares y de un suplente para cada uno de estos cargos, designación que se hace de entre los acreedores con derecho a voto o sus representantes, quienes desempeñarán su labor en las próximas juntas, si las hubiere;
- iv) Los honorarios del liquidador, los que se rigen por las normas previstas en los artículos 39 y 40, y
- v) Cualquier otro acuerdo que la junta estime conducente, entre ellos la celebración de otras juntas, salvo que ellas sean citadas por el liquidador o por cualquiera de los acreedores que representen a lo menos el 25% del pasivo. En los aspectos no regulados por el artículo 278, se aplica lo previsto en el artículo 189, relativo al derecho a voto.

vii) Realización del activo y pago del pasivo.

En estas materias se aplican las disposiciones previstas en el artículo 204, y en los Párrafos 1 y 3 del Título 5 del Capítulo IV, respectivamente (ver Arts. 241 y siguientes y 247 y siguientes).

viii) Cuenta final de administración y término del procedimiento.

A la liquidación de bienes de la persona deudora se le aplica lo dispuesto en los Párrafos 2 del Título 3 del Capítulo II, relativo a la cuenta final de administración (ver Arts. 49 y siguientes) y el Párrafo 4 del Título 5 del Capítulo IV, sobre el término del procedimiento concursal de liquidación (ver Arts. 254 y siguientes).

B) La Liquidación Forzosa de los Bienes de una Persona Deudora.

a) Hecho revelador de cesación de pagos o “causal”.

El artículo 282 describe la causal para solicitar el inicio del procedimiento de liquidación de bienes de una persona deudora, de la siguiente forma:

- i) Mientras no se declare la admisibilidad de un procedimiento de renegociación de una persona deudora, cualquier acreedor puede solicitar el inicio del procedimiento de liquidación, “siempre que existieren en su contra 2 o más títulos ejecutivos vencidos, provenientes de obligaciones diversas, encontrándose iniciadas 2 ejecuciones y no se hubieren presentado bienes suficientes para responder de la prestación que se adeude y sus costas”.
- ii) Además, deben considerarse todas aquellas situaciones que ocasionan la liquidación de bienes de una persona deudora, en forma refleja.

b) Tramitación.

La solicitud para la aplicación del procedimiento de liquidación forzosa de bienes de la persona deudora, se presenta **ante el tribunal** del domicilio de ésta, que es el competente según la ley, describiendo la causal que se invoca y sus hechos justificativos, acompañada de los documentos indicados en el artículo 283:

- i) Los documentos o antecedentes escritos que acreditan la causal invocada.
- ii) Vale vista o boleta bancaria emitida a la orden del tribunal por la suma equivalente a 200 unidades de fomento, para subvenir a los gastos iniciales del procedimiento concursal de liquidación de los bienes de la persona deudora.
- iii) El nombre de los liquidadores titular y suplente, para el caso que el deudor no efectuaré actuación alguna por escrito en la audiencia prevista para este tipo de procedimiento.

El acreedor que pide la aplicación del procedimiento de liquidación puede nombrar a un veedor vigente de la nómina que existe al respecto, quien asume en caso de que la persona deudora se oponga al procedimiento concursal de liquidación de sus bienes, que tiene la misión de supervigilancia de las actividades del deudor mientras dure la tramitación del juicio de oposición, sustanciado según las normas de la ley concursal y tiene las facultades de interventor previstas en el artículo 25.

Los honorarios del veedor no pueden ser superiores a 50 unidades de fomento y son de cargo del acreedor petionario.

- iv) El solicitante puede pedir en su libelo cualquiera de las medidas cautelares indicadas en los Títulos IV y V del Libro II del CPC.

c) Revisión, primera providencia, notificación de la demanda y audiencia.

Ingresada a solicitud de aplicación de este procedimiento, el tribunal competente examina el cumplimiento de los requisitos legales ya indicados, en el plazo de 3 días.

- i) Si se han cumplido los requisitos legales: Si el juez estima que se han cumplido las exigencias legales, tiene por presentada la demanda, debe ordenar su publicación en el Boletín Concursal y cita a las partes a una audiencia que tiene lugar el 5° día, contado desde la notificación personal del deudor o conforme al artículo 44 del CPC, aun cuando no se encuentre en el lugar del juicio.
- ii) Si no se han cumplido los requisitos legales: En el evento de que la petición no satisfaga los requisitos legales, el tribunal de ordenar al demandante la corrección pertinente fijando un plazo de 3 días para que subsane, bajo apercibimiento de tener por no presentado el libelo.
- iii) La audiencia se desarrolla según las reglas establecidas en el artículo 284:
 - (1) El juez informa a la persona deudora sobre la demanda interpuesta en su contra y de los efectos del procedimiento concursal de liquidación de bienes que se le aplica.
 - (2) A continuación, la persona deudora puede proponer, por escrito o verbalmente, alguna de las alternativas que se señalan más adelante, debiendo siempre indicar el nombre o razón social, domicilio y correo electrónico, si lo conoce, de los 3 mayores acreedores o de sus representantes legales.

En caso de que el deudor no cumpla con esta última exigencia, el tribunal debe tener por no presentada la actuación de que se trata y dictar de inmediato la resolución de liquidación de los bienes de la persona deudora, nombrando a los liquidadores titulares y suplentes, ambos en carácter de provisionales, que el acreedor solicitante del procedimiento haya indicado en su demanda.

Las alternativas de solución que la persona deudora puede proponer en esta audiencia son las siguientes:

- Consignar fondos suficientes para el pago del crédito demandado y las costas correspondientes.

En este caso, el tribunal debe tener por realizada la consignación, ordenar practicar la liquidación del crédito, la regulación y tasación de las costas, y establecer un plazo en que la persona deudora demandada debe pagarlos, que se cuenta desde que las actuaciones recién señaladas quedan firmes.

En el evento de que el deudor demandado no pague en el término señalado, el tribunal debe pronunciar la respectiva resolución de liquidación de sus bienes.

- Allanarse a la demanda, por escrito o verbalmente, caso en el cual el tribunal debe dictar la respectiva resolución de liquidación.
- Oponerse a la demanda de liquidación forzosa, caso en el cual se aplican las disposiciones del juicio de oposición de la liquidación forzosa del procedimiento concursal de liquidación de la empresa deudora contenidas en el Párrafo 3, del Título I del Capítulo IV (ver Arts. 121 y siguientes).

La oposición del deudor sólo puede fundarse en las excepciones que el demandado puede oponer en el juicio ejecutivo, previstas en el artículo 464 del CPC.

- (3) Finalmente, si el deudor no comparece a la audiencia o al comparecer no realiza ninguna de las actuaciones recién señaladas, el tribunal debe pronunciar la resolución de liquidación de los bienes y nombrar a los liquidadores titulares y suplentes en calidad de provisionales, que el acreedor solicitante del procedimiento haya mencionado en su libelo.

d) Resolución de liquidación de los bienes de una persona deudora.

Esta resolución se dicta conforme al tenor del artículo 274, por lo que debe contener las enunciaciones previstas en el artículo 129.

Una vez dictada esta resolución, la tramitación del procedimiento continúa como en el caso de la liquidación voluntaria de los bienes de la persona deudora.

e) Antecedentes que se envían a la Superintendencia.

Cuando la ley ordena que la Superintendencia remita antecedentes al tribunal para que dicte la resolución de liquidación de los bienes de una persona deudora, se considera que debe enviar los siguientes:

- i) Copia de los antecedentes aportados por la persona deudora a los que se refiere el artículo 261, es decir, aquellos que este sujeto debe acompañar a la Superintendencia cuando solicita el inicio del procedimiento de renegociación.
- ii) Copia de la resolución a que alude el artículo 263, relativo a la resolución de admisibilidad del procedimiento antes indicado.
- iii) Copia de la propuesta de determinación del pasivo, a la que se refiere el artículo 265, relativa al mismo procedimiento.
- iv) Copia del acta de audiencia de ejecución, en que conste que se llegó a acuerdo.
- v) Copia de la resolución que declara terminado anticipadamente el procedimiento concursal de renegociación.

En resumen, el procedimiento tiene causales distintas pero es muy parecido al de liquidación de la empresa deudora. Además, el procedimiento de liquidación voluntaria ha tenido mucha aplicación en la práctica, pero ha habido muchos abusos dados sus efectos, principalmente para dejar de pagar créditos hipotecarios. Por eso se discuten algunas modificaciones a los procedimientos, que probablemente los hagan más lentos y minuciosos.

5. Acciones revocatorias concursales

5.1 Generalidades

La ley concursal y la ley civil regulan estas acciones (en general la ley concursal facilita su interposición) que buscan recuperar para la masa los bienes que debieran pertenecer al deudor y estar disponibles para la liquidación. Hay que recordar que la posibilidad de recuperar bienes no es la regla general sino que es excepcional por un tema de seguridad jurídica y también por un tema de respeto de los contratos con terceros.

Uno de los propósitos fundamentales del concurso consiste en que ésta abarque todos los bienes del deudor que están legalmente afectos a dicho concurso.

Sin embargo, cuando se declara la liquidación el deudor puede encontrarse en posesión de bienes de su dominio y de bienes de terceros, como también de bienes que no están comprendidos legalmente en el concurso, como son, por ejemplo, los bienes inembargables.

Estos bienes forman lo que se denomina “activo de hecho” del concurso. Pero existe otro concepto, “el activo de derecho del concurso”, que es aquel que comprende a todos los bienes que deben ingresar al concurso, excluyendo aquellos no afectos a él por pertenecer a terceros o por ser inembargables y agregando aquellos que, perteneciendo o debiendo pertenecer al deudor, no se encuentran en poder de éste, pero legalmente corresponden a la masa por disposición de la ley.

Entonces, los bienes que pertenecen o deben pertenecer a la masa pueden encontrarse en tres situaciones de hecho:

A) Bienes que pertenecen al deudor y que están al momento de la resolución de liquidación en su poder.

El liquidador adquiere la tenencia de estos bienes mediante el procedimiento de la incautación, que consiste en la facultad de este de tomar la tenencia material de los bienes del deudor y ponerlos en un lugar seguro bajo inventario, aun con el auxilio de la fuerza pública, la cual debe facilitarse con la sola exhibición de la copia autorizada de la resolución que declara la liquidación, sin necesidad de otra orden adicional.

B) Bienes que pertenecen al deudor, pero cuya tenencia la detenta un tercero.

Se trata de aquellos bienes cuyo dominio corresponde al deudor, pero que se encuentran en la tenencia material de un tercero, sea a título de precario o sin título legal, o en virtud de actos ejecutados o contratos celebrados por el deudor con anterioridad a la resolución de liquidación, tales como arrendamientos, comodatos, depósitos, consignaciones, etc.

Para la realización del activo del deudor será preciso que estos bienes pasen materialmente a manos del liquidador y éste, en virtud del desasimiento, representando judicial y extrajudicialmente al deudor y también a la masa de acreedores, está facultado para intentar las acciones legales correspondientes, tendientes a recuperar la tenencia y/o posesión material de estos bienes para la masa, tales como interdictos posesorios, acciones reivindicatorias, de comodato precario, de terminación de arriendo, desahucio, etc.

Como el liquidador es administrador de los bienes y no de la PJ, este puede iniciar acciones para recuperar bienes.

C) Bienes que deben pertenecer al deudor pero que se encuentran fuera de su patrimonio.

Antes lo denominamos de los “bienes pasados del deudor”, que son activos que estuvieron en el patrimonio del deudor pero salieron de él.

Aquí nos referimos a bienes de los que el deudor no sólo está privado de su tenencia, sino que no es dueño de ellos, pero que legalmente le corresponden porque han salido ilegítimamente de la esfera de su dominio.

En efecto, la ley se ha puesto en el caso de bienes que han salido del patrimonio del deudor mediante actos **jurídicos viciados de nulidad, afectados por lesión enorme, transferido por contratos resolubles o por causa de actos simulados.**

Especialmente, puede tratarse de bienes que han salido del patrimonio del deudor mediante actos directamente perjudiciales a los intereses de los acreedores, realizados por el deudor a plena conciencia, con el objeto de sustraer dichos bienes del alcance de los acreedores y usarlos en beneficio propio con posterioridad a una liquidación que se avizora que sobrevendrá. Ej. ventas simuladas, ocultaciones, donaciones a parientes, etc.

Las acciones judiciales que tienden a recuperar en beneficio de la masa estos últimos bienes que han salido del patrimonio del deudor, son las que se denominan **“de integración o recuperación de patrimonio”** dentro de las cuales se encuentran aquellas que la ley denomina **“efectos retroactivos del concurso”**.

Doctrinariamente, las acciones que tienen por objeto aumentar o reintegrar el patrimonio del deudor se agrupan en dos clases: (1) acciones indirectas, oblicuas o subrogatorias y (2) acciones revocatorias.

(1) Las acciones subrogatorias, oblicuas o indirectas son aquellas que facultan a los acreedores para ejercer (directamente o través del liquidador) en juicio los derechos que corresponden al deudor, con el objeto de incrementar su patrimonio. Ej. acción de cobro de un arriendo.

En virtud de este derecho de subrogación, los acreedores están facultados para intentar, aun antes de declarada la reorganización o la liquidación, acciones de nulidad, reivindicación, resolución, simulación o lesión enorme, y otras que correspondan a su deudor, con el fin de incrementar el patrimonio de éste y poder satisfacer y/o garantizar de mejor forma sus acreencias.

Por otra parte, se otorgan también a los acreedores las denominadas **(2) acciones revocatorias**, *que son aquellas que tienen por finalidad dejar sin efecto actos que el deudor ha realizado expresamente en fraude o perjuicio de sus acreedores.*

En nuestra legislación concursal, por regla general, sólo existen las acciones revocatorias; las acciones subrogatorias u oblicuas sólo se confieren en los casos especialmente determinados por ley y no como norma general. Sin embargo, nada obsta a que en dichos casos un tercero interponga estas acciones, pero debiendo hacerlo en beneficio de la masa, según señala el art. 291. Incluso algunos creen que las subrogatorias serían un efecto del desasimiento (sería el mismo deudor, a través del liquidador, quien ejerce las acciones).

Sólo en el caso del concurso, por la representación del deudor que detenta el liquidador, éste puede y se encuentra obligado, a intentar todas las acciones que competan y que interesen a la masa. Es decir, sólo en el proceso de liquidación pueden venir a intentarse las acciones que hemos llamado subrogatorias, aun cuando Vargas con razón expresaba que no hay acción subrogatoria propiamente tal, sino el ejercicio del liquidador de una mera representación del fallido que le corresponde por ley.

5.2 Acción Pauliana

A) Definición de Acción Pauliana o Revocatoria

“Aquella que tiene por objeto dejar sin efecto los actos o contratos ejecutados por el deudor en fraude o perjuicio de sus acreedores y reintegrar a la masa los bienes de los que éste fraudulentamente ha dispuesto o enajenado”.

“Es aquella que tiene por objeto hacer volver al patrimonio del deudor bienes que no se encuentran en su poder y de los cuales se ha desprendido mediante actos ejecutados en fraude de sus acreedores”.

B) Acción Pauliana Concursal

Como se desprende de los artículos 287 y siguientes, *es la acción pauliana civil del artículo 2468 del Código Civil ejercida dentro del procedimiento de liquidación.*

La regla general es que todo acto o contrato celebrado por el deudor con anterioridad a la resolución de liquidación, distinto a los contemplados en el artículo 74 puede ser impugnado por la acción pauliana que se encuentra instituida en el artículo 2468 del Código Civil y que ejercida en el marco de la liquidación se denomina acción pauliana concursal.

Su función es hacer plenamente aplicable la acción pauliana civil al procedimiento concursal de liquidación, con las modificaciones que le introduce la ley reorganización y liquidación. Lo que hace la legislación concursal es facilitar el ejercicio de la acción pauliana, principalmente en cuanto la prueba del fraude pauliano (mala fe o conocimiento del mal estado de los negocios del deudor).

C) Campo de aplicación

Permite obtener la declaración de inoponibilidad de actos o contratos que el deudor ejecute o celebre a título gratuito en cualquier tiempo –siempre dentro de los plazos de prescripción del artículo 291–, **con anterioridad a la resolución de reorganización o de liquidación.**

También puede servir al acreedor para obtener la ineficacia de un acto o contrato a título oneroso en diferentes causales.

D) Diferencias entre la Acción Pauliana Concursal y la Acción Pauliana Civil

a) Legitimado Activo:

La acción civil corresponde a cualquier acreedor. La acción pauliana concursal puede ser ejercida:

- Por un acreedor cuyo crédito sea incluso posterior al acto que se busca impugnar (acreedores concurrentes que han verificado créditos).

Sólo pueden interponerla quienes sean tenidos como parte activa del procedimiento de liquidación: los acreedores concurrentes, es decir, quienes hayan hecho valer sus derechos en el concurso.

Ellos son quienes tienen un interés real en interponer la acción y NO necesitan tener un título ejecutivo.

- Con la apertura del concurso surge un nuevo titular de las acciones: el liquidador o el veedor, según sea el caso. No solo es administrador de bienes del deudor, sino que protege a los acreedores.
- Se deben interponer en beneficio de la masa, siendo el deudor y el contratante los demandados.

b) Sujeto Pasivo:

Para determinar quién ha de ser considerado legítimo contradictor, es necesario distinguir entre la acción pauliana civil y las acciones revocatorias concursales, dentro de las que se comprende la acción pauliana concursal.

i) En la acción pauliana civil, son legítimos contradictores (demandados):

- El deudor.
- El tercero contratante.
- Los subadquirentes.

ii) En las acciones concursales:

Se comprenden dentro de esta categoría:

- El tercero contratante o el acreedor pagado (pago anticipado del acreedor).
- Los subadquirentes.

- El deudor, si se ejerce la acción pauliana concursal. En este caso, el deudor puede ejercer su defensa en el juicio sin necesidad de requerir la autorización del liquidador o veedor.

c) Resultado:

Admitido el éxito del ejercicio de la acción, beneficiará ya no sólo al acreedor que la interpone, sino a todos los acreedores, y es que, conforme a lo dispuesto en el artículo 291, esta acción puede ser ejercida por cualquiera de los acreedores “en interés de la masa.”

Por esto mismo, el art. 293 señala que el acreedor que interpone la acción tiene derecho a que se le paguen con cargo a los fondos del concurso todos los gastos y costas, con la preferencia del art. 2472 N° 1.

Asimismo, tiene derecho a una **recompensa** de hasta el 10% del beneficio que la acción reporte a la masa, no pudiendo ser superior al crédito verificado, lo fija el tribunal en la sentencia definitiva con cargo al deudor o a la masa. Este derecho no se tiene si se adquiere con posterioridad el crédito.

Sin embargo, el acreedor que inicie estas acciones debe informar al liquidador o al veedor para que este informe a la Junta en un plazo de 30 días desde que sea notificado.

Si la acción la interpone el liquidador o veedor, las costas son gastos generales.

d) Prueba:

Se establece una presunción simplemente legal en contra de la persona deudora en el inciso cuarto del artículo 290, al señalar que “Se presume que el deudor conocía el mal estado de sus negocios antes del inicio del procedimiento concursal respectivo.”

Así, si el acto es celebrado, dentro del período de un año desde el inicio del respectivo procedimiento de renegociación o liquidación, no será necesario probar el *concilium fraudis*.

El que el acto haya sido celebrado antes de dicho período, no significa que no puede ejercerse esta acción, sino simplemente no goza de dicho beneficio probatorio.

e) Plazo de Prescripción:

Según el número 3 del artículo 2468 del Código Civil, esta acción “expira en un año contado desde la fecha del acto o contrato.” Pero el artículo 291 de la ley señala:

Las acciones revocatorias (dentro de las cuales, está la pauliana concursal), prescriben en el plazo de un año contado desde la resolución de reorganización, de liquidación o de admisibilidad, según corresponda.

Tribunal puede dictar medidas conservativas.

f) Procedimiento Aplicable:

Para la acción pauliana civil del artículo 2468 no se establece procedimiento especial al cual deba sujetarse en cuanto a su tramitación, por lo que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 3 del

Código de Procedimiento Civil, ha de sujetarse al juicio ordinario, en tanto procedimiento de aplicación supletorio.

Por el contrario, el artículo 291 de la ley concursal dispone que la acción pauliana concursal, al igual que las restantes acciones revocatorias concursales, se “tramitarán con arreglo al procedimiento sumario”, de los artículos 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

E) Sentencia:

La sentencia que resuelva la acción revocatoria debe pronunciarse sobre lo siguiente:

- a) Declarar la revocación
- b) Ordenar la restitución de bienes
- c) Realizar o cancelar inscripciones
- d) Si fuere el caso, determinar el valor que las cosas tenían en el mercado en la época del contrato. Esto porque la ley le da oportunidad a la contraparte para restituir la diferencia y enervar la recuperación del bien.

F) Efectos

Si esto sucede, la parte condenada debe restituir el bien y tiene derecho a recibir lo pagado por ella. Para estos efectos –como sanción– debe verificarlo y queda subordinado al pago de los acreedores valistas.

Sin embargo, tiene derecho a quedarse con la cosa si dentro de tres días contados desde la fecha de la notificación del cumplimiento incidental del fallo paga la diferencia con el valor de mercado determinado por el tribunal, incluyendo reajustes e intereses desde la fecha de celebración del contrato hasta la fecha de pago efectivo.

Apenas el demandado se pronuncie al respecto, el tribunal debe realizar la liquidación, y una vez entregada existen 3 días para el pago efectivo.

Si no se restituye la cosa, se inicia el cumplimiento incidental. Contra la sentencia definitiva solo procede la apelación en un plazo de 10 días contados desde la notificación del fallo.

G) Efectos frente a terceros

La sentencia tiene plenos efectos frente a terceros (subadquirente), cuando estos conozcan el mal estado de los negocios del deudor al momento de celebrar el acto o contrato.

H) Características

- a) Es una inoponibilidad de derecho: no significa que no requiera de declaración judicial, sino que, verificados los requisitos de procedencia, el juez está obligado a declarar la ineficacia.
- b) Es de utilidad para impugnar actos o contratos celebrados a título oneroso en cualquier tiempo y también a título gratuito según lo visto.

- c) Exige la procedencia de los requisitos de la acción pauliana civil, con las modificaciones ya analizadas, en el caso de la persona deudora: el artículo 290 señala: “se observará lo prevenido en el artículo 2468 del Código Civil.” Al igual que en la civil, es necesario distinguir si el acto es gratuito u oneroso.

I) Requisitos de la Acción Pauliana Civil o Revocatoria Ordinaria (Art: 2468)

a) Que la acción sea ejercida por un acreedor

La acción de revocación supone un interés, el que sólo se ve en los acreedores, para quienes la revocación importa una ampliación de sus posibilidades de cobro, al acrecentar a garantía común. Por ello, el único legitimado para interponer la acción pauliana civil es un acreedor del deudor.

Existen 4 materias que sufren una alteración cuando se trata de la acción pauliana ejercitada en la quiebra o de las acciones revocatorias concursales:

- i) La acción la puede interponer un acreedor cuyo crédito sea incluso posterior al acto impugnado, lo que no sería admisible en el caso de la acción pauliana fuera de la liquidación.
 - ii) El resultado de la acción, admitido su éxito, ya no beneficia sólo al acreedor que la interpone, sino a todos los acreedores.
 - iii) Con la apertura del concurso, surge un tercer titular de las acciones revocatorias (ordinarias o concursales): el liquidador o el veedor, según el caso.
 - iv) Deja de ser requisito del ejercicio de la acción revocatoria que los acreedores que la interpongan invoquen un título ejecutivo. Sólo pueden interponerla los acreedores que son parte activa del proceso de quiebra: quienes han verificado.
- b) Que se trate de un acto jurídico celebrado con anterioridad a la resolución de reorganización o de liquidación, según el caso.
- i) Debe tratarse de un acto jurídico y no material
 - ii) Debe haberse producido con antelación a la resolución respectiva de reorganización o de liquidación

Esto último por (1) el desasimio que se produce con la resolución y (2) la ley dice de qué manera se liquidan los bienes (siendo muy difícil que hayan ventas directas) y cómo se paga a los acreedores: estas dos razones muestran que es casi imposible que hayan actos o contratos posteriores a la resolución que afecten la par conditio.

c) Que el acto a revocar sea perjudicial para la masa

El acto dudoso debe ser causante o agravante de la insolvencia.

El demandante debe probar el carácter dañoso del acto y el nexo causal entre el acto y el perjuicio. Sin embargo, en la revocación concursal muchas veces la ley presupone el perjuicio y el

nexo, justamente porque se trata de actos jurídicos que son por sí mismos prueba del perjuicio (donación, pago anticipado, etc.).

d) Que exista fraude pauliano

La concepción del fraude pauliano es justamente el punto que separa a las acciones revocatorias concursales de la acción pauliana civil. El Art. 2468 del Código Civil siempre demanda un conocimiento del mal estado de los negocios del deudor y exige ese conocimiento al tercero que contrata onerosamente con él, o que celebra actos de garantía real.

Sin embargo, dentro del proceso de reorganización o liquidación, la acción pauliana civil sufre una variación hacia su objetivización, puesto que el Art. 290 **presume de derecho que la persona deudora conocía el mal estado de sus negocios**: esto porque, si además el acto es perjudicial para la masa, lo más probable es que el acto se haya realizado cuando ya había un estado de cesación de pago.

Asimismo, en los actos a título gratuito la exigencia de fraude pauliano es absolutamente eliminada de la revocación concursal. Aquí se revoca por el daño objetivo a la par conditio.

Sólo se atiende a un factor subjetivo en los actos a título oneroso, pero ello, como una extensión al principio de la protección a los terceros de buena fe.

J) Importancia de la Acción Pauliana Civil en el Derecho Concursal

Tiene un alcance subsidiario, pues es la acción que el acreedor o el liquidador o veedor (según el caso) intentará a falta de otra mejor y más específica.

El carácter supletorio de esta acción se deriva de las siguientes circunstancias:

- a) Se intentará contra cualquier acto celebrado en el período sospechoso si no existe una acción revocatoria especial.
- b) Aun cuando exista una acción revocatoria especial para tal tipo de acto, se interpondrá toda vez que ese acto haya sido celebrado fuera de su período sospechoso especial, pues procede contra cualquier tipo de acto celebrado en cualquier tiempo.

5.3 Determinación del Período Sospechoso

Lo óptimo en materia concursal es que se ponga en movimiento alguno de los concursos alternativos tan pronto como se produzca la cesación de pagos. Pero en la práctica ello no pasa de una ilusión, siendo la regla general que pase justamente lo contrario.

Habitualmente, el deudor retarda la aparente “infamia” de su situación financiera y eventual liquidación hasta el límite que un acreedor solicita el inicio de un procedimiento concursal.

Entonces, se hace imperativo echar una mirada retrospectiva y determinar ese momento en que se produjo el colapso económico. Desde allí debe empezarse a reconstruir el patrimonio estimado como garantía general y común de los acreedores concursales.

El límite de retrospección ha cambiado. Antiguamente era precisamente la fecha de cesación de pagos y todo el tiempo que lo sigue ha de estar impregnado de una presunción de fraude a la *par conductio*.

La fijación de la fecha de cesación de pagos tenía por objeto determinar el período durante el cual los actos del fallido están envueltos en esa presunción de fraude.

Actualmente esto ha cambiado, ya que no hay fijación ni presunciones sobre la fecha de cesión de pagos, sino que la ley fija como antecedente objetivo la resolución de reorganización o de liquidación y en base a ella construye el periodo sospechoso para revisar los actos sujetos a esta revisión, que generalmente es de un año contado hacia atrás desde la fecha de la correspondiente resolución.

5.4 Estudio Particular de las Acciones Revocatorias Concuriales

A) Empresa deudora.

La ley diferencia entre causales de revocabilidad objetiva y subjetiva, según disponen los **Arts. 287 y siguientes (OJO)**.

a) Causales de revocabilidad objetiva:

Como norma de común aplicación, al deducir la acción por estas causales el tribunal solo debe verificar:

- Que el acto o contrato se haya celebrado y que corresponda a algunas de las descripciones del Art. 287; y
- Que haya ocurrido dentro en los plazos indicados en el Art. 287.

Para estos efectos, el peso de la prueba para probar en contrario lo tendrá el deudor o el tercero adquirente, en el sentido de señalar que dichos actos o contratos no **produjeron perjuicios a la masa**. Recordemos que si no aplican las revocatorias, interpongo una acción pauliana.

Esta última norma es muy relevante, ya que aunque transfiere el peso de la prueba da una oportunidad al deudor o tercero de mostrar las bondades del acto o contrato y en especial su beneficio para la masa.

i) Acción revocatoria contra pagos anticipados (Art. 287, inc. 1, N° 1)

La intención de esta letra es mantener la posición de igualdad que debe existir entre los acreedores.

La acción destinada a la declaración de ineficacia de los pagos anticipados (antes de plazo) hechos por el deudor requiere que se acredite tal carácter de anticipado y que se pagó durante el período sospechoso, que es de 1 año anterior a la fecha de la resolución de reorganización o de liquidación.

La ley asimila al pago anticipado el descuento por parte del deudor de efectos de comercio o facturas de su cargo o renuncia del plazo estipulado a su favor. Esto a menos que se pruebe que la tasa de descuento fue beneficiosa para la masa.

ii) Acción revocatoria contra daciones en pago (Art. 287, inc. 1, N° 2)

Las daciones en pago hechas por el deudor son revocables siempre que se hayan efectuado en el período sospechoso (que es igual al anterior). Esto porque se paga en una forma no pactada (ej. se paga con un bien que tiene mayor valor que la deuda en sí).

Esto incluye cualquier forma de pago que no sea la que se pactó. La ley presume además que en el caso de efectos de comercio el pago debe realizarse en dinero.

iii) Acción revocatoria contra garantías reales para obligaciones preexistentes (Art. 287, inc. 1, N° 3)

También son revocables las hipotecas, prendas y anticresis constituidas por bienes propios del deudor durante el período sospechoso (que es igual al anterior), destinadas a garantizar deudas preexistentes.

Mejora la calidad de un acreedor, ya que antes del otorgamiento de ellas no gozaba de este beneficio.

iv) Acción revocatoria contra actos a título gratuito propiamente tales (Art. 287, inc. 2°)

Sólo requieren acreditar que se celebraron dentro del plazo que señala la ley y que corresponde a alguna de las descripciones señaladas en ella. En este caso, el período sospecho se extiende hasta los **2 años** anteriores a la fecha de la resolución de reorganización o de liquidación.

Sigue el principio de que cualquier activo que sale del patrimonio del deudor debe traer aparejada la entrada de la contraprestación, la misma que no existe en este tipo de actos.

v) Acción revocatoria contra actos realizados por personas relacionadas

La ley se pone en el caso en que los actos especificados en los numerales anteriores (Art. 287 Inc. 1°, números 1, 2 y 3) se realicen con personas relacionadas.

En este caso también existe la acción revocatoria, pero el periodo sospechoso se aumenta a **dos años** contados desde la resolución de reorganización o de liquidación.

b) Causales de revocabilidad subjetiva (Art. 288):

Estas causales tienen un periodo sospechoso ampliado a dos años anteriores a la fecha de la resolución de reorganización o de liquidación, según corresponda.

Sin embargo, para estos efectos la ley exige que se prueben en juicio las causales correspondientes, basadas ya no en la mera ocurrencia de un acto o contrato objetivo, sino que en el conocimiento que se tiene del deudor o de sus negocios.

Los requisitos copulativos son los siguientes:

i) Conocimiento del mal estado de los negocios del deudor:

En esto radica fundamentalmente la subjetividad de la causal, ya que es materia de prueba compleja. Sin embargo, el legislador ha entendido que actualmente existen sistemas de información que de alguna manera entregan mayores recursos para facilitar esta determinación (ej DICOM).

Acá ya no aplica la presunción de derecho que sí aplica en las causales objetivas.

ii) Acto o contrato cause perjuicio a la masa o altere la *par conductio creditorum*.

Para estos efectos, se entiende que existe perjuicio cuando las condiciones del acto o contrato se alejan de las condiciones que prevalecían en el mercado para operaciones similares a la fecha en que se celebraron.

De hecho, la ley dispone que, en caso de ventas o permutas de activos, se entienden como ingresos solo los montos efectivamente percibido por el deudor a la fecha en que se interponga la acción revocatoria o el valor que el mismo tribunal le asigne en el caso de permuta.

c) Otras causales (Art. 289):

La ley también incluye dentro de las acciones concursales la posibilidad de dejar sin efecto las modificaciones de estatutos sociales celebradas en el plazo de 6 meses contados desde el comienzo del procedimiento si es que suponen una disminución del patrimonio del deudor, tomando ambos como requisitos copulativos. Hubo mucha discusión a principio de año, por ejemplo con LATAM, porque en 2019 ganó plata entonces había obligación legal de repartir al menos 30% de utilidades lo que obviamente es una disminución patrimonial. Solo por unanimidad se puede no distribuir utilidades, lo que es prácticamente imposible, entonces, ¿puedo revocar esta distribución de dividendo? En base a esta causal, en teoría sí.

Algo similar ocurre en el caso de filiales y coligadas, cuando éstas actúan como fiadoras o codeudoras solidarias del deudor. En este caso, si es que tales actos disminuyeron el patrimonio de este tipo de sociedades, dichas modificaciones serán inoponibles a quienes hubieren contratado con ellas con anterioridad a las reformas.

B) Persona Deudora

Se aplican las mismas disposiciones que las establecidas para empresas deudoras, incluyendo causales y plazos, excepto aquella relacionada a modificaciones de estatutos sociales, por razones obvias.

Sin embargo, el Art. 290 dispone en su inciso 4 que en caso de que se traten de otros actos o contratos celebrados a título oneroso, se aplica el Art. 2468 del Código Civil (acción pauliana), presumiéndose que el deudor conocía el mal estado de sus negocios antes del inicio del procedimiento concursal.

Según Puga, este es el único caso donde se mantendría la acción pauliana, precisamente por esta referencia al Art. 2468.

5.5 Naturaleza Jurídica de las Acciones Revocatorias

La acción revocatoria, sea ordinaria o concursal, presenta caracteres que han dado origen a un acalorado debate en la doctrina. En primer lugar, se discute si se trata de una acción de nulidad o de inoponibilidad; la segunda dice relación con su clasificación entre real o personal, y, en tercer lugar, se polemiza en torno a si se trata de acciones indemnizatorias o bien si es una acción restitutoria.

A) La acción revocatoria es una acción de inoponibilidad y no de nulidad

Ya no parece existir fundamento para calificar las acciones revocatorias como acciones de nulidad. La propia ley habla hoy de inoponibilidad y no de nulidad.

Existen varias razones para concluir que siempre la sanción propia de la revocación ha sido la inoponibilidad y no la nulidad.

Ello, porque la nulidad dice relación con vicios congénitos al acto, sea por la falta o ilicitud de su objeto o causa, por la falta de solemnidades, la falta o vicios en el consentimiento o falta de capacidad legal. No ocurre así con la revocación, en que el acto es intrínsecamente válido, pero que, por las circunstancias de su otorgamiento, el estado de cesación de pagos, importa un atentado al orden público, representado por el interés de la colectividad de acreedores.

Algunos sostenían la teoría de la nulidad porque: a) hay vicios del consentimiento (falta información del tercero contratante sobre la situación del deudor) b) falta de capacidad del deudor, c) objeto ilícito por atentar contra el orden público. *Pero todos estos argumentos estiran mucho la ley.* Por esto es más propio hablar de inoponibilidad del contrato que se revoca, frente a la masa concurrente de acreedores.

Las inoponibilidades se dividen en de **forma** y de **fondo**. Como la infracción a la *par conditio* es un atentado contra una norma sustantiva, lo lógico es encuadrarla dentro del conjunto de las inoponibilidades de fondo.

Ahora, ¿qué significa que un acto jurídico sea inoponible? Significa que el acto celebrado por el fallido no puede ser opuesto a los acreedores congregados en el concurso, sin perjuicio de la validez entre las partes. Un acto válido, se transforma en un acto contrario al interés de los acreedores.

Esta es la doctrina radical de la inoponibilidad. Revocado un acto, éste no se extingue en cuanto fuente de obligaciones para los otorgantes o concurrentes, pero pasa a ser inexistente respecto de la masa.

Lo delicado de esta sanción no está en los actos a título gratuito declarados inoponibles; sino en la **revocación de actos a título oneroso**. El asunto se traduce en averiguar en qué condición queda la contraprestación que recibió el deudor del tercero co contratante.

¿Debe la masa restituir, antes de reintegrar el bien a la masa, dicha contraprestación? ¿Debe el tercero, por el contrario, verificar y supeditarse a la suerte de los demás acreedores en los repartos que haga el liquidador o veedor? ¿O es que el tercero pierde su contraprestación?

a) Restitución de la Contraprestación

Para algunos autores, al tercero se le debe restituir su contraprestación, sin que para obtenerla deba verificar su crédito; de lo contrario, sostienen, la masa de acreedores experimentaría un enriquecimiento sin causa.

b) Verificación de la Contraprestación (tesis mayoritaria)

Otros autores son de la opinión de que el tercero co contratante debe verificar en el procedimiento concursal y se restituya de su contraprestación mediante el pago en los respectivos repartos.

Señalan que la ley no dice que con motivo de la ineficacia declarada se deba reintegrar al tercero su contraprestación, colocándolo virtualmente en mejor situación que cualquier acreedor y otorgándole una posición más privilegiada.

Además, estiman que es justo y equitativo que el tercero deba insinuarse en el pasivo como acreedor valista por la contraprestación que le es debida, corriendo la misma suerte que todos los acreedores, por la doble circunstancia de que:

- i) En estos actos el fraude anda rondando, es vecino o está próximo a este género de negocios.
- ii) Para permitir la verificación en tiempo se establece un procedimiento (revocatorio) rápido, rapidez que se prescribe justamente para que el tercero alcance a verificar.

c) Privación de la Contraprestación (postura minoritaria)

Una tercera posición es la que se pregunta si es tan ilegítimo que este tercero sea absolutamente privado de su contraprestación, lo que lleva implícita la solución al problema de si la inoponibilidad es tan absoluta que se le desconozca al tercero su calidad de acreedor y su legitimación, por lo tanto, para insinuarse en el pasivo mediante demanda de verificación.

Antes de ver las razones de esta postura, hay que recordar que:

- i) El sobrante del producto de la realización del bien restituido, una vez pagados los acreedores, debe serle devuelto al tercero, porque la revocación jamás aprovecha al deudor, lo que es idéntico a decir que el tercero sigue siendo dueño del bien. En el fondo se pagarían después de los valistas, porque no es consecuencia del concurso que exista este crédito.
- ii) El acto revocado por la circunstancia que causó perjuicio a la masa debe haberse cumplido por el deudor; esto es, dicho tercero es un acreedor pagado y la obligación emanada del acto se encuentra cumplida, por lo que podría objetarse la respectiva verificación oponiendo la excepción de pago. En otras palabras, esta deuda ya se pagó.

Admitir la tesis de quienes postulan que el tercero puede verificar, significaría que la inoponibilidad perjudica sólo al deudor y no al tercero, en circunstancias de que en los actos onerosos se requiere su mala fe, su conocimiento de la ilicitud circunstancial del acto revocado.

Además, en nuestro derecho no existe ninguna norma que permita deducir que la revocación declarada resucita una obligación extinta.

Existe una norma en nuestro derecho que podría respaldar la tesis que sostiene que el tercero queda privado absolutamente de su contraprestación. En efecto, el Art. 1468 del Código Civil dispone que “no podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas”.

Tenemos, por un lado, que el tercero, extra concurso, sigue siendo propietario del bien reintegrado a la masa o, lo que es igual, sigue siendo un acreedor satisfecho; y, por otro lado, sabemos que para que prospere la revocación de los actos a título oneroso, es menester que dicho tercero haya estado en conocimiento de la insolencia del deudor, esto es, que el acto revocado constituía cuando menos una amenaza a la *par condictio*, un atentado al orden público.

Sabemos que los actos jurídicos deben tener un objeto lícito, so pena de nulidad absoluta, y hay objeto ilícito en las cosas moralmente imposibles, vale decir, en aquellas prohibidas por las leyes, o contrarias a las buenas costumbres o al orden público (ART. 1461 inc. 3º del C. Civil). En virtud de estas consideraciones, deberíamos llegar a la conclusión de que el pago o contraprestación del tercero hecho a causa del contrato infractor de la *par condictio*, adolecería de causa ilícita y, en consecuencia, no admitiría repetición.

Por esto, dicen que la revocación tampoco puede aprovechar al tercero cocontratante, que, por una parte, sigue siendo titular del bien reintegrado y, por la otra, no puede repetir contra el fallido o deudor.

En suma, sea que el tercero haya sido acreedor a título oneroso o a título gratuito, no puede insinuarse en el concurso o, dicho en otras palabras, los actos revocados son absolutamente inoponibles a la masa, sin perjuicio de las relaciones entre el fallido y el tercero cocontratante.

Por lo anterior, concluyen que la sanción de inoponibilidad es absoluta: los actos revocados no pueden invocarse por los terceros cocontratantes en el procedimiento concursal.

B) La acción revocatoria como acción personal

En el concepto civil, las acciones se clasifican en reales o personales, según sea la naturaleza del derecho de que emanan.

Siguiendo esta clasificación, hubo quienes sostuvieron en el pasado que las acciones revocatorias eran acciones reales porque perseguían la restitución de un bien y que esta restitución podía reclamarla la masa de acreedores aún al tercero adquirente, y hasta a los subadquirentes de dicho bien transferido, mediante el acto revocado.

Pero **resulta manifiesto su carácter personal** si se tiene en cuenta que el acreedor revocante invoca un derecho de crédito para intentar su acción y que su propósito no es el desconocimiento o ineficacia de un derecho real, sino la inoponibilidad de un acto o contrato. Además, declarada la revocación del acto o contrato, su ineficacia es *erga omnes*, de forma que el bien, para los fines

concursoales, sigue siendo de propiedad del fallido, aun cuando fuera del concurso no se altere la titularidad del dominio del bien en cuestión.

NO es una acción para perseguir bienes sino el pago de una obligación. De hecho, muchas veces, el éxito de una acción revocatoria importará el ejercicio subsecuente de una acción reivindicatoria o posesoria, que sí son acciones reales, pero ello es como consecuencia de la reincorporación al patrimonio del fallido del bien, para los solos efectos concursales, y no como resultado inmediato del ejercicio de las acciones revocatorias.

C) Las acciones revocatorias no son indemnizatorias ni restitutorias

Se discutía si estas acciones eran de carácter indemnizatorio o si eran meramente restitutorias.

El problema estaba mal enfocado en su misma formulación. Las acciones revocatorias son, por sobre todo, acciones de inoponibilidad. Esto es, son acciones que persiguen la mera declaración de la ineficacia de actos jurídicos respecto de terceros.

Por la inoponibilidad del acto, sucede que tanto el tercero cocontratante como los terceros subadquirentes son, en lo que respecta a los acreedores concursales, poseedores sin título y en consecuencia, deben restituir todo lo que recibieron del deudor: la cosa, sus frutos naturales y civiles o, en su defecto, el valor de lo que hayan recibido por ella, todo conforme a las reglas de las acciones posesorias y reivindicatorias, y de las prestaciones mutuas dadas por el Código Civil, al tratar de la acción reivindicatoria.

De forma que se debe distinguir entre las revocatorias, que son acciones de mera declaración, y las acciones que nazcan del éxito de aquéllas, que habitualmente serán restitutorias, pero que también pueden ser indemnizatorias.

5.6 Aspectos Relevantes sobre el Ejercicio de las Acciones Revocatorias Concuriales

A) Tribunal Competente

La ley nada dice, pero hay consenso en que es el juez competente para conocer de la liquidación. Puelma difiere: para él, se aplican las reglas generales de competencia.

B) Procedimiento

Es el juicio sumario (art. 291)

C) Prescripción (Art. 291)

Las acciones revocatorias prescriben en el plazo de 1 año desde la fecha de la resolución de Reorganización o de Liquidación.

D) Sentencia

En lo dispositivo, debe ordenar lo siguiente: Art. 292

- a) Que se disponga la restitución del bien
- b) Realizar las inscripciones y cancelaciones que sean pertinentes

- c) En forma expresa, señalar el monto que el tribunal estime necesario y que corresponda a la diferencia de valor entre el acto o contrato revocado y el valor de mercado

Esto hace que el cocontratante deba, a su elección:

- Restituir la cosa a la masa, o
- Pagar del diferencial

Contra la sentencia, se puede deducir apelación en un plazo de 10 días contados desde la notificación del fallo.

E) Efectos respecto a terceros

El art. 294 regula el alcance que puede tener para terceros la sentencia. Si los terceros conocían el mal estado de los negocios al momento de celebrar el acto o contrato, el fallo:

- a) Determina el valor de los bienes objeto de la revocación para efectos del reintegro o pago de su valor
- b) Ordena la cancelación de inscripciones a nombre de vencidos y la inscripción de reemplazo a nombre del deudor.

6. Insolvencia transfronteriza

6.1 Regulación anterior a la Ley N° 20.720

No es ninguna novedad deducir que la generalidad de las relaciones comerciales han ido globalizándose con el pasar de los años, al punto de entender que hoy el comercio y las inversiones internacionales son la regla general en materia económica. Por lo mismo, resulta evidente observar que poco a poco algunas de las legislaciones concursales más modernas han ido adoptando normativas sobre insolvencia tendientes a regular dichas situaciones, es decir, aquellos casos en que la quiebra o concurso de un deudor trasciende las fronteras o límites territoriales del país que declaró la apertura del procedimiento, con el objeto de involucrar a sus acreedores y sus bienes situados en el extranjero. El Libro IV del Código de Comercio no contemplaba reglas relativas a supuestos de insolvencia transfronteriza, salvo las normas sobre notificación al acreedor extranjero, contenidas en su artículo 52 N° 7.

Sin perjuicio de lo anterior, la materia se encontraba parcialmente recogida en el Libro IV, Título IX de la Convención de Derecho Internacional Privado (o “Código de Bustamante”), que ha sido ratificada, normalmente con reservas, por 15 países, entre éstos, Chile, quien la ratificó en 1933 y publicó en abril de 1934.

Sin embargo, esta normativa reconoce los siguientes problemas:

- A) Nuestro país ratificó la Convención con reserva general, lo que hace siempre necesario coordinar y verificar sus normas con el derecho interno. Por ejemplo, parece discutible la aplicación del artículo 415, que consagra la pluralidad o territorialidad de la quiebra

disponiendo que si una persona o sociedad tiene establecimientos mercantiles en más de un Estado “(...) puede haber (respecto de ella) tantos juicios de procedimiento preventivos y de quiebra como establecimientos mercantiles”. La contradicción normativa se fundamentaría en admitir la posibilidad de que una persona tenga varios establecimientos mercantiles y pueda ser declarada en quiebra en cada uno de ellos. Así, se estaría aceptando que el sujeto pasivo de un procedimiento concursal podría ser un establecimiento mercantil y no una persona (natural o jurídica), como exigía el artículo 1° del Libro IV del Código de Comercio. Lo anterior también significa una contraposición a la universalidad del concurso —traducida en la indivisibilidad que se crea con la respectiva declaratoria entre el deudor y sus acreedores, en todos los bienes y obligaciones del primero— contenida en el artículo 2° del mismo cuerpo legal.

- B) El Código de Bustamante, atendida su normativa de tratado intencional, sólo produce efectos en relación a otros Estados signatarios de la Convención. Lo anterior implica una serie de deficiencias prácticas en la aplicación de sus reglas, traducándose lo anterior especialmente en una triple carga de trabajo para nuestro Poder Judicial, por cuanto además de revisar si la norma a aplicar para el caso transfronterizo es procedente conforme a la reserva general con la que adoptó Chile la referida Convención, deberá también distinguir si el país de donde proviene la solicitud del procedimiento concursal materia del requerimiento —vía exequátur, conforme a las disposiciones del mismo Código— adoptó la Convención de Derecho Internacional Privado; y si lo hizo, deberá además distinguir si fue con o sin reservas, las cuales a su vez deberán verificarse, para dar curso progresivo a la solicitud, en su contenido y extensión.
- C) La necesidad de que las resoluciones dictadas por tribunales extranjeros deban someterse necesariamente al trámite de exequátur para efectos de aplicarse en Chile, implica una evidente y consecuente dilación en sus efectos, restando eficiencia a los procedimientos concursales.
- D) En cuanto a las acciones y derechos reales, su artículo 420 dispone que “continuarán sujetos no obstante la declaración de quiebra o concurso, a la ley de la situación de las cosas a que afecten y a la competencia de los jueces de lugar en que estas se encuentren”. Lo anterior, en línea con lo dispuesto en el artículo 16 inciso primero del Código Civil, podría impedir el cumplimiento de sentencias extranjeras sobre bienes situados en Chile, en cuanto podría entenderse que tales bienes quedan sometidos exclusivamente a la ley chilena y, por tanto, a la jurisdicción nacional, sin posibilidad de exequátur, debiendo entonces el solicitante interesado en la liquidación y pago universal, recurrir necesariamente a alguna de las causales que contemplaba el artículo 43 del Libro IV del Código de Comercio, las cuales podrían no necesariamente configurarse para el supuesto en análisis.
- E) Finalmente, tampoco quedan claros ciertos aspectos básicos acerca de la protección de los acreedores nacionales frente a deudores y procedimientos extranjeros, como son las

notificaciones, la realización de bienes, la forma en que deben pagarse y hacer efectivo su crédito, entre otros.

6.2 Necesidad de uniformar normativa. Propuesta según Ley Modelo de UNCITRAL

Desde la década de los noventa ha ido aumentado notablemente el número de casos de insolvencia transfronteriza; sin embargo, esta tendencia no se ha reflejado en el número de regímenes jurídicos, tanto nacionales como internacionales, para hacer frente a las cuestiones que plantean tales casos. Muchas veces la falta de una normativa especial ha hecho que se adopten criterios inadecuados y descoordinados que no solamente son imprevisibles y largos de aplicar, sino que además carecen de transparencia y de los instrumentos necesarios para afrontar las disparidades y, en algunos casos, los conflictos que pueden surgir entre las leyes nacionales y los regímenes de la insolvencia. Esos factores han obstaculizado la protección del valor de los bienes de empresas con dificultades financieras y han dificultado la rehabilitación de esas empresas.

Para solucionar lo anterior, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, más conocida por su abreviación CNUDMI, o UNCITRAL por sus siglas en inglés, crea en el mes de diciembre del año 1997 mediante resolución 52/158 una **Ley Modelo sobre insolvencia Transfronteriza**, trabajada en el seno del Grupo de Trabajo V dedicado al estudio del Régimen de la Insolvencia, con la asistencia de la Asociación Internacional de Profesionales de la Insolvencia (INSOL) y de la sección de Derecho Empresarial de la Asociación Internacional de Abogados, y lo pone a disposición de los distintos Estados del globo con el objeto de “ayudar a los Estados a dotar a su régimen de la insolvencia (interno) de una normativa moderna, equitativa y armonizada para abordar con más eficacia los casos de procedimientos transfronterizos relativos a deudores que se encuentren en graves apuros financieros o que sean insolventes”. Desde dicho año, esta normativa ha sido puesta a disposición de los distintos Estados para su adopción, siempre con la finalidad de simplificar y facilitar, mediante la “unificación y armonización” de marcos normativos jurídicos mercantiles, la actividad comercial y las inversiones internacionales. A la fecha, un total de 20 países —incluyendo Chile— han adoptado la referida Ley Modelo.

Con la incorporación de un texto uniforme, *se pretende asegurar la celeridad y transparencia procesal, así como la certeza jurídica y una claridad respecto de las acciones y medidas aplicables y los efectos resultantes de los distintos procedimientos donde se aplique la citada normativa*. Dicha uniformidad resulta indispensable a la hora de aplicar en los distintos regímenes jurídicos normas tendientes a una coordinación judicial y administrativa.

La Ley Modelo es importante porque ella y su historia legislativa son fuente de interpretación de la normativa chilena.

6.3 Aspectos Generales. Instituciones que actúan.

En relación a los aspectos generales y las principales instituciones que operan conformen a esta Ley Modelo, podemos destacar:

6.3.1 Objetivo

El objetivo de esta normativa internacional es permitir una coordinación y cooperación tanto judicial como administrativa entre los tribunales y órganos que intervienen en un procedimiento de insolvencia que adquiera la calidad de transfronterizo. Esto permitiría mayor seguridad jurídica en el comercio y las inversiones internacionales, protegiendo los intereses de la totalidad de los acreedores y de los demás interesados, inclusive del deudor.

6.3.2 Ámbito de aplicación

La Ley de Insolvencia Transfronteriza que ahora está contenida en el Capítulo VIII de la Ley N° 20.720, entra en aplicación en las siguientes situaciones, art. 300:

- a) Cuando un tribunal o representante extranjero solicita asistencia a los tribunales u otros organismos chilenos involucrados en los procedimientos concursales (Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento o administradores concursales).
- b) Cuando se solicite asistencia en un Estado extranjero en relación a un procedimiento concursal que se esté tramitando con arreglo a la Ley de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas u otras normas especiales relativas a la insolvencia.
- c) Cuando se estén tramitando simultáneamente y respecto de un mismo deudor procedimientos concursales en Chile y el extranjero, y
- d) Cuando un acreedor u otros interesados extranjeros soliciten la apertura de un Procedimiento Concursal en Chile con arreglo a las reglas generales de la ley.

En relación a las situaciones de aplicación normativa antes señalada, cabe hacer varias **precisiones**.

En primer lugar, y según Sandoval, “la piedra angular sobre la que se sustenta el ámbito de aplicación de la Ley Modelo es la noción del ‘procedimiento extranjero’, porque gracias a ellas se describen las situaciones a las cuales se aplican las reglas uniformes (...)”. Este procedimiento extranjero, que se define en el artículo 301 letra (a) y a su vez en el artículo 2° de la Ley Modelo, resulta el elemento fundante de las reglas procesales a aplicar, ya que establece, basado especialmente en la importancia que tiene el concurso traducido en dicho procedimiento para el deudor, el criterio de la “fuerza” de las medidas que se aplicarán al caso concreto. Así, si el procedimiento extranjero se declara como principal —lo anterior debido a que el deudor tiene en el país de procedencia del referido procedimiento el centro de sus principales intereses— la intensidad de las medidas provisionales correspondientes serán de mucha mayor gravedad que aquellas que pudieran declararse para los procedimientos que no contaran con tal calidad, sin mencionar además que para el primer caso la aplicación de las medidas son de pleno derecho, mientras que para el segundo son facultativas para el criterio del juez competente.

LATAM demostró que su centro de interés fue NY, pero acreditar esto no es tan fácil. ¿A quién se le demuestra esto? En realidad hay libertad para concurrir a otra jurisdicción, el problema es si

aparece un tercero, normalmente deudor, que cuestiona esto (intentando hacer valer un procedimiento concursal en Chile, o bien haciendo valer las resoluciones de tribunales chilenos en el procedimiento extranjero).

En la práctica, lo que sucede es que se reconoce el procedimiento extranjero en Chile.

En segundo lugar, cabe destacar que el legislador también innovó respecto de la competencia del órgano a conocer del Procedimiento. Como regla general, mantiene como tribunal natural al del domicilio del deudor. Sin embargo, puede darse el caso de que el deudor en Chile no tenga su domicilio, sino que únicamente mantenga bienes en nuestro país, encontrando entonces en tal hipótesis una laguna jurídica que el legislador supere replicando lo dispuesto en numerosas disposiciones, estableciendo una competencia múltiple respecto de aquellos tribunales en cuyos territorios jurisdiccionales estuvieren situados los bienes del deudor en Chile. Finalmente, cabe destacar que la ley reconoce también competencia para conocer de las solicitudes de reconocimiento a los tribunales arbitrales que se encontraren conociendo del procedimiento en Chile, así como a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, para el caso en que un Procedimiento Concursal de Renegociación del Deudor se encontrare abierto. Sin embargo, debemos tener presente que ambas instituciones carecen de facultad de imperio, con lo cual todo reconocimiento resulta —procesalmente— inútil, por lo que a nuestro criterio, y pese a que la ley no lo regula, lo lógico debiera ser que ambas instituciones, una vez presentada la referida solicitud, acompañen los antecedentes al tribunal ordinario competente, para que sea éste quien decrete finalmente el reconocimiento del Procedimiento.

6.3.3 Igualdad de acreedores

Hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley N°20.720, podía darse el injusto jurídico de que un mismo acreedor pudiera verificar y cobrar su crédito más de una vez. Lo anterior, acompañado a la nula cooperación y comunicación procesal entre los distintos procedimientos de insolvencia llevados respecto de un mismo deudor en Chile y en el extranjero, permitían que se trataran de manera completamente independiente y descoordinada dichos concursos, generándose así un “crédito fantasma” respecto de los procedimientos foráneos a ser cobrado por el acreedor en el extranjero, atentando directamente contra la par conditio creditorum. Para sortear lo anterior, la nueva ley establece una igualdad de derechos tanto para los acreedores chilenos como para los extranjeros, quienes se sujetarán al orden de prelación de créditos contenido en el Código Civil. Respecto a los pagos en procedimientos paralelos, se establece que el acreedor que haya percibido un pago parcial en un procedimiento llevado en un Estado extranjero, no podrá percibir un nuevo pago por ese mismo crédito en un procedimiento concursal chileno, tratándose del mismo deudor, mientras los demás acreedores de su misma categoría reciban su pago.

6.3.4 Representación de procedimientos nacionales en el extranjero

Con el objeto de mantener una fiscalización y supervigilancia permanente en todos los procedimientos concursales, la ley establece que la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento será el órgano legitimado para actuar con un Estado extranjero, en representación de un procedimiento abierto en Chile, sin perjuicio de la facultad de poder delegar

esta legitimación en el administrador concursal que esté conociendo del procedimiento en particular, correspondiéndole a este último la responsabilidad consecuente en que pudiere incurrir en el ejercicio de sus funciones. La intención del legislador en esta materia, no fue la de establecer una administración concursal pública distinta a la llevada por los liquidadores, veedores o administradores de la continuación de las actividades económicas del deudor, sino simplemente *facilitar la labor fiscalizadora de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, para aquellos procedimientos que exceden de la jurisdicción nacional.*

6.3.5 Reconocimiento de un procedimiento extranjero en Chile

El representante extranjero que haya sido nombrado como tal en un procedimiento extranjero, podrá solicitar —acreditando su calidad de tal— el reconocimiento de dicho procedimiento frente a los tribunales chilenos competentes. A partir del reconocimiento de un procedimiento extranjero, o incluso a partir de su sola solicitud (dependiendo de la calidad del procedimiento), el tribunal competente puede adoptar medidas tendientes a suspender toda ejecución de bienes del deudor, o encomendar al mismo representante u a otra persona designada por el tribunal, la administración de todos o parte de los bienes, entre otras medidas. Además, a partir del reconocimiento del procedimiento extranjero, el representante extranjero estará legitimado para entablar las acciones revocatorias concursales.

La figura del representante extranjero se presenta como una institución fundamental para la tramitación del procedimiento regulado en el Capítulo VIII de la ley. Dicha figura es el eje gatillante del procedimiento transfronterizo, quien con su sola solicitud pone en completo movimiento la máquina jurisdiccional. Esta institución se encuentra definida en el artículo 301 letra d) de la ley como aquella “(...) persona o el órgano, incluso el designado a título provisional, que haya sido facultado en un procedimiento extranjero para administrar la reorganización o la liquidación de los bienes o negocios del deudor o para actuar como representante del procedimiento extranjero (...)”, por lo que debemos entender que, en la práctica, puede traducirse en un sinnúmero de figuras reguladas en el derecho extranjero.

La figura del representante extranjero cobra especial relevancia al momento de la dictación de las medidas provisionales, una vez reconocido el procedimiento, por cuanto será —por regla general— quien designe el juez para administrar o realizar los bienes del deudor, pudiendo superponerse así, a la figura del liquidador o veedor, los individuos naturales para llevar a cabo tales labores.

El artículo 305 de la ley dice que se puede obtener el reconocimiento del reconocimiento extranjero en la medida que no se oponga a normas de OP. Sin embargo, este último es un concepto muy amplio. Por ejemplo, si la norma de notificación es distinta ¿eso es contrario al OP? ¿qué pasa con la posibilidad de contratar créditos que no excedan del 20%? Esto genera problemas de aplicabilidad.

6.3.6 Cooperación y comunicación entre tribunales y representantes extranjeros

La cooperación, que puede ser tanto judicial como administrativa, se hará ya sea directamente o por conducto de los administradores concursales. Además, el tribunal chileno competente estará

facultado para ponerse en comunicación directa con los tribunales o representantes extranjeros para recabar información o asistencia directa de los mismos. Regla similar se aplica respecto de los administradores concursales. Para el caso judicial, la comunicación se hará por cualquier medio que el tribunal competente considere oportuno, y la cooperación se materializará mediante el nombramiento de una persona u órgano que actúe bajo dirección o supervisión del tribunal competente, además de coordinar la administración y supervisión de los bienes y negocios del deudor.

Si se tramitare más de un procedimiento extranjero respecto de un mismo deudor, el tribunal competente igualmente procurará cooperación y coordinación entre los procedimientos y los órganos involucrados.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente que la normativa contenida en el Capítulo VIII de la Ley N° 20.720, contiene los resguardos necesarios para hacer prevalecer nuestra normativa nacional y compromisos internacionales:

- (a) El artículo 302 dispone que en caso de conflicto entre este capítulo y una obligación del Estado de Chile nacida de un tratado u otra forma de acuerdo en el que Chile sea parte con uno o más Estados donde se estén tramitando los procedimientos extranjeros; prevalecerán las disposiciones de ese tratado o acuerdo; y
- (b) El artículo 307 dispone que lo dispuesto en el referido título no impedirá que el tribunal competente y la Superintendencia se nieguen a adoptar una medida específica dictada por un tribunal extranjero manifiestamente contraria al orden público nacional.

6.4 Ámbito de aplicación

Un procedimiento de insolvencia transfronterizo es aquel en que: (i) el deudor tiene bienes en más de un Estado, o (ii) algunos de los acreedores del deudor no se encuentran en el Estado donde se está tramitando el procedimiento de insolvencia. Estas hipótesis nos ponen en cuatro supuestos de acción distintos:

- 1) Que se solicite asistencia o reconocimiento respecto de un procedimiento extranjero desde el extranjero hacia Chile.
- 2) Que se solicite asistencia o reconocimiento de un procedimiento concursal desde Chile hacia el extranjero.
- 3) Que existan procedimientos paralelos respecto de un mismo deudor, y es necesario coordinar las medidas pertinentes para llevar dichos procedimientos de forma fluida.
- 4) Que existan acreedores en el extranjero, y requieren participar en un procedimiento abierto en Chile, o en su defecto, abrir un procedimiento concursal conforme a las causales objetivas de la Ley N° 20.720.

Cabe destacar que el inciso final del artículo 300 de la Ley N° 20.720, **exceptúa expresamente de la aplicación del Capítulo VIII a las Instituciones Bancarias y a las Compañías de Seguro**, por tener

éstas una regulación concursal íntegra en sus normativas especiales, y por cuanto la aplicación de las medidas provisionales contenidas en la misma podría afectar gravemente el interés general.

Respecto de la primera hipótesis (desde “el extranjero hacia Chile”), cabe destacar que todo se inicia con la sola presentación de solicitud de reconocimiento de procedimiento extranjero por parte del representante extranjero -quien debe actuar mediante abogado habilitado para el ejercicio de la profesión—, conforme lo dispone el artículo 314.

Paralelamente, está facultado para eventualmente también solicitar la dictación de una serie de medidas precautorias para el mejor resguardo de los intereses de los involucrados en el procedimiento, hasta que se resuelva la solicitud de reconocimiento presentada ante el tribunal o autoridad competente.

Una vez resuelta la solicitud, se procederá a decretar una serie de medidas que pueden ser “automáticas” o “facultativas” para el tribunal, dependiendo si la calificación del procedimiento extranjero se considera como principal o no principal, todo lo anterior conforme a la ubicación del centro de sus principales intereses que tenga el deudor. Finalmente, y una vez reconocido el procedimiento, el representante extranjero también queda facultado legalmente para ejercer las acciones revocatorias concursales antes señaladas.

Por otra parte, también un tribunal extranjero puede comunicarse directamente con su par chileno (bastando para ello la sola certificación del secretario del tribunal, respecto de la existencia de la comunicación propiamente tal y de su contenido), con el objeto de recabar información adicional respecto de un procedimiento relativo a la insolvencia que se esté llevando en su país, o también para coordinar varios procedimientos que se estén tramitando respecto de un mismo deudor. Finalmente, los acreedores extranjeros siempre podrán participar o solicitar la apertura de los procedimientos concursales regulados en la Ley N° 20.720, conforme a las reglas generales.

Sobre la segunda hipótesis (desde “Chile hacia el extranjero”), se prevé la posibilidad de que la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento -que tiene la facultad legal de delegar su legitimación activa en el administrador concursal del procedimiento mismo— actúe en el extranjero en representación de un procedimiento abierto en Chile, cuando éste adquiera el carácter de transfronterizo. También podrían los tribunales chilenos comunicarse con sus pares extranjeros, con el objeto de recabar mayor información respecto de un procedimiento concursal abierto en Chile o, bien, para coordinar varios procedimientos respecto del mismo deudor. Cabe destacar que todo lo anterior solo será procedente en la medida que la normativa extranjera lo permita, por cuanto el Capítulo VIII de la Ley N° 20.720 que analizamos, no establece normas de reciprocidad, por lo que eventualmente, y en el caso de que los órganos extranjeros no permitan estos medios de comunicación, deberá hacerse por medio de los procedimientos procesales regulares, esto es, mediante los exhortos y exequátur internacionales.

Finalmente, y en el caso de que exista una coordinación paralela de procedimientos de insolvencia y concursales, deberán aplicarse las medidas antes descritas.